

Registro de Imóveis

Teoria e Prática

2ª Edição

Revista, Ampliada e Atualizada

Alyne Yumi Konno

Registro de Imóveis

Teoria e Prática

2ª Edição

Revista, Ampliada e Atualizada

MEMÓRIA JURÍDICA EDITORA

São Paulo / 2010

Diagramação e Arte

PENA – Composição e Arte

Fone: (51) 3434-2641

CNPJ 94618667/0001-04

Porto Alegre - RS

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Konno, Alyne Yumi

Registro de imóveis : teoria e prática / Alyne Yumi Konno. – São Paulo : Memória Jurídica Editora, 2010.

Bibliografia

INBN XXX-XX-XXXXXX-XX-X

1. Registro de imóveis – Brasil I. Título

Índices para catálogo sistemático

1. Brasil : Registro de imóveis : Direito civil
xxx.xxx.xx(xx)

Todos os direitos reservados. Respeite a autora e a editora, não faça cópias.

MEMÓRIA JURÍDICA EDITORA

São Paulo: Rua Santo Amaro, 345 - Bela Vista

Porto Alegre: Rua Riachuelo 1238 - Centro

email: fabbris8@terra.com.br

website: www.memoriajuridica.com.br

www.memoriajuridica.com.br

Aos meus pais, por tudo que representam
em minha vida e pelo apoio e carinho
dedicados por todos esses anos

*“O direito não é uma pura teoria, mas uma força viva.
Por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança
em que pesa o direito, e na outra a espada de que
se serve para o defender.”*

(Rudolf von Ihering).

Prefácio da 1ª Edição

Quando ingressei no 1º Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo como Oficial recém aprovado no 2º Concurso Público para Outorga de Delegações de Registro do Estado de São Paulo, fiquei surpreso ao constatar que a maior parte das rotinas e procedimentos era transmitida aos escreventes e auxiliares de forma verbal. Os funcionários raramente buscavam soluções para suas dúvidas na legislação ou na Jurisprudência, mas quase sempre apenas na experiência de seus colegas de trabalho.

Como consequência disso, decisões eram tomadas e atos praticados utilizando apenas conhecimentos pessoais e baseados somente na experiência prática, o que era uma realidade absolutamente incompatível com a amplitude de conhecimentos que é exigida dos que atuam em uma área tão vasta e importante, cujos atos não podiam continuar sendo praticados confiando-se apenas na lembrança e opinião dos funcionários.

Essa realidade não resultava da ausência de fontes de consulta, já que os classificadores obrigatórios contendo as decisões judiciais eram mantidos à disposição de todos, além da existência de ementário de decisões e amplo acesso a legislação. Analisando o que ocorria evidenciou-se que era consequência dos materiais de conduta disponíveis não serem consolidados de forma prática, dificultando a localização da legislação e das decisões associadas ao assunto procurado, o que inibia a utilização dos recursos disponíveis.

Para mudar esse cenário surgiu a idéia da elaboração de trabalhos que abrangessem os principais tópicos relacionados ao Registro e que associassem a experiência prática à fundamentação jurídica da forma mais clara e acessível possível. Nessa tarefa se envolveram os escreventes mais brilhantes deste Registro, e o primeiro fruto desse trabalho é esta excelente obra, que reflete a extrema competência e dedicação de sua autora, a escrevente-chefe Alyne Yumi Konno, talentosa profissional que conta com a admiração e respeito de todos que têm o extraordinário privilégio de trabalhar ao seu lado, que abraçou essa tarefa com empenho impressionante e tornou o pro-

jeto realidade, ultrapassando as mais elevadas expectativas ao criar uma magnífica obra que surpreende pela clareza e conteúdo.

Em suas páginas são elaborados os temas mais relevantes do dia-a-dia do Registro, sendo explicado dos conceitos mais simples aos mais complexos, sem pressupor conhecimento anterior ao leitor, mas mantendo grande apuro técnico. As explicações são complementadas com esclarecedoras transcrições de trechos selecionados de pareceres e decisões judiciais, além de serem apresentados os dispositivos legais mais relevantes sobre cada matéria, sempre procurando manter o enfoque prático e fornecer as informações da forma mais completa possível, sem prolixidade.

Esta obra certamente irá agradar a todos que atuam na área, incluindo os Oficiais de Registro que necessitem de uma fonte de consulta para seus prepostos, os profissionais que busque referências rápidas e também os estudantes que pretendem ingressar na atividade de Registro Públicos, seja como advogados, seja como Oficiais de Registro através dos concursos públicos que na atualidade abrem as portas dessa importante função aos profissionais do direito.

Por isso, é com extremo orgulho e indiscreto alegria que tenho a honra de apresentar esta excepcional obra, de uma autora que é uma pessoa admirável de raros e extraordinários predicados e que produziu um inestimável trabalho, que torna realidade o anseio de muitos e que certamente será de grande valia a todos que atuam na área registral imobiliária.

São Bernardo do Campo, fevereiro de 2007.

André de Azevedo Palmeira – Oficial do 1º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Bernardo do Campo.

Sumário

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS	17
1. Princípio da Especialidade.....	19
1.1. Especialidade Objetiva	19
1.2. Especialidade Subjetiva.....	23
1.3. Direito de <i>Saisine</i>	26
2. Princípio da Publicidade	27
3. Princípio da Prioridade	28
4. Princípio da Unitariedade	30
5. Princípio da Taxatividade	32
6. Princípio da Continuidade	36
6.1. O princípio da continuidade e a alienação por espólio.....	40
7. Princípio da Instância.....	42
8. Princípio da Inscrição ou do Registro.....	43
9. Princípio <i>Tempus Regit Actum</i>	44
10. Princípio da Disponibilidade.....	45
11. Princípio da Legalidade ou Legitimidade.....	47
12. Princípio da Presunção de Eficácia do Registro	48
12.1. Cancelamento do Registro	49
12.2. Cancelamento administrativo.....	52
12.3. Bloqueio	53
13. Princípio da Cindibilidade	54
14. Princípio da Autotutela.....	57
 CAPÍTULO II – QUALIFICAÇÃO DE TÍTULOS.....	59
A qualificação dos títulos	62
Requisitos extrínsecos.....	62
1. Forma.....	62
2. Título original.....	64
2.1. Traslado e certidão	64
2.2. Pública forma.....	65
2.3. Distinção entre títulos e documentos	66

2.4. Publicações.....	67
2.5. Certidões do Registro de Títulos e Documentos	68
3. Rasuras e retificação	68
4. Assinatura do notário	69
4.1. Sinais público e raso.....	69
5. Idioma nacional.....	70
6. Elementos de segurança.....	70
Requisitos Intrínsecos	71
7. Pessoa natural.....	72
7.1. Menores.....	72
7.1.1. Necessidade da presença de ambos os pais	72
7.1.2. Falta de um dos pais.....	73
7.1.3. Limitação da representação ou assistência dos pais	74
7.1.4. Curador Especial	75
7.1.5. Emancipação	76
7.1.6. Tutelados	77
7.2. Incapazes.....	78
7.2.1. Curatelados.....	78
7.2.2. Pródigos	78
7.3. Analfabeto.....	79
8. Procuração	79
8.1. Vinculação da forma.....	80
8.2. Poder de disposição	80
8.3. Autocontrato	81
8.4. Vigência.....	82
8.5. Procuração estrangeira	82
9. Pessoas Jurídicas	85
9.1. Representação.....	85
9.2. Sociedade Simples	85
9.3. Sociedade Anônima	86
9.4. Associações.....	87
9.5. Fundações	87
9.6. Sociedade Limitada	88
9.7. Empresário.....	88
9.8. Recuperação Judicial e Falência.....	89
10. A Lei Federal 7.433/85	90
11. Valor do contrato, da coisa ou da dívida	95
12. Qualificação Negativa	98
 CAPÍTULO III – INSTRUMENTOS PARTICULARES.....	 101
1. Reconhecimento de firmas	104
1.1. Regularização fundiária	106
2. Testemunhas	107

3. Procuração.....	108
4. Vinculação da forma.....	108
4.1. Anuência e autorização	108
4.2. Distrato	108
4.3. Procuração.....	110
5. Analfabetos e pessoas que não possam ler ou assinar	110
6. Rasura.....	111
7. Alvarás judiciais em instrumentos particulares	111
Dispensa da forma pública	111
8. Valor do imóvel	112
9. Sistema Financeiro da Habitação – SFH	113
9.1. Restrições decorrentes de financiamento do SFH	114
10. Alienação Fiduciária	117
11. Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI	120
12. Compromisso de Compra e Venda	121
12.1. O compromisso de compra e venda e a falência	124
13. Cessão de direitos	125
14. Loteamentos populares.....	126
15. Programa de Arrendamentos Residencial – PAR	127
15.1. Arrendamento Imobiliário Especial.....	130
16. Patrimônio da União	130
17. Cartas de arrematação	131
18. Imóveis na Constituição e Alteração de Pessoas Jurídicas	132
18.1. Conferência de Bens	132
18.2. Fusão, cisão e Incorporação.....	136
19. Locação	137
19.1. Vênia conjugal.....	138
19.2. Proprietário como anuente.....	138
19.3. Registro em Títulos e Documentos.....	138
19.4. Contratos de sublocação.....	139
19.5. Imóveis anteriormente locado a terceiro	139
19.6. Contrato de locação com prazo vencido	140
19.7. Registro de locação após a alienação do imóvel	140
19.8. Locação por não proprietário	140
19.9. Imóveis alienados fiduciariamente	141
19.10. Caução.....	141
19.11. Cláusula de vigência	143
19.12. A cláusula de vigência na locação e o usufruto.....	145
19.13. Direito de preferência	146
19.14. Duplo lançamento	147
19.15. Análise do contrato de locação	148
20. Consórcio para aquisição de imóveis	149
21. Incorporação, Convenção, Instituição e Atribuição em Condomínios..	150

22. Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV	153
CAPÍTULO IV – PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA	155
1. Pessoa Jurídica de Direito Público Externo	157
2. Sociedades estrangeiras	158
2.1. Situações que exigem a autorização.....	158
2.2. Motivos da necessidade de autorização	159
2.3. Competência para autorizar	160
CAPÍTULO V – ENTES SEM PERSONALIDADE JURÍDICA	163
1. Consórcio de Pessoas Jurídicas.....	165
2. Espólio.....	166
2.1. Sub-rogação objetiva ou real.....	167
3. Condomínio edilício e loteamento	167
3.1. Execução de despesas condominiais	169
4. Empresário	170
5. Sociedades sem registro	171
6. Fundos de Investimento Imobiliário.....	172
7. Cartório.....	173
8. CNPJ de entes sem personalidade jurídica	173
CAPÍTULO VI – ATOS NÃO REGISTRÁVEIS	175
1. Promessa de Dação	177
2. Novação.....	178
3. Promessa de Permuta.....	179
4. Promessa de Instituição de Usufruto	180
5. Cessão de Direitos Hereditários	181
6. Escritura pública de partilha amigável anterior e a Lei 11.441/07	182
7. Arrendamento	183
8. Posse	185
9. Protesto Contra a Alienação de Bens.....	186
10. Multipropriedade	188
11. Sucessão Provisória	189
CAPÍTULO VII – DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO.....	191
1. Carteira de identidade – Registro Geral.....	194
1.1. modelos antigos de carteiras de identidade	194
1.2. Extração de dados das carteira de identidade	195
1.3. Estatuto da Igualdade e RG	195
1.4. Alteração do número de identidade	196
A. Mudança de Estado	196
B. Substituição por duplicidade	196
2. Documento de estrangeiro	196

2.1.	Prazo de validade.....	1987
2.2.	Modelos antigos de carteiras de estrangeiros	197
2.3.	Implantação do Registro Nacional de Estrangeiros.....	197
2.4.	Naturalização	198
3.	Carteira Nacional de Habilitação	198
4.	Carteiras profissionais	199
5.	Cartões de identidade funcional.....	199
6.	Retificação judicial.....	200
7.	Cadastro de Pessoas Físicas – CPF	200
7.1.	Comprovação de inscrição	201
7.2.	Cartão de CPF de estrangeiros.....	201
7.3.	Alteração do número de inscrição	202
7.4.	Inscrição cancelada ou nula.....	202
7.5.	Regiões Fiscais	203
8.	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)	203
8.1.	Sociedades estrangeiras	204
8.2.	Inscrição inapta.....	204
8.3.	Alteração de inscrição	204
8.4.	Matriz e filiais.....	205
8.5.	CNPJ de entes públicos	205
9.	Retenção de documentos.....	205

CAPÍTULO VIII – REGIME DE BENS, CASAMENTO E DISSOLUÇÃO

DO VÍNCULO MATRIMONIAL.....	207
Regime de Bens	209
1. Regimes legais	209
1.1. Regime da comunhão parcial de bens	209
A. Outorga uxória.....	210
B. Sub-rogação	212
1.2. Regime da separação obrigatória de bens	214
2. Regimes Convencionais	216
2.1. Regime da comunhão universal de bens.....	216
2.2. Regime da participação final nos aquestos	217
2.3. Regime da separação convencional de bens.....	218
3. Averbação e registro do pacto antenupcial.....	219
4. Alteração do regime de bens	220
Averbação do Casamento.....	222
5. Casamento religioso	223
6. Casamento no Exterior.....	223
7. Continuidade.....	224
8. Justificação da falta ou perda do registro civil	225
9. Regime de bens e casamento no exterior.....	226
10. Separação e divórcio.....	227

11. Partilha	228
12. Alienação de bens não partilhados	229
13. Bem de família	230
14. Reconciliação.....	231
15. Separação de fato.....	231
16. Alienação entre cônjuges	233
17. Habilitação anterior à Lei 6.515/77.....	234
 CAPÍTULO IX – CLÁUSULAS	235
1. Cláusulas Restritivas: Inalienabilidade, Impenhorabilidade e Incomunicabilidade	237
1.1. Imposição de cláusulas por escritura de retificação	239
1.2. Cláusula em um único grau	239
1.3. Restrição aos próprios bens	240
1.4. Inalienabilidade contratual.....	241
1.5. Imposição de cláusula por promissário comprador.....	241
1.6. Doação de numerário e imposição de cláusulas	241
1.7. Justa causa	242
1.8. Sub-rogação da restrição.....	243
1.9. Inalienabilidade relativa	244
1.10. Exceções às cláusulas restritivas	245
a. Despesas condominiais	245
b. Dívidas Fiscais.....	245
c. Dívidas Trabalhistas	246
1.11. Cancelamento das cláusulas.....	246
1.12. Cancelamento por revogação	247
1.13. Cancelamento por morte dos donatários ou herdeiros.....	248
1.14. Cancelamento por interpretação da vontade dos doadores	249
1.15. Cancelamento pela ocorrência de termo ou condição	249
2. Cláusula restritiva convencional em loteamento.....	250
3. Cláusula resolutiva e pacto comissório	251
4. Cláusula de reversão	252
5. Cláusula de acrescer.....	254
6. Cláusula de decaimento.....	254
7. Cláusula de indivisibilidade.....	255
8. Cláusula <i>constituti</i>	255
9. Cláusula de retrovenda	255
10. Fideicomisso.....	257
11. Cláusulas em transcrições	260
12. Cláusula de preempção ou preferência	260
13. Cláusula de reserva de domínio	262

CAPÍTULO X – ASPECTOS FISCAIS.....	263
Tributos	265
1. Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI.....	265
1.1. Transmissão <i>Inter vivos</i>	265
1.2. Aquisição originária e derivada	265
1.3. Usucapião	266
1.4. Desapropriação	267
1.5. Adjudicação compulsória.....	267
1.6. Transmissão onerosa.....	267
1.7. Partilha	268
1.8. Divisão	269
1.9. Permuta.....	269
1.10. Transmissão de direitos sobre imóveis	270
1.11. Cessão de direitos registrados	270
1.12. Cessão de direitos não registrados.....	271
1.13. Conferência de bens, fusão, cisão, incorporação e extinção de sociedade	272
1.14. Dação em pagamento.....	272
1.15. Retrovenda	273
1.16. Sisa.....	273
2. ITCMD – Imposto sobre Transmissão <i>Causa Mortis</i> e Doação	273
2.1. Doação com reserva de usufruto e extinção	274
2.2. Extinção do usufruto instituído pelo nu-proprietário.....	277
2.3. ITBI Doação	278
2.4. Isenção	278
2.5. Fideicomisso	279
2.6. Pagamento	279
2.7. Penalidade.....	280
2.8. Certidão de Regularidade do ITCMD.....	280
3. IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.....	281
4. ITR – Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	282
5. Análise do registrador	285
5.1. Competência para arrecadar o tributo.....	285
5.2. Tempestividade.....	286
5.3. Evidentes incorreções	286
5.4. Decadência e prescrição de tributos.....	287
5.5. Consequência da falta de recolhimento	287
6. Certidões Negativas de Débitos – INSS, SRF e PFN.....	288
6.1. Contribuições Sociais	288
6.2. CND da Dívida Ativa da União	288
6.3. Obrigatoriedade de apresentação de CNDs no Registro de Imóveis.....	289

6.4. Alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo	290
6.5. Pessoa Física equiparada à Pessoa Jurídica	290
6.6. Alienação ou oneração de bem imóvel.....	291
6.7. Direitos relativos a imóveis.....	292
6.8. Oneração de bens móveis	292
6.9. Construção.....	292
6.10. Hipóteses de Dispensa da apresentação das CND.....	293
1) Instrumento de ratificação.....	293
2) Pessoas jurídicas da área imobiliária	293
3) Construções unifamiliares	295
4) Construções antigas	296
5) Constituição de garantia para concessão de crédito rural	296
6) Administradora de grupo de consórcios	297
6.11. Certidões apresentadas ao tabelião	297
6.12. Cédulas de Crédito	298
6.13. Adjudicação	298
6.14. Falência	300
6.15. Entes públicos e filantrópicos.....	300
6.16. Certidões eletrônicas	301
6.17. Certidão positiva com efeitos de negativa	301
6.18. Validade das certidões.....	301
6.19. Finalidade das certidões	302
6.20. Estabelecimento matriz e filial.....	302
6.21. Incorporação, fusão e cisão.....	302
6.22. Microempresas	303
6.23. Fundos Imobiliários	303
6.24. Penalidades	303
6.25. Nulidade do ato	303
6.26. Arquivamento de certidões	304
7. Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI	304
8. Cadastro Fiscal Imobiliário.....	305
9. Arrolamento Fiscal	306
APÊNDICE	
Livros	309
Prazos	311
Modelos	315
Bibliografia	331
ÍNDICE REMISSIVO.....	333

CAPÍTULO I

PRINCÍPIOS

Para corretamente aplicar o direito registral imobiliário é essencial conhecer os princípios básicos que o regem. A compreensão desses princípios permite aos operadores do direito registral encontrar com facilidade as soluções corretas para as mais inusitadas situações que surgem nesse dinâmico ramo do direito.

1. Princípio da Especialidade

“O princípio da especialidade significa que toda inscrição deve recair sobre um objeto precipuamente individuado”¹.

O imóvel e os sujeitos envolvidos no instrumento objeto de registro devem estar perfeitamente descritos, permitindo a exata localização do imóvel no mundo físico e a perfeita identificação das pessoas que figurarem nos atos.

A especialidade deve ser observada tanto quanto aos imóveis (denominada especialidade objetiva), como quanto às pessoas (especialidade subjetiva).

1.1. Especialidade Objetiva

Segundo Afrânio de Carvalho, “o requisito registral da especialização do imóvel, vertido no fraseado clássico do direito, significa a sua descrição como corpo certo, a sua representação escrita como individualidade autônoma, com o seu modo de ser físico, que o torna inconfundível e, portanto, heterogêneo em relação a qualquer outro”².

O artigo 176, § 1º, II, nº 3, da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) traz os requisitos para a identificação do imóvel:

Se rural, mediante a indicação do código do imóvel, dos dados constantes do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), da denominação e de suas características, confrontações, localização e área.

¹ CARVALHO, Afrânio de. *Registro de Imóveis: comentários ao sistema de registro em face da Lei nº 6.015, de 1973, com as alterações da Lei nº 6.216, de 1975*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p.219.

² Op. cit., p.224.

Tratando-se de imóvel urbano, a identificação consistirá na declaração de suas características, confrontações, localização, área, logradouro em que fica situado, número (do lote e quadra ou predial, caso haja construção) e de sua designação cadastral (número de inscrição no cadastro imobiliário do município). Ainda, o artigo 225 do mesmo diploma legal prevê que os títulos³ indiquem os nomes dos confrontantes, e quando se tratar só de terreno, se o imóvel fica situado do lado par ou ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima.

Esse importante princípio tem sido mitigado em algumas situações a fim de que sua aplicação não obste o tráfego de transações envolvendo imóveis transcritos⁴, sendo admitidas que descrições imprecisas, constantes de antigas transcrições sejam mantidas quando da abertura de matrículas, desde que haja elementos mínimos para se determinar a situação do imóvel e seja transmitido ou onerado por inteiro, isto é, desde que a nova matriz a ser aberta o abranja em sua totalidade. Contudo, se o imóvel for objeto de desmembramento, fusão ou instituição de condomínio, sua descrição deverá submeter-se aos requisitos da Lei de Registros Públicos, como reiteradamente tem decidido a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo: “Quando, porém, criam-se novos imóveis decorrentes de desmembramentos ou de fusões, as unidades segregadas ou unificadas devem subordinar-se aos requisitos do artigo 176 da Lei n. 6.015/73”⁵.

No mesmo sentido tem se posicionado o Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo: “Imóvel descaracterizado por destaques de áreas e desapropriações. Necessidade de apuração das reais características remanescentes”⁶.

E não é possível que nos títulos apresentados a descrição do imóvel seja feita por dedução, isto é, seja apresentada a descrição do imóvel anterior ao destaque e depois descrita a área destacada, nem que seja registrada alienação ou oneração do imóvel na matrícula já desfigurada por destaque. No título

³ Títulos são os documentos hábeis a constituir ou transmitir direitos reais.

⁴ Antes da vigência da Lei 6.015/73 e da adoção do sistema de matrículas, as transmissões de imóveis eram transcritas na forma regida pelo Decreto 4.857/39, que impunha menos exigências quanto à descrição dos imóveis.

⁵ CGJSP. Processo 001241/96. Data: 07/06/96. Localidade: Jundiaí. Parecer Juiz Auxiliar Francisco Eduardo Loureiro. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶ CSMSP. Apelação Cível nº 080067-0/0. Data: 03/12/2001. Localidade: Barueri. Relator: Luis de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

deverá constar a descrição da área remanescente e, antes do registro, deverá o oficial encerrar a matrícula anterior e descerrar matrícula para a área remanescente⁷, o que, em situações em que o imóvel seja descrito de forma deficiente, só é possível após regular procedimento de retificação⁸:

"Não há, na matrícula, a descrição da área remanescente, decorrente destas desapropriações. Esta situação, por si só, já indica a inviabilidade de registro de qualquer título, porque, à mingua da devida descrição da área remanescente, houve ofensa ao princípio da especialidade objetiva, segundo o qual, no conceito dado por Afrânio de Carvalho, na obra 'Registro de Imóveis', toda inscrição deve recair sobre um objeto precisamente individuado (4ª edição, Forense, Rio de Janeiro, 1997)"⁹.

Também nos casos dos denominados registros flutuantes não é possível o descerramento de matrícula sem a prévia retificação. Os registros flutuantes são aqueles em que: "apesar de traduzirem retrato de uma época, mostram-se inteiramente desprovidos de elementos que os permitem localizar geograficamente. Trazendo apenas referência à área, em alqueires¹⁰, e confrontações não mais identificáveis na época presente, registros de tal natureza em significativa expressão como que 'flutuam' geograficamente, não mais sendo localizados no solo em atenção à especialidade".¹¹

Essa falha descritiva denomina-se vício de ablaqueação¹², e decorre dos imóveis estarem "deslastreados, já que originários dos 'chamados registros flutuantes', porquanto não seria possível conhecer sua base imobiliária. Como tais, suas descrições, por serem vagas, são imprestáveis. E isso porque não permitiriam afirmar a situação do imóvel com segurança"¹³.

⁷ Art. 233, II, da Lei 6.015/73.

⁸ Art. 213, §7º, da Lei 6.015/73.

⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 513-6/3. Data: 20/7/2006. Localidade: Campos do Jordão. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J. em 01/11/2006.

¹⁰ No Estado de São Paulo 1 alqueire equivale a 24.200 m², em Minas Gerais a 48.400 m² e no Norte do País a 27.225 m².

¹¹ CGJSP. Decisão 001931/98. Data: 02/03/1999. Localidade: São Bernardo do Campo. Juiz Auxiliar da Corregedoria: Antonio Carlos Morais Pucci. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹² Do latim ablaqueare: desprender.

¹³ CSMSP. Apelação Cível nº 021744-0/9. Data: 22/6/1995. Localidade: Mococa. Relator: Des. Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

A necessidade de precisa caracterização do imóvel, que decorre do princípio da especialidade, também não permite que na análise dos títulos submetidos a registro sejam toleradas diferenças descritivas do imóvel, mesmo que pequenas: "não cabe em sede de direito registrário o menosprezo de pequenas metragens com a finalidade de se ajustar documentos. A metragem constante no ato notarial tem que corresponder àquela constante na unidade de registro de imóveis. Essa caracterização detalhada e precisa do imóvel encontra-se estampada no princípio da especialidade, constante no art. 176 da Lei 6.015/73"¹⁴.

Havendo divergência na descrição do imóvel entre os dados do registro e os documentos apresentados, deve ser corrigido o título ou o registro anterior, eliminando qualquer perplexidade e definindo a correta caracterização do imóvel, preservando-se a especialidade objetiva.

Quanto aos imóveis urbanos, na escritura pública são dispensadas "sua descrição e caracterização, desde que constem, estes elementos, da certidão do Cartório do Registro de Imóveis"¹⁵, devendo o título, no entanto, consignar "o número do registro ou matrícula no Registro de Imóveis, sua completa localização, logradouro, número, bairro, cidade, Estado"¹⁶. Claro que essa regra, por exigir que no título conste a completa localização do imóvel, logradouro e número, não pode ser utilizada, por exemplo, para um terreno que não possa ser identificado por seu lote e quadra, haja vista que uma descrição que indique um terreno sem número em determinada rua, não localiza o imóvel, sendo, nesses casos, necessária a completa descrição, incluindo a área, as confrontações do terreno, distância da esquina, lado par ou ímpar da rua, etc., para que se possa defini-lo.

Sobre esse tema, em parecer com caráter normativo, assim estabeleceu a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo quanto à aplicação da Lei 7.433/85: "A propósito das dúvidas surgidas na aplicação do novo texto legal mister, finalmente, anotar que, a dispensa de descrição e caracterização de imóveis urbanos (art. 2º da Lei nº 7.433/85), não desobriga a observância dos demais elementos previstos no art. 225 da Lei nº 6.015/73, como se de-

¹⁴ CSMSp. Apelação Cível nº 073149-0/9. Data: 28/03/2001. Localidade: Itanhaém. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁵ Art. 2º da Lei 7.433/85.

¹⁶ Art. 2º, § 1º, da Lei 7.433/85.

preende do teor do parágrafo primeiro do artigo 2º do indigitado diploma legal"¹⁷.

Importante observar que jamais a descrição do imóvel pode ser substituída pela simples referência à matrícula. A obrigação da indicação da matrícula ou registro anterior¹⁸ e a necessidade da descrição do imóvel¹⁹ decorrem de dispositivos legais distintos, que não se confundem, não podendo ser registrado título que apresente apenas o número da matrícula: "o instrumento desatende assim à indeclinabilidade de caracterização minuciosa do imóvel (art. 225, § 1º, da Lei de Registros Públicos) – que não se confunde com a obrigatoriedade de referência à matrícula ou ao registro anterior (art. 222)"²⁰.

Observa-se ainda que a dispensa da completa descrição do imóvel na hipótese do artigo 2º da Lei 7.433/85 tem sido estendida para instrumentos particulares e títulos judiciais: “através da Lei n. 7.433, de 18/12/85, permitiu-se ao tabelião que, nas escrituras públicas, os imóveis urbanos negociados fossem descritos e caracterizados apenas pelo 'número do registro ou matrícula no registro de imóveis, sua completa localização, logradouro, número, bairro, cidade, Estado', e essa linha de conduta merece ser estendida aos títulos judiciais e aos instrumentos particulares”²¹.

1.2. Especialidade Subjetiva

Assim como a especialidade objetiva, a subjetiva exige perfeição na qualificação registral, contudo, nesta, o objeto são os participantes do ato registrado.

“Artigo 176:

§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas:

III – são requisitos do registro no Livro nº 2:

¹⁷ CGJSP. Processo 001415/86. Data: 16/1/1986. Localidade: São Paulo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁸ Arts. 222 e 223 da Lei 6.015/73.

¹⁹ Art. 225 da Lei 6.015/73.

²⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 281100/79. Data: 7/8/1979. Localidade: Serra Negra. Relator: Humberto de Andrade Junqueira. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

²¹ CSMSP. Apelação Cível nº 026999-0/8. Data: 5/10/1995. Localidade: Campinas. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

2) o nome, domicílio²² e nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou credor, bem como:

a) tratando-se de pessoa física, o estado civil²³, a profissão²⁴, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da Cédula de identidade, ou à falta deste, sua filiação;

b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes²⁵ do Ministério da Fazenda;²⁶

Mas nem sempre é imprescindível que esses elementos estejam no próprio título submetido a registro, podendo ser complementados por documentos hábeis, desde que não haja risco na identificação das pessoas envolvidas:

"O formal de partilha contém qualificação incompleta das herdeiras a que se atribuiu o bem imóvel: ou se o adita, para complementação, ou se suprem as lacunas existentes quanto à especialização subjetiva, mediante documentos idôneos a serem exibidos ao registrador"²⁷.

Da mesma forma: "Para o registro²⁸ da penhora é necessária a qualificação do credor no título judicial, podendo ser suprida tal exigência com a apresentação de documentos oficiais idôneos como complementação ao título"²⁹.

²² A indicação do domicílio deve permitir a localização da pessoa e, por isso, títulos que indiquem apenas a cidade de domicílio devem ser complementados.

²³ São elementos essenciais do estado civil a qualificação do cônjuge e o regime de bens adotado no casamento (item 52 do Capítulo XX das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo -NSCGJSP).

²⁴ Desempregado não pode ser utilizado como indicação de profissão, sendo apenas um estado transitório, devendo ser solicitada a indicação da efetiva profissão da pessoa.

²⁵ Atualmente, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), que substituiu o antigo Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), mantendo os mesmos números anteriores, tendo os cartões de CGC perdido a validade em 30/06/1999 (IN SRF 142/98).

²⁶ Artigo 176, § 1º, III, 2, da Lei 6.015/73.

²⁷ CSMSp. Apelação Cível nº 012216-0/9. Data: 9/4/1991. Localidade: São Paulo. Relator: Onei Raphael. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

²⁸ Embora o art. 167, I, 5, da Lei 6.015/73 estabeleça que a penhora será registrada, o art. 659, § 4º, do CPC, com a redação determinada pela Lei 11.382/06, indica que a penhora deverá ser averbada.

²⁹ CSMSp. Apelação Cível nº 033358-0/0. Data: 15/4/1997. Localidade: São Vicente. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

E essa complementação pode ser feita inclusive com dados já existentes em outros lançamentos feitos em outras transcrições ou matrículas: "Matrícula que não consigna o estado civil do proprietário. Escritura pública de venda e compra que qualifica o vendedor e sua esposa. Existência, porém, na mesma unidade de registro imobiliário, de outra matrícula imobiliária, que contém a qualificação completa do proprietário, bem como de sua esposa, em harmonia com suas qualificações insertas no título negocial apresentado a registro. Possibilidade de tais elementos de qualificação do proprietário e sua mulher serem transportados de uma matrícula à outra pelo registrador"³⁰.

Em decorrência da necessidade da perfeita identificação das pessoas envolvidas no registro, não é admitida a utilização de abreviaturas em nomes. As abreviaturas, que devem ser evitadas na escrituração de atos notariais e de registro, quando utilizadas em nomes violam a especialidade subjetiva e impedem o registro do documento em que ocorrerem:

"O acesso do título apresentado ao fôlio³¹ era mesmo de ser negado, por infringência a expressa disposição legal constante do art. 176, § 1º, inciso II nº 3, alínea "a" da Lei nº 6.015/73, que estabelece como requisito da matrícula o nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como o estado civil, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da cédula de identidade, ou, à falta deste, sua filiação.

Os próprios recorrentes reconhecem que abreviaturas do nome da compromissária compradora e a falta da completa qualificação do casal ferem dispositivo da Lei de Registros Públicos, pretendendo seja o óbice superado sob o argumento de evidente dificuldade de retificação do instrumento.

Em que pese o argumento, a eventual dificuldade na retificação do instrumento, não autoriza a dispensa do cumprimento da exigência, que constitui elemento indispensável da especialização subjetiva, princípio registrário que não pode ser mitigado pela alegada dificuldade em atender a exigência"³².

³⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 077859-0/8. Data: 05/09/2001. Localidade: Bragança Paulista. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³¹ Os termos fôlio, fôlio real, tábuas prediais, são usados frequentemente como sinônimos do Livro 2 – Registro Geral, no qual são lançados todos os atos que digam respeito diretamente ao imóvel (art. 176 da Lei 6.015/73).

³² CSMSP. Apelação Cível nº 090348-0/1. Data: 6/8/2002. Localidade: Jundiaí. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

1.3. Direito de Saisine

A qualificação de herdeiros no caso de transmissão *causa-mortis* requer cuidado, haja vista que em decorrência do direito de *saisine*³³, previsto no art. 1.784 do CC, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”, embora, “a transmissão da herança pela abertura da sucessão é do patrimônio indiviso e não se especifica o quanto caberá a cada um dos sucessores. Tal especificação de quinhões dá-se com a partilha, ao final do inventário e a aquisição efetiva da propriedade ocorre com o registro, conforme o sistema nosso para aquisição da propriedade imobiliária”³⁴.

Em decorrência da *saisine*, se o herdeiro era casado no regime da comunhão universal de bens quando do falecimento, o imóvel se comunicará com seu cônjuge, mesmo que a partilha seja homologada ou o registro ocorra após a separação do casal, devendo por isso o oficial qualificar os herdeiros no estado civil em que se encontravam quando do falecimento do *de cujus*, e não do momento da partilha, averbando em seguida eventuais alterações ocorridas após a abertura da sucessão: “É sabido que, por força do disposto no artigo 1.572³⁵ do Código Civil, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos (direito de *saisine*), no exato momento da abertura da sucessão. Via de consequência, em atenção ao que contém o artigo 262³⁶, também do Código Civil, teria ocorrido, a princípio, comunicação dos bens herdados ao cônjuge, em razão do regime da comunhão universal de bens adotado pelo casal”³⁷.

Exceções a essa regra ocorrem quando foram partilhados na separação os direitos hereditários ao herdeiro, que então recebe a herança no estado civil de separado³⁸, ou ainda, quando, não havendo partilha na separação ou divór-

³³ Do francês *saisir*, que significa agarrar, prender, tomar, apoderar-se de, assenhorar-se, apreender.

³⁴ CSMSp. Apelação Cível nº 000045-6/7. Data: 16/12/2003. Localidade: São Paulo. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁵ Art. 1.784 do CC de 2002.

³⁶ Art. 1.667 do CC de 2002.

³⁷ CSMSp. Apelação Cível nº 031141-0/5. Data: 4/6/1996. Localidade: São Paulo. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁸ 1ª VRPSP. Processo 284/2/98. Data: 23/3/1998. Localidade: São Paulo. Relator: Oscar José Bittencourt Couto. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

cio³⁹, o ex-cônjuge do herdeiro renuncia a sua meação nos autos do inventário: “Recusa em registrar formal de partilha em que a herdeira foi qualificada como divorciada, quando era casada no regime da comunhão universal de bens ao tempo da abertura da sucessão - Ex-cônjuge que renunciou ao direitos de meação, em favor do monte, por meio de termo lavrado nos autos do inventário - Admissibilidade - Partilha que, de resto, não ofende o trato contínuo, porque cuidou dos direitos de meação do ex-cônjuge, existentes ao tempo da abertura da sucessão”⁴⁰.

Igual cuidado na indicação do estado civil do proprietário deve ocorrer no registro de mandado de usucapião, em que o domínio é adquirido pelo transcurso do prazo, sendo a sentença meramente declaratória⁴¹.

2. Princípio da Publicidade

Pelo princípio da publicidade garante-se ao proprietário do bem a oponibilidade *erga omnes* de seu direito, pois como assevera o Código Civil, só se adquire a propriedade imóvel por ato entre vivos mediante o registro do título no Registro de Imóveis (artigo 1.245 do CC), o qual é materializado no Livro 2, denominado Registro Geral, sendo sua certidão o instrumento hábil para a comprovação da propriedade. Em um segundo aspecto, este princípio efetiva o direito previsto no artigo 17 da Lei 6.015/73, qual seja, a possibilidade de qualquer pessoa requerer a certidão do registro, sem haver necessidade de demonstrar-se motivo ou interesse.

Angel Cristóbal Montes, em sua obra “Direito Imobiliário Registral” nos adverte a respeito da importância da publicidade dos registros:

“Efetivamente, a publicidade dos assentos do registro procura no terceiro adquirente a eliminação dos perigos a que dá lugar a clandestinidade no que diz respeito à verdadeira situação jurídica das propriedades territoriais, com o qual evitam-se, com relação a terceiros, as nefastas consequências do estelionato (ocultação maliciosa de gravames) e da venda dupla de uma mesma coisa”⁴².

³⁹ Art. 1.581 do CC.

⁴⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 038649-0/4. Data: 21/8/1997. Localidade: São Paulo. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴¹ Art. 1.241 do CC e art. 941 do CPC.

⁴² CRISTÓBAL MONTES, Angel. *Direito Imobiliário Registral*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2005, p. 179.

Mas essa publicidade não é absoluta. Embora os dados arquivados no Registro Imobiliário sejam essencialmente públicos, algumas informações que chegam a seus arquivos são sigilosas e devem assim permanecer. Nesses casos encontram-se, por exemplo, cartas de sentença extraídas de processos de separação judicial que contenham peças protegidas pelo segredo de justiça ou mandados de indisponibilidade que contenham informações reservadas. Nesses casos, em que o segredo decorra de disposição legal ou de expressa determinação judicial, o Registro Imobiliário somente poderá emitir certidões das peças que diretamente tratem do imóvel objeto de registro, mantendo o sigilo das peças que não digam respeito ao imóvel, mas que tenham instruído o título submetido a registro. Essa restrição envolve apenas o título arquivado, e não o registro lavrado, que é público, não sendo possível haver nenhuma restrição à emissão de certidão dos atos relacionados ao imóvel, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei 6.015/73.

Além disso, a publicidade não é direta, mas indireta, ou seja, ocorre pela emissão de certidões, e não pela consulta pelo usuário dos próprios livros de registro: "Distinção entre publicidade direta e indireta, observando que aquela, antes prevista no Decreto 4.857/39 (art. 19), não é acolhida pela Lei n.º 6.015/73 (art. 16), que, em regra, segue o sistema da publicidade indireta (via certidões e informações, que não se confundem com exibição direta de livros e fichas)"⁴³.

Essa regra, porém, tem exceções, como a estabelecida no art. 24 da Lei 6.766/79: "o processo do loteamento e os contratos depositados em cartório poderão ser examinados por qualquer pessoa, a qualquer tempo, independentemente do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a título de busca".

3. Princípio da Prioridade

“O princípio de prioridade significa que, num concurso de direitos reais sobre um imóvel, estes não ocupam todos o mesmo posto, mas se graduam ou classificam por uma relação de precedência fundada na ordem cronológica do seu aparecimento: *prior tempore potior jure*. Conforme o tempo em que surgi-

⁴³ Prot. CGJ 42.249/2005 – Ementário CGJ – Extrajudicial nº 1/2006 – 1º Trimestre – Registro de Imóveis – D.O.J de 19/04/2006.

rem, os direitos tomam posição no registro, prevalecendo os anteriormente estabelecidos sobre os que vierem depois.”⁴⁴

Na Lei de Registros Públicos o princípio da prioridade está assim estabelecido:

“Art. 186. O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente”.

Mas claro que essa precedência não vigora por prazo indeterminado, nem é absoluta.

A precedência requer que o título esteja apto para registro ou, caso necessite ser corrigido, seja sanado e reapresentado no prazo de validade da prenotação⁴⁵, que é fixado em 30 dias (art. 205 da Lei 6.015/73). Cessados os efeitos da prenotação anterior por omissão do interessado, os demais títulos que aguardavam sua oportunidade de registro podem ser analisados e, se aptos, registrados, na ordem subsequente de prenotação.

Não se pode deixar de observar que na contagem do prazo de prenotação deve-se incluir o dia de início: "O prazo da prenotação segue a regra do artigo 205 da Lei n. 6.015/73, sendo, pois, contado do seu lançamento no protocolo. Não se aplica, portanto, a regra geral do artigo 125 do Código Civil⁴⁶, que manda excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento"⁴⁷.

O princípio da prioridade também não significa que todos os títulos devam ser registrados sempre na mesma ordem em que prenotados. E isso é evidente quando se observa que na prática títulos são devolvidos diariamente para serem corrigidos, devoluções são contestadas em processos administrativos e judiciais, atrasando o registro desses documentos, o que não poderia impedir o registro de todos os outros títulos prenotados posteriormente, incluindo os que nenhuma relação tenham com aqueles, por apenas terem sido apresentados posteriormente. Somente títulos contraditórios, ou seja, que en-

⁴⁴ CARVALHO, Afrânio de. Op. cit., p.191.

⁴⁵ Prenotação é o lançamento no Livro 1, denominado Protocolo, do título apresentado ao Registro Imobiliário.

⁴⁶ Atualmente, art. 132 do CC.

⁴⁷ Parecer aprovado pelo Corregedor Geral da Justiça Des. Márcio Martins Bonilha no Processo 002524/97. Data: 29/12/97. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

volvam o mesmo imóvel e gerem direitos concorrentes estão subordinados à rigorosa ordem de prenotação.

Note-se que o princípio da prioridade do registro aplica-se a direitos reais, assim, por exemplo, a prioridade de uma penhora sobre outra, por não se tratar de confronto de direitos reais, não se vincula à ordem de lançamento no Livro 2: "No concurso de credores, interessa a cronologia das penhoras, não a cronologia dos registros dessas penhoras"⁴⁸.

Atente-se que a Lei 8.212/91 em seu artigo 53, § 1º, determina que os bens penhorados a partir de ação de execução judicial de dívida ativa movida pela União, suas autarquias e fundações públicas ficam indisponíveis, assim, nos termos do disposto em lei, estando o imóvel penhorado a esses entes a indisponibilidade que grava o bem, a princípio, não permitiria que posteriores penhoras fossem averbadas. Contudo, entendimento consolidado do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo admite o ingresso de novas penhoras em imóveis indisponíveis nos termos da Lei 8.212/91, ressalvado apenas o registro de eventual carta de arrematação:

“Registro de Imóveis. Averbação de penhora de imóvel. Bem considerado indisponível por força de penhora realizada em ação de execução fiscal movida pela Fazenda Nacional (art. 53, § 1º, da Lei n. 8.212/1991). Indisponibilidade que não impede nova penhora sobre o mesmo imóvel e a averbação correspondente. Entendimento firmado pelo Conselho Superior da Magistratura. Ressalva, porém, no sentido da impossibilidade de registro da arrematação do bem enquanto perdurar a indisponibilidade. Recusa do Oficial Registrador que deve ser afastada. Recurso provido.”⁴⁹

4. Princípio da Unitariedade

Todo imóvel deve ser matriculado no Livro 2 - Registro Geral, sendo que é na matrícula que se descreve o imóvel, e em seguida a ela são lançados os atos que o afetam e os sujeitos a ele relacionados, constituindo o Livro 2 o repositório das informações que digam respeito ao imóvel, previstas no art. 167 da Lei 6.015/73.

⁴⁸ NEGRÃO, Theotonio. *Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor*. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 698 (Lex JTA 146/61 em nota ao art. 711).

⁴⁹ Processo CGJSP 2009/11330. Data: 07/5/2009. Localidade: Santa Adélia. Relator: Ruy Pereira Camilo. Publicado no D.O.J. em 25/5/2009.

Além da descrição, a matrícula, que para cada imóvel receberá um número de ordem sequencial próprio, também deve conter a data em que foi aberta, a qualificação do proprietário e o número do registro anterior (matrícula ou transcrição que a originou), como estabelece o art. 176, § 1º, II, da Lei 6.015/73.

A matrícula, que por conter a descrição do imóvel, é o cerne do Registro Imobiliário, está subordinada ao princípio da unitariedade, que determina que a cada imóvel deve corresponder uma única matrícula e a cada matrícula um único imóvel (art. 176, § 1º, I, da Lei 6.015/73).

Assim, não é possível a abertura de matrícula para fração ideal de imóvel ou que uma única matrícula abranja diversos imóveis, como ocorre, por exemplo, quando um terreno é dividido por uma rua. Pela mesma razão não se pode registrar a alienação de parte certa e localizada de um imóvel na matrícula da área maior, devendo ser descerrada matrícula para o imóvel alienado e nela registrada a venda:

"Com relação aos respeitáveis julgados colacionados pelos recorrentes, deve ser ressaltado que a venda de frações ideais até pode ser levada ao fôlio, desde que expressa em percentuais incidentes sobre a área e não em medida certa ('correspondendo a 3,75 alqueires ou 9,075 hectares⁵⁰'), como aqui verificado"⁵¹.

A mesma regra se aplica na oneração de parte certa e localizada: "A hipoteca não pode - sem desmembramento prévio - incidir sobre parte localizada dentro do todo. O que se admite - seja em percentual, seja mesmo em expressão métrica - é o registro que incide sobre parte não localizada sobre o todo"⁵².

O princípio da unitariedade não era adotado no antigo sistema de transcrições, surgindo com a Lei 6.015/73, mudança que deve ser observada com cuidado quando do descerramento de matrículas a partir de antigas transcrições:

⁵⁰ 1 hectare equivale a 10.000 m2.

⁵¹ CSMSp. Apelação Cível nº 462-6/0. Data: 17/8/2006. Localidade: Paraibuna. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J. em 01/11/2006.

⁵² CSMSp. Apelação Cível nº 021223-0/1. Data: 17/01/95. Localidade: Palmital. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

“Em havendo, pois, partes ideais objeto de transcrições diversas, indispensável todos esses registros sirvam de suporte para a matrícula”⁵³.

5. Princípio da Taxatividade

No Livro 2 do Registro de Imóveis, além da matrícula⁵⁴, são lançados dois tipos de atos, o registro⁵⁵ e a averbação⁵⁶, cuja distinção é muito importante, embora em algumas oportunidades o próprio legislador não seja preciso na terminologia dos atos, determinando a prática de registro quando se trata de averbação e vice-versa, o que inclusive reforça a importância do conhecimento da definição técnica desses atos:

"Pelo registro (sentido estrito) se constitui o direito real e se anotam os atos translativos da propriedade. (...)

Já a averbação se destina à anotação de circunstâncias relativas às pessoas ou ao imóvel que, sem interferirem na propriedade, atualizem ou tragam à matrícula informações relevantes”⁵⁷.

Portanto, se o lançamento visa à constituição ou transferência de direitos reais sobre imóveis, deve ser em regra⁵⁸ lançado por registro. Assim, é por registro que ingressa no Livro 2 a alienação do imóvel ou a constituição de hipoteca, por exemplo.

Por outro lado, se apenas se está alterando a qualificação das partes ou a descrição do imóvel, o ato é de averbação, como ocorre na alteração da numeração predial, mudança de estado civil por casamento e até na retificação da descrição da matrícula do imóvel, todos esses atos lançados por averbação.

⁵³ CSMSp. Apelação Cível nº 022983-0/6. Data: 23/06/95. Localidade: Santa Cruz do Rio Pardo. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵⁴ Art. 167, caput, da Lei 6.015/73.

⁵⁵ Em sentido amplo, o termo registro é encontrado diversas vezes englobando os conceitos de registro (em sentido estrito) e averbação.

⁵⁶ Conforme estabelece o subitem 41.1 do Capítulo XX das NSCGJSP, no Livro 2 “será indevido qualquer lançamento por certidão ou ‘observação’, pois o ato deve ser registrado ou averbado, inexistindo previsão legal diversa”.

⁵⁷ CGJSP. Decisão 04/90. Data: 11/1/1990. Localidade: Santos. Juiz: Ricardo Cintra Torres de Carvalho. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵⁸ Em algumas situações são excecionadas essas regras por expressa determinação legal, como será visto ao longo desta obra.

E o princípio da taxatividade ou dos *numerus clausus* limita o que pode ser registrado ou averbado na matrícula de um imóvel.

Esse princípio estabelece que no registro imobiliário somente podem ser lançados os atos que contem com expressa previsão legal, ou seja, os relacionados no art. 167, I e II, da Lei de Registros Públicos, e os expressamente especificados na legislação subsequente (arrolamento fiscal, previsto na Lei 9.532/97, por exemplo):

"Em primeiro lugar, afirma-se a natureza exaustiva do rol constante no inciso I do artigo 167 da Lei 6.015/73. 'Os direitos registráveis são taxativamente fixados pela lei, constituem um *numerus clausus*', como afirma Afrânio de Carvalho (Registro de Imóveis, Forense, Rio de Janeiro, 1976, pág. 76) e vem sendo reconhecido, de forma pacífica, pela jurisprudência, devido à tipicidade marcante no âmbito do regramento normativo dos direitos reais. Não cabe, portanto, ao juiz ou a qualquer outro interessado ampliar o rol dos atos inscrivíveis no sistema registrário, vedada a aplicação de analogia para alargar as hipóteses legais"⁵⁹.

Embora seja defendido por muitos que o Registro de Imóveis deva ser o repositório de todos os fatos relacionados ao imóvel, e que não deveria haver limites ao que possa ser registrado ou averbado (*numerus apertus*), a taxatividade impede que atos irrelevantes ou que visem apenas causar prejuízos ao detentor do direito real possam alcançar indevidamente o fôlio real.

Exemplos da necessidade de imposição de limites são encontrados na prática, quando se pretende averbar que no imóvel se encontra instalada determinada linha telefônica ou o título de sócio remido na matrícula do imóvel em que sediado um clube, bem como na frequente tentativa de se lançar por simples requerimento que determinado imóvel não pode ser alienado ou que será objeto de futuro litígio, pretensões que nenhuma informação relevante ou válida agregam ao registro e apenas tumultuariam eventual disponibilidade do bem, o que a taxatividade impede, sem, contudo, impedir a preservação de direitos, haja vista a existência de alternativas no rol do art. 167, como a possibilidade de registro da citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis (art. 167, I, 21, da Lei 6.015/73) ou a averbação das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados

⁵⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 032930-0/3. Data: 21/11/96. Localidade: Marília. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

ou averbados (art. 167, II, 12, da Lei 6.015/73). Além da possibilidade de averbação visando noticiar o ajuizamento de execução, encontrada no artigo 615-A do CPC, inserido pela Lei 11.382/06.

A taxatividade também está intrinsecamente ligada à liberdade que há de qualquer pessoa requerer o registro ou averbação (art. 217 da Lei 6.015/73), sendo que naturalmente haveria a necessidade de se criar uma limitação. Não sendo de quem pode requerer o registro, imprescindivelmente deve ser do que pode ser lançado na matrícula, sob pena de se gerar uma desordem nos assentamentos registrários.

"O poder de soberania sobre a coisa e a sua eficácia *erga omnes* criam a chamada obrigação passiva universal (*jura excludendi omnes allos*), mas, em contrapartida, subordinam os direitos reais ao princípio da tipicidade (*numerus clausus*). Não se justifica que se confiasse à iniciativa dos interessados a livre criação de instrumentos que podem causar séria perturbação no comércio jurídico e atingir terceiros que não se vincularam ao negócio (cf. João Matos de Antunes Varela, *Das obrigações em geral*, 8. ed., Coimbra : Almedina, 1994, Vol. I, p. 191 et seq.; Mário Júlio de Almeida Costa, *Direito das obrigações*, 6. ed., Coimbra : Almedina, 1994, p. 103)"⁶⁰.

Necessário ressaltar que o caput do art. 246 da Lei 6.015/73 estabelece que "além dos casos expressamente indicados no item II do artigo 167, serão averbados na matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro".

No Estado de São Paulo, em decorrência do disposto no referido artigo, consideram-se taxativos apenas os atos de registro, e não os de averbação. Em parecer que admitiu a publicidade registral de áreas contaminadas por substâncias tóxicas e perigosas, autorizando a averbação de declaração ou termo emitido pela Cetesb, o art. 246 da Lei 6.015/73 foi interpretado como atribuindo "ao elenco de hipóteses de averbação discriminadas na Lei de Registros Públicos o caráter de rol meramente exemplificativo, diversamente do que se passa com as hipóteses de registro do art. 167, I, enumeradas em caráter taxativo"⁶¹. Em posterior decisão, ao se autorizar a averbação de termo de ajusta-

⁶⁰ CSMSp. Apelação Cível nº 282-6/8. Data: 20/4/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶¹ Parecer aprovado pelo Corregedor Geral da Justiça Des. Gilberto Passos de Freitas em 2 de maio de 2006. Processo 167/2005. Data 20/4/2006. Localidade: São Paulo. Publicado no D.O.J. de 12/06/2006.

mento de conduta⁶², estabeleceu-se: "Hipóteses de averbação não previstas, de modo exaustivo, no art. 167, II, da LRP. Tratam-se de *numerus apertus*, admitindo as diversas averbações enunciativas que, de qualquer modo, alterem o registro (art. 246 da LRP)"⁶³.

No entanto, esse artigo não permite qualquer averbação, mas apenas aquelas que alterem o registro, mantendo, assim, limitadas as hipóteses de averbação. Em decisão que indeferiu o lançamento no Livro 2 de cessão de direito de uso de bem público⁶⁴, em que não havia efetiva transmissão de direito real, esse tema foi analisado: "também o art. 246 da Lei 6.015/73 que dá amparo à averbação na matrícula de outras ocorrências, enfraquecendo a regra da taxatividade já referida, não beneficia a recorrente, uma vez que a providência em pauta não modifica, de qualquer maneira, o registro imobiliário"⁶⁵.

Em 2009 o rol do artigo 167, II da Lei 6.015/73 sofreu duas alterações, passando a incluir os itens 24 e 26, admitindo-se a averbação do destaque de imóvel de gleba pública originária⁶⁶ e do auto de demarcação urbanística⁶⁷.

Deve-se ressaltar ainda que não se pode tentar contornar o princípio da taxatividade com fundamento no artigo 178, VII, da Lei 6.015/73, que permite o registro no Livro 3 – Registro Auxiliar dos "títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato praticado no Livro 2".

Esse dispositivo legal apenas permite que, a requerimento do interessado, o título registrado ou averbado no Livro 2 também seja transcrito integralmente no Livro 3. Não é qualquer documento que pode ser registrado em inteiro teor no Livro 3, mesmo porque o art. 177 da Lei 6.015/73 restringe os lançamentos nesse Livro aos atos que, por disposição legal, tenham sido atribuídos ao Registro de Imóveis.

⁶² Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85.

⁶³ Processo nº 215/2006 – Ementário CGJ – Extrajudicial nº 4/2006 – 3º Trimestre – Registro de Imóveis – D.O.J de 27/10/2006.

⁶⁴ Atualmente a concessão de direito de uso é admitida pelo Código Civil em seu artigo 1.225.

⁶⁵ CGJSP. Processo nº 195/2001. Data 7/2/2001. Localidade: Mairiporã. Juiz Auxiliar: Eduardo Moretzsoin de Castro. Corregedor Geral da Justiça: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁶ Acrescentado pela Lei 11.952/09.

⁶⁷ Acrescentado pela Lei 11.977/09.

Assim, somente será possível o registro em inteiro teor no Livro 3 dos atos lançados no Livro 2, e essa possibilidade decorre dos atos de registro e averbação serem lavrados de modo sintético, transpondo-se no Livro 2 apenas os elementos necessários, previstos no art. 176 da Lei 6.015/73, em forma narrativa, como determina o art. 231, I, da Lei 6.015/73, facultando por isso o art. 178, VII, da mesma lei, que seja também feito o registro em inteiro teor do título, desde que requerido pelo interessado. Atualmente, com a adoção em quase todos os registros de imóveis do arquivamento dos títulos em microfilme⁶⁸ e sistemas digitais⁶⁹, esse dispositivo tornou-se ultrapassado, estando em completo desuso.

6. Princípio da Continuidade

Consagrado no artigo 195 da Lei de Registros Públicos:

“Art. 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro.”

Na realidade, o objetivo deste princípio é que haja um encadeamento de atos de registro a fim de que ninguém que não seja o proprietário possa alienar o bem. Afrânio de Carvalho define bem esse princípio:

“O princípio da continuidade, que se apoia no da especialidade, quer dizer que, em relação a cada imóvel, adequadamente individuado, deve existir uma cadeia de titularidades à vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o outorgante dele aparecer no registro como seu titular. Assim, as sucessivas transmissões, que derivam umas das outras, asseguram sempre a preexistência de imóvel no patrimônio do transferente.

Ao exigir que cada inscrição encontre sua procedência em outra anterior, que assegure a legitimidade da transmissão ou da oneração do direito, acaba por transformá-la no elo de uma corrente ininterrupta de assentos, cada um dos quais se liga ao seu antecedente, como o seu subsequente a ele se ligará posteriormente. Graças a isso o Registro de Imóveis inspira confiança ao público”⁷⁰.

⁶⁸ Lei 5.433/68 e Decreto 1.799/96.

⁶⁹ Art. 41 da Lei 8.935/94.

⁷⁰ Op. cit., p. 285.

O respeito a esse princípio tem sido exigido, qualquer que seja a origem do título:

“Registro de Imóveis - Dúvida - Ingresso de mandado de registro de penhora - Objeto da penhora cujo titular está qualificado, na matrícula, como solteiro - Registro de pacto antenupcial, no livro nº 03, com a adoção do regime da comunhão universal de bens - Ademais, qualificação do réu como divorciado - Exigência do oficial registrador quanto a apresentação da carta de sentença extraída dos autos do respectivo divórcio - Alegação no sentido de que não realizada a partilha dos bens - Necessidade, porém, de apresentação da respectiva certidão de casamento, devidamente averbada, para a verificação da circunstância, na hipótese de não ter sido realizada a partilha dos bens - Em caso positivo, dever-se-á apresentar a respectiva carta de sentença - Ofensa ao princípio da continuidade - Recurso improvido - Decisão mantida”⁷¹.

Assim, mesmo os títulos judiciais se submetem à qualificação registrária, devendo, dessa forma, observar os princípios atinentes ao Registro de Imóveis, tanto que quando o título é ingressado na serventia, deverá o Oficial ao analisá-lo encontrar elementos suficientes que assegurem a segurança jurídica ao ato praticado. Assim como nos casos em que a ação judicial é movida contra pessoa diversa do proprietário que consta na matrícula, apresentado o mandado de penhora em que o executado é uma pessoa jurídica, que possui personalidade jurídica própria (Código Civil), atingindo bem de titularidade da pessoa física do sócio da empresa, deverá constar expressamente no título judicial que houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa pelo magistrado, a fim de que seja respeitada a continuidade:

“Verifica-se, em tese, que as mais recentes decisões deste Conselho Superior da Magistratura, embora se reportem a questões de mérito diversas das decididas pelo Juízo Trabalhista expedidor do título ora em análise, vêm se orientando quanto à inviabilidade da apreciação, pelo oficial registrador, do mérito de decisões proferidas na esfera jurisdicional, que constem do título e tenham abordado expressamente a questão relativa à possibilidade do registro, salvo, à evidência, a necessária análise dos elementos formais, a ofensa aos princípios norteadores do registro imobiliário ou outra regra de ordem pública. O recurso, no entanto, não é de ser provido, tendo em vista que, no caso,

⁷¹ CSMSp. Apelação Cível nº 060580-0/5. Data: 05/10/1999. Localidade: Mairiporã. Relator: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

somente de forma implícita se permite a ilação de que tenha sido determinada, nos autos da reclamação trabalhista que deu ensejo ao mandado judicial, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa reclamada, tendo em vista que, com relação a esse aspecto, não foi transcrita a decisão judicial, nem instruído o mandado com cópia do decidido. A ausência, no título, do teor dessa decisão judicial, impõe a manutenção do óbice registrário (...)⁷²

E essa continuidade é ampla, exigindo o encadeamento com relação a todos os aspectos que tenham repercussão no registro, tanto quanto às pessoas e descrição do imóvel, quanto aos direitos envolvidos no ato.

Deve-se observar, no entanto, que a continuidade exigida se refere a atos lançados no Livro 2 - Registro Geral. No caso de contratos noticiados em títulos submetidos a registro, mas cujo ingresso no fôlio real não tenha ocorrido e não seja do interesse dos contratantes, seu registro não é imprescindível, desde que seja mantida a continuidade apenas com os atos lançados e os que se pretende registrar.

Como exemplo, a dispensa do registro do compromisso de compra e venda, registrando-se apenas o título definitivo de alienação. Também muito frequente é a dispensa do registro do compromisso de compra e venda e de posterior cessão de direitos, registrando-se apenas a escritura de compra e venda em que o proprietário tabular aliena o imóvel diretamente ao cessionário, permanecendo o compromisso e a cessão fatos alheios ao registro, embora referidos na escritura. É como tem decidido o Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo:

“A vendedora figura no fôlio real como titular do domínio. A promessa de venda e compra, mencionada na escritura pública, não foi registrada e, por consequência, não gerou qualquer direito real, mas apenas direitos pessoais. Não são, portanto, os compromissários compradores cedentes titulares de qualquer direito real relativo às unidades autônomas. Nesse caso, o registro da escritura pública de compra e venda é possível sem o prévio registro do compromisso de venda e compra e de sua cessão pelos compromissários adquirentes. Não há aí qualquer afronta ao princípio registrário da continuidade, entendimento, aliás, já acolhido por este Conselho Superior da Magistratura no

⁷² CSMSP. Apelação Cível nº 77.412-0/9. Data: 08/10/2001. Localidade: Limeira. Relator: Luís de Macedo. Disponível em: <www.arisp.com.br> (Kollemata).

julgamento da Ap. Cív. nº 43.481-0/9, da Comarca de São Vicente, relatada pelo eminente Des. Nigro Conceição⁷³.

Importante lembrar que essa ausência de registro de compromissos e cessões é temerária, haja vista que somente o registro gera direitos reais e pode ser oponível a terceiros.

Sobre esse tema deve-se observar ainda que se o compromisso de compra e venda estiver registrado, o contrato de cessão tem que ser obrigatoriamente registrado para que, somente após, possa ser registrada a escritura em que o proprietário aliena o imóvel ao cessionário, isso porque havendo compromisso registrado, somente ao compromissário comprador pode ser alienado o imóvel, podendo o compromissário comprador, no entanto, ceder esse direito registrado, o que só se opera pelo registro do instrumento de cessão, mantendo-se assim o encadeamento dos atos e respeitando-se o princípio da continuidade.

De forma análoga, em decorrência do mesmo princípio, para que a cessão de direitos de compromisso de compra e venda possa ser registrada, antes deve ser registrado o compromisso de compra e venda: "É vedado o registro da cessão, enquanto não registrado o respectivo compromisso de compra e venda"⁷⁴.

Finalmente, a continuidade também deve ser observada na descrição dos imóveis, estabelecendo o art. 225, § 2º da Lei 6.015/73, que são "irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior".

O art. 213, § 13, da Lei 6.015/73, porém, cria uma exceção a essa regra:

"Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição". Ressalte-se que a aplicação dessa exceção não pode ser feita de ofício, mas depende de requerimento do adquirente, não podendo ser aceito pedido de outro interessado, como o alienante ou o apresentante, haja vista a expressa determinação encontrada no referido dispositivo legal.

⁷³ CSMSP. Apelação Cível nº 081307-0/4. Data: 18/2/2002. Localidade: São Caetano do Sul. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁴ Item 68.2, Capítulo XX, NSCGJSP.

6.1. O princípio da continuidade e a alienação por espólio

Situação em que é essencial a análise da continuidade é a alienação de imóvel realizada por espólio, quando diferentes hipóteses podem surgir:

1 - No caso de falecimento de um dos cônjuges proprietários e havendo comunicação do bem ao casal em decorrência do regime de bens, o imóvel pode ser alienado apenas pelo espólio, devidamente autorizado por alvará judicial. Não há violação à continuidade porque com o falecimento cria-se uma indivisibilidade que só se encerra com a partilha.

Assim, antes da partilha o imóvel é alienado integralmente pelo espólio, sendo posteriormente separada a meação e partilhados os recursos provenientes da alienação: "Visto que a meação, embora se distinga da herança, até que seja o acervo patrimonial partilhado, integra o monte-mor, numa relação jurídica de continuidade decorrente da transmissão *causa-mortis*, não há justificativa a que se exija a participação do cônjuge sobrevivente em eventual alienação de bens que integrem o acervo. A administração do patrimônio compete ao inventariante, que pode alienar bens do espólio, se devidamente autorizado pelo Juízo, após ouvidos os interessados"⁷⁵.

2 - Na hipótese em que ambos os cônjuges proprietários falecem, sem a partilha do bem, ambos os espólios devem alienar o imóvel:

"Ora, na hipótese de morte dos cônjuges, se não partilhado o bem comum do casal, aplica-se a orientação externada por este Conselho no julgamento da Apelação Cível n.º 45.71-0/5, da Comarca de Ribeirão Preto, cuja ementa é a seguinte:

‘Registro de Imóveis – Dúvida – Ingresso de escritura de venda e compra outorgada apenas pelo espólio do cônjuge-varão – Inadmissibilidade – Hipótese em que o imóvel é de titularidade do casal – Necessidade de outorga do espólio da mulher – Ofensa ao princípio da continuidade – Recurso improvido – Decisão mantida’"⁷⁶.

3 - Se o imóvel a ser alienado se comunicou com o cônjuge em decorrência do regime de bens adotado, mas quando do falecimento o autor da herança

⁷⁵ 1ª VRPSP. Processo n.º 001441-0/99. Data: 23/03/99. Localidade: São Paulo. Juiz: Dr. Oscar José Bittencourt Couto. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁶ CSMSP. Apelação Cível n.º 221-6/0. Data: 26/11/04. Localidade: Atibaia. Relator: Des. José Mario Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

era divorciado ou separado judicialmente, previamente deverá ser registrada a carta de sentença pela qual o *de cujus* recebeu o imóvel, para somente depois poder o espólio autorizado judicialmente alienar a totalidade do imóvel. Não tendo havido partilha do bem na separação ou divórcio, pode ser realizada “a separação de meação da suscitada”⁷⁷ nos autos do inventário dos bens deixados pelo ex-marido, ainda que ostente a condição de desquitada”⁷⁸, ou, alternativamente, havendo autorização judicial, a alienação do imóvel pode ser realizada pelo espólio e pelo ex-cônjuge a terceiro.

4 - Situação diferente é aquela em que há o falecimento de um dos cônjuges proprietários sem que tenha se comunicado o bem, como ocorre quando os cônjuges adquirem o imóvel solteiros, na proporção de metade para cada um e posteriormente se casam pelo regime da comunhão parcial de bens. Nesse caso o espólio, representado pelo inventariante, desde que tenha autorização judicial, aliena 50% do imóvel, devendo os outros 50% serem alienados pelo cônjuge supérstite, proprietário da outra fração.

5 - Por outro lado, quando o imóvel permanece no patrimônio exclusivo de um dos cônjuges, falecendo o outro será necessário apenas atualizar o estado civil do proprietário antes de alienar o imóvel.

Se o proprietário era casado ou separado judicialmente quando do falecimento do cônjuge, seu estado civil será atualizado para viúvo. Se o proprietário é divorciado, como o divórcio põe termo ao casamento⁷⁹, o posterior falecimento do ex-cônjuge não provocará alteração de seu estado civil.

Nas transmissões por espólio, antes do registro da transmissão se averbará previamente o óbito à vista da certidão do Registro Civil de Pessoas Naturais⁸⁰, sempre deverá ser apresentado alvará judicial⁸¹, dentro do prazo de validade, e o inventariante poderá representar o espólio mesmo após a conclusão do inventário: “o fato de estar findo o inventário não impedia que o inventariante ficasse autorizado a outorgar as escrituras, representando o espólio, para conclusão dos negócios realizados, em especial havendo anuência expressa

⁷⁷ Ex-esposa.

⁷⁸ 1ª VRPSP. Processo nº 1116/91. Data: 21/02/1992. Localidade: São Paulo. Juiz: Dr. Kioitsi Chicuta. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁹ Art. 24 da Lei 6.515/77.

⁸⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 094816-0/7. Data: 30/10/2002. Localidade: Atibaia. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸¹ Art. 992, I, CPC.

dos herdeiros, como já se decidiu em hipótese semelhante (Rev. Trib. 413/197)"⁸².

A verificação dos dados constantes da certidão de óbito é fundamental na qualificação do título em que espólio aliena imóvel e também para o registro de formal de partilha. É da certidão que serão extraídos dados como o estado civil do falecido, com quem era casado, se o cônjuge também é falecido, quais eram seus filhos, data do falecimento, etc.

7. Princípio da Instância

O princípio da instância, insculpido no art. 13 da Lei 6.015/73, estabelece que os atos praticados no Registro Predial dependem de solicitação ou instância do interessado ou de autoridade:

“Art. 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados:

I - por ordem judicial;

II - a requerimento verbal ou escrito dos interessados;

III - a requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar.”

Quando se pretende a realização de um ato de registro a provocação se dá apenas pela apresentação do título⁸³. Já nas hipóteses de averbação, deve ser apresentado requerimento com a firma reconhecida do interessado⁸⁴.

Embora haja necessidade de provocação, o interessado que pode solicitar o ato não é apenas o titular de direito real, mas qualquer pessoa, desde que apresente documentos hábeis, como estabelece o art. 217 da LRP:

“Art. 217. O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas.”

Importante ressaltar que é apenas a provocação que pode ser feita por qualquer pessoa, mas o ato só será praticado se atendidas as exigências legais. Assim, por exemplo, embora qualquer pessoa possa apresentar no protocolo o

⁸² 1ª VRPSP. Processo nº 000082/78. Data: 29/12/78. Localidade: São Paulo. Juiz de Direito: Dr. Gilberto Valente da Silva. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸³ Art. 193, Lei 6.015/73.

⁸⁴ Art. 246, § 1º, da Lei 6.015/73.

requerimento de unificação⁸⁵ de 2 lotes, esta só será lançada nas matrículas, averbando-se o encerramento delas e abrindo-se nova matrícula para o imóvel unificado, se o documento apresentado estiver subscrito por todos os proprietários⁸⁶, a unificação estiver autorizada pelo Município⁸⁷ e atender os demais requisitos legais⁸⁸: os imóveis serem contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários⁸⁹.

O art. 246, § 1º, da Lei 6.015/73 traz limitação ao disposto no art. 217, estabelecendo que as averbações do art. 176, II, 4 e 5 da Lei 6.015/73 serão feitas a requerimento dos interessados. A mesma limitação é encontrada para o pedido de retificação previsto no art. 213 da Lei 6.015/73. Menos restrita é a legitimidade para suscitação de dúvida, que pode ser requerida pelo apresentante do título⁹⁰.

8. Princípio da Inscrição ou do Registro

A transmissão de direito real por ato *inter-vivos* somente se opera mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (princípio da inscrição ou do registro).

Esse princípio foi assim esclarecido em acórdão do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo:

"Como é elementar, em nosso direito positivo a aquisição da propriedade imóvel não se adquire *solo consensu*. Gera o contrato tão somente um direito de crédito, também denominado de direito pessoal.

Tem o registro, no caso, efeito constitutivo, criador do direito real de propriedade. Em termos diversos, a criação, extinção ou transmissão de direitos reais sobre bens imóveis só se operam por ato *inter-vivos*, mediante inscrição no registro (princípio da inscrição). (...)

⁸⁵ A Lei 6.015/73 utiliza o termo fusão para a união de matrículas e unificação para a junção de imóveis.

⁸⁶ Item 67.2 do Capítulo XX das NSCGJSP.

⁸⁷ Item 67.1 do Capítulo XX das NSCGJSP.

⁸⁸ Art. 234 da Lei 6.015/73.

⁸⁹ Além de serem os mesmos proprietários, também devem ter as mesmas proporções em ambas as matrículas, pois, do contrário, a fusão implicará em transmissão de propriedade sem título e sem cumprimento das demais exigências (recolhimento de ITBI, etc.).

⁹⁰ Art. 198 da Lei 6.015/73.

Inviável, diante do acima exposto, sustentar, em nosso sistema jurídico, que a ultimação do contrato gera direito adquirido à transmissão da propriedade imobiliária no registro. Isso porque a mutação jurídico-real é um ato complexo (título somado a registro), que somente gerará direito adquirido se decorrido por inteiro, com todos os seus elementos constitutivos, na pendência da lei a que é contemporânea (cfr. Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 17ª. Edição, Forense, vol. I, p. 96; Limongi França, *A irretroatividade das leis e o direito adquirido*, 4ª Edição RT, pág. 252-262)."⁹¹

9. Princípio *Tempus Regit Actum*

Em decorrência do princípio da inscrição, prevalece no registro o aforismo *tempus regit actum*, ou seja, quando da análise de um título deve-se aplicar as exigências legais contemporâneas ao registro, e não aquelas que vigoravam quando da lavratura do título apresentado a registro:

“Todos os títulos (judiciais ou extrajudiciais) submetem-se à qualificação registrária com aplicação de princípios e normas formais da legislação específica, vigentes à época e no momento do seu ingresso no Registro”.⁹²

Esse princípio, no entanto, tem exceções, como, por exemplo, o expressamente disposto no art. 176, § 2º, da Lei 6.015/73, que criou uma regra de transição entre a legislação anterior (Decreto 4.857/39) e a Lei de Registros Públicos⁹³ que, à época, trouxe tantas inovações que poderiam interromper as transações imobiliárias pela inviabilização do registro de títulos anteriores se não fosse preservada a validade dos títulos antigos ainda não registrados, estabelecendo o referido dispositivo legal que: "para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na vigência do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, não serão observadas as exigências deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior".

⁹¹ CSMSp. Apelação Cível nº 035714-0/0. Data: 24/02/1997. Localidade: Osasco. Relator: Des. Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁹² CSMSp. Apelação Cível nº 035623-0/4. Data: 24/02/1997. Localidade: Santa Rita do Passa Quatro. Relator: Des. Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁹³ A Lei 6.015/73 entrou em vigor em 01/01/76.

Outras exceções são as mutações naturalmente ocorridas, em que não há dúvida sobre o imóvel transmitido e que não justificam a retificação do título anteriormente lavrado:

"Sem embargo de ser procedente a dúvida, tal como decidido, pela pertinência dos óbices antes examinados, se afigura de muito rigor a determinação de que se retifique o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel e outras avenças, celebrado quando da incorporação, por já constar dos assentos registrários a instituição e especificação bem como o término da construção.

O fato de não ter sido levado a registro o instrumento particular de promessa de compra e venda na época em que firmado, quando não existia a construção, mas simplesmente a incorporação, quando tal exigência não seria levantada e provavelmente o título teria acesso, não autoriza a recusa agora por constar dos assentos registrários a instituição e especificação bem como o término da construção, isto porque celebrado antes do ingresso quando objeto do negócio jurídico a fração ideal de terreno e a construção de futura unidade autônoma.

O que não é possível após a averbação da construção e o registro da especificação de condomínio é o acesso de instrumentos lavrados posteriormente sem menção expressa a unidade autônoma já concluída"⁹⁴.

10. Princípio da Disponibilidade

A análise da disponibilidade visa assegurar que ninguém possa dispor do que não tem:

"O sistema registrário submete-se a princípios específicos e, dentre eles, se destaca o denominado princípio da disponibilidade, que se vincula ao enunciado de que ninguém pode transferir mais direito do que tem ou, no dizer dos latinos, *nemo dat quot non habet*. E a idéia de disponibilidade não pode ser dissociada da titularidade do direito real e da necessidade do registro, mesmo

⁹⁴ CSMSP. Apelação Cível nº 090348-0/1. Data: 6/8/2002. Localidade: Jundiaí. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

porque decorrente do art. 859 do Código Civil⁹⁵ ('Presume-se pertencer o direito real à pessoa em cujo nome se inscreveu ou transcreveu')"⁹⁶.

Denomina-se aquisição *a non domino* a realizada de quem não seja o proprietário do imóvel: "a escritura, que contém a transmissão da totalidade do imóvel, que não está na força do título dos outorgantes, significa compra *a non domino* insusceptível de efeitos"⁹⁷.

A disponibilidade deve ser analisada não apenas sobre o aspecto quantitativo, ou seja, se o proprietário detém a metragem quadrada alienada, mas também qualitativo, ou seja, se o imóvel corresponde fisicamente ao alienado:

"O controle da disponibilidade registrária, que a especialidade impõe, significa, de um lado, a segurança sobre a extensão aritmética do imóvel. Significa, de outro, a segurança sobre sua localização geodésica. É a disponibilidade quantitativa e a disponibilidade qualitativa"⁹⁸.

Asseverou o Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo sobre a disponibilidade quantitativa:

"Fere o princípio de disponibilidade o acesso de título judicial de divisão que ostente área cuja extensão supera a força do respectivo assento registrário".⁹⁹

Sobre a disponibilidade qualitativa, assim já se manifestou:

"A divisão em partes certas e descritas, tal como sucedido, se levada ao fôlio implicará em evidente afronta à disponibilidade qualitativa. Em verdade, dada a descrição incompleta da área, o fracionamento impõe como resultante parcelas que não podem ser definidas, de forma geodésica, dentro do todo.

⁹⁵ Sem correspondente idêntico no Código Civil de 2002, estabelecendo o artigo 1245, §2º, do novo CC que "Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel".

⁹⁶ CSMSp. Apelação Cível nº 023.792-0/1. Data: 26/06/1995. Localidade: Campinas. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁹⁷ CSMSp. Apelação Cível nº 000031/76. Data: 25/06/76. Localidade: São Paulo. Relator: Gentil do Carmo Pinto. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁹⁸ CSMSp. Apelação Cível nº 000188-6/9. Data: 13/10/2004. Localidade: Barueri. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁹⁹ CSMSp. Apelação Cível nº 22.417-0/4. Data: 31/05/1996. Localidade: Piracaia. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Mas, como já decidiu este Conselho, ‘nas segregações e divisões, o registro das parcelas destacadas exige sua localização dentro do todo, e se o lugar deste é incerto, não é de se admitir, em caso algum, que a incerteza se difunda com novas matrículas referentes às partes’. É o que ficou recentemente decidido pelo E. Conselho, no julgamento da Ap. 14.144-0/4, seguindo a linha iterativa de sua jurisprudência, no sentido de que, nos registros dos desfalques de área, há sempre necessidade de localizar a parte destacada no todo de que tem origem”¹⁰⁰.

11. Princípio da Legalidade ou Legitimidade

Esse princípio é o que determina que o Oficial de Registro promova a análise de legalidade dos títulos, denominada de qualificação, avaliando a possibilidade de registro dos títulos apresentados:

"(...) cumpre interpor entre o título e a inscrição um mecanismo que assegure, tanto quanto possível, a correspondência entre a titularidade presuntiva e a titularidade verdadeira, entre a situação registral e a situação jurídica, a bem da estabilidade dos negócios imobiliários. Esse mecanismo há de funcionar como um filtro que, à entrada do registro, impeça a passagem de títulos que rompam a malha da lei, quer porque o disponente careça da faculdade de dispor, quer porque a disposição esteja carregada de vícios ostensivos”¹⁰¹.

E nem mesmo os títulos judiciais escapam à qualificação registrária, não no tocante ao mérito das decisões, mas quanto aos elementos formais e princípios registrários (vide item 6 deste capítulo).

O controle de legalidade é expressamente determinado no Código Civil para o registro de hipotecas¹⁰². "A regra vale, todavia, para todos os registros. A Lei 6.015/73, depois de fixar o prazo para a efetivação dos registros (art. 188), relaciona algumas cautelas que o registrador deve tomar, relativas: ao direito real – disputa de grau entre hipotecas (art. 189) e de direitos contraditórios (art. 190); ao instrumento e sua forma (arts. 193 e 194); a requisitos do registro – princípio da continuidade (art. 195) e da especialidade (art. 196).

¹⁰⁰ CSMSp. Apelação Cível nº 25.179-0/9. Data: 28/09/1995. Localidade: Conchas. Relator: Des. Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁰¹ CARVALHO, Afrânio de. Op. cit., p.250-251.

¹⁰² Art. 1.496 do CC.

Apenas por estes dispositivos é possível vislumbrar o alcance da qualificação¹⁰³.

Mas mesmo passando por esse controle de legalidade, o título, somente por ter sido registrado, não se liberta de eventuais vícios que o maculem, podendo vir a ser anulado, com repercussões no correspondente registro:

"Interliga-se a disponibilidade com o princípio da legalidade ou legitimidade, segundo o qual a validade da inscrição depende da validade do negócio jurídico que lhe dá origem"¹⁰⁴.

Assim, o registro permanece associado ao título que o origina. Invalidado este, aquele é atingido.

12. Princípio da Presunção de Eficácia do Registro

O registro lançado no Livro 2 produz todos os efeitos legais enquanto não cancelado. É o que estabelece o art. 252 da Lei 6.015/73: "O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido". Da mesma forma dispõe o art. 1245, § 2º, do Código Civil: "Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel".

Por força desse princípio: "Enquanto não cancelados os registros tidos como irregulares, a serem obtidos, em sendo o caso, pelas vias adequadas, não cabe ao registrador negar seus efeitos"¹⁰⁵. Assim, não pode o interessado pretender que o oficial não pratique nenhum outro ato em decorrência de registro supostamente viciado. Deve o interessado buscar o cancelamento do registro apontado como irregular, que somente perderá seus efeitos após ser efetivamente cancelado.

¹⁰³ CSMSP. Apelação Cível nº 000.480-6/1. Data: 23/03/06. Localidade: Sorocaba. Relator: Gilberto Passos de Freitas. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁰⁴ CSMSP. Apelação Cível nº 023. 792-0/1. Data: 26/06/1995. Localidade: Campinas. Relator: Antonio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁰⁵ CSMSP. Apelação Cível nº 011067-0/0. Data: 2/7/1990. Localidade: São Carlos. Relator: Onei Raphael. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

O princípio da presunção de eficácia, no entanto, não é aplicável no caso de duplicidade de registros, como, por exemplo, quando há duas matrículas ou transcrições para o mesmo imóvel: "A presunção de que o direito pertence àquele em cujo nome está registrado não pode conviver com o duplo registro. Seria ilógico raciocinar com a presunção favorecendo, ao mesmo tempo, duas pessoas cujos direitos não podem coexistir. Em outras palavras, a presunção de veracidade do registro desaparece quando há duplicidade. A consequência é a impossibilidade de prática de qualquer ato em qualquer das correntes filiatórias, até que, na via adequada, se decida pela prevalência de uma ou de outra"¹⁰⁶.

Nosso sistema distingue-se do adotado na Alemanha por ser apenas relativa a presunção da efetividade do registro, ou seja, possibilitando prova em contrário e permitindo o cancelamento do registro: "Em nosso direito positivo, diferentemente do sistema alemão, a transcrição do título no registro de imóvel tem presunção *juris tantum*"¹⁰⁷¹⁰⁸. Porém, "apesar de o registro ser causal e não ter presunção absoluta de veracidade, em nosso sistema, é certo que produz ele todos os efeitos legais enquanto não cancelado (art. 252 da Lei 6.015/73). Em outras palavras, o dono do imóvel é quem, até prova em contrário, o registro de imóveis indica ser. Mais ainda. Também a extensão do direito de propriedade, ou seja, quais características do imóvel, são indicadas pelo registro"¹⁰⁹.

12.1. Cancelamento do Registro

Quando se busca o cancelamento é importante observar que "há duas vias básicas para o cancelamento do registro: a voluntária e a coacta"¹¹⁰.

¹⁰⁶ CSMSP. Apelação Cível nº 004094-0/85. Data: 23/07/1985. Localidade: São Vicente. Relator: Marcos Nogueira Garcez. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁰⁷ Presunção relativa, em oposição à presunção *juris et de jure* (absoluta, que não admite prova em contrário).

¹⁰⁸ STJ. Recurso Especial nº 409.303 - RS (2002/0011624-1). Relator : Ministro José Delgado.

¹⁰⁹ CGJSP. Processo 255/93. Data: 7/12/1993. Localidade: São Paulo. Juiz Auxiliar: Francisco Eduardo Loureiro. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹¹⁰ CGJSP. Processo 1413/97. Data: 26/09/97. Localidade: São José do Rio Preto. Juiz Auxiliar: Francisco Eduardo Loureiro. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

O cancelamento voluntário, por sua vez, ocorre em duas hipóteses: 1) "a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião"¹¹¹ como ocorre, por exemplo, quando há o distrato de um contrato de locação registrado, ou, 2) "a requerimento do interessado, instruído com documento hábil"¹¹², sendo documento hábil, por exemplo, a certidão de óbito do usufrutuário para o cancelamento do usufruto¹¹³.

Quando para o cancelamento não ocorra a "resilição da avença, mas sim sua resolução judicial"¹¹⁴, somente poderá ser lançado na matrícula após o trânsito em julgado da decisão¹¹⁵. Essa exigência é reforçada no art. 259 da Lei 6.015/73, que estabelece que "o cancelamento não pode ser feito em virtude de sentença sujeita, ainda, a recurso", não importando se eventual recurso foi recebido no efeito devolutivo, e não no efeito suspensivo, exigindo-se sempre o trânsito em julgado, "porque a norma processual genérica não revoga lei especial que trata, especificamente, dos efeitos da sentença judicial nos assentos imobiliários"¹¹⁶.

A exigência de trânsito em julgado da decisão decorre da definitividade do cancelamento: "O cancelamento de registro não pode ser levado a efeito de modo provisório ou condicional. O cancelamento extingue, destrói em absoluto o direito a que se refere"¹¹⁷.

E em decorrência dessa definitividade, não é possível eventual cancelamento da averbação de cancelamento¹¹⁸, estabelecendo o art. 254 da Lei 6.015/73 o procedimento a ser seguido quando seja necessário restabelecer o

¹¹¹ Art. 250, II, da Lei 6.015/73.

¹¹² Art. 250, III, da Lei 6.015/73.

¹¹³ Art. 1.410, I, do CC.

¹¹⁴ CGJSP. Processo 001413/97. Data: 26/09/97. Localidade: São José do Rio Preto. Juiz Auxiliar: Francisco Eduardo Loureiro. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹¹⁵ Art. 250, I, da Lei 6.015/73.

¹¹⁶ CGJSP. Processo 001413/97. Data: 26/09/97. Localidade: São José do Rio Preto. Juiz Auxiliar: Francisco Eduardo Loureiro. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹¹⁷ CGJSP. Processo 001413/97. Data: 26/09/97. Localidade: São José do Rio Preto. Juiz Auxiliar: Francisco Eduardo Loureiro. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹¹⁸ Art. 248 da Lei 6.015/73.

ato cancelado: "Se, cancelado o registro, subsistirem o título e os direitos dele decorrentes, poderá o credor promover novo registro, o qual só produzirá efeitos a partir da nova data".

A necessidade de repetição do ato, todavia, não provocará nenhuma despesa quanto a emolumentos ao interessado, tendo a CGJSP já impedido a cobrança de emolumentos dos atos lançados em cumprimento ao disposto no art. 254 da Lei 6.015/73¹¹⁹.

Deve-se observar, no entanto, que excepcionalmente é possível o cancelamento do cancelamento quando o ato administrativo de cancelamento for inquinado de nulidade:

“O Exmo. Sr. Des. Corregedor Geral da Justiça, acolhendo o raciocínio tecido pelos eminentes Magistrados, Drs. Geraldo Francisco Pinheiro Franco e Ricardo Henry Marques Dip concluiu no Proc. 66/89 que, definitivamente, era viável o cancelamento do cancelamento quando o ato administrativo (cancelamento) for inquinado de nulidade, e, conseqüentemente, não produz qualquer efeito, sendo, então, possível ser restaurado o registro cancelado por este cancelamento nulo.

Notadamente, em primeiro plano, não se pode esquecer que todo cancelamento registrário é definitivo, ou seja, ele não se submete a um evento futuro e incerto. Ora, se assim o é, como imaginar-se o cancelamento do cancelamento. A solução aviltrada pelos nobres juízes *susso* mencionados e acatada por Sua Exa. o Corregedor Geral da Justiça é, no todo, brilhante, uma vez que se o fundamento maior do cancelamento é a nulidade de pleno direito (art. 214 da Lei 6.015/73), por esse mesmo azo há de se cancelar o ato de cancelamento, isto é, se o cancelamento ordenado e realizado se mostra totalmente eivado deverá ele ser, igualmente, cancelado, pois não revestido de regularidade formal e substancial”¹²⁰.

Deve-se frisar que o cancelamento pode ser total ou parcial e atingir averbação, registro propriamente dito¹²¹, ou matrícula.

¹¹⁹ Parecer Publicado pelo INR em 17/04/2006 com omissão dos elementos de identificação do processo.

¹²⁰ CGJSP. Processo 000195/91. Data: 1/10/1991. Localidade: São Paulo. Juiz Auxiliar: Ricardo Mair Anafe. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹²¹ Art. 249 da Lei 6.015/73.

12.2. Cancelamento administrativo

O art. 214 da Lei 6.015/73 permite que, no caso de nulidade de pleno direito do registro, após ouvidos os atingidos¹²², possa ser cancelado o ato por decisão transitada em julgado do Juiz Corregedor: "A jurisprudência de nossos tribunais tem admitido o cancelamento do registro na esfera administrativa, desde que se trate de nulidade de pleno direito, entendida como tal aquela que diga respeito à errônea, equivocada qualificação positiva de título no cadastro imobiliário"¹²³.

Assim, na aplicação do art. 214 da Lei 6.015/73 é necessário distinguir as denominadas nulidades do registro (ou formal), mista e do título, porque somente as duas primeiras permitem o cancelamento administrativo: "Quais seriam, então, as chamadas "nulidades de pleno direito", que invalidam o registro na via administrativa, independentemente de ação direta? Explica-nos o clássico Miguel Maria de Serpa Lopes, que, do ponto de vista do registro de imóveis, e quanto à sua origem, as nulidades podem ser assim classificadas: "a) nulidade exclusivamente formal, inerente tão só ao próprio registro b) nulidade mista, isto é, a que atinge tanto o título que deu causa ao registro como a este, tornando, em ambos, o ato ineficaz, por si mesmo c) nulidade do ato jurídico que deu causa ao registro, em que a nulidade deste ocorre obliquamente, e não diretamente, como nos dois primeiros casos" (Tratado dos Registros Públicos, 1942, volume IV, pág. 305). Tem-se entendido, de outro lado, que as nulidades que admitem o cancelamento independentemente de ação direta são aquelas inerentes ao próprio processo, ou seja, ao próprio mecanismo de registro (cfr. também, Afrânio de Carvalho, Registro de Imóveis, ed. Forense, pág. 175)"¹²⁴.

Mas, mesmo havendo nulidade de pleno direito, o cancelamento não poderá ser declarado "se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel"¹²⁵.

¹²² Art. 214, § 1º, da Lei 6.015/73.

¹²³ CGJSP. Processo 001549/96. Data: 18/11/96. Localidade: São Paulo. Juiz Auxiliar: Francisco Eduardo Loureiro. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹²⁴ CGJSP. Processo 000247/97. Data: 6/3/1997. Localidade: São Paulo. Relator: Francisco Eduardo Loureiro. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹²⁵ Art. 214, § 5º, da Lei 6.015/73.

Não havendo vício no processo de registro, mas apenas no título, o cancelamento deverá ser buscado na via jurisdicional, como prevê o art. 216 da Lei 6.015/73: “O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução”.

No caso de fraude à execução, embora o art. 216 da Lei 6.015/73 afirme que o ato será anulado, o lançamento, na realidade, será apenas ineficaz em relação ao exequente: “É tema absolutamente tranquilo, como decidido em inúmeras oportunidades na esfera jurisdicional, à qual deve se afeiçoar o direito registrário, que a alienação ou oneração de bens em fraude de execução é ineficaz em relação ao exequente, embora válida quanto aos demais, razão porque não há necessidade de cancelamento do registro imobiliário (RT 601/117, 639/119, JTA 92/175; RSTJ 20/282). O negócio jurídico que fraudava a execução gera plenos direitos entre adquirente e alienante. Apenas não pode ser oposto ao exequente”¹²⁶.

Como consequência do cancelamento são atingidos todos os atos que tinham como substrato o ato cancelado: “nenhum registro pode subsistir sem o necessário encadeamento com a origem. A filiação, ou seja, o princípio da continuidade não pode deixar de ser observado. Cancelada, por qualquer motivo, a transcrição anterior, matrículas e registros nela fundadas também não podem prevalecer autonomamente. Como já frisou o magistrado que decidiu na primeira instância administrativa, ‘desapareceu o elo da corrente filiatória’”¹²⁷.

12.3. Bloqueio

Embora a perda dos efeitos do registro dependa de seu cancelamento, se o juiz corregedor “entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”¹²⁸.

¹²⁶ CSMSp. Apelação Cível nº 033474-0/9. Data: 8/11/1996. Localidade: Limeira. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹²⁷ CGJSP. Processo 000084/82. Data: 6/7/1982. Localidade: São Paulo. Juiz Auxiliar: Hélio Lobo Junior. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹²⁸ Art. 214, § 3º, da Lei 6.015/73.

Após decretado o bloqueio da matrícula “o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio”¹²⁹.

Usualmente o bloqueio é decretado por provocação do oficial de registro ou do próprio interessado e perdura até que o vício detectado no registro seja sanado ou, não sendo possível sanar o registro, até que o ato seja definitivamente cancelado, impedindo assim a proliferação da falha para outros atos. “O bloqueio representa, portanto, providência acautelatória-instrumental, caracterizada pela provisória suspensão do *ius disponendi* referente a determinado imóvel, destinada a salvaguardar a integridade dos assentamentos registrários e servindo de substitutivo ao cancelamento, só podendo, por princípio, ser decretado quando, configurada a incidência do art. 214 da Lei Federal 6.015/73, seja viável, por meio da prática de novos atos, a recuperação da validade”¹³⁰.

O bloqueio diverge do assento de contradição adotado no sistema alemão: “Já se disse que o bloqueio se aproxima do assento de contradição (*Widerspruch*) do direito germânico, porque ambos não conduzem a cancelamento de registro, possuem alguma função acautelatória e buscam a correção de erro pretérito; ao reverso do assento de contradição, entretanto, o bloqueio não se limita a excluir os efeitos da boa-fé de terceiros, nem impede a usucapião tabular, como no direito alemão”¹³¹.

13. Princípio da Cindibilidade

Pelo princípio da cindibilidade do título é possível cindir, ou seja, separar do título o que comporta registro, afastando o que não puder ser registrado.

Esse princípio, que não era aplicável no antigo sistema de transcrições, foi assim explicado em v. acórdão do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo:

¹²⁹ Art. 214, § 4º, da Lei 6.015/73.

¹³⁰ CGJSP. Processo 29.831/99. Data 27/03/2006. Localidade: Mogi das Cruzes. Juiz Auxiliar Roberto Maia Filho.

¹³¹ CGJSP. Processo 000038/87. Data: 19/3/1987. Localidade: São Paulo. Juiz Auxiliar: Ricardo Henry Marques Dip. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

"Atualmente o princípio pretoriano da incindibilidade dos títulos, construído sob a égide do anterior sistema registral, já não vigora. Nesse sentido já se posicionou o Colendo Conselho Superior da Magistratura, conforme, v.g., Ap. Cível da Comarca de São Paulo, recurso número 2.642-0, in D.O.J. de 24 de novembro de 1993.

Isso porque só aquele sistema da transcrição dos títulos justificaria não se admitisse a cisão do título, para considerá-lo apenas no que interessa.

Vale dizer que hoje é possível extrair só o que comporta inscrição, afastando-se aquilo que não puder constar do registro, por qualquer motivo, como quando, eventualmente, houver ofensa à continuidade registrária.

Na verdade, com o advento da Lei de Registros Públicos de 1973, e, consequentemente, a introdução do sistema cadastral, que até então não havia no direito registral brasileiro, a cindibilidade do título passou a ser perfeitamente possível e admitida.

Com isso o ato de registro imobiliário deixou de exigir a reprodução textual dos instrumentos recepcionados no fôlio real, cumprindo que ele reflita, apenas, aquilo que for possível ter ingresso no cadastro"¹³².

Como exemplo de aplicação desse princípio está a possibilidade de se registrar escritura pública de venda de imóvel noticiando a existência de construção ainda não averbada no Livro 2. Não sendo possível averbar previamente a construção, é possível a cindibilidade do título para registrar a aquisição do terreno, mas desde que haja expresse requerimento do interessado (princípio da instância) e o terreno tenha sido perfeitamente descrito no título: "Assim, não haveria, em tese, óbice a cisão do mandado de penhora, mediante requerimento escrito do apresentante, registrando-o nas matrículas imobiliárias dos imóveis lindeiros sem qualquer consideração à construção nele mencionada"¹³³.

¹³² CSMSP. Apelação Cível nº 021841-0/1. Data: 31/03/95. Localidade: Americana. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹³³ CSMSP. Apelação Cível nº 048258-0/8. Data: 26/03/1999. Localidade: São José do Rio Preto. Relator: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Esse princípio também é utilizado quando se deseja, por exemplo, registrar apenas um dos imóveis partilhados em um formal de partilha, deixando os demais para serem registrados futuramente.

No entanto, a aplicação desse princípio requer cuidado. Por ele não se sa- na vícios dos títulos, que, quando ocorrem, devem ser corrigidos: "A possibi- lidade de extrair do título aquilo que comporta inscrição não implica altera- ção dos dados nele consignados"¹³⁴.

Também não se pode aplicar a cindibilidade na hipótese de unicidade ne- gocial, ou seja, quando uma parte do título indissolavelmente ligada à outra que o apresentante não quer seja registrada, como, por exemplo, em escritura pública de dação de imóveis em pagamento com liberação de garantia sobre outros imóveis, situação em que não é possível registrar-se apenas o cancela- mento da hipoteca sem a transmissão dos bens ao credor.

Da mesma forma, não se pode pela cindibilidade registrar fração da alie- nação: "A se admitir a cindibilidade do título judicial de adjudicação, estar-se- ia a admitir causa apartada do instrumento que a corporifica: não se deferiu, em Juízo, a adjudicação compulsória de sete oitavas partes ideais do imóvel, senão de toda a unidade imobiliária. Consoante já se ponderou "a visualização dogmática do sistema registral de 1973 permite de logo inferir da observância do princípio da unitariedade a admissão da cindibilidade dos títulos quanto aos imóveis deles objeto, quando mais de um prédio em mesmo instrumento se contiver com ressonância em situação jurídica real imobiliária. Estende-se ainda a possibilidade de cisão dos instrumentos às hipóteses de pluralidade de fatos jurídicos concernentes a mesmo imóvel, com a ressalva de que da multi- plicidade de causas não sobrevenha unicidade negocial" (parecer do magistra- do Ricardo Henry Marques Dip, na A.C. n.º 5.599-0, de Franco da Rocha, j. 19.5.86, Rel. o Des. Sylvio do Amaral)"¹³⁵.

¹³⁴ CSMSP. Apelação Cível n° 059966-0/4. Data: 29/11/1999. Localidade: SOCORRO
Relator: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-
ROM.

¹³⁵ CSMSP. Apelação Cível n° 008696-0/3. Data: 12/7/1989 Localidade: São Paulo
Relator: Milton Evaristo dos Santos. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

14. Princípio da Autotutela

Embora seja necessária a provocação para a prática de atos, a correção de erros registrares ou cancelamento de atos irregulares pode ser feita de ofício.

"O ato de registro tem natureza administrativa. Uma vez constatada a ocorrência de nulidade de ato administrativo de registro, a Administração Pública pode invalidá-lo (autotutela)"¹³⁶.

O princípio da autotutela, que abrange toda a atividade administrativa, que inclui a exercida nos registros públicos, encontra-se bem definido na primeira parte da Súmula STF 473: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

Mas embora "as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta"¹³⁷, as nulidades só podem ser decretadas "depois de ouvidos os atingidos"¹³⁸.

¹³⁶ CGJSP. Processo 001963/96. Data: 21/03/1997. Localidade: São Paulo. Parecer Francisco Eduardo Loureiro. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹³⁷ Art. 214 da Lei 6.015/73.

¹³⁸ Art. 214, § 1º, da Lei 6.015/73.

CAPÍTULO II
QUALIFICAÇÃO
DE TÍTULOS

A transmissão ou constituição de direito real entre vivos é um ato complexo que se inicia com um título, em que as partes celebram o negócio jurídico, mas que só se concretiza com o registro¹³⁹:

"Por ser o registro um ato jurídico causal, ou seja, sempre vinculado ao título translático hábil, pode-se dizer que nasce o direito real imobiliário da união de dois elementos: a) o título, isto é, o acordo de vontades que cria o direito pessoal (*jus ad rem*) b) a inscrição, que transforma o *jus ad rem* em direito real (*jus in re*) (cf. Afrânio de Carvalho, Registro de Imóveis, 2ª. Edição, Forense, 1977, p. 135)"¹⁴⁰.

O artigo 221 da Lei 6.015/73 elenca os títulos que formalizam a transmissão e constituição de direitos reais admitidos a registro no fôlio real:

“I - escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros;

II - escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro de Habitação;

III - atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, e registrados no cartório de Registro de Títulos e Documentos, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação pelo Supremo Tribunal Federal ¹⁴¹;

IV - cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo.”

Quando esses títulos são apresentados para registro cabe ao oficial qualificá-los, ou seja, analisar se estão aptos a constituir ou transmitir direitos reais, registrando os hábeis e impedindo o acesso dos que não satisfaçam os requisi-

¹³⁹ Art. 1.245 do Código Civil.

¹⁴⁰ CSMSp. Apelação Cível nº 035714-0/0. Data: 24/02/1997. Localidade: Osasco. Relator: Des. Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁴¹ Atualmente Superior Tribunal de Justiça, conforme Emenda Constitucional nº 45 de 2004 que incluiu a alínea i do art. 105, I, da Constituição Federal.

tos exigidos em lei, quer sejam consubstanciados em instrumentos públicos ou particulares, quer em atos judiciais¹⁴².

Nessa importante tarefa de qualificação dos títulos que são apresentados ao oficial é fundamental conhecer não apenas as normas gerais que todos os instrumentos devem atender, mas também a legislação específica de cada modalidade, o que será visto a seguir, com enfoque neste Capítulo na análise da escritura pública, que é elencada em primeiro lugar no rol do art. 221 da Lei 6.015/73, por ser efetivamente o principal título de transmissão e constituição de direitos reais.

A qualificação dos títulos

A análise de um título envolve a verificação de diversos elementos que, neste capítulo, para fim de organização, serão divididos em requisitos extrínsecos e intrínsecos. Os elementos extrínsecos serão considerados aqueles relacionados à exteriorização do ato, concernentes à forma do título¹⁴³, como foi escriturado e como está sendo apresentado. Os elementos intrínsecos envolverão os requisitos fundamentais do negócio jurídico materializado pelo título apresentado.

Requisitos extrínsecos

1. Forma

O primeiro aspecto a ser observado na análise de um título é se obedece a forma exigida em lei¹⁴⁴, essencial à validade do negócio jurídico e que, quando violada, torna-o nulo.¹⁴⁵

O Código Civil estabelece em seu artigo 108 como regra a obrigatoriedade da forma pública nos atos envolvendo direito real sobre imóvel de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no País.

“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, mo-

¹⁴² Item 106, Capítulo XX, NSCGJSP.

¹⁴³ Pode-se também classificar a forma externa do ato no plano da legalidade intrínseca formal. CSMSP. Apelação Cível nº 6.391-0. Data: 12/11/1986. Localidade: Atibaia. Relator: Sylvio do Amaral. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁴⁴ A forma especial é também denominada de essencial ou solene.

¹⁴⁵ Art. 166, IV, do Código Civil.

dificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”

Atente-se que o artigo em comento determina que o valor a ser considerado é o relativo ao imóvel e não ao valor da transação. Assim, o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo já decidiu ser procedente a recusa do registro de um instrumento particular relativo a imóvel de valor superior a trinta salários mínimos, apesar do valor negociado ser inferior ao limite legal, tendo em vista que admitir interpretação diversa daria margem a eventuais simulações com intuito de dispensar a lavratura de escritura públicas: “Conforme se vê, o legislador civil referiu-se expressamente ao valor do imóvel e não ao valor do negócio como parâmetro para a verificação do limite estabelecido para a obrigatoriedade da escritura pública e, portanto, na medida em que restou incontroverso nos autos que o bem adquirido pelos apelantes têm valor superior a trinta salários mínimos, mostra-se inviável a materialização do negócio através de instrumento particular, como ocorreu, já que referido título colide com expressa vedação contida no dispositivo legal em comento. Irrelevante que o quinhão que foi negociado, correspondente a 70% do imóvel, tenha valor abaixo de 30 salários mínimos, uma vez que, como visto, não foi esse o critério adotado pelo legislador para definir quando é admissível o instrumento particular e quando é obrigatória a escritura pública”¹⁴⁶.

Além dessas hipóteses, o art. 109 do CC acrescenta ainda que a escritura pública é da substância do ato quando o negócio jurídico for celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público.

Assim, a escritura pública, lavrada por tabelião no livro de notas¹⁴⁷, é o título primordial na constituição, alteração ou transmissão de direitos reais, apenas sendo prescindível para imóveis de pequeno valor¹⁴⁸ e nas expressas hipóteses em que há dispensa legal¹⁴⁹, situações que devem ser analisadas com extrema cautela, haja vista a nulidade que pode decorrer da violação da forma exigida em lei.

¹⁴⁶CSMSP. Apelação Cível nº 1.088-6/0. Data: 15/07/2009. Localidade: Paraguaçu Paulista. Relator: Ruy Camilo. Disponível em: <www.arisp.com.br> (kollemata).

¹⁴⁷ Art. 7º, inciso I, da Lei 8.935/94.

¹⁴⁸ Mesmo para imóveis de valor inferior ao limite, há necessidade de escritura pública na transmissão de imóveis rurais a pessoa estrangeira, física ou jurídica, por expressa determinação legal (art. 8º da Lei 5.709/71).

¹⁴⁹ Sobre esse tema ver o Capítulo Instrumentos Particulares.

2. Título original

O título deve ser apresentado no original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas¹⁵⁰, já que o rol do artigo 221 da LRP é taxativo e não as inclui:

"A Lei dos Registros Públicos, elenca, taxativamente, em seu art. 221, os títulos admitidos a registro, sem incluir nesse rol cópias, ainda que autenticadas de qualquer dos títulos especificado, inclusive o de origem judicial. (...) A cópia constitui mero documento e não instrumento formal previsto como idôneo a ter acesso ao registro (...) "¹⁵¹.

Além disso a cópia impede a verificação direta da autenticidade do instrumento, o que é fundamental na qualificação que compete ao oficial de registro:

"Inarredável essa premissa, pois da análise direta do próprio título, inclusive no tocante a sua autenticidade, regularidade formal e conteúdo, análise essa logicamente precedente ao próprio exame das questões de direito debatidas, depende a aferição de sua admissibilidade, ou não, no âmbito do fólio real "¹⁵².

2.1. *Traslado e certidão*

Mas a necessidade de apresentação do instrumento original não significa que a escritura pública propriamente dita deva ser apresentada, haja vista permanecer esta arquivada no Tabelionato no correspondente Livro de Notas. O título hábil a ser apresentado é o traslado da escritura ou certidão extraída pelo tabelião:

"Intuitivo, como explica Afrânio de Carvalho, que pela expressão legal escrituras públicas se entende aquelas 'lavradas em livros de tabeliães e trasladas ou certificadas em avulso para o fim do registro' (Registro de Imóveis, 2a, ed. Forense, p. 259) "¹⁵³.

Assim, são aceitas certidões e traslados extraídos pelo tabelião, cujos conceitos precisam ser conhecidos com clareza:

¹⁵⁰Ressalvado o disposto no art. 294, § 1º, da Lei 6.015/73.

¹⁵¹ CSMSp. Apelação Cível nº 100754-0/0. Data: 10/12/2003. Localidade: São José dos Campos. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁵² CSMSp. Apelação Cível nº 348-6/0. Data: 25/10/2005. Localidade: Jundá. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁵³ Parecer- Francisco Eduardo Loureiro, Juiz Auxiliar da Corregedoria in RDI 41. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

"Traslado é a cópia do original, ou na definição de Clovis Bevilacqua, a cópia do que está escrito no livro de notas (Código Civil Comentado, 1927, 1.º volume, comentário ao art. 148).

Em sentido amplo, traslado é qualquer cópia. Em sentido estrito, que aqui nos interessa é o duplo que o oficial pôs nas suas notas (Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, 1983, Ed. RT, vol. III, p. 429).

Como explica Moacir Amaral Santos, 'é a cópia fiel da nota lançada no livro de notas do oficial público. É o que as Ordenações chamavam de escritura cuja matriz, ou original, é a nota' (*Prova Judiciária no Cível e Comercial*, 1972, vol. IV, p. 357).

Certidões são também cópias extraídas dos livros de notas. Podem ser integrais, parciais, ou em breve relatório.

Diferem dos traslados, porque estes constituem uma nova via, uma duplicata do original, enquanto a certidão é a asseveração autêntica, feita por oficial público e com as formalidades legais, do documento constante de suas notas e livros (cf. Moacir Amaral Santos, *op. cit.*, p. 360).

Têm as certidões forma peculiar, contendo cabeçalho, onde o tabelião declara essa sua qualidade, o ato que pratica, qual seja e onde se encontra o original, o que deste consta, portando por fé a verdade do que declara (cf. Lopes da Costa, *Direito Processual Civil Brasileiro*, 1946, 2.º volume, n. 303)¹⁵⁴.

2.2. Pública forma

Em hipótese nenhuma podem ser registradas cópias autenticadas, públicas formas e cópias simples dos títulos:

"A pública-forma, conhecida hoje como cópia autenticada, é cópia de papel avulso, via de regra de instrumentos particulares, embora nada impeça seja de documento público.

Logo, é a pública-forma cópia, sem ter a eficácia da certidão, nem a do traslado de notas.

Por isso mesmo, apenas se refere ao original que o oficial público copiou e não ficou em sua serventia (cf. Pontes de Miranda, *op. cit.*, p. 431).

¹⁵⁴ Parecer- Francisco Eduardo Loureiro, Juiz Auxiliar da Corregedoria in RDI 41. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Finalmente, cópia simples, ou comum, é aquela extraída sem qualquer formalidade, pelo próprio interessado ou por terceiro, sem intervenção de um oficial, nem forma legal ou autêntica"¹⁵⁵.

De Plácido e Silva, após definir pública forma, distingue a conferência do concerto da pública forma:

"Pública forma: Denominação dada à cópia de um documento, feita por um tabelião ou escrivão, na qual faz constar, palavra por palavra, tudo o que está ou se encontra no original. (...)

No entanto, a pública forma é cópia feita por pessoa estranha ou que não produziu o escrito original, enquanto a certidão é feita ou extraída pelo serventuário do cartório em que foi passada a escritura ou produzido o ato. (...)

A pública forma somente se considera autêntica, depois que é conferida pelo mesmo oficial que a fez ou por outrem, na presença da parte contrária ou contra quem possa surtir efeito. (...)

A pública forma diz-se consertada, quando a cópia literal do documento é feita por um tabelião e conferida e subscrita por outro. O concerto, assim, não se confunde com a conferência necessária para dar força probante à pública forma"¹⁵⁶.

Nesse aspecto deve-se notar que são plenamente válidas certidões extraídas pelos notários, mesmo que por processo de cópia, haja vista a expressa autorização estabelecida no artigo 19, § 1º, da Lei 6.015/73, não se confundindo a certidão extraída por meio reprográfico, que pode ser registrada, com a mera cópia autenticada, esta sim inábil.

2.3. Distinção entre títulos e documentos

Também importante observar que a exigência de apresentação do instrumento original refere-se apenas aos títulos, e não aos documentos¹⁵⁷ em geral apresentados para instruir os instrumentos ou para permitir averbações de atualizações ou alterações relacionadas ao imóvel ou pessoas envolvidas no registro.

Assim, para o registro de uma compra e venda é necessária a apresentação do título, ou seja, a escritura original, seja na forma de traslado ou de certidão

¹⁵⁵ Parecer- Francisco Eduardo Loureiro, Juiz Auxiliar da Corregedoria *in* RDI 41. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁵⁶ SILVA, De Plácido e. *Vocabulário Jurídico*. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 1132-1133.

¹⁵⁷ Artigo 246, § 1º, da LRP.

expedida pelo próprio tabelião, mas para a averbação de casamento, basta um mero documento, como uma cópia autenticada da certidão de casamento, não sendo necessária a apresentação da própria certidão de casamento, por não ser um título propriamente dito. A cópia simples em hipótese nenhuma deve ser aceita no Registro Público, pois não tendo fé pública não pode amparar lançamento do qual emanará essa fé.

A distinção entre título e documento não pode ser feita apenas com base na espécie de lançamento que se pretende, ou seja, se será praticado registro ou averbação, mas sim pelo próprio instrumento apresentado, embora tecnicamente registro e averbação destinem-se a finalidades definidas¹⁵⁸, que indicariam que somente os registros requerem a apresentação de título propriamente dito, e para as averbações seriam suficientes documentos, em várias situações a legislação, mesmo a Lei 6.015/73, como se verifica da leitura do rol do artigo 167, determina que atos sejam lançados por averbação, quando, tecnicamente seriam registros, e vice-versa, o que faz com que deva ser analisado o ato pretendido e não apenas a espécie de lançamento no Livro 2 para se saber se é necessário um título, ou mero documento.

Assim, se o que se pretende é a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, é necessário um título, que deve ser apresentado no original, mesmo que o ato a ser lançado seja, por determinação legal, averbação, como ocorre, por exemplo, na caução de imóvel como garantia de locação¹⁵⁹, hipótese em que deve ser exigido o próprio contrato de locação, não se aceitando cópia autenticada para a averbação. Da mesma forma, nos casos de incorporação de sociedade anônima¹⁶⁰, em que deve ser apresentada a ata original registrada ou certidão de inteiro teor expedida pela Junta Comercial¹⁶¹.

2.4. Publicações

Nos casos das sociedades anônimas, em decorrência dos estatutos e atas das assembleias serem obrigatoriamente publicadas¹⁶² no Diário Oficial e em

¹⁵⁸ A distinção entre registro e averbação foi tratada ao se abordar o princípio da taxatividade no Capítulo I desta obra.

¹⁵⁹ Artigo 38, § 1º, da Lei 8.245/91.

¹⁶⁰ Artigo 234 da Lei das S/A.

¹⁶¹ CGJSP. Processo 735/97. Data: 23/06/97. Localidade: Santa Bárbara D'Oeste. Parecer Dr. Francisco Eduardo Loureiro, Juiz Auxiliar da Corregedoria; CGJSP. Processo 1404/96. Data: 6/8/96. Localidade: São Paulo. Parecer Dr. Marcelo Martins Berthe. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁶² Art. 94 da Lei 6.404/76.

jornal local de grande circulação¹⁶³, publicações que devem ser apresentadas e anotadas na Junta Comercial¹⁶⁴ têm sido amplamente aceitas para comprovar a forma como é administrada a sociedade, porém, jamais podem ser aceitas como títulos, ou seja, não substituem as atas originais registradas ou certidões dos órgãos de registro quando haja a necessidade de apresentação do título para registro ou averbação, como ocorre, por exemplo, na cisão de uma sociedade anônima que importe em transmissão de bens imóveis para a nova sociedade criada.

2.5. Certidões do Registro de Títulos e Documentos

Nem mesmo a certidão extraída do Registro de Títulos e Documentos pode ser aceita no Registro Imobiliário para a prática de atos de constituição ou transmissão de direitos reais, apesar do disposto no art. 161 da Lei 6.015/73, que determina que "as certidões do registro integral de títulos terão o mesmo valor probante dos originais, ressalvado o incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo":

"Permitir que certidões de instrumentos particulares registrados em Ofícios de Títulos e Documentos possam ingressar no registro predial, apenas por isso que tenham o mesmo valor probante dos originais e acaso admitam avaliação de autenticidade, é concluir à margem do caráter restritivo do preceito do art. 221, regra que quadra a idoneidade da instrumentação dos fatos inscritíveis em ordem a seu ingresso no Registro de Imóveis"¹⁶⁵.

3. Rasuras e retificação

Na qualificação devem ser recusados títulos que apresentem rasuras ou entrelinhas, que só podem ser aceitas se ressalvadas pelas partes antes das assinaturas e desde que não envolvam elementos essenciais do instrumento, como as partes, o objeto e o preço.

As Normas de Serviço do Estado de São Paulo são rígidas quanto a isso (Capítulo XIII):

"20. É vedado o uso de borracha, detergente ou raspagem por qualquer meio, mecânico ou químico.

¹⁶³ Art. 289 da Lei 6.404/76.

¹⁶⁴ Art. 54 da Lei 8.934/94.

¹⁶⁵ CSMSp. Apelação Cível nº 006391-0. Data: 12/11/1986. Localidade: Atibaia. Relator: Sylvio do Amaral. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

21. A escrituração dos atos será feita sem abreviaturas nem algarismos, evitando-se erros, omissões, rasuras ou entrelinhas e, caso ocorram, devem ser ressalvadas no final do instrumento, antes das assinaturas e subscrições, de forma legível e autenticada.

21.1. Ficam proibidas as entrelinhas que afetem elementos essenciais do ato, como, por exemplo, o preço, o objeto, as modalidades de negócio jurídico, dados inteiramente modificadores da identidade das partes e a forma de pagamento".

Assim, o título não pode conter rasuras ou entrelinhas que, por comprometerem a confiabilidade do instrumento, viciam-no, sendo proibido o uso de borrachas ou quaisquer meios químicos de correção, que incluem os atuais corretores líquidos. No entanto, rasuras e ressalvas feitas no momento do ato, em decorrência de erros percebidos pelo notário ou pelas partes antes de assinarem a escritura, não invalidam o instrumento desde que ressalvados antes das assinaturas e não envolvam elementos essenciais do negócio.

Se, no entanto, a retificação do ato se der em momento posterior, somente por nova escritura de rerratificação poderá ser alterado o instrumento: "Escritura pública de divisão amigável - Erro na descrição dos lotes - Retificação por Ata Notarial - Inviabilidade - Necessária nova manifestação de vontade das partes, por meio de escritura de rerratificação - Recurso não provido"¹⁶⁶

4. Assinatura do notário

Na qualificação do título deverá ser observado se o traslado ou certidão apresentado está subscrito pelo tabelião ou seu substituto¹⁶⁷ e se todas as folhas estão rubricadas¹⁶⁸.

4.1. Sinais público e raso

Nas escrituras o tabelião usualmente consigna que assina em público e raso, o que significa que está apondo seus sinais público e raso, assim definidos por De Plácido e Silva:

¹⁶⁶ Processo nº 2008/45352, com parecer em 26/02/2009, aprovação em 05/03/2009, publicada no D.J.E. em 18/05/2009.

¹⁶⁷ Item 13.1, Capítulo XIV, das NSCGJSP, que veda a concessão de autorização para subscrição de escrituras, procurações, traslados e certidões, cassadas aquelas já concedidas a escreventes, com exceção do substituto legal do serventuário, interino ou substituto.

¹⁶⁸ Item 49 do Capítulo XIV das NSCGJSP.

"Sinal Público: Denominação dada à assinatura de um tabelião, ou notário, cercada de arabescos, ou de dísticos e linhas, que a distinguem de qualquer outra.

O sinal público, assim, não é simplesmente representado pela rubrica ou firma do notário. Mas, desta firma cercada ou enfeitada de desenhos adotados, que se constituem em marca do tabelião.

Para que dê autenticidade aos atos trasladados, concertados ou conferidos por ele, o tabelião deve apor, nos respectivos documentos, além de sua assinatura pura e simples, o seu sinal público.

Sinal Raso: É a simples assinatura do tabelião, sem conduzir os traços que constituem o sinal público, dito ainda como guardas de sua assinatura"¹⁶⁹.

Na prática as escrituras, embora ditas como contendo os sinais público e raso do tabelião, apresentam apenas a assinatura e rubrica do notário, que devem ser confrontadas com os cartões de assinatura arquivados no Registro Imobiliário¹⁷⁰.

5. Idioma nacional

A língua portuguesa é o idioma oficial¹⁷¹ do Brasil e por isso as escrituras públicas devem ser completamente grafadas em português. Não devem ser utilizadas nas escrituras termos em idiomas estrangeiros, salvo os já oficialmente incorporados ao idioma nacional, o que deve ser observado na qualificação do título.

No entanto, o uso de palavras isoladas em idioma estrangeiro e desde que não envolvam elementos essenciais do negócio, não viciam completamente o título, devendo o oficial apenas não repetir a irregularidade, lançando nos seus livros oficiais os termos correspondentes em português. Expressões como "box", "home theater", "shaft", "personal trainer", "sushi man", "moto boy", encontradas com frequência em descrição de imóveis e indicação de profissões, devem ser necessariamente traduzidas.

6. Elementos de segurança

Também é fundamental verificar se os títulos apresentam os elementos de segurança previstos nas Normas de cada Estado.

¹⁶⁹ Op. cit., p. 1303.

¹⁷⁰Item 7, Capítulo XIV, NSCGJSP.

¹⁷¹ Art. 13 da Constituição Federal.

Em São Paulo, desde 28 de abril de 2006, todos os traslados e certidões de atos notarias devem ser emitidos em papel com elementos e características técnicas de segurança¹⁷², que incluem selo holográfico, numeração individual das folhas com código de barras, impressão de marcas d'água visíveis contra a luz, textos e imagens visualizáveis apenas sob a luz ultra-violeta, mistura de fibras coloridas na fabricação do papel, que se incorporam a cada folha em posições variáveis, fazendo com que todas as folhas sejam diferentes¹⁷³, fundo especial, composto de linhas extremamente finas e bastante próximas entre si, que dão a ilusão de que houve uma impressão contínua, e microimpressão de textos.

Da mesma forma, selos de autenticidade e de reconhecimento de firma devem ser exigidos quando obrigatórios e necessariamente tenham sua validade verificada nos endereços eletrônicos correspondentes¹⁷⁴, que relacionam todos os selos furtados, roubados e extraviados de cada Estado. No caso de detecção de uso de selos em uma dessas condições deve-se imediatamente confirmar a ocorrência com a própria unidade de serviço notarial de origem e, de posse da confirmação expressa do furto ou roubo do selo utilizado, encaminhar o documento original ao Ministério Público mediante representação fundamentada e instruída com todos os documentos disponíveis para permitir a persecução penal dos envolvidos. Em hipótese nenhuma deve o oficial restituir documento nessa situação ao apresentante por se tratar da prova de ilícito penal.

Requisitos Intrínsecos:

Após a análise dos elementos extrínsecos passa-se à análise dos requisitos essenciais do negócio jurídico consubstanciado no título que se pretende ter registrado, denominados elementos intrínsecos, que envolvem a capacidade das partes¹⁷⁵, que será abordada a seguir, e também os elementos próprios de cada negócio jurídico realizado.

¹⁷² Provimento CG nº 37/05, publicado no D.O.J. de 29/12/2005.

¹⁷³ A fim de distinguir os filamentos de simples imitação por impressão é possível, por exemplo, observar as fibras superficiais, que se destacam do papel e podem até ser extraídas com uma pinça.

¹⁷⁴ Os selos utilizados no estado de São Paulo podem ser verificados no endereço <www.anoregsp.org.br>.

¹⁷⁵ Art. 215, §1º, II, CC.

7. Pessoa natural

Para que uma pessoa natural, também denominada de pessoa física¹⁷⁶, possa transmitir ou onerar seus bens, faz-se necessário que ela esteja apta a praticar os atos da vida civil e as condições para tal exercício estão no Código Civil.

Somente têm a disponibilidade sobre seus bens os maiores e capazes, sendo que os interesses dos absolutamente incapazes, elencados no artigo 3º do Código Civil, são representados por seus pais, tutores ou curadores. Qualquer ato praticado por pessoa absolutamente incapaz é nulo de pleno direito. Já os relativamente incapazes são apenas assistidos por seus representantes e a falta da assistência gera a anulabilidade do ato praticado.

7.1. Menores

Com o advento do Código Civil de 2002 a menoridade civil passou a cessar aos 18 anos completos. Os menores absolutamente incapazes (impúberes, até completarem 16 anos) não comparecem ao ato, mas apenas seus pais, que os representam. Já os relativamente incapazes (menores púberes, dos 16 anos até completarem 18 anos) comparecem pessoalmente ao ato, mas necessariamente assistidos por seus pais: "Em qualquer caso, quem aliena é o filho, representado ou assistido pelo pai, havendo impropriedade na expressão 'alienar, hipotecar ou gravar de ônus reais os imóveis dos filhos', empregada no citado art. 386¹⁷⁷. Como ensina Clóvis, 'se o filho for menor de 16 anos, estes atos extraordinários serão praticados em nome dele, porém será dispensada a sua intervenção. Sendo maior de 16 anos, deve ter parte no ato, para o qual o pai necessita de autorização do juiz' ('Código Civil Comentado', 1954, art. 386)"¹⁷⁸.

7.1.1. Necessidade da presença de ambos os pais

A regra é de que ambos os pais representem ou assistam os seus filhos, diante do princípio constitucional da igualdade entre os cônjuges¹⁷⁹, tendo os dispositivos do Código Civil que tratam da matéria utilizado a palavra pais, no plural¹⁸⁰, e havendo dispositivo inclusive regrando a hipótese em que os pais

¹⁷⁶ Termo utilizado na legislação tributária e também adotado pela Lei de Registros Públicos.

¹⁷⁷ Art. 1.691 do CC de 2002.

¹⁷⁸ Apelação cível 43.976. Localidade: Rio de Janeiro - (1 TARJ). j. 12 de março de 1980. Relator: Raul Quental. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁷⁹ Art. 226, § 5º, da Constituição Federal.

¹⁸⁰ Art. 1.634 e 1.690 do Código Civil.

não concordem sobre o ato, situação em que é assegurado a qualquer deles recorrer ao Poder Judiciário para solução do desacordo¹⁸¹. Essa regra aplica-se não apenas à entidade familiar constituída pelo casamento, mas também pela união estável¹⁸², e não é alterada pela separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável¹⁸³.

Portanto, é irregular um título em que o menor, por exemplo, seja representado ou assistido apenas pelo pai, ou pela mãe, sem justificativa expressa quanto à falta do outro genitor, devendo o instrumento nessa situação ser necessariamente recusado pelo oficial.

7.1.2. Falta de um dos pais

No entanto, há situações em que não é possível a participação de ambos os pais no ato em decorrência da falta de um deles, estabelecendo então o Código Civil a regular participação de apenas um deles: "compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de dezesseis anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados"¹⁸⁴.

Além das hipóteses de falecimento e ausência declarada judicialmente¹⁸⁵, também têm sido aceitas para justificar a participação de apenas um dos genitores situações de não presença:

“São comuns, infelizmente, os casos de completa falência do núcleo familiar e de inviabilidade da colheita do consentimento expresso de um ou de outro genitor, dada a total perda de contato com sua prole. O pátrio poder¹⁸⁶ é exercido, então, efetivamente, apenas por um dos pais, que mantém contato direto com o filho menor e, concretamente, pode avaliar seu discernimento e sua aptidão para a aquisição da capacidade civil plena. (...)”

O texto do artigo 5º, § único, inciso I do novo Código Civil, cuja vigência está prevista para se iniciar em 11 de janeiro 2003, não destoa e confere a legitimidade negocial a ambos os pais, ou a ‘um deles na falta do outro’, cabendo entender significar o vocábulo ‘falta’, não apenas a ausência ou a morte, mas a ‘não-presença’.

¹⁸¹ Art. 1.631, parágrafo único, e art. 1.690, parágrafo único, do Código Civil.

¹⁸² Art. 226, § 3º, da Constituição Federal e art. 1.631 do Código Civil.

¹⁸³ Art. 1.632 do Código Civil.

¹⁸⁴ Caput do art. 1690 do Código Civil.

¹⁸⁵ Art. 22 do Código Civil

¹⁸⁶ Atualmente, poder familiar: art. 1.630 do CC

Em suma, a regra a ser observada é da manifestação conjunta de ambos os pais, mas diante da falta de um destes, devidamente, declarada no instrumento de emancipação, é conferida a legitimidade, isoladamente, a um dos pais.

Na espécie, não consta do título a menor referência à atual situação do genitor, o Sr. A. da S., com o que se descaracteriza a hipótese exceptiva. Sua falta foi alegada perante o MM. Juiz Corregedor Permanente e nas razões recursais, mas este dado não foi incorporado à escritura pública lavrada e apresentada ao registrador, o que seria de rigor¹⁸⁷.

Assim, a incidência de uma dessas hipóteses deve ser expressamente consignada no título em que comparece apenas um dos pais para que possa ser aceita pelo registrador.

Importante ressaltar que essas hipóteses abrangem apenas situações de real falta de um dos genitores, não se aplicando a situações de dificuldade de obtenção de anuência, como quando um dos genitores encontra-se, por exemplo, trabalhando no exterior, situação que pode ser solucionada simplesmente pela outorga de procuração, que pode ser lavrada até mesmo no Consulado do Brasil do local em que se encontra um dos genitores, para que o ascendente que está no país possa representá-lo.

Além das situações de falta que justificam a participação de apenas um dos genitores, quando o filho não foi reconhecido pelo pai o poder familiar compete exclusivamente à mãe, por expressa disposição legal¹⁸⁸, o que pode ser comprovado diretamente ao oficial, por exemplo, através da apresentação de certidão de nascimento.

Finalmente, títulos antigos, lavrados na época em que era possível a assistência ou representação apenas pelo pai são válidos e devem ser aceitos por terem sido lavrados de acordo com a legislação então vigente¹⁸⁹.

7.1.3. Limitação da representação ou assistência dos pais

No entanto, mesmo com a participação de ambos os pais, não é possível ao menor dispor ou onerar seus bens imóveis, o que só pode ocorrer em situ-

¹⁸⁷ CSMSp. Apelação Cível nº 096914-0/9. Data: 18/12/2002. Localidade: Americana. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁸⁸ Art. 1.633 do Código Civil.

¹⁸⁹ Art. 380 do Código Civil de 1916.

ações extraordinárias em que haja necessidade ou evidente interesse da prole e mediante prévia autorização judicial¹⁹⁰.

Assim, os pais só podem administrar os bens dos filhos, o que inclui a compra de imóveis em nome dos filhos, mesmo que os pais estabeleçam que o usufruto será destacado em seu benefício, desde que essa parcela do preço provenha dos pais¹⁹¹. Também podem os pais participar da aceitação de doações de imóveis gravados com cláusulas restritivas. Em todas essas situações não ocorre alienação ou oneração de bens imóveis, nem há conflito de interesses.

Por outro lado, não é possível, sem autorização judicial, realizar a compra de imóvel quando no mesmo ato o bem é dado em hipoteca ao vendedor, por exemplo, para garantia de parte do preço quando o pagamento for a prazo. Nesta situação, não há apenas aquisição, mas também oneração, que depende de autorização judicial. Na mesma situação está a compra de imóvel com pacto comissório ou cláusula resolutiva¹⁹², haja vista a estipulação de perda do imóvel em caso de descumprimento da obrigação, o que equivale à disposição de imóvel.

Também, fundamental que os pais sejam informados quando adquirem bens em nome de filhos menores da restrição legal quanto à alienação ou oneração, pois devem estar conscientes de que no futuro, caso haja interesse na disposição do imóvel, só poderá ser realizada antes da cessação da incapacidade do filho mediante autorização judicial, que depende da comprovação da necessidade ou evidente interesse do menor.

7.1.4. Curador Especial

Os menores podem ser representados ou assistidos por seus pais, mas quando o interesse do menor conflitar com o de seus genitores, o ato deverá contar com a participação de curador especial regularmente nomeado em procedimento judicial¹⁹³.

Assim, por exemplo, na venda de bem imóvel dos pais para o filho menor há colidência de interesses, o que reclama a nomeação de curador especial:

"No caso em tela lavrou-se, primeiro, uma escritura pública mercê da qual pai e mãe vendiam imóvel a seu filho, menor púbere, assistido exclusivamente

¹⁹⁰ Art. 1.691 do Código Civil.

¹⁹¹ Conforme item 11.2.25 das NSCGJ do Estado do Paraná se o valor destinado a aquisição do imóvel já pertencer ao menor será necessário alvará judicial.

¹⁹² Art. 474 do Código Civil.

¹⁹³ Art. 1.692 do Código Civil.

pela genitora. Seguiu-se, então, novo ato notarial, agora de instituição de usufruto, pelo adquirente, em favor de sua mãe, que no ato o assistiu.

Ou seja, uma verdadeira sequência de irregularidades, que só podiam mesmo ensejar a desqualificação ocorrida.

Já a compra e venda de pais a filho deveria ter contado com a nomeação de curador pelo juiz, evidenciando-se a potencialidade de conflito de interesses entre as partes no tocante à fixação do preço. Isto já não fosse a falta de assistência paterna.

Porém, não bastasse, depois da compra o menor instituiu usufruto, veja-se, em favor da mãe, que o assistia no ato, de novo faltando o 'placet' paterno e, mais, novamente ostentando-se agora óbvio conflito de interesses, a reclamar a providência, olvidada, prevista no artigo 1.692 do Código Civil.

Enfim, desrespeitou-se, a uma, a outorga paterna indispensável se ele não faltava e se se tem em mira ato de expressão do poder familiar, de ambos os genitores concernente. Depois, afrontou-se a exigência legal de garantia dos interesses do menor se seus interesses colidem com o dos pais, como no caso em tela, então impondo-se ao juiz a nomeação de curador especial"¹⁹⁴.

Situação diversa é a da doação de imóvel dos pais para os filhos, mesmo que com reserva de usufruto e com imposição de cláusulas restritivas, hipótese que não caracteriza conflito de interesses:

"Finalmente, dispensável a nomeação de curador especial à donatária e adquirente da nua-propriedade relativamente incapaz, assistida no negócio jurídico por seus pais. 'Porque contrato benéfico, o donatário não precisa ter capacidade de fato para aceitar a doação, embora se suponha necessário o consentimento do seu representante legal' (Orlando Gomes, *op. cit.*, p. 236). A imposição da cláusula restritiva não se traduz em obrigação a ser cumprida pela donatária, mas, sim, em proibição de alienação, penhora ou comunicação do bem que a beneficia"¹⁹⁵.

7.1.5. Emancipação

Ao completar 16 anos o menor poderá ser emancipado, ou seja, a capacidade plena poderá ser concedida conjuntamente pelos pais, ou por um deles

¹⁹⁴ CSMSp. Apelação Cível nº 113-6/8. Data: 30/3/2004. Localidade: Paraibuna. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹⁹⁵ CSMSp. Apelação Cível nº 78.532-0/3. Data: 08/10/2001. Localidade: São José do Rio Preto. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

na falta do outro, por escritura pública, ou por sentença quando o menor estiver sob tutela¹⁹⁶.

Mas embora a emancipação seja realizada por escritura pública ou sentença, seus efeitos só se operam após o registro no Livro E¹⁹⁷ do 1º Registro Civil de Pessoas Naturais da comarca¹⁹⁸. Assim, o documento a ser apresentado no Registro de Imóveis para comprovar a emancipação e permitir a averbação da mudança de estado é a certidão de emancipação lançada no Registro Civil de Pessoas Naturais, e não a escritura pública ou a sentença se tutelado.

Além da hipótese de emancipação, o menor também adquire capacidade, tornando-se apto a praticar todos os atos da vida civil, incluindo a possibilidade de transmissão e oneração de seus bens nas demais hipóteses do art. 5º, parágrafo único, do Código Civil, que decorrem: do casamento, do exercício de emprego público efetivo; da colação de grau em curso de ensino superior; do estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.

7.1.6. Tutelados

A tutela é o instituto jurídico que confere ao tutor o encargo de representação do menor, em virtude da impossibilidade de exercício do poder familiar pelos pais do representado. Assim, a tutela pressupõe prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar exercido naturalmente pelos pais, o falecimento destes, ou a declaração de sua ausência. A tutela assemelha-se ao poder familiar, mas este estende-se até o fim da menoridade, já a tutela é temporária, pois o tutor não é obrigado a servir além de dois anos.

Ressalte-se que o tutor não pode emancipar o tutelado, nem tem o usufruto de seus bens.

Além disso a venda de imóveis do tutelado, que na escritura será representado pelo tutor¹⁹⁹, depende de autorização judicial, que será deferida apenas se houver manifesta vantagem ao menor e após prévia avaliação judicial.²⁰⁰ Nem mesmo com autorização judicial pode o tutor dispor gratuitamente de bens do tutelado ou adquiri-los para si²⁰¹.

¹⁹⁶ Art. 5º, parágrafo único, inciso I, do Código Civil.

¹⁹⁷ Art. 89 da Lei 6.015/73.

¹⁹⁸ Art. 91, parágrafo único, da Lei 6.015/73.

¹⁹⁹ Art. 1.748 do Código Civil.

²⁰⁰ Art. 1.750 do Código Civil.

²⁰¹ Art. 1.749 do Código Civil.

7.2. Incapazes

Além dos menores, são incapazes: 1) absolutamente: os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos; os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade²⁰²; 2) relativamente: os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; os pródigos²⁰³. A capacidade dos índios é regulada por legislação especial²⁰⁴.

7.2.1. Curatelados

A curatela também é uma forma de representação, mas neste caso o representante exerce a administração dos bens de pessoa maior, mas incapaz de exercer os atos da vida civil, em virtude de enfermidade ou deficiência. As regras quanto à disposição de bens do tutelado aplicam-se ao curatelado²⁰⁵, estendendo-se aos bens dos filhos menores do curatelado²⁰⁶.

Para a averbação da alteração de estado, deverá ser apresentada certidão do registro da interdição no Livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais²⁰⁷.

7.2.2. Pródigos

Pródigo é aquele que, "sem justa razão, esbanja a fortuna, gastando-a inutilmente ou fazendo gastos e despesas insensatas e excessivas, que possam destruir seus haveres"²⁰⁸, e o Código Civil, ao incluir o pródigo entre os relativamente incapazes, busca proteger o patrimônio da pessoa que dissipa seus bens em função de uma doença mental, reconhecida por profissional médico competente. O pródigo é representado por curador devidamente designado por processo judicial de interdição.

As restrições do pródigo são apenas de cunho patrimonial, não podendo, sem curador, "emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração"²⁰⁹.

²⁰² Art. 3º do Código Civil.

²⁰³ Art. 4º do Código Civil.

²⁰⁴ Estatuto do Índio: Lei 6.001/73.

²⁰⁵ Art. 1.774 do Código Civil

²⁰⁶ Art. 1.778 do Código Civil.

²⁰⁷ Art. 92 da Lei 6.015/73

²⁰⁸ SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 1106.

²⁰⁹ Art. 1.782 do Código Civil.

Em decorrência dessas restrições legais, não deve o oficial, por exemplo, aceitar o registro de pacto antenupcial em que pródigo adote o regime da comunhão universal de bens, por representar ato que implica em comunicação com o seu cônjuge de seu patrimônio atual, do qual não tem livre disposição.

7.3. Analfabeto

A forma de corporificação da manifestação direta de vontade de pessoa analfabeta, e também daquela que não possa assinar, seja por enfermidade ou por acidente, é a escritura pública, já que essas pessoas não podem legitimamente contratar diretamente por instrumento particular:

“A proibição de assinatura a rogo nos instrumentos particulares não está no Código Civil, ou, ao menos não vem nele expressa. Decorre, isto sim, da interpretação sistemática da lei. A assinatura dos contratantes, ensina Affonso Dionysio Gama, 'não é só um elemento de prova, mas encerra, também, a absoluta declaração de vontade do signatário. O simples ato de assinar contém, antes de tudo, uma definitiva declaração de vontade' (*Teoria e Prática dos Contratos por Instrumento Particular no Direito Brasileiro*, Freitas Bastos, 7a. ed., 1943, nota 186, p. 86). Sem declaração de vontade não há contrato. Sem assinatura não há declaração de vontade. A assinatura a rogo não é senão o exercício de um mandato outorgado por quem não pode ou não sabe assinar. Esse mandato exige instrumento público quando conferido por analfabeto. Assim, quando o tabelião admite, na escritura pública, uma assinatura a rogo, pratica ato de seu Ofício: outra escritura de mandato. Já no instrumento particular, exatamente porque ausente o notário, a mesma outorga de poderes para assinar exige outro instrumento, mas público”²¹⁰.

As normas de cada Estado estabelecem procedimentos especiais na lavratura de escrituras públicas em que uma das partes seja analfabeta. Em São Paulo, se alguma das partes não puder ou não souber assinar, outra pessoa capaz assinará por ela, a seu rogo, devendo ser colhida a impressão digital, exclusivamente com a utilização de coletores de impressões digitais, vedado o emprego de tinta para carimbo²¹¹.

8. Procuração

O Código Civil estabelece a possibilidade de representação do interessado na celebração de negócios jurídicos, sendo que esta outorga de poderes pode

²¹⁰ CSMSp. Apelação Cível nº 005553-0/86. Data: 03/09/1986. Localidade: Tambaú. Relator: Sylvio do Amaral. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

²¹¹ Item 15, q, do Capítulo XIV das NSCGJSP.

ter origem legal ou convencional. Assim, o interessado outorga poderes ao representante, por um instrumento de mandato, para que este manifeste sua vontade representando-o na celebração do negócio jurídico, nos termos e limites em que foi estabelecido pelo instrumento outorgado.

A procuração é o instrumento do mandato²¹², ou seja, "o documento em que se outorga o mandato escrito, na qual se expressam os poderes conferidos"²¹³, e a procuração pode ser pública ou particular, respeitando sempre a forma exigida em lei para o ato a ser praticado²¹⁴.

8.1. Vinculação da forma

Não há vinculação da forma no que tange ao substabelecimento, ou seja, ainda que a procuração seja pública, pode ser substabelecida por instrumento particular se o ato a ser praticado não exigir instrumento público²¹⁵.

8.2. Poder de disposição

Na análise da representação por procuração é importante verificar se o ato a ser praticado trata-se de mera administração, ou de efetiva disposição de bens, haja vista que o mandato em termos gerais só confere poderes de administração, sendo necessária procuração com poderes especiais e expressos para "alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária"²¹⁶.

"Os poderes de disposição devem sempre vir expressamente. Não se comportam no mandato de administração. E quando o administrador ou gerente está autorizado a alienar bens do mandante, é porque o mandato, claramente, lhe outorga semelhante poder. Ele não se deduz do poder de administração ou administrativo"²¹⁷.

Deve-se frisar que para a validade dos atos que não sejam de mera administração a procuração deve conter poderes especiais e expressos²¹⁸, que não se confundem: "Estes últimos são os referidos no mandato (exemplo: poderes para vender, doar, hipotecar, etc.). Já aqueles correspondem à determinação específica do ato a ser praticado (exemplo: vender o imóvel "A", hipotecar o

²¹² Art. 653 do CC.

²¹³ SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 1103.

²¹⁴ Art. 657 do CC.

²¹⁵ Art. 655 do CC.

²¹⁶ Art. 661 do CC.

²¹⁷ SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 1052.

²¹⁸ Art. 661, parágrafo único, do CC.

imóvel "B", etc.). E o ordenamento jurídico, como já visto, exige a presença de ambos na procuração com o escopo de se alienar bens"²¹⁹.

8.3. Autocontrato

Em seu artigo 117, o Código Civil determina a anulabilidade de negócio jurídico celebrado pelo representante consigo mesmo, ainda que por conta de outrem, chamado “autocontrato” como, por exemplo, num contrato de venda e compra, em que o representante do vendedor vende para si mesmo o objeto da alienação. Mas o mesmo diploma legal traz hipóteses de validade para esse tipo de contratação, autorizando-o quando a lei ou o próprio representado o permitir.

O autocontrato, na hipótese de compra e venda, também viola o art. 489 do Código Civil: "Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço".

Como hipótese em que a lei permite o autocontrato temos o denominado mandato com a cláusula "em causa própria", em que o mandatário pode transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais²²⁰.

Nelson Nery e Rosa Maria Nery explicam o que vem a ser a procuração em causa própria, espécie de “autocontrato” válido:

“Procuração em causa própria (CC 685), na qual o credor confere poderes ao representante para alienar imóvel para ele mesmo ou a quem convier, declarando que já recebeu o preço e exonerando o mandatário da prestação de contas (Nelson Pinheiro de Andrade, Auto-contrato, REDB, v. V, n.3, p. 117). Esse negócio jurídico é válido porque: a) não há conflito de interesses e o representado já recebeu o preço, nada tendo a reclamar; b) o representante celebra contrato que consiste no próprio cumprimento da obrigação assumida por ele para com o representado, de alienar o imóvel para ele mesmo ou para outrem”²²¹.

Importante observar que a procuração em causa própria, por ser ato de efetiva transmissão de bem, pode ser registrada e é fato gerador de imposto de transmissão.

²¹⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 524-6/3. Data: 3/8/2006. Localidade: Serra Negra. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Disponível em: <www.arisp.com.br> (Kollemata).

²²⁰ Art. 685 do CC.

²²¹ NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código civil anotado e legislação extravagante*. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 208.

8.4. Vigência

Na lavratura e registro dos títulos que instrumentalizam o negócio jurídico celebrado, deverá ser verificada a vigência do mandato outorgado, pois há hipóteses em que cessam os seus efeitos²²²: pela revogação ou pela renúncia; pela morte ou interdição de uma das partes; pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer; pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.

Assim, é fundamental a exigência de certidão atualizada da procuração, haja vista que eventual revogação será averbada na procuração, impedindo seu uso²²³. A aceitação de certidão antiga poderá permitir o registro de ato com base em procuração revogada.

Também importante verificar se há prazo estabelecido de validade e sua correta contagem. É muito comum a outorga de procurações válidas por prazo determinado e por isso é necessário observar na contagem de prazos as regras do art. 132 do Código Civil, que estabelece, entre outros parâmetros, que a contagem em meses ou anos expira no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Atente-se que se a validade da procuração já estiver vencida quando prenotado o título, mas ainda estava vigente quando da lavratura do ato, o registro deve ser procedido, sendo o ato plenamente válido.

No caso de fundada suspeita de uma das demais causas de extinção do mandato (morte, interdição ou mudança de estado), deve-se exigir certidão de nascimento ou casamento do mandante atualizada, haja vista que essas situações são anotadas nesses assentos²²⁴.

8.5. Procuração estrangeira.

Os elementos de identificação da procuração devem sempre constar do título apresentado a registro²²⁵, mas no caso de procurações lavradas no exterior, por força do disposto no art. 163 da Lei 6.015/73, além dos dados de identificação, "os tabeliães e escrivães, nos atos que praticarem, farão sempre referência ao livro e à folha do registro de títulos e documentos em que tenham sido trasladados os mandatos de origem estrangeira, a que tenham de reportar-se", o que deve ser observado pelo registrador.

²²² Art. 682 do CC.

²²³ Item 22.1 do Capítulo XIV das NSCGJSP.

²²⁴ Art. 107 do CC.

²²⁵ Item 15, d, Capítulo XIV, NSCGJSP.

Essa determinação é decorrência do disposto no art. 129, 6, da Lei 6.015/73, que estabelece que devem ser arquivados no Registro de Títulos e Documentos "todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal". Essa exigência é absolutamente natural. Um documento estrangeiro precisa de publicidade em território nacional para produzir efeitos em relação a terceiros. Não seria possível conceder a um documento estrangeiro com força pública em seu país o mesmo tratamento se nenhuma publicidade tivesse no Brasil, e essa publicidade é gerada pelo arquivamento no Registro de Títulos e Documentos.

Deve-se observar ainda que "para que um documento originário do exterior tenha efeito no Brasil é necessária a legalização pela Autoridade Consular brasileira, do original expedido em sua jurisdição consular, seja por reconhecimento de assinatura, seja por autenticação do próprio documento"²²⁶.

A legalização consular, que "consiste no reconhecimento, pela autoridade consular, da firma e do cargo do oficial público que subscreveu o documento"²²⁷, deve ser exigida para todos os documentos de procedência estrangeira, e impede, por exemplo, que seja utilizada uma procuração expedida por autoridade incompetente no país estrangeiro, haja vista que o cônsul brasileiro não reconhecerá o subscritor como notário daquele país, impedindo eventual fraude que, sem essa formalidade, seria de fácil consumação, haja vista a dificuldade de se verificar a autenticidade de documentos estrangeiros.

No entanto, em decorrência de acordos internacionais, estão dispensados de legalização documentos provenientes da Itália²²⁸, França²²⁹, Espanha²³⁰, Argentina²³¹ e Uruguai²³², mas antes de se aceitar documentos desses países sem legalização deve-se verificar nos decretos que promulgaram os acordos internacionais se não há condições específicas para a dispensa, pois em alguns casos podem abranger apenas alguns tipos de documentos ou exigir que os documentos tenham requisitos como timbres ou selos oficiais da autoridade estrangeira.

²²⁶ Item 4.7, Capítulo 4, Manual de Serviço Consular e Jurídico - Ministério das Relações Exteriores e art. 221, III, da Lei 6.015/73.

²²⁷ Item 8.1 do Capítulo XVII das NSCGJSP.

²²⁸ Decreto 1.476, de 2 de maio de 1995.

²²⁹ Decreto nº 3.598, de 12 de setembro de 2000.

²³⁰ Decreto nº 166, de 3 de julho de 1991.

²³¹ Decreto nº 1.560, de 18 de julho de 1995.

²³² Decreto nº 1.850, de 10 de abril de 1996.

Além disso, as procurações no todo ou em parte em idioma estrangeiro deverão ser apresentadas traduzidas por tradutor público, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 18 do Regulamento do Ofício de Tradutor Público e Intérprete Comercial²³³:

“Art 18. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que for exarado em idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartições da União dos Estados e dos municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades mantidas, fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado da respectiva tradução feita na conformidade deste Regulamento.

Parágrafo único. Estas disposições compreendem também os serventuários de notas e os cartórios de registro de títulos e documentos que não poderão registrar, passar certidões ou públicas-formas de documento no todo ou em parte redigido em língua estrangeira.”

Essas regras não se aplicam apenas a procurações, valendo para todos os documentos estrangeiros, como certidões de casamentos celebrados no exterior²³⁴, etc.

Sobre esse tema, é importante ressaltar que procuração lavrada em consulado brasileiro no exterior tem a mesma força de procuração lavrada em tabelionato de notas²³⁵, mas os cônsules só lavram procurações e outros atos com força pública quando as partes são brasileiros ou estrangeiros com residência permanente no Brasil, comprovada mediante a apresentação de carteira de identidade válida expedida pelo Departamento da Polícia Federal²³⁶. O estrangeiro não portador de carteira de residente deverá outorgar procuração segundo o rito local do país estrangeiro²³⁷.

A assinatura do cônsul do Brasil que lavrar a procuração ou outro documento público não precisa ser reconhecida²³⁸.

²³³ Aprovado pelo Decreto 13.609/43.

²³⁴ Se um dos contraentes for brasileiro, o Registro de Imóveis só poderá aceitar certidão da transcrição do casamento no Livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, conforme determina o art. 32, § 1º, da Lei 6.015/73.

²³⁵ Art. 18 da LICC.

²³⁶ Item 4.11.3 do Capítulo 4 do Manual de Serviço Consular e Jurídico do Ministério das Relações Exteriores.

²³⁷ Item 4.11.4 do Capítulo 4 do Manual de Serviço Consular e Jurídico do Ministério das Relações Exteriores.

²³⁸ Art. 2º do Decreto 84.451/80.

9. Pessoas Jurídicas

As pessoas jurídicas são representadas por pessoas físicas determinadas segundo a lei e seus estatutos próprios, assim, em todos os atos em que uma pessoa jurídica for parte deverá ser verificada a sua devida representação.

9.1. Representação

As pessoas jurídicas de direito privado somente adquirem personalidade jurídica após o registro do contrato ou estatuto social no registro público competente²³⁹. As sociedades simples (sejam sociedades limitadas ou não), associações, fundações, organizações religiosas e partidos políticos arquivam seus atos constitutivos e alterações no Registro Civil de Pessoa Jurídica, e as sociedades empresárias e sociedades anônimas nas Juntas Comerciais.

E é o contrato social ou estatuto, e somente depois de devidamente registrado, o documento essencial na verificação da correta representação da pessoa jurídica, haja vista que "obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo"²⁴⁰. O contrato ou estatuto necessariamente contém a forma como a entidade é representada²⁴¹.

Importante observar que no Registro de Imóveis são lançados tanto os atos que envolvem mera administração de patrimônio (locação, v.g.), como os atos de alienação e oneração (compra e venda, hipoteca, etc.), e por isso é essencial distinguir atos de administração e de disposição, haja vista que, em regra, nem sempre as pessoas e órgãos que podem administrar são os mesmos que têm poderes para alienar e, embora a regra seja a estabelecida no contrato social, não havendo disposição expressa aplicam-se as regras estabelecidas na legislação específica de cada sociedade, que devem ser conhecidas.

9.2. Sociedade Simples

A regra geral para a alienação de bens das sociedades simples é a da deliberação da maioria dos sócios, sendo que as disposições do Código Civil sobre o tema deixam clara a importância da distinção entre as atividades de mera administração e de disposição do patrimônio da sociedade:

“Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto soci-

²³⁹ Art. 45 do CC e art. 119 da Lei 6.015/73.

²⁴⁰ Art. 47 do CC.

²⁴¹ Art. 46, III, e 997, VI, do Código Civil.

al, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir".

Como se vê, se a sociedade tem como objeto social a atividade imobiliária, no silêncio do contrato, os administradores podem alienar e onerar imóveis, isso porque se trata efetivamente do exercício da própria atividade da sociedade, ou seja, sua efetiva administração, já que os imóveis são o ativo circulante da sociedade. O contrato social, todavia, pode dispor de forma diversa e, por isso, sempre deve ser analisado.

Por outro lado, se a sociedade não exerce a atividade de compra e venda de imóveis, na omissão do contrato, um imóvel só pode ser alienado ou onerado com a autorização da maioria dos sócios. Assim, por exemplo, para uma sociedade de ensino, a venda de um imóvel jamais será um ato de administração, mas de disposição, e, por isso, não pode ser praticado por alguém que represente a escola, sem que haja expressa autorização no contrato social da sociedade educacional que autorize esse representante a alienar imóveis, ou, na falta de disposição contratual, sem autorização da maioria dos sócios.

Relevante indicar que todas as limitações quanto à representação da sociedade na alienação de imóveis aplicam-se à oneração, porque "só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese"²⁴².

Para a sua validade, a ata que deliberou sobre a alienação deve ter sido arquivada no Registro Civil de Pessoa Jurídica²⁴³.

9.3. Sociedade Anônima

O conselho de administração é o órgão deliberativo e fiscalizador das Sociedades Anônimas, "integrado por no mínimo três acionistas, com competência para qualquer matéria do interesse social, exceto as privativas da assembleia geral (art. 122 da LSA). Sua função é agilizar o processo de tomada de decisão, no interior da organização empresarial"²⁴⁴.

No que abrange a alienação de imóveis, o artigo 142 da Lei 6.404/76 traz o seu âmbito de competência:

“Art. 142. Compete ao Conselho de Administração:

²⁴² Art. 1.420 do CC.

²⁴³ Arts. 1075, § 2º, e 1.154 do CC.

²⁴⁴ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*, volume 2. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 215.

VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de terceiros”.

Mas claro, sendo a assembleia Geral, o órgão máximo da sociedade, pode avocar essa atribuição e autorizar a alienação de imóvel da sociedade.

Essas mesmas regras se aplicam às sociedades de economia mista:

“ADMINISTRATIVO - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.

1. A sociedade de economia mista tem como órgão soberano a assembleia-Geral que administra a sociedade, podendo autorizar a alienação de seus bens. 2. O Poder Público como acionista, despe-se do seu *jus imperii*, igualando-se aos demais acionistas. 3. Alienação que, autorizada pela assembleia-Geral, não sofre o crivo político do Legislativo. 4. Recurso provido, segurança concedida”²⁴⁵.

9.4. Associações

As associações têm como órgão máximo a assembleia geral²⁴⁶, a quem em regra compete a deliberação sobre a disposição de bens, salvo expressa indicação do estatuto social em contrário.

Assim, o presidente da Associação só poderá alienar ou onerar imóveis mediante autorização da assembleia geral, o que se prova por ata arquivada no Registro Civil de Pessoa Jurídica, ou se o estatuto social registrado expressamente conceder esse poder ao presidente. Sem isso, o presidente, embora presente e administre a associação, não pode isoladamente alienar bens da associação.

9.5. Fundações

Já no caso das fundações, o Código Civil Brasileiro determina que o instituidor deve, por meio de escritura ou testamento, especificar os bens livres que a integram, a finalidade à qual são destinados e a forma de administrá-los, sendo que depois de aprovada pelo Ministério Público, autoridade competente a acompanhar o funcionamento da fundação, a escritura deverá ser registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

²⁴⁵ STJ. RMS nº 9.012/SP. Segunda Turma. Data: 09/11/99. Relatora Ministra Eliana Calmon. DJU: 17/12/99, p. 341.

²⁴⁶ Art. 59 do CC.

A princípio, os bens imóveis das fundações são inalienáveis pois se destinam à própria finalidade da fundação. Mas a alienação poderá ser concretizada quando restar comprovado que a venda do bem imóvel não afetará a finalidade da entidade, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público, órgão que vela pelo patrimônio e atividades da fundação²⁴⁷:

“Para a validade da alienação do patrimônio da fundação é imprescindível a autorização judicial com a participação do órgão ministerial, formalidade que se suprimida acarreta a nulidade do ato negocial, pois a tutela do Poder Público – sob a forma de participação do Estado-juiz, mediante autorização judicial, é de ser exigida²⁴⁸”.

9.6. Sociedade Limitada

A sociedade limitada rege-se pelas normas da sociedade simples no que tange à alienação de bens imóveis, podendo ainda ser regida pelas normas da sociedade anônima se o contrato social assim estabelecer²⁴⁹, aplicando-se a ela, portanto, o que já foi exposto quanto às sociedades simples e anônima, conforme estabelecido no contrato social.

9.7. Empresário

Empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços em nome próprio²⁵⁰, sendo também denominado de pessoa jurídica individual.

Embora tenha tratamento diferenciado sob o aspecto fiscal, recebendo número de CNPJ como as demais pessoas jurídicas, o empresário responde pessoal e ilimitadamente pelos atos que pratica em sua atividade, confundindo-se com a própria pessoa natural.

O Código Civil, tratando especificamente de venda de imóveis estabelece que "o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real"²⁵¹.

No Estado de São Paulo, não se admite aquisição de bens por pessoa jurídica individual por não ter personalidade jurídica²⁵².

²⁴⁷ Art. 66 do Código Civil.

²⁴⁸ STJ. Recurso Especial nº 303.707/MG. DJU: 15/04/2002, p. 216.

²⁴⁹ Art. 1.053 do Código Civil.

²⁵⁰ Art. 966 do Código Civil.

²⁵¹ Art. 978 do Código Civil.

²⁵² Sobre o tema veja o Capítulo Entes Sem Personalidade Jurídica.

9.8. Recuperação Judicial e Falência

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial a empresa sofre limitações quanto à disponibilidade de seus bens, não podendo alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê de credores, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial²⁵³.

Após a decretação da falência, são ineficazes em relação à massa falida os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados, salvo se tiver havido prenotação anterior, independentemente da boa-fé do contratante²⁵⁴. Também são ineficazes "a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente"²⁵⁵ e a prática de atos a título gratuito e a renúncia a herança ou a legados, desde 2 anos antes da decretação da falência²⁵⁶, entre outras hipóteses elencadas no art. 129 da Lei 11.101/05.

Como outros aspectos importantes da Lei 11.101/05, no que tange aos Registros de Imóveis, estão a definição de que o título para registro de transmissão de bens na realização do ativo é o mandado judicial²⁵⁷, e que o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho²⁵⁸.

Como outra consequência relevante da decretação da quebra, todas as ações envolvendo a massa falida, inclusive as execuções trabalhistas²⁵⁹, são atraídas ao juízo da falência, o que deve ser analisado pelo registrador quando se pretenda a prática de ato envolvendo imóvel cuja arrecadação tenha sido averbada: "Lembre-se que, nos termos do artigo 23 do Decreto-lei nº 7.661/45, ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor comum, alegando e provando seus direitos. E, segundo seu artigo 24²⁶⁰, as ações ou execuções individuais dos credores ficam suspensas. Não faltará quem invoque, ainda, o artigo 215 da Lei nº 6.015/73. Inviável, deveras, no presente caso

²⁵³ Art. 66 da Lei 11.101/05.

²⁵⁴ Art. 129, VII, da Lei 11.101/05. O art. 215 da Lei 6.015/73 declarava esses atos nulos.

²⁵⁵ Art. 129, III, da Lei 11.101/05.

²⁵⁶ Art. 129, IV e V, da Lei 11.101/05.

²⁵⁷ Art. 140, § 4º, da Lei 11.101/05.

²⁵⁸ Art. 141, II, da lei 11.101/05.

²⁵⁹ Art. 6º, § 2º, da Lei 11.101/05.

²⁶⁰ Atualmente, art. 6º da Lei 11.101/05.

concreto, no contexto em que apresentado o título ao registrador, a realização do registro pretendido"²⁶¹.

Também eventual usucapião de imóvel da massa falida merece atenção do registrador, pois, embora a aquisição originária sob a forma de usucapião não se vincule à situação anterior do imóvel, deve o oficial observar o cumprimento da Lei de Falências quanto à competência e prescrição: “Em suma, tendo em vista que a ação de usucapião foi proposta posteriormente à falência, em cujo procedimento foi arrecadado o bem usucapiendo, força é convir incidir na espécie o preceito insito no § 2º, do art. 7º, do referido Diploma Falimentar²⁶², que reza ser o Juízo da Falência indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida, sendo pertinente salientar que, se a ação de usucapião tivesse sido ajuizada anteriormente à falência, não se aplicaria a disposição supramencionada”²⁶³.

10. A Lei Federal 7.433/85

O art. 215, § 1º, do Código Civil elenca como requisitos das escrituras públicas:

- 1) data e local de sua realização;
- 2) reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas;
- 3) nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação;
- 4) manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes;
- 5) referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato;
- 6) declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram;
- 7) assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato.

²⁶¹ CSMSp. Apelação Cível nº 235-6/4. Data: 20/4/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

²⁶² Atualmente, art. 76 da Lei 11.101/05.

²⁶³ Agravo de Instrumento 152.076-4/5. 7ª Câmara de Direito Privado do TJSP. Data 21/06/2000. Localidade: Pindamonhangaba. Relator: Des. Júlio Vidal.

Para a validade das escrituras públicas esses requisitos devem ser cumpridos, o que deve ser observado pelo oficial, mas além desses, a Lei 7.433/85 e o Decreto nº 93.240/86, que a regulamentou, elencam outros requisitos para sua lavratura, que também devem ser observados.

Esses diplomas legais estabelecem que devem ser apresentados ao tabelião²⁶⁴:

I - os documentos de identificação das partes e das demais pessoas que comparecerem na escritura pública, quando julgados necessários pelo Tabelião;

II - o comprovante do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos, quando incidente sobre o ato, ressalvadas as hipóteses em que a lei autorize a efetivação do pagamento após a sua lavratura;

III - as certidões fiscais, assim entendidas:

a) em relação aos imóveis urbanos, as certidões referentes aos tributos que incidam sobre o imóvel;

b) em relação aos imóveis rurais, o Certificado de Cadastro emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com a prova de quitação do Imposto Territorial Rural, atualmente dos últimos 5 exercícios²⁶⁵;

IV - a certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e a de ônus reais, expedidas pelo Registro de Imóveis competente, cujo prazo de validade, para este fim, é de 30 dias;

V - os demais documentos e certidões, cuja apresentação seja exigida por lei.

Desses documentos, os elencados nos itens II a V deverão ter sua apresentação consignada na escritura²⁶⁶. Mas há hipóteses em que alguns desses documentos podem ser dispensados.

Assim, as certidões fiscais dos imóveis urbanos somente são exigidas para a lavratura das escrituras públicas que impliquem em transferência de domínio²⁶⁷. Dessa forma, não é exigível, por exemplo, em uma escritura de consti-

²⁶⁴Art. 1º, incisos I a V, do Decreto 93.240/86.

²⁶⁵Art. 21 da Lei 9.393/96.

²⁶⁶Art. 1º, § 1º, do Decreto 93.240/86.

²⁶⁷ Art. 1º, § 2º, Decreto 93.240/86.

tuição de hipoteca. Além disso, nos casos de transferência de domínio a sua apresentação poderá ser dispensada pelo adquirente que, neste caso, responderá, nos termos da lei, pelo pagamento dos débitos fiscais existentes²⁶⁸. Essas regras não se aplicam aos imóveis rurais, cuja apresentação das certidões é obrigatória em todos os casos e não pode ser dispensada pelo adquirente.²⁶⁹

Além da apresentação das certidões de ações reais e pessoais reipersecutórias e a de ônus reais, e da apresentação das certidões de feitos ajuizados²⁷⁰, deverá constar na escritura a declaração do outorgante, sob pena de responsabilidade civil e penal, quanto à existência de outras ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e de outros ônus reais²⁷¹.

Se as declarações quanto à existência de outras ações e ônus reais não forem coerentes com os dados constantes no Registro de Imóveis, a escritura não deverá ser registrada: “O título, cujo registro se persegue, menciona que o todo está livre e desembaraçado de quaisquer ônus, fato que se contrapõe à constatação de que pende mandado de arresto em favor de M. O. B. Ltda, circunstância não infirmada e, só por si, apta a inviabilizar o acesso do título ao cadastro predial”²⁷².

Quanto à discussão sobre a apresentação das certidões de feitos ajuizados ser facultativa ou cogente, trata-se de aspecto já pacificado por parecer aprovado pelo Corregedor Geral da Justiça no Estado de São Paulo em 16 de janeiro de 1986 no Processo 1.415/86, que assim definiu esse tema:

"Visando, pois, o dever de apresentação das certidões à proteção da parte, constitui benefício de que pode livremente dispor, a seu critério. Basta lembrar hipótese de escritura de doação de bem imóvel feita pelo pai a seu filho. A confiança entre as partes, no caso, torna até inconcebível o dever de apresentar certidões.

Mesmo se o outorgante afirmar a existência de ações poderá o outorgado dispensá-lo da exibição das certidões, assumindo, então, o risco pelos eventos futuros. Não se compreende seja cerceada a liberdade individual em prol da segurança negocial. Seria a defesa de um valor, em detrimento de outro mais

²⁶⁸Art. 1º, § 2º, do Decreto 93.240/86.

²⁶⁹Art. 21 da Lei 9.393/96.

²⁷⁰Art. 1º, § 2º, da Lei 7.433/85.

²⁷¹Art. 1º, § 3º, do Decreto 93.240/86.

²⁷²CSMSP. Apelação Cível nº 022166-0/8. Data: 22/6/1995. Localidade: Itapeva. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

relevante. Se a pessoa capaz prefere arrostar as consequências de sua conduta incauta, o ordenamento jurídico não estará a criar-lhe obstáculo. O sistema legal não pode ser encarado de maneira a entravar os negócios, em prejuízo da própria economia nacional.

Em conclusão, caso o outorgado dispense a apresentação das certidões relativas a feitos em trâmite, relativas ao imóvel, basta sua declaração expressa no corpo do ato para atendimento à determinação legal"²⁷³.

Entre os demais documentos cuja apresentação seja exigida por lei²⁷⁴ está a necessidade, no caso de alienação de unidade autônoma, de comprovação da quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condomínio²⁷⁵.

E essa obrigação não foi revogada pelo Código Civil de 2002:

"Deveras, o parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 4.591/64 é categórico ao dispor que a alienação de unidades condominiais, assim como a transferência de direitos a elas relativos, 'dependerá de prova de quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condomínio. (...)

Quanto ao artigo 1.345 do novel diploma civil substantivo, longe de revo-
gar tal regra, teve por escopo, tão-somente, explicitar o caráter *propter rem*²⁷⁶
dos débitos condominiais. É norma destinada a preservar o condomínio de
inadimplemento decorrente de eventual disputa entre alienante e adquirente
acerca da responsabilidade pelo pagamento. Porém, de modo nenhum exime o
primeiro daquela obrigação antes destacada, que é requisito legal para aliena-
ção da unidade e representa garantia não só a favor da comunidade condomi-
nial, mas, também, do próprio adquirente, máxime ante a responsabilidade
realçada pelo citado dispositivo do Código Civil"²⁷⁷.

²⁷³ CGJSP. Processo 1.415/86. Data: 16/1/1986. Localidade: São Paulo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

²⁷⁴ Art. 1º, V, do Decreto 93.240/86.

²⁷⁵ Art. 4º, parágrafo único, da Lei 4.591/64.

²⁷⁶ "Trata-se, pois, de obrigação relacionada com a *res*, a coisa. Como essa obrigação apresenta-se sempre ligada a um direito real, como um acessório, sua natureza fica a meio caminho entre o direito obrigacional e o direito real, embora sua execução prenda-se ao primeiro aspecto (...) A propriedade deve ser respeitada por todos, mas o vizinho, em face do muro limítrofe, não apenas deve respeitar a propriedade confinante, como também concorrer para as despesas de conservação desse bem" (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 31).

²⁷⁷ CSMSp. Apelação Cível nº 158-6/2. Data: 12/05/2004. Localidade: São Paulo. Relator: José Mario Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Essa comprovação de quitação poderá ser por "declaração feita pelo alienante²⁷⁸ ou seu procurador, sob as penas da Lei, a ser expressamente consignada nos instrumentos de alienação ou de transferência de direitos"²⁷⁹.

Deve-se ressaltar que a exigência de comprovação de quitação das despesas condominiais aplica-se igualmente às hipóteses de promessa de venda e de cessão de direitos relativos a unidades autônomas: "frise-se, tal disponibilidade guarda pertinência não só com os casos de alienação de imóvel, como também de transferência de direitos a ele referentes"²⁸⁰.

Entre os documentos que são exigidos em decorrência de outras normas também estão as certidões negativas quanto a contribuições sociais, expedidas pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), SRF (Secretaria da Receita Federal) e PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)²⁸¹.

No tocante às testemunhas nas escrituras públicas, embora sejam imprescindíveis em diversos atos notariais, como no caso de testamentos²⁸², a regra geral é de que as testemunhas apenas são necessárias na hipótese do art. 215, § 5º, do CC: "Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade". Neste sentido as Normas de Serviço do Estado de São Paulo: "Ressalvados os testamentos e hipóteses em que, por lei, o requisito seja essencial à validade do ato, dispensável a presença e assinaturas de testemunhas instrumentárias"²⁸³.

Em suma, para que a escritura seja passível de registro deverá consignar:

1 - A apresentação da certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e a de ônus reais, expedidas pelo Registro de Imóveis;

2 - A apresentação das certidões de feitos ajuizados ou a expressa dispensa pelo outorgado da apresentação dessas certidões;

3 - A apresentação da certidão fiscal: IPTU se urbano, e ITR e CCIR se rural. A certidão fiscal municipal quando o imóvel se localizar em área urbana

²⁷⁸Atente-se que a legislação permite que a declaração seja feita somente pelo alienante e não pelo adquirente.

²⁷⁹ Art. 2, § 2º, da Lei 7.433/85.

²⁸⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 024033-0/6. Data: 16/10/1995. Localidade: São Paulo. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

²⁸¹ Sobre essas certidões e as hipóteses de exigibilidade e dispensa veja o Capítulo Aspectos Fiscais.

²⁸² Arts. 1.864 e 1.868 do CC.

²⁸³ Item 24, Capítulo XIV das NSCGJSP.

poderá ser dispensada pelo adquirente, nos termos do §2º do artigo 1º do Decreto nº 93.240/86;

4 - Quando o transmitente for pessoa jurídica deverá ser apresentada certidão negativa de débito expedida pela Previdência Social, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, se não caracterizada nenhuma das hipóteses de dispensa. Se for necessária declaração, esta deverá ser feita pelo alienante e não pelo adquirente (veja item 6.10 do capítulo X);

5 - Para os imóveis submetidos ao regime condominial deverá ser apresentada declaração do alienante de que os débitos condominiais estão quitados, ou declaração do síndico nesse sentido, com cópia autenticada da ata que o elegeu arquivada no Registro de Títulos e Documentos;

6 - Declaração do vendedor sobre a existência de ações judiciais que possam comprometer o imóvel e de outros ônus reais incidentes sobre o bem;

7 - Apresentação do comprovante do recolhimento do imposto, ITBI para transmissões onerosas, e ITCMD para as gratuitas.

Também deve o oficial verificar se nas escrituras de transmissão de direitos reais consta a emissão da declaração sobre operações imobiliárias (DOI). A ausência dessa informação não impede o registro, mas o oficial então deverá apresentá-la ao órgão fiscal²⁸⁴. Outras exigências ainda são encontradas nas Normas de cada Estado²⁸⁵.

11. Valor do contrato, da coisa ou da dívida

O valor do contrato, da coisa ou da dívida deverá constar do título e será lançado no ato a ser praticado, estabelecendo o art. 176, § 1º, III, 5, da Lei 6.015/73 como requisitos do registro no Livro 2: "o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros, se houver".

Quanto à estipulação do valor, o art. 318 do Código Civil estabelece que: "São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial".

Não se aplicam essas restrições²⁸⁶:

²⁸⁴ A DOI é tratada nesta obra no Capítulo Aspectos Fiscais.

²⁸⁵ No Estado de São Paulo, nos itens 15 e 16 do Capítulo XIV das NSCGJSP.

²⁸⁶ Art. 2º do Decreto-lei 857/69.

“I - aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de mercadorias;

II - aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens de produção nacional, vendidos a crédito para o exterior;

III - aos contratos de compra e venda de câmbio em geral;

IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional;

V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no País.”

Quando o pagamento for a prazo, eventual correção monetária não poderá ter periodicidade inferior a 12 meses, como determina o art. 2º, § 1º, da Lei 10.192/01: "É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano".

Essa regra foi excetuada para os contratos de alienação de imóveis com prazo mínimo de pagamento de 36 meses, conforme autoriza o art. 46 da Lei 10.931/04: "Nos contratos de comercialização de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos de arrendamento mercantil de imóveis, bem como nos títulos e valores mobiliários por eles originados, com prazo mínimo de trinta e seis meses, é admitida estipulação de cláusula de reajuste, com periodicidade mensal, por índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança".

Assim, somente se o prazo de pagamento do imóvel for igual ou superior a 36 meses é possível convencionar correção monetária mensal. Se o prazo for inferior a 36 meses, a atualização só poderá ser anual.

Também quanto à atualização monetária, não é possível a utilização do salário mínimo como índice de correção, conforme determina a parte final do art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.

Poderá ainda ser convencionado, além da correção monetária, a incidência de juros sobre as parcelas pagas a prazo, os denominados juros remunerató-

rios, que não se confundem com os juros moratórios²⁸⁷, estes incidentes apenas no caso de atraso no adimplemento da obrigação.

Na estipulação de juros remuneratórios deverá ser respeitado o limite legal de 12% ao ano²⁸⁸, que, no entanto, não se aplica a instituições financeiras²⁸⁹, sendo vedado o anatocismo, ou seja, a incidência de juros sobre juros, proibição que não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano²⁹⁰. As taxas de juros mais utilizadas pelas instituições financeiras são: Taxa Selic, Taxa DI, TBF, TR e TJLP.

Embora o art. 176, § 1º, III, 5, da Lei 6.015/73 expresse como requisitos do registro o valor e prazo da dívida, condições e mais especificações, incluindo os juros, se houver, apenas o valor da dívida é efetivamente imprescindível.

Quanto aos juros, o próprio dispositivo legal expressamente indica que deverão ser lançados se houver, o que evidencia não serem obrigatórios.

Da mesma forma, não é imprescindível que o título indique o prazo da dívida: "Sabido que o termo - e o prazo é justamente o espaço de tempo compreendido entre dois termos, o inicial e o final - encerra elemento accidental do negócio jurídico, cuja ausência significa reputar-se exigível à vista a obrigação (art. 952 do CC²⁹¹), salvo hipótese em que a prestação demande, por natureza, tempo para cumprimento, em que se estabelece, judicialmente, o chamado prazo moral, de que ora não se cuida, porém. Se é assim, na verdade somente se exige alusão expressa ao prazo da dívida, no instrumento de constituição da hipoteca, se ele tiver sido expressamente acordado"²⁹².

Por outro lado é indispensável a indicação do valor da dívida: "No instrumento de constituição da hipoteca, e para conhecimento não só do devedor, como de terceiros, até mesmo eventuais outros credores, sem contar potenciais adquirentes, é preciso explicitar o valor do débito garantido pela hipoteca, e porque, afinal, isto significa aferir até quanto o imóvel hipotecado garante. É evidente que, nem sempre, se poderá precisar, como quer a lei, o valor total do crédito, via de regra dependente de acessórios só em potência incidentes. Aliás, em outros casos a indeterminação é ainda maior, como nos débitos condicionais, futuros ou que envolvam preços variáveis, como se quer

²⁸⁷ Art. 406 do CC.

²⁸⁸ Art. 1º, *caput* e § 3º, do Decreto 22.626/33.

²⁸⁹ Súmula STF 596.

²⁹⁰ Art. 4º do Decreto 22.626/33 e art. 591 do CC.

²⁹¹ Art. 331 do CC de 2002.

²⁹² CSMSP. Apelação Cível nº 093236-0/2. Data: 14/8/2002. Localidade: Araraquara. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

ocorrente na hipótese em tela. Mas é por isso mesmo que a lei exige ou a indicação do valor, que seja ao menos inicial, e a especialização de seus acréscimos, do débito garantido ou, então, a sua estimação (art. 761, I, do CC²⁹³)²⁹⁴".

Na análise das demais condições da dívida, deve o Oficial observar se a fixação da multa moratória obedece as limitações legais. Atualmente, tanto as multas moratórias decorrentes da relação de consumo²⁹⁵, como as decorrentes de despesas condominiais²⁹⁶, estão limitadas a 2% sobre o débito.

12. Qualificação Negativa

Quando o título não puder ser registrado por não atender os requisitos legais, sofrerá qualificação negativa, devendo ser elaborada nota devolutiva na qual serão elencadas as exigências necessárias ao registro do título, que "deverão ser formuladas de uma só vez, por escrito, de forma clara e objetiva, em papel timbrado do cartório, com identificação e assinatura do servidor responsável"²⁹⁷.

Embora a Lei 6.015/73 não estabeleça o prazo máximo para a análise e devolução do título com exigências, este prazo tem sido fixado em cada Estado. Em São Paulo, o prazo para a devolução do título com exigências foi estabelecido em no máximo 15 dias corridos²⁹⁸, restando, assim, no mínimo 15 dias ao apresentante para o cumprimento das exigências dentro do prazo de validade da prenotação²⁹⁹:

"Com isso, tendo o interessado, ao final de quinze dias, o título à sua disposição, com exigências formuladas na nota devolutiva, poderá utilizar a quinzena faltante para cumpri-las. (...)

Reingressado o título na serventia imobiliária, haverá nova qualificação, para conferência, pelo Oficial Delegado, do efetivo cumprimento das exigências. Poderá ocorrer, em tal caso, estouro do trintídio, contado do lançamento original no Livro Protocolo (basta lembrar a hipótese do reingresso dar-se no

²⁹³ Art. 1.424, I, do CC de 2002.

²⁹⁴ CSMSP. Apelação Cível nº 093236-0/2. Data: 14/8/2002. Localidade: Araraquara. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

²⁹⁵ Art. 51, § 1º, da Lei 8.078/90.

²⁹⁶ Art. 1336, §1º, do C.C.

²⁹⁷ Item 12 do Capítulo XX das NSCGJSP.

²⁹⁸ Item 32 e 11.1 do Capítulo XX das NSCGJSP.

²⁹⁹ Art. 205 da Lei 6.015/73.

trigésimo dia). Haverá, então, prorrogação, da prenotação, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetivação do registro³⁰⁰.

Claro que, havendo nova devolução, uma vez decorrido o prazo inicial da prenotação, seus efeitos cessarão automaticamente"³⁰¹.

No Estado de São Paulo, se o oficial elaborar exigências após o prazo máximo, perderá o direito de cobrar o valor da prenotação previsto no art. 206, parte final, da Lei 6.015/73³⁰².

Todas as exigências devem ser relevantes e sempre baseadas em expressa disposição legal, haja vista que exigências desnecessárias ou infundadas podem provocar a perda do prazo de validade da prenotação e se, entre o vencimento da prenotação e a reapresentação do título, ingressar outro título contraditório, restará impedido o registro do título anterior, devolvido indevidamente.

³⁰⁰ Art. 188 da Lei 6.015/73.

³⁰¹ Parecer aprovado pelo Corregedor Geral da Justiça Des. Márcio Martins Bonilha. Processo 002524/97. Data: 29/12/97. Localidade: São Paulo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁰² Item 4.2 das Notas Explicativas da Tabela II da Lei Estadual 11.331/02.

CAPÍTULO III

INSTRUMENTOS

PARTICULARES

A Lei 6.015/73, em seu art. 221, II, estabelece como títulos registráveis os: "escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação".

Na qualificação desses instrumentos particulares o oficial observará os princípios registrais e aplicará, em essência, os mesmos parâmetros utilizados na análise das escrituras públicas. Todas as exigências quanto à especialização subjetiva e objetiva, continuidade, legalidade e aos demais princípios que norteiam o registro imobiliário abordados nos capítulos específicos devem ser atendidas.

Também, pela mesma razão que o tabelião deve exigir que a certidão da procuração que lhe é apresentada seja atualizada e tenha o reconhecimento de firma de quem a subscreveu³⁰³, a procuração que instrui contrato particular deve atender as mesmas exigências. Da mesma forma que não se pode aceitar traslado de escritura sem que todas as folhas estejam rubricadas pelo tabelião³⁰⁴, os instrumentos particulares devem ter todas as suas folhas rubricadas pelas partes.

É importante lembrar que as legislações que autorizam sejam aceitos instrumentos particulares em determinadas hipóteses de transmissões e constituições de direitos reais, apenas dispensam a forma pública nessas específicas situações, mas não dão a esses instrumentos particulares mais força do que têm as escrituras públicas, não dispensando, além da forma, as exigências que para a lavratura das escrituras públicas deveriam ser cumpridas, o que deve ser observado pelo oficial, que não pode realizar uma qualificação menos rigorosa desses instrumentos.

Por isso, as observações feitas no capítulo anterior quanto à qualificação de escrituras públicas também se aplicam à análise dos instrumentos particulares, que ainda estão sujeitos às demais exigências encontradas na Lei 6.015/73 e nas legislações que regulam cada modalidade de instrumento particular.

³⁰³ Item 12 do Cap. XIV das NSCGJSP.

³⁰⁴ Item 49 do Cap. XIV das NSCGJSP.

1. Reconhecimento de firmas

A regra geral é que o instrumento particular apresente o reconhecimento de firma de todas as partes, bem como das testemunhas, como expressamente determina o art. 221, II, da Lei 6.015/73, que excetua apenas os contratos do Sistema Financeiro da Habitação.

O reconhecimento de firma exigido pela lei é plenamente justificado, trazendo segurança jurídica ao título que será registrado e que passará a produzir efeitos em relação a terceiros, sendo a dispensa para as operações vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) explicada pelo fato das assinaturas serem apostas na presença do representante da instituição financeira, competindo à instituição integrante do SFH as medidas necessárias à identificação das partes do contrato.

O reconhecimento de firma pode ser feito por semelhança, por autenticidade ou por abono.

A forma mais utilizada de reconhecimento é a por semelhança, em que o tabelião confronta a assinatura lançada no documento com o padrão de assinatura existente na denominada ficha-padrão³⁰⁵, arquivada no tabelionato, que contém os dados de qualificação da pessoa e sua assinatura, que foi aposta pessoalmente³⁰⁶ no tabelionato quando do preenchimento da ficha-padrão.

O reconhecimento de firma que gera mais segurança é o autêntico, também denominado verdadeiro, no qual a assinatura a ser reconhecida é lançada no documento na presença do tabelião³⁰⁷. No entanto, é pouco difundido, e na prática só tem sido utilizado quando é obrigatório, como nos documentos de alienação de veículos³⁰⁸.

O reconhecimento por abono ocorre quando a assinatura a ser reconhecida pelo tabelião vem abonada por terceira pessoa, que deve ser idônea e ter ficha-padrão arquivada no tabelionato. No Estado de São Paulo "é vedado o reconhecimento por abono, salvo no caso de procuração firmada por réu preso e outorgada a advogado, desde que visada pelo Diretor do Presídio, com sinal ou carimbo de identificação"³⁰⁹.

³⁰⁵ Item 59 do Capítulo XIV das NSCGJSP.

³⁰⁶ Itens 65 e 66 do Capítulo XIV das NSCGJSP.

³⁰⁷ Item 61.3 do Capítulo XIV das NSCGJSP.

³⁰⁸ Portaria Detran-SP 1.606/05 e Resolução Contran 664/86.

³⁰⁹ Item 61.1 do Capítulo XIV das NSCGJSP.

Assim, nos instrumentos particulares deve ser exigido que todas as assinaturas sejam reconhecidas por semelhança ou autenticidade, facultada às partes a escolha da modalidade de reconhecimento.

Quanto à dispensa de reconhecimento de firma, deve-se observar que embora a lei utilize a expressão "atos praticados por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação", não basta que uma das partes seja uma instituição vinculada ao SFH, mas que no contrato ela esteja agindo efetivamente como entidade vinculada ao SFH. Se assim não fosse, todos os contratos de bancos que integram o SFH estariam dispensados de reconhecimento, como, por exemplo, o contrato de locação de um imóvel para a instalação de uma agência bancária, ato totalmente estranho ao SFH. Assim, deve-se observar a efetiva operação imobiliária, e não apenas as partes envolvidas.

Conforme estabelece o art. 1º do Regulamento anexo à Resolução Bacen 1.980/93, "integram o Sistema Financeiro da Habitação, na qualidade de agentes financeiros, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, as caixas econômicas, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias de habitação, as fundações habitacionais, os institutos de previdência, as companhias hipotecárias, as carteiras hipotecárias dos clubes militares, os montepios estaduais e municipais e as entidades e fundações de previdência privada".

Sobre o reconhecimento de firmas ainda se deve observar as normas específicas para determinados títulos. No Estado de São Paulo, por exemplo, nos casos de cédulas de crédito (cédulas de crédito industrial, rural, à exportação e comercial, bem como de seus aditivos), é dispensado o reconhecimento das assinaturas apostas nas cédulas, mas deve-se exigí-los nos termos de quitação apresentados para baixa dos registros das cédulas³¹⁰.

Na Comarca de São Paulo, em resposta a solicitação da Associação dos Advogados de São Paulo, a Corregedoria Permanente dos Registros de Imóveis determinou aos oficiais que deixassem de exigir "o reconhecimento de firma do advogado, em requerimento por ele formulado, pertinente a ato de averbação ou com conteúdo diverso, desde que acompanhado de procuração, contendo poder específico, firmada por interessado com a firma deste reconhecida no instrumento de mandato"³¹¹.

Mas, apesar do benefício estabelecido na parte final do art. 221, II, da Lei 6.015/73 para as entidades do SFH, ou em qualquer outra disposição norma-

³¹⁰ Item 77, Capítulo XX, das NSCGJSP.

³¹¹ Processo nº 000204/96. Data: 18/08/96. Localidade: São Paulo. Juiz Corregedor: Dr. Asbrubal Nascimbeni. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

tiva, o oficial pode e deve exigir o reconhecimento de firma quando tenha fundada dúvida sobre a autenticidade da assinatura. É o que estabelece o item 22 do Capítulo XVI das NSCGJSP: "Sempre que ocorra fundada dúvida sobre a autenticidade de firma constante de documento público ou particular, o oficial do Registro deverá, sob pena de responsabilidade, exigir o seu reconhecimento, valendo aquele feito pelo escrivão-diretor do processo nos documentos judiciais".

A solicitação de reconhecimento de firma com fundamento no referido item das Normas de Serviço, no entanto, é excepcional: "(...) a exigência de reconhecimento de firma realizada com fundamento no item 22 do Capítulo XVI das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça apenas deve ser feita quando efetivamente necessária, para que não constitua encargo indevidamente imputado ao usuário do serviço público, competindo ao oficial registrador, antes de efetuar-la, promover as diligências de que dispuser para confirmar a autenticidade da firma constante do documento público³¹²

Interessante observar que em decisão prolatada acerca de representação formulada por Tabelião contra ato praticado por Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, a Segunda Vara de Registros Públicos da Capital de São Paulo manifestou entendimento que o reconhecimento de firma em documento com data futura é legítimo, assim, o reconhecimento de firmas em 27/08/2007 em contrato de locação datado de 01/09/2007 não é vedado pelas NSCGJSP, já que a vedação da prática de tal ato restringe-se somente aos documentos que estiverem sem data, incompletos ou que contenham espaços em branco no contexto³¹³, não cabendo ao Tabelião questionar outros aspectos: "verifica-se a autenticidade e a veracidade das assinaturas, e não o aspecto de nulidade do negócio jurídico, que, eventualmente, poderá ser questionada na via jurisdicional adequada³¹⁴".

1.1. Regularização fundiária

A lei 11.977 de 7 de julho de 2009 que instituiu o programa federal Minha Casa Minha Vida – PMCMV, alterou o artigo 221 da Lei 6.015/73, passando a admitir o registro de contratos ou termos administrativos, assinados com a União, Estados e Municípios no âmbito de regularização fundiária, dispensado o reconhecimento de firma.

³¹²CGJSP. Protocolado CG 44.670/2003, citado no parecer do processo CGJSP 792/2006. Publicado no D.O.J. de 08/01/2007.

³¹³Capítulo XIV, item 64.

³¹⁴Processo nº 583.00.2007.222090-4. Segunda Vara de Registro Públicos da Capital do Estado de São Paulo. Juiz: Márcio Martins Bonilha Filho.

2. Testemunhas

Ainda quanto ao artigo 221, II, da Lei 6.015/73, este dispositivo legal também exige que o documento contenha a assinatura de ao menos duas testemunhas, haja vista a palavra testemunha ser empregada no plural, exigência que novamente visa conferir segurança ao ato, devendo ser necessariamente qualificadas pelo nome e documento de identidade para que possam ser identificadas, pois poderão ter que ser localizadas para depor sobre o documento que testemunharam: "testemunhas signatárias são aquelas que assinam o instrumento de um contrato, ou o documento, em segurança de sua autenticidade, ou para satisfazer exigência legal. São as mesmas testemunhas instrumentárias, também nomeadas como documentárias, ou certificadoras. As testemunhas signatárias podem ser chamadas a depor, se o documento que testemunharam, ou certificaram, é trazido a juízo, como fundamento de uma demanda judicial"³¹⁵.

Sobre as testemunhas, o Código Civil de 2002, no seu art. 221, não manteve a sua necessidade no documento particular para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor, como exigia expressamente o art. 135 do Código Civil anterior, mas essa alteração em dispositivo de caráter geral não modificou a regra especial que determina a sua necessidade nos instrumentos particulares submetidos a registro, que permanece vigente.

Note-se que nas escrituras públicas compete ao tabelião reconhecer a identidade e manifestação de vontade das partes³¹⁶, e no instrumento particular relativo a imóvel, cujos efeitos após o registro atingirão terceiros, a presença das testemunhas instrumentárias gera maior segurança, como demandam as transações imobiliárias, comparecendo no ato "não somente para certificarem a identidade das pessoas que neles são partes, como para presenciarem a sua feitura, autenticando-os, afinal, com a assinatura"³¹⁷.

Importante observar, no entanto, que quanto à necessidade das testemunhas serem presenciais o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, ao analisar a qualificação de documento particular antigo, exigiu a subscrição de testemunhas, "muito embora não necessariamente contemporâneas ao ato"³¹⁸.

Observe-se que são suficientes duas testemunhas, motivo pelo qual a ausência de reconhecimento de firma de outras testemunhas não impede o regis-

³¹⁵ SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 1398.

³¹⁶ Art. 215 do CC.

³¹⁷ SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 1397.

³¹⁸ CSMSP. Apelação Cível nº 093956-0/8. Data: 30/10/2002. Localidade: São Paulo. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

tro do título: "Exige-se apenas a presença de duas testemunhas, cujas firmas deverão ser reconhecidas. Uma terceira testemunha poderá ser desprezada, sem a necessidade do reconhecimento de sua firma"³¹⁹.

3. Procuração

As procurações referidas no instrumento particular deverão ser apresentadas por traslado ao oficial, para que possa verificá-las: "em se tratando de negócio jurídico reduzido à forma de instrumento particular, como é caso, incumbe ao oficial delegado, ao qualificar o título recepcionado, examinar a procuração que lhe dê suporte, verificando se está em forma regular e se contém os poderes necessários (Apelação n. 6.401-0, da Comarca de Taquaritinga). Sem a exibição do instrumento de procuração mencionado no corpo do próprio título, tal qual ocorre na espécie, não há como qualificá-lo inteira e corretamente"³²⁰.

4. Vinculação da forma

Em diversas situações ocorre a vinculação da forma, ou seja, o novo ato deve obedecer a forma de outro ato, o que deve ser sempre lembrado. As hipóteses mais importantes são a seguir relacionadas:

4.1. Anuência e autorização

O art. 220 do CC expressamente estabelece que "a anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento".

Assim, no caso de anuência de descendente a uma venda de ascendente para outro descendente³²¹, o consentimento deverá constar do próprio título. Se a venda se operou por escritura pública não se poderá aceitar que a anuência seja apresentada por instrumento particular.

4.2. Distrato

Estabelece o art. 472 do CC que "o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato". Assim, se uma escritura foi lavrada com cláusula resolutiva, o eventual distrato deve respeitar a mesma forma exigida para o contrato.

³¹⁹ CSMSp. Apelação Cível nº 031716-0/0. Data: 15/4/1997. Localidade: São Paulo. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³²⁰ CSMSp. Apelação Cível nº 035544-0/3 Data: 18/12/1996. Localidade: Catanduva. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³²¹ Art. 496 do CC.

Deve-se destacar dois aspectos. O primeiro é que no Código Civil anterior se exigia que o distrato tivesse a "mesma forma do contrato"³²². Assim, mesmo que o contrato pudesse ter sido lavrado por instrumento particular, se lavrado por escritura pública, o distrato deveria ser também por escritura pública. A redação posterior estabelece que deve ter a "mesma forma exigida para o contrato".

O segundo aspecto é que não é possível realizar o distrato de contratos já cumpridos: "Compra e venda pura, quando perfeita e exaurida nas suas obrigações, não comporta arrependimento nem distrato. Todo distrato supõe contrato ainda por executar, pois se destina a extinguir vínculo obrigacional por esse estabelecido. Logo, aparente distrato de venda e compra já exaurida encobre compra e venda em sentido inverso"³²³. Esse aspecto deve ser analisado com cuidado pelo registrador, inclusive sobre os aspectos fiscais, pois, embora irrelevante a denominação que se dê ao contrato³²⁴, deve ser qualificado como uma nova transmissão.

Uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitiu a validade do distrato antes do registro da venda e compra, tendo em vista que o aperfeiçoamento da alienação dá-se somente com o registro do direito real: "Assim, no direito brasileiro o ato jurídico de transcrição do título no Registro de Imóveis só é eficaz se o título que lhe dá causa existe, é válido e eficaz. Caso o título causal não exista ou seja nulo, o ato de transmissão do domínio é nulo ou ineficaz. (...) Ocorre que no dia 16 de outubro de 2003 a própria adquirente firmou com o alienante uma Escritura Pública de Desfazimento de Compra e Venda, vale dizer, assinou distrato do negócio jurídico de compra e venda anteriormente ajustado. Como consta expressamente na escritura pública cuja cópia encontra-se a fl. 12, as partes decidiram 'de comum acordo desfazer a escritura pública de Compra e Venda nestas notas no livro nº 126, fl. 122, sob o nº 19.882/11.082, datada de 06 de outubro de 2003, incidente sobre 50% do prédio de alvenaria nº 1.492 sito na Rua Monte Casseiros, nesta cidade'...ficando a referida escritura, a partir desta data, sem nenhuma validade jurídica. O distrato é plenamente admissível no direito brasileiro, desde que obedeça a forma exigida para o contrato, conforme exige expressamente o art. 472 do Código Civil. (...) Como se viu, o distrato foi feito em 16 de outubro de 2003, e o registro da escritura pública de compra e venda de 03 de outubro de 2003 foi efetuado no dia 23 de outubro de 2003. Assim,

³²² Art. 1.093 do CC.

³²³ CSMSp. Apelação Cível nº 067781-0/3. Data: 15/03/2000. Localidade: Guarulhos. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³²⁴ Art. 112 do CC.

quando no registro no cartório imobiliário, o título original já não subsistia, ou seja, a causa do ato jurídico de transferência da propriedade desaparecera do mundo jurídico pelo distrato. E sem causa não há transmissão do domínio³²⁵”.

4.3. Procuração

O art. 655 do CC estabelece que "ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode substabelecer-se mediante instrumento particular". No entanto, esse artigo deve ser interpretado em conjunto com o art. 657 do CC, que determina que "a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito".

Por esses dispositivos se verifica que apenas se poderá substabelecer por instrumento particular mandato que poderia ter sido outorgado por instrumento público. Se o mandato teve a forma pública porque o ato a ser realizado demanda a forma pública, eventual substabelecimento não poderá se dar por instrumento particular.

5. Analfabetos e pessoas que não possam ler ou assinar

Os analfabetos e as pessoas que não possam assinar somente podem celebrar contratos particulares representados por mandatários, constituídos por escritura pública. Nada adianta a assinatura a rogo e a aposição de impressão digital³²⁶.

Observe-se que situação muito diversa é a dos cegos, havendo inclusive expressa previsão nas NSCGJSP da forma como deve ser depositada a sua assinatura na ficha padrão que depois será utilizada nos reconhecimentos de firma³²⁷, que no Estado de São Paulo poderão ser por semelhança ou autenticidade³²⁸. Já o Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê que o reconhecimento de firma de signatário cego se dará somente por autenticidade.³²⁹

³²⁵TJRS. Apelação Cível nº 70021651088. Data: 18/06/2008. Relator: Glênio José Wasserstein Hekman. Localidade: Uruguaiiana.

³²⁶Sobre o tema, ver tópico específico no Capítulo Qualificação de Títulos.

³²⁷Item 59, g, Capítulo XIV, das NSCGJSP.

³²⁸CGJSP. Processo nº 002812/2001. Data: 31/1/2003. Localidade: São Paulo. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³²⁹Art. 291, §3.

6. Rasura

As mesmas restrições a rasuras existentes para escrituras públicas aplicam-se aos instrumentos particulares. Assim, eventual rasura ou emenda deve ser ressalvada ao final, com a assinatura de todas as partes, e, se alterar elemento essencial, invalida o documento³³⁰: "Nesse capítulo, ainda que se repete irrelevante o equívoco da correta denominação do instrumento, de sorte a prevalecer a manifestação da vontade das partes, no corpo da escritura, verifica-se que, na hipótese versada nos autos, há rasura em parte essencial do título, incidindo na indicação da proporção do bem cujos direitos foram negociados. A ressalva à rasura, aposta na parte final do contrato, com a menção de que a cedente é possuidora de metade da parte ideal do imóvel, não veio acompanhada sequer de rubrica dos intervenientes, em quadro, portanto, revelador de comprometimento da confiabilidade do instrumento"³³¹.

7. Alvarás judiciais em instrumentos particulares

Quando a transmissão formalizada por documentos particulares dependa de autorização judicial, o alvará deve ser apresentado no original ao Registro Público, e não em cópia autenticada, não apenas para verificação de sua autenticidade, como para que o lançamento do registro ocorra no próprio documento, impedindo sua nova utilização.

Deverá ainda o oficial verificar o seu prazo de validade, eventuais condições estabelecidas (como preço mínimo, por exemplo) e se a assinatura do juiz está autenticada³³², autenticação que, no entanto, é “dispensada quando os documentos são provenientes de outros Estados, uma vez que as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, que exigem tal providência (item 63.1 do Capítulo II) têm vigência apenas no Estado de São Paulo”.³³³

Dispensa da forma pública

O art. 221, II, da Lei 6.015/73, em harmonia com o art. 108 do Código Civil, deixa claro que somente pode ser aceito o instrumento particular "autorizado em lei", o que deve ser analisado pelo oficial com muito cuidado, haja vista ser nulo o ato jurídico que não revestir a forma pública quando esta for

³³⁰ Item 23.1, Cap. XIV, NSCGJSP.

³³¹ CSMSP. Apelação Cível nº 021764-0/0. Data: 17/01/95. Localidade: São Paulo. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³³² Item 12, e, Capítulo XIV, NSCGJSP.

³³³ CGJSP. Processo CG nº 23.674/2004. Publicado no D.O.J. em 29/08/2005. Parecer da Juíza Auxiliar da Corregedoria: Fátima Vilas Boas Cruz. Corregedor Geral de Justiça: José Mário Antonio Cardinale.

exigida³³⁴. As principais hipóteses de dispensa de forma pública serão vistas a seguir.

8. Valor do imóvel

A obrigatoriedade da escritura pública ocorre para os "negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País"³³⁵.

Para imóveis de valor inferior ou igual a 30 vezes o salário mínimo a forma é livre, podendo ser usado o instrumento particular. Visando dar ampla divulgação dessa faculdade, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, determinou a transcrição do art. 108 do Código Civil em cartaz que deve ser afixado em local público em todos os tabelionatos de notas³³⁶.

Importante observar que, embora o dispositivo legal indique como parâmetro o maior salário mínimo do País, o salário mínimo está nacionalmente unificado³³⁷, sendo que a Lei Complementar 103/2000 estabeleceu a possibilidade de criação de pisos salariais estaduais, já adotados no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, pisos esses de que trata o art. 7º, V, da Constituição Federal, que não se confundem com o salário mínimo definido no art. 7º, IV, da Constituição. Assim, deve o oficial considerar como parâmetro o salário mínimo fixado pelo Governo Federal, não importando o valor dos pisos regionais.

Também, não deve o oficial tolerar fraudes, devendo recusar títulos particulares e exigir a formalização da transação por escritura pública quando, à vista de documentos, como, por exemplo, o documento de valor venal do imóvel expedido pelo município, ficar evidenciada a tentativa de burla à lei, com a indicação de valores irrisórios apenas para tentar evitar a forma pública.

Deve-se ainda observar que mesmo que o imóvel não seja de valor superior a 30 salários mínimos, o instrumento deverá ser público nos casos em que a legislação exija para o ato a forma pública, como na aquisição de imóvel

³³⁴ Art. 166, IV, do CC.

³³⁵ Art. 108 do CC.

³³⁶ Comunicado CG 780/06.

³³⁷ Art. 7º, IV, CF.

rural por pessoa estrangeira, física ou jurídica³³⁸, e na realização de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais por via administrativa³³⁹.

9. Sistema Financeiro da Habitação – SFH

A hipótese mais comum de utilização de instrumentos particulares é a decorrente de operações do Sistema Financeiro da Habitação, instituído pela Lei 4.380/64.

O "Sistema Financeiro da Habitação, destinado a facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população"³⁴⁰, tem suas aplicações voltadas, fundamentalmente, para "a aquisição de casa para residência do adquirente, sua família e seus dependentes, vedadas quaisquer aplicações em terrenos não construídos, salvo como parte de operação financeira destinada à construção da mesma"³⁴¹.

A dispensa da escritura pública nas operações do SFH está expressa no art. 61, § 5º, da Lei 4.380/64, que estabelece que: "os contratos de que forem parte o Banco Nacional de Habitação ou entidades que integrem o Sistema Financeiro da Habitação, bem como as operações efetuadas por determinação da presente Lei, poderão ser celebrados por instrumento particular, os quais poderão ser impressos, não se aplicando aos mesmos as disposições do art. 134, II, do Código Civil³⁴², atribuindo-se o caráter de escritura pública, para todos os fins de direito, aos contratos particulares firmados pelas entidades acima citadas até a data da publicação desta Lei".

O Banco Nacional da Habitação referido nesse dispositivo legal foi extinto pelo Decreto-lei 2.291/86, sendo o seu patrimônio incorporado pela Caixa Econômica Federal, que o sucedeu em todos os seus direitos e obrigações³⁴³. As atividades de fiscalização das instituições financeiras que integram o SFH foram transferidas ao Banco Central³⁴⁴.

Para os contratos do SFH, requisitos como os de que os instrumentos particulares "serão obrigatoriamente rubricados por todas as partes em todas as suas folhas"³⁴⁵ e que devem atender as mesmas exigências das escrituras

³³⁸ Art. 8º da Lei 5.709/71.

³³⁹ Arts. 982 e 1.124-A do CPC.

³⁴⁰ Art. 8º da Lei 4.380/64.

³⁴¹ Art. 9º da Lei 4.380/64.

³⁴² Atualmente, art. 108 do CC de 2002.

³⁴³ Art. 1º DL 2.291/86.

³⁴⁴ Art. 8º DL 2.291/86.

³⁴⁵ Art. 61, §6º, da Lei 4.380/64.

públicas³⁴⁶ são encontradas expressamente nas Leis 4.380/64 e 7.433/85, cujo cumprimento deve ser exigido pelo oficial.

Aqui importante ressaltar que não deve o oficial inferir pelas características do contrato que se trata de operação do SFH. O contrato deve conter expressamente essa declaração, haja vista que elementos como a origem dos recursos e o tipo de imóvel não são suficientes para a caracterização da operação como do SFH.

Isso porque o Banco Central autoriza que parte dos recursos do SFH seja utilizada em outras operações, como operações de financiamento imobiliário contratadas a taxas de mercado³⁴⁷, que não se confundem com as operações do SFH.

Mas mesmo no caso de declaração expressa de se tratar de operação do SFH, deve o oficial rejeitar contratos que à evidência não se enquadram nessas operações, como, por exemplo, a aquisição de um imóvel comercial: "Se a destinação do edifício é comercial, não se autoriza a utilização do instrumento particular de compra e venda de que trata o § 5º do art. 61 da Lei 4.380/64"³⁴⁸.

9.1. Restrições decorrentes de financiamento do SFH

Embora em regra a hipoteca não impeça a venda do imóvel onerado³⁴⁹, estabelecendo o art. 1.475 do Código Civil que nos contratos "é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado", quando a hipoteca decorre de financiamento do SFH o imóvel não poderá ser alienado livremente pelo mutuário, que só pode transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes do contrato de financiamento com a anuência da instituição financeira do SFH, conforme estabelece o art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.004/90: "A formalização de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição financiadora".

³⁴⁶ Art. 1º, §1º, da Lei 7.433/85.

³⁴⁷ Resolução Bacen 3.005/02.

³⁴⁸ CSMSP. Apelação Cível nº 10.301-0/2. Data: 31/07/89. Localidade: São Paulo. Juiz Auxiliar: Kioitsi Chicuta. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁴⁹ As cédulas de crédito enquanto válidas por expressa determinação legal impedem a alienação e oneração do bem hipotecado sem anuência do credor cedular, conforme art. 59 do Decreto-lei 167/67 e art. 51 do Decreto-lei 413/69.

E como só o bem que se pode alienar pode ser dado em hipoteca³⁵⁰, o mutuário também não poderá hipotecar o imóvel sem anuência da instituição financeira enquanto onerado para garantir financiamento do SFH.

Essa restrição aplica-se mesmo aos financiamentos anteriores à Lei 8.004/90, devendo ser analisado o momento da nova transmissão pretendida, e não da transação imobiliária originária financiada pelo SFH: "Ao contrário do sustentado pelos recorrentes, a referida lei se aplica ao caso em questão, uma vez que, em que pese o financiamento ter sido pactuado anteriormente a sua promulgação, o contrato de transferência que se pretende registrar foi firmado posteriormente a sua edição"³⁵¹.

E a ausência da participação da instituição financeira impede o registro de alienação realizada de imóvel financiado pelo SFH: "O entendimento do Conselho Superior da Magistratura também é no sentido de ser obrigatória a anuência do credor para a transferência do imóvel hipotecado"³⁵².

Por outro lado, não estão sujeitas às restrições da Lei 8.004/90 as transmissões decorrentes de partilha em separação judicial ou divórcio: "Não se tratando de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de imóvel gravado com hipoteca em favor de instituição financeira integrante do Sistema Financeiro da Habitação, inaplicável o art. 1º e parágrafo único da Lei Federal 8.004, de 14.3.90, que modificou a norma contida no art. 292 da Lei de Registros Públicos. No caso, cuida-se de partilha em separação judicial, hipótese não contemplada no referido dispositivo de lei"³⁵³.

Também não estão sujeitas às restrições da Lei 8.004/90 as operações de financiamento do SFH realizadas diretamente com o construtor ou incorporador, e não com o mutuário do SFH, assim entendido o adquirente da casa própria:

“Nesse passo, segundo o disposto no artigo 1º, e parágrafo único, da Lei Federal 8.004, de 14 de março de 1990, os mutuários do SFH podem transferir a terceiros os direitos e deveres decorrentes do respectivo contrato, observado o disposto nessa referida lei, dependendo a alienação dos imóveis objeto desses financiamentos da interveniência da instituição financeira mutuante e

³⁵⁰ Art. 1.420 do CC.

³⁵¹ CSMSP. Apelação Cível nº 163-6/5. Data: 13/10/2004. Localidade: Campinas. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁵² CSMSP. Apelação Cível nº 163-6/5. Data: 13/10/2004. Localidade: Campinas. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁵³ CSMSP. Apelação cível nº 20.897-0/9. Data: 19/04/1995. Localidade: Cubatão. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

credora hipotecária, que, por sua vez, deverá comparecer no título de alienação, manifestando sua expressa concordância. (...)

O exame dos artigos seguintes desse diploma legal torna claro que esses mutuários são apenas aqueles que tenham adquirido imóvel, construído ou em construção, com financiamentos que utilizem recursos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação. Com estes não se confundem, pois, as construtoras ou incorporadoras, que, para os fins da lei, não são consideradas mutuárias sujeitas às regras próprias do Sistema Financeiro da Habitação. (...)

Na verdade não se cogita de transferência de financiamento quando a incorporadora aliena, pela primeira vez, o imóvel construído, ainda que, para a compra, valha-se o adquirente de financiamento vinculado ao SFH"³⁵⁴.

Porém, esse entendimento, mantido em Acórdão do Conselho Superior da Magistratura do ano de 2005³⁵⁵, não significa que não há nenhuma restrição à alienação. Não sendo aplicável a Lei 8.004/90, aplica-se então aos imóveis hipotecados ao SFH por construtoras as restrições do art. 292 da Lei 6.015/73, cuja comprovação de atendimento deve ser exigida pelo oficial: "É vedado aos Tabeliães e aos Oficiais de Registro de Imóveis, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar escritura ou escritos particulares autorizados por lei, que tenham por objeto imóvel hipotecado a entidade do Sistema Financeiro da Habitação, ou direitos a eles relativos, sem que conste dos mesmos, expressamente, a menção ao ônus real e ao credor, bem como a comunicação ao credor, necessariamente feita pelo alienante, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias".

Outra disposição protetiva específica do SFH é encontrada no art. 9º da Lei 5.741/71, que tipifica como crime: "invadir alguém, ou ocupar, com o fim de esbulho possessório, terreno ou unidade residencial construída ou em construção, objeto de financiamento do Sistema Financeiro da Habitação", norma que também tem como repercussão inviabilizar usucapião do imóvel: "uma vez prevista a invasão e ocupação de imóvel do Sistema Financeiro da Habitação como fato típico penal (Lei 5.741/71), descabe cogitar da configuração de usucapião"³⁵⁶.

³⁵⁴ CSMSP. Apelação cível nº 038170-0/8. Data: 9/5/1997. Localidade: Santo André. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁵⁵ CSMSP. Apelação cível nº 405-6/0. Data: 13/10/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁵⁶ STF. RE 191.603.6/MS. Min. Marco Aurélio *in* RT 758/129.

10. Alienação Fiduciária

A Lei 9.514/97, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, define-a como sendo: "o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel"³⁵⁷, acrescentando que "com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante³⁵⁸ possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel³⁵⁹".

Essa garantia, que se constitui mediante registro no competente Registro de Imóveis³⁶⁰ e pode "ser contratada por pessoa física ou jurídica, podendo ter como objeto imóvel concluído ou em construção, não sendo privativa das entidades que operam no Sistema de Financiamento Imobiliário - SFI"³⁶¹, também pode ser celebrada por instrumento particular, como estabelece o art. 38 da Lei 9.514/97: "os atos e contratos referidos nesta Lei ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública".

A alienação fiduciária tem se difundido com grande rapidez em decorrência das vantagens que gera ao credor.

O principal benefício ao credor fiduciário é a segurança que traz, haja vista que o imóvel é transferido em garantia ao credor, deixando de integrar o patrimônio do devedor e, por consequência, não pode ser penhorado para garantir outras dívidas do devedor fiduciante, devendo eventual penhora receber qualificação negativa do oficial: "o bem dado em garantia por alienação fiduciária constitui óbice à penhora na esfera trabalhista, pois, ao contrário do que consignou o Regional, o bem é de propriedade do terceiro embargante, no caso, o banco-recorrente, estranho à execução, já não pertencendo mais ao patrimônio da executada (devedora)"³⁶².

Também, à semelhança do que ocorre no SFH, o devedor está sujeito a restrições na transmissão de seus direitos, que só podem ser transmitidos com

³⁵⁷ Art. 22 da Lei 9.514/97.

³⁵⁸ Na alienação fiduciária o credor é denominado de fiduciário e o devedor de fiduciante.

³⁵⁹ Art. 23, parágrafo único, da Lei 9.514/97.

³⁶⁰ Art. 23 da Lei 9.514/97.

³⁶¹ Art. 22, parágrafo único, da Lei 9.514/97.

³⁶² TST. Acórdão RR-67177/2002-900-04. Data: 4/5/2005. Localidade: Rio Grande do Sul. Relator: José Pedro de Camargo.

anuência expressa do credor: "O fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações"³⁶³.

Outra vantagem da alienação fiduciária é a rapidez com que a dívida pode ser executada extrajudicialmente.

Em síntese, o procedimento de execução ocorre da seguinte forma: havendo inadimplemento e ultrapassado o prazo de carência³⁶⁴ o oficial intimará o devedor³⁶⁵ para pagar a dívida, pagamento que deverá ser realizado nas dependências do próprio Registro de Imóveis³⁶⁶, no prazo de 15 dias³⁶⁷. Sendo paga a dívida, o oficial fornecerá recibo ao devedor, entregará a importância recebida, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação, ao credor, no prazo máximo de 3 dias³⁶⁸, e arquivará o procedimento, cancelando a prenotação.

Não havendo o pagamento o oficial certificará o ocorrido e após o recolhimento do ITBI e eventual laudêmio³⁶⁹ averbará a consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário³⁷⁰. No prazo de 30 dias da consolidação o credor promoverá leilão público³⁷¹, mediante a publicação do aviso em jornal por três vezes, sob pena de nulidade³⁷², e no caso da praça ser negativa, novo leilão nos 15 dias seguintes³⁷³.

³⁶³ Art. 29 da Lei 9.514/97.

³⁶⁴ O prazo de carência de que trata o art. 26, § 2º, da Lei 9.514/97 é o prazo de inadimplemento estabelecido no contrato após o qual o Oficial de Registro de Imóveis expedirá intimação para o devedor purgar a mora.

³⁶⁵ Sendo o devedor casado, o seu cônjuge também deverá receber a intimação.

³⁶⁶ Art. 26, § 5º, da Lei 9.514/97.

³⁶⁷ Art. 26, § 1º, da Lei 9.514/97.

³⁶⁸ Art. 26, § 6º, da Lei 9.514/97.

³⁶⁹ Laudêmio é o valor devido ao senhorio direto quando da venda ou dação em pagamento do domínio útil de imóvel objeto de enfiteuse, também, denominado aforamento ou emprazamento (Art. 686 do Código Civil de 1916 e artigo 2038 do Código Civil de 2002).

³⁷⁰ Art. 26, § 7º, da Lei 9.514/97.

³⁷¹ Art. 27 da Lei 9.514/97.

³⁷² Art. 38 do Decreto 21.981/32, alterado pelo Decreto 22.427/33: "Art. 38. Nenhum leilão poderá ser realizado sem que haja, pelo menos, três publicações no mesmo jornal, devendo a última ser bem pormenorizada, sob pena de multa (...).

Parágrafo Único. Todos os anúncios de leilões deverão ser claros nas descrições dos respectivos efeitos, principalmente quando se tratar de bens imóveis ou de objetos que se caracterizem pelos nomes dos autores e fabricantes, tipos e números, sob pena de nulidade e de responsabilidade do leiloeiro."

³⁷³ Art. 27, § 1º, da Lei 9.514/97.

Sendo positiva a praça, o credor deverá alienar o imóvel ao arrematante por instrumento público ou particular, haja vista a inexistência de previsão na Lei 9.514/97 de registro da própria carta de arrematação. Não havendo arrematante no 2º leilão, o credor deverá comprovar perante o Registro de Imóveis a realização dos leilões e que forneceu quitação³⁷⁴ ao devedor³⁷⁵, o que será averbado no Livro 2, passando o imóvel então a integrar definitivamente o patrimônio do credor.

Embora sem previsão expressa na Lei 9.514/97, não é raro que no curso do procedimento de intimação de devedor fiduciante, credor e devedor componham-se quanto à dívida, tornando desnecessário o prosseguimento do procedimento. Antes da averbação da consolidação da propriedade, como ainda não foi lançado nenhum ato no Livro 2, basta a apresentação de requerimento do credor e o oficial poderá arquivar o procedimento, cancelando a correspondente prenotação. Após a averbação da consolidação da propriedade e o pagamento do ITBI e eventual laudêmio, porém, somente por novo título e novos registros, pago novamente o ITBI e eventual laudêmio, poderá regressar-se à situação anterior.

É possível, ainda, independentemente do procedimento de intimação e da realização de leilões públicos, que o devedor, com a anuência do credor, dê seu direito sobre o imóvel em pagamento da dívida³⁷⁶.

Importante ressaltar que os Tribunais do Estado de São Paulo têm reafirmado que "a previsão de leilão extrajudicial e consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor por ato do registrador imobiliário não afronta a Constituição Federal, já que o acesso ao Judiciário, a ampla defesa e o contraditório continuam assegurados ao devedor que se sentir prejudicado"³⁷⁷.

O cumprimento do contrato tem como consequência o cancelamento do registro da alienação fiduciária, o que será averbado no Livro 2 à vista do termo de quitação³⁷⁸, fornecido pelo credor fiduciário no prazo máximo de 30

³⁷⁴Interessante notar que a Lei nº 11.795/2008 em seu artigo 14, parágrafo 6º, prevê que no caso do oferecimento da alienação fiduciária em garantia a contrato de participação em grupo de consórcio, a dívida não fica quitada meramente com a execução da garantia, já que a responsabilidade do consorciado é integral, ou seja, a quitação fica condicionada ao pagamento da parte que ainda remanescer.

³⁷⁵ Art. 27, § 6º, da Lei 9.514/97.

³⁷⁶ Art. 26, § 8º, da Lei 9.514/97.

³⁷⁷ TJSP. Agravo de Instrumento nº 880.879-00/2. 5ª Câmara do Terceiro Grupo. Relator Desembargador Pereira Calças. Data do julgamento: 27/1/05. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>.

³⁷⁸ Art. 25, § 2º, da Lei 9.514/97.

dias da liquidação da dívida, sob pena de multa a ser paga ao devedor fiduciante no valor equivalente a 0,5% do valor do contrato, por mês ou fração de atraso³⁷⁹.

Quando da análise dos contratos de alienação fiduciária, além das regras a que se submetem todos os demais títulos, deve o oficial observar se foi cumprido o art. 24 da Lei 9.514/97, que elenca disposições que deverão constar obrigatoriamente do contrato, como, por exemplo, a especificação da dívida, indicação do procedimento de alienação do imóvel, o seu valor para fim de leilão, etc: "Contrato de alienação fiduciária em que não observados integralmente os requisitos previstos no artigo 24, e seus incisos, da Lei nº 9.514/97 - Registro inviável"³⁸⁰.

11. Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI

Além de ter instituído a alienação fiduciária de imóvel, a Lei 9.514/97 também criou o Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI, com a finalidade de promover o financiamento imobiliário em geral³⁸¹, criando diversos meios de fomentar o crédito imobiliário pela adoção de institutos como o regime fiduciário³⁸², os certificados de recebíveis imobiliários³⁸³ e a securitização de créditos³⁸⁴, visando aumentar a segurança e facilitar a circulação dos créditos imobiliários.

Os contratos decorrentes de operações do Sistema de Financiamento Imobiliário igualmente podem ser formalizados por instrumentos particulares³⁸⁵.

Importante observar que às operações imobiliárias de que trata a Lei 9.514/97 não se aplicam as disposições legais referentes ao Sistema Financeiro da Habitação, conforme expressamente determina o art. 39, I, da Lei 9.514/97.

Assim, seja nos instrumentos particulares de alienação fiduciária, ou nos decorrentes do SFI, não se aplica, por exemplo, a dispensa de reconhecimento

³⁷⁹ Art. 25, § 1º, da Lei 9.514/97.

³⁸⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 254-6/0. Data: 20/4/2005. Localidade: Avaré. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁸¹ Art. 1º da Lei 9.514/97.

³⁸² Art. 9º da Lei 9.514/97.

³⁸³ Art. 6º da Lei 9.514/97.

³⁸⁴ Art. 8º da Lei 9.514/97.

³⁸⁵ Art. 38 da Lei 9.514/97.

de firma existente no art. 221, II, da Lei 6.015/73, só aplicável às operações do SFH.

Isso, no entanto, não significa que em operações do SFH não se possa adotar garantias ou institutos próprios do SFI, sem descaracterizar o financiamento como sendo do SFH. Neste sentido sentença do Juiz Corregedor do Registro de Imóveis de Araraquara, ao sentenciar sobre contrato do SFH : "Sem muita dificuldade se enxerga que a este sistema foram acrescidos institutos do SFI, sem que possa se admitir uma desnaturação do contrato."³⁸⁶

Podem operar no SFI "caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional - CMN, outras entidades"³⁸⁷.

12. Compromisso de Compra e Venda

Igualmente dispensados da forma pública são os compromissos de compra e venda, estabelecendo o art. 1.417 do Código Civil que "mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel".

Logo após o início da vigência do Código Civil de 2002 houve discussão se na aplicação do art. 1.417 do CC deveriam ser verificados os valores estabelecidos no art. 108 do mesmo Código, ou seja, se ultrapassado o valor de 30 salários mínimos deveria ser exigida a forma pública, mesmo para os compromissos de compra e venda, tendo o Conselho Superior da Magistratura reafirmado a dispensa da forma pública independentemente do valor do imóvel: "Registro de contrato particular de compromisso de compra e venda com valor superior a trinta salários mínimos - Escritura pública que não se mostra essencial para a validade do negócio jurídico - Inteligência dos artigos 108 e 1.417, ambos do Código Civil - Recurso provido para autorizar o registro do título"³⁸⁸.

³⁸⁶ Corregedoria Permanente de Araraquara. Processo nº 605/05. Data: 13/7/2005. Localidade: Araraquara. Juiz Corregedor: João Battaus Neto. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁸⁷ Art. 2º da Lei 9.514/97.

³⁸⁸ CSMS. Apelação Cível nº 311-6/1. Data: 6/6/2005. Localidade: Serra Negra. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

O oficial, ao analisar o compromisso deve fazer a qualificação completa do título, exigindo todos os requisitos essenciais que exigiria na análise do título definitivo. É o que determina o art. 462 do Código Civil: "O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado".

Posteriormente, quando da apresentação de escritura de compra e venda cumprindo o compromisso de compra e venda não é necessário averbar o cancelamento do registro do compromisso, mas se por conveniência a averbação ocorrer, deverá ser lançada após o registro da escritura, não antes, e no Estado de São Paulo não serão devidos emolumentos pela averbação³⁸⁹.

Após o registro do compromisso de compra e venda constitui-se em favor do compromissário comprador um direito real que impede o registro posterior de títulos incompatíveis com ele: "É o título registrável o compromisso de compra e venda, com ou sem cláusula de arrependimento – no caso, com caráter irrevogável e irretratável –, que tenha por objeto imóvel não loteado e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou em prestações. Assim é o de fls. (art. 167, inc. I-9, da Lei de Registros Públicos). E foi registrado. Contrato dessa natureza, desde que inscrito (= registrado) a qualquer tempo, atribui ao compromissário direito real oponível a terceiros, e lhe confere o direito de adjudicação compulsória, nos termos da lei processual civil (art. 22 do Decreto-lei n.º 58, de 10.12.37, da Lei n.º 6.014, de 27.12.73, art. 1º). É o quanto basta para impedir um novo registro, agora de compra e venda do mesmo bem, a terceiro, que não o titular do direito real conferido pelo compromisso registrado"³⁹⁰.

Mas a alienação ou oneração a terceiros é possível desde que conte com a participação do compromissário comprador: "Este Conselho Superior da Magistratura (Ap. Cív. n 76.466.0/7-00, Comarca de Sorocaba, j. 22.2.01, v.u.), já decidiu: 'Ora, com o registro do compromisso de compra e venda nos moldes da do art. 167, I, nº 9, da Lei 6.015/73, esgotou a possibilidade do imóvel ser adquirido por terceiro, que não fosse a própria recorrente. Ou, excepcionalmente, por terceiro com expressa aquiescência da recorrente (compromissária compradora)'³⁹¹".

³⁸⁹ Item 122 do Capítulo XX das NSCGJSP.

³⁹⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 001234-0. Data: 11/12/1982. Localidade: Ribeirão Bonito. Relator: Bruno Affonso de André. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁹¹ CSMSP. Apelação Cível nº 079718-0/0. Data: 05/09/2001. Localidade: São Paulo. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Não obstante, deve o registrador observar se o instrumento trata efetivamente de um negócio preliminar, ou já definitivo. Isso porque, em muitas situações denomina-se de compromisso contrato que na realidade instrumenta compra e venda definitiva, apenas para evitar a forma pública e retardar o recolhimento do imposto de transmissão nos municípios que não exigem a antecipação de pagamento quando do compromisso.

Para evitar isso, não deve o oficial apenas restringir-se a verificar a denominação do contrato, haja vista que "A natureza e o tipo do contrato são fixados por seu conteúdo e não pela sua denominação ou rótulo"³⁹², devendo o oficial verificar o efetivo negócio praticado: "Insuficiente, para a caracterização de contrato preliminar, a mera menção a outorga de escritura pública de permuta, a ser lavrada quando do pagamento de dívida garantida por hipoteca e averbação de construção. Isso porque, como acima frisado, o objeto primeiro do contrato é a entrega das coisas, realizada naquele momento, e não declaração de vontade futura. Em termos diversos, o objeto da obrigação é típica prestação de coisa e não prestação de fato. Em resumo, do conteúdo do negócio, em especial das obrigações essenciais de dar assumidas pelas partes, conclui-se que o título contém verdadeiro contrato de permuta e não mero contrato promessa, ou preliminar. Se assim é, diante do valor do negócio atribuído pelas partes, a forma pública constituía elemento essencial de sua validade, a teor do que dispõe o artigo 134 do Código Civil³⁹³ (cfr. Apelação Cível n. 10.519-0/7 da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo)"³⁹⁴.

Ressalte-se que na verificação do contrato o fato do pagamento ser à vista por si só não o descaracteriza como contrato preliminar, haja vista estabelecer o art. 167, I, 9, da Lei 6.015/73, a possibilidade de registro de contratos de compromisso de compra e venda cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração.

O compromisso de compra e venda registrado gera direito tão potente que permite ao compromissário comprador promover incorporação de condomínio edilício³⁹⁵, desde que o contrato seja "irrevogável e irretratável, do qual conste cláusula de imissão na posse do imóvel, não haja estipulações impeditivas de sua alienação em frações ideais e inclua consentimento para de-

³⁹² CSMSp. Apelação Cível nº 037727-0/3. Data: 2/7/1997. Localidade: Itu. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁹³ Art. 108 do CC de 2002.

³⁹⁴ CSMSp. Apelação Cível nº 037727-0/3. Data: 2/7/1997. Localidade: Itu. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

³⁹⁵ Art. 31, a, da Lei 4.591/64.

molição e construção"³⁹⁶. O mesmo não se aplica aos loteamentos, que não podem ser realizados por promissário comprador, somente pelo proprietário³⁹⁷, ressalvada a hipótese de loteamento popular³⁹⁸.

No registro de promessa de compra e venda deve-se lembrar que embora o art. 1.417 do CC estabeleça que para a aquisição de direito real não pode ter sido pactuado arrependimento, o art. 167, I, 9, da Lei 6.015/73 permite o registro do compromisso de compra e venda com ou sem cláusula de arrependimento.

12.1. O compromisso de compra e venda e a falência

A obrigação da promessa de compra e venda de imóvel não é atingida com o pedido de falência do promissário vendedor, pois tais contratos não se submetem à Lei de Falências (Lei 11.101/05), tendo disciplina própria, conforme dispõe o artigo 119, VI da referida norma: “Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras: VI – na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a legislação respectiva”.

A antiga Lei de Falências (Decreto-Lei 7.661/45), que é posterior ao Decreto-Lei 58/37 e seu Decreto Regulamentador 3.079/38 e anterior à Lei de Incorporações (Lei 4.591/64) já tratava da matéria no art. 43 dispondo que os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser executados pelo síndico, se achar de conveniência para a massa.

A atual Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Lei nº 11.101/05), na mesma linha que a anterior, contempla que o contrato bilateral não se resolve com a falência, como aponta o art. 117:

“Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê.”

Sendo, pois, a promessa de compra e venda contrato bilateral, não se resolverá com o deferimento do processamento de recuperação judicial, sua posterior concessão ou com a sentença de quebra.

Dessa forma, competirá ao promitente comprador interpor judicialmente o administrador judicial para manifestar-se quanto ao cumprimento da obrigação contratada.

³⁹⁶ Art. 32, a, da Lei 4.591/64.

³⁹⁷ Art. 18, I, da Lei 6.766/79.

³⁹⁸ Art. 18, § 5º, da Lei 6.766/79.

Todavia, quanto ao promitente comprador de imóvel alcançado pela Lei de Incorporação, o legislador da falência deu-lhe tratamento diferenciado porque o bem imóvel não será objeto de arrecadação para formação da massa falida, dispondo o artigo 119, IX, da Lei 4.591/64.

“Art. 119

IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer.”

Com o advento da Lei 10.931/04, que introduziu o chamado patrimônio de afetação para as construtoras e incorporadoras de imóveis em construção, o patrimônio desses agentes foi separado, o ativo permanente propriamente dito, dos patrimônios circulantes de cada um dos empreendimentos objeto de construção. Assim, a insolvência do incorporador não atingirá o patrimônio de afetação, cabendo aos condôminos deliberar pela continuação da incorporação ou pela liquidação do patrimônio de afetação.

13. Cessão de direitos

A transmissão dos direitos do compromissário comprador se dá por cessão³⁹⁹, que igualmente pode ser formalizada por instrumento particular, haja vista transmitir direitos de contrato preliminar.

O mesmo não ocorre com a transmissão dos direitos do compromissário vendedor. Seja a transmissão para o compromissário comprador, seja para terceiro, nesta última hipótese apenas se com a expressa anuência do compromissário comprador, trata-se de transmissão de propriedade, que deve ter a forma pública: “É indubitável que o imóvel, embora comprometido, permanece, até o registro da escritura definitiva, em nome do promitente vendedor, ainda que esse direito de propriedade seja apenas residual, se limitando a um direito creditício e à possibilidade de rescisão no caso de inadimplência do promitente comprador” (R.T. 454/170)”⁴⁰⁰.

³⁹⁹ Art. 167, I, 9, da Lei 6.015/73.

⁴⁰⁰ CSMSp. Apelação Cível nº 002470-0/83. Data: 22/09/1983. Localidade: São Paulo. Relator: Humberto de Andrade Junqueira. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Nesse tópico, importante observar que eventual cessão de direitos creditórios dos compromissários vendedores transmitirá apenas o direito a receber o crédito decorrente do compromisso de compra e venda, não a propriedade, que não poderá ser transmitida pelos cessionários ao compromissário comprador: "Se o imóvel não foi partilhado aos herdeiros, mas tão somente os direitos creditórios resultantes do compromisso, por certo que os herdeiros não podem vender o que não lhes pertence"⁴⁰¹.

Hipótese totalmente diversa é a da cessão de créditos hipotecários que, por transmitir o direito real de hipoteca ao cessionário, salvo as expressas hipóteses de dispensa legal, como a decorrente de operação do SFH, por exemplo, deve ser formalizada por escritura pública: "Ora, uma vez que as cessões levadas ao Registro de Imóveis são, na verdade, como nelas está expresso, cessões de crédito hipotecário e dado o seu valor, somente mediante escritura pública podiam ser formalizadas. Nenhuma ressalva consta dos instrumentos particulares no sentido de que os direitos acessórios ficavam excluídos da cessão, impondo-se, por isso mesmo, a aplicação integral do que dispõe o art. 1.066⁴⁰², do Código Civil"⁴⁰³.

Quando do lançamento de compromissos de compra e venda e cessões no Livro 2 a regra é de que o ato deve ingressar por registro⁴⁰⁴, porém quando se referirem a lotes de parcelamento formalizado antes da vigência da Lei 6.015/73, os contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas de cessão serão lançados por averbação⁴⁰⁵.

14. Loteamentos populares

Outra hipótese de dispensa de forma pública na transmissão de bem imóvel é a encontrada na Lei de Parcelamento do Solo, que estabelece que: "os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação"⁴⁰⁶.

⁴⁰¹ CSMSP. Apelação Cível nº 002470-0/83. Data: 22/09/1983. Localidade: São Paulo. Relator: Humberto de Andrade Junqueira. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁰² Art. 287 do CC de 2002.

⁴⁰³ CSMSP. Ag. Pet. 204731/72. Data: 13/3/1972. Localidade: Santo André. Relator: José Carlos Ferreira de Oliveira. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁰⁴ Art. 167, I, 9 da lei 6.015/73.

⁴⁰⁵ Art. 167, II, 3 da lei 6.015/73.

⁴⁰⁶ Art. 26, § 6º, da Lei 6.766/79.

Atualmente está pacificado o entendimento de que essa regra excepcional aplica-se apenas aos loteamentos populares: "O texto do § 6º do artigo 26 da Lei 6.766/79, acrescido pela Lei 9.785/99, necessita ser interpretado restritivamente, ante a regra geral de que a instituição ou a transmissão de direito real incidente sobre imóvel requer instrumentalização pública. O legislador construiu um sistema destinado a dotar de absoluta praticidade a realização de empreendimentos habitacionais e de salvaguardar a posição dos adquirentes de lotes em 'parcelamentos populares'. Foram introduzidos, numa única oportunidade, os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do aludido artigo 26, os quais merecem apreciação conjunta e sempre observada a consonância entre cada uma das novas normas positivadas estatuídas. Assim, 'os compromissos de compra e venda, as cessões e promessas de cessão' referidas no texto legal, para que sejam admitidos como 'título para registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação', devem se referir a imóveis provenientes de parcelamento populares e não a qualquer unidade imobiliária, proveniente de qualquer parcelamento"⁴⁰⁷.

15. Programa de Arrendamento Residencial – PAR

Da mesma forma que a Lei 9.514/97 trouxe para a área imobiliária a alienação fiduciária, uma garantia que até então era utilizada com grande sucesso, mas apenas no financiamento de bens móveis, a Lei 10.188/01, que criou o Programa de Arrendamento Residencial, embora de forma mais restritiva, procurou incorporar instituto similar ao *leasing* ou arrendamento mercantil, até então utilizado apenas para bens móveis, à gama existente de operações imobiliárias.

O arrendamento residencial é a operação "que tenha por objeto o arrendamento com opção de compra de bens imóveis adquiridos para esse fim específico"⁴⁰⁸, para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da população de baixa renda⁴⁰⁹.

Esse instituto difere da locação por nele haver opção de compra ao final do período de arrendamento, somente quando o arrendatário adquirirá a propriedade do imóvel, detendo até então a mera posse, motivo pelo qual "na hipótese de inadimplemento no arrendamento, findo o prazo da notificação ou interpelação, sem pagamento dos encargos em atraso, fica configurado o

⁴⁰⁷ CSMSp. Apelação Cível nº 098984-0/1. Data: 11/4/2003. Localidade: São Paulo (2º SRI). Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁰⁸ Art. 6º da Lei 10.188/01.

⁴⁰⁹ Art. 1º da Lei 10.188/01.

esbulho possessório que autoriza o arrendador a propor a competente ação de reintegração de posse"⁴¹⁰.

Ou seja, diferentemente do que ocorre em outras formas de aquisição de imóveis a prazo, em que o adquirente é proprietário do imóvel, que é onerado para garantir a dívida, no arrendamento residencial o arrendatário tem apenas a posse, o que, em eventual inadimplemento, simplifica o procedimento de retomada do imóvel pelo credor e afasta a aplicação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, que declara nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas no caso de rescisão e retomada do imóvel por inadimplemento nos contratos de compra e venda de imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia.

O arrendamento residencial, contudo, é de aplicação limitada, sendo a operacionalização do programa feita pela Caixa Econômica Federal, sob a gestão do Ministério das Cidades⁴¹¹, e tendo como objetivo atender a "necessidade de moradia da população de baixa renda"⁴¹².

Todos os bens adquiridos no âmbito do programa de arrendamento residencial compõem um fundo financeiro⁴¹³, denominado de fundo de arrendamento residencial, e como a Caixa Econômica Federal apenas operacionaliza o programa de arrendamento, os bens adquiridos para o fundo não integram o patrimônio da CEF, ficando apenas sob sua propriedade fiduciária⁴¹⁴, motivo pelo qual esses bens: não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da CEF; não compõem a lista de bens e direitos da CEF, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial; não podem ser dados em garantia de débito de operação da CEF; não são passíveis de execução por quaisquer credores da CEF, por mais privilegiados que possam ser; e não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre os imóveis, restrições essas que devem ser averbadas após o registro da aquisição dos imóveis do programa⁴¹⁵. Igualmente, por não constituir patrimônio da CEF, a alienação dos bens independe de apresentação de certidões negativas quanto a contribuições sociais⁴¹⁶.

E a Lei 10.188/01 também trouxe novas hipóteses de dispensa de escritura pública, estabelecendo que "o contrato de aquisição de imóveis pelo arren-

⁴¹⁰ Art. 9º da Lei 10.188/01.

⁴¹¹ Art. 1º, § 1º, da Lei 10.188/01.

⁴¹² Art. 1º da Lei 10.188/01.

⁴¹³ Art. 2º da lei 10.188/01.

⁴¹⁴ Art. 2º da Lei 10.188/01.

⁴¹⁵ Art. 2º, § 5º, da Lei 10.188/01.

⁴¹⁶ Art. 2º, § 6º, da Lei 10.188/01.

dador, as cessões de posse e as promessas de cessão, bem como o contrato de transferência do direito de propriedade ou do domínio útil ao arrendatário, serão celebrados por instrumento particular com força de escritura pública e registrados em cartório de Registro de Imóveis competente"⁴¹⁷.

Assim, não apenas os títulos de transmissão ao arrendatário e posterior cessão, mas até as aquisições de imóveis que serão incorporados ao fundo de arrendamento são dispensadas da forma pública, além da dispensa do cumprimento das disposições da lei de licitação⁴¹⁸.

Sobre o programa de arrendamento residencial, o art. 35 da Lei 10.150/01 determinou a redução de 50% dos emolumentos de todos os atos praticados no Registro de Imóveis relacionados com o Programa, dispositivo que não tem sido aplicado em decorrência de sua inconstitucionalidade⁴¹⁹, por violação ao art. 151, III, da Constituição Federal, sendo, no entanto, aplicado aos imóveis adquiridos pelo fundo a isenção parcial estabelecida na lei estadual de emolumentos⁴²⁰, e nos demais atos em favor dos arrendatários a redução específica da mesma lei⁴²¹.

A Lei 10.150/00 também estendeu aos entes públicos estaduais e municipais, desde que obtidas as autorizações legislativas pertinentes, a possibilidade de alocarem recursos próprios em empreendimentos habitacionais específicos enquadrados no Programa de Arrendamento Residencial⁴²².

Em 12 de fevereiro de 2007 foi publicada a Lei nº 11.474 que alterou algumas disposições da referida Lei 10.188/01, dentre elas, o artigo 8º do diploma, que em seus parágrafos trouxe a inalienabilidade nos contratos de compra e venda referente ao imóvel objeto de arrendamento residencial, ainda que o pagamento integral seja feito à vista, mediante cláusula no contrato que impede o adquirente, no prazo de 24 meses, vender, prometer vender ou ceder seus direitos sobre o imóvel alienado. O referido prazo pode, excepcionalmente, ser reduzido conforme critério a ser definido pelo Ministério das Cidades, nos casos de arrendamento com período superior à metade do prazo final regulamentado.

⁴¹⁷ Art. 8º da Lei 10.188/01.

⁴¹⁸ Art. 4º, parágrafo único, da Lei 10.188/01.

⁴¹⁹ CGJSP. Protocolado 49.016/2004. Data: 10/3/2005. Localidade: Araçatuba. Relator: José Marcelo Tossi Silva. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴²⁰ Art. 8º da Lei Estadual n.º 11.331/02.

⁴²¹ Item 1.1 da Tabela II da Lei Estadual n.º 11.331/02.

⁴²² Art. 36 da Lei 10.150/00.

15.1. Arrendamento Imobiliário Especial

O arrendamento imobiliário especial com opção de compra de imóvel é definido como "operação em que o arrendatário se compromete a pagar ao arrendador, mensalmente e por prazo determinado, contraprestações pela ocupação do imóvel com direito ao exercício de opção de compra no final do prazo contratado"⁴²³. Esse arrendamento só é autorizado para "instituições financeiras captadoras de depósitos à vista e que operem crédito imobiliário"⁴²⁴ e apenas para "imóveis que tenham arrematado, adjudicado ou recebido em dação em pagamento por força de financiamentos habitacionais por elas concedidos"⁴²⁵.

A formalização desses contratos poderá ser realizada por instrumento particular, com força de escritura pública, como estabelece o art. 39, parágrafo único, da Lei 10.150/00: "Os contratos celebrados no âmbito do programa de arrendamento imobiliário especial com opção de compra, incluindo os de dação em pagamento de imóveis destinados ao arrendamento, serão formalizados por instrumento particular com força de escritura pública".

O contrato de arrendamento especial, para ser registrado, deve conter todas as cláusulas previstas no art. 39 da Lei 10.150/00.

Conforme estabelece o art. 40 da Lei 10.150/00, se o arrendatário não pagar três parcelas mensais, fica constituído em mora de pleno direito e configurado o esbulho possessório que autoriza o arrendador a promover a reintegração de posse.

16. Patrimônio da União

Embora não se trate de hipótese de instrumento particular, não se pode deixar de abordar a dispensa de escritura pública nas operações imobiliárias realizadas pela União Federal.

Estabelece o artigo 13, VI, do Decreto-lei 147/67, com a redação da Lei 5.421/68, que compete às Procuradorias da Fazenda Nacional: "fazer lavrar, no livro próprio da repartição competente, os atos relativos à aquisição, alienação, cessão, aforamento, locação, entrega e outros concernentes a imóveis do patrimônio da União, que terão força de escritura pública".

Atualmente os contratos são lavrados em livro da Gerência Regional do Patrimônio da União do Estado em que localizado o imóvel, tendo obrigatori-

⁴²³ Art. 38, § 1º, da Lei 10.150/00.

⁴²⁴ Art. 38 da Lei 10.150/00.

⁴²⁵ Art. 38 da Lei 10.150/00.

amente a participação de Procurador da Fazenda Nacional representando a União, e devendo atender, com exceção da forma, todos os requisitos exigidos dos demais títulos apresentados a registro, devendo, inclusive, ser apresentada a DOI⁴²⁶.

Os Estados e Municípios não têm o mesmo benefício, devendo as transmissões de direitos reais envolvendo imóveis ser formalizadas por escrituras públicas, salvo com relação às expressas exceções legais, como, por exemplo, os contratos de concessão de direito real de uso⁴²⁷, os títulos de concessão de uso especial para fins de moradia⁴²⁸, os títulos concedidos em regularização fundiária previstos na legislação que instituiu o “Programa Minha Casa Minha Vida”⁴²⁹. A necessidade de escritura pública como regra para os demais entes públicos é reforçada no art. 60 da Lei de Licitações⁴³⁰: “Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem”.

17. Cartas de arrematação

Diferentemente do que ocorre na alienação fiduciária, o Decreto-lei 70/66, ao tratar da execução extrajudicial de dívida hipotecária, estabelece que a carta de arrematação será o título de transmissão da propriedade.

Estabelece o art. 37 do Decreto-lei 70/66 que uma vez efetivada a alienação do imóvel será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro oficial, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas⁴³¹, documento que servirá como título para a transcrição no Registro Geral de Imóveis. “O devedor, se estiver presente ao público leilão, deverá assinar a carta de arrematação que, em caso contrário, conterà necessariamente a constatação de sua ausência ou de sua recusa em subscrevê-la”⁴³².

⁴²⁶ A DOI é tratada no Capítulo Aspectos Fiscais.

⁴²⁷ Art. 48, I, da Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade.

⁴²⁸ Art. 6º, § 4º, da MP 2.220/01.

⁴²⁹ Lei 10.977/09.

⁴³⁰ Lei 8.666/93.

⁴³¹ Mais restritivo que a regra geral, que permite ao menor relativamente incapaz ser testemunha: art. 228, I, CC.

⁴³² Art. 37, § 1º, Decreto-lei 70/66.

Não se pode esquecer que a execução extrajudicial prevista no Decreto-lei 70/66 não é exclusiva do SFH⁴³³, razão pela qual benefícios aplicáveis apenas a operações do SFH não podem ser indiscriminadamente estendidos a essas cartas de arrematação, como, por exemplo, a dispensa de reconhecimento de firma⁴³⁴ e a redução de emolumentos⁴³⁵.

De forma diversa, nos casos de incorporação por administração⁴³⁶, embora seja possível levar à praça a unidade do condômino inadimplente, desde que cumprido o disposto no art. 63 da Lei de Incorporações, a carta de arrematação não é o título que possa ser registrado, devendo, após o leilão, ser outorgada escritura ao arrematante, que será o título que será apresentado no Registro de Imóveis, juntamente com a comprovação do cumprimento do disposto no referido artigo e da regular constituição da Comissão de Representantes, com seu arquivamento no Registro de Títulos e Documentos⁴³⁷: " Com efeito, é insuficiente a extração de mera carta ou auto de arrematação para a transferência da propriedade da cota de terreno e a correspondente parte construída do condômino inadimplente para o condomínio. O parágrafo 5º do artigo 63 da Lei n. 4.591/64 dispõe que para os fins das medidas estipuladas na norma legal, a Comissão de Representantes fica investida de mandato irrevogável, com poderes necessários para, em nome do condômino inadimplente, efetuar transações, inclusive fixar preço e condições, bem como outorgar escrituras e contratos. Como se vê, a lei deixou clara a forma pela qual deverá reduzir-se a alienação: escritura e contrato"⁴³⁸.

18. Imóveis na Constituição e Alteração de Pessoas Jurídicas

Visando facilitar a constituição e alteração do capital de sociedades, bem como simplificar as operações decorrentes das transformações ocasionadas pela fusão, cisão e incorporação de pessoas jurídicas, a legislação criou várias hipóteses de transmissão de bens imóveis por instrumentos particulares.

18.1. Conferência de Bens

Fábio Ulhoa Coelho explica o que vem a ser a integralização do capital social:

⁴³³ Art. 30, II, do Decreto-lei 70/66.

⁴³⁴ Art. 221, II, da Lei 6.015/73.

⁴³⁵ Item 2.2 das Notas Explicativas da Tabela II da Lei Estadual 11.331/02.

⁴³⁶ Art. 58 da Lei 4.591/64.

⁴³⁷ Art. 50, § 1º, da Lei 4.591/64.

⁴³⁸ CSMSP. Apelação Cível nº 336-6/5. Data: 23/9/2005. Localidade: Ubatuba. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

“A principal obrigação que o sócio contrai ao assinar o contrato social é a de investir, na sociedade, determinados recursos, geralmente referidos em moeda. Se duas pessoas contratam a formação de uma sociedade, o ponto central do acordo de vontades por elas expresso é a de organizarem juntas a empresa. Cada contratante assume, perante o outro, a obrigação de disponibilizar, de seu patrimônio, os recursos que considerar necessários ao negócio que vão explorar em parceria. Quer dizer, ele tem de cumprir o compromisso, contraído ao assinar o contrato social, de entregar para a sociedade, então constituída, o dinheiro, bem ou crédito, no montante contratado com os demais sócios. Na linguagem própria do direito societário, cada sócio tem o dever de *integralizar* a quota do capital social que *subscreeveu*”⁴³⁹.

Denomina-se conferência de bens a entrega de bens à sociedade para a integralização ou aumento do capital: "Conferência de bens, pois, é espécie de alienação que tem por fim a transferência de domínio do sócio à sociedade para formação ou aumento do capital social. Nas palavras de Aguiar Vallim, 'tanto poderá assemelhar-se a uma permuta (troca do imóvel pelas cotas subscritas) como a uma *datio in solutum* (dação do imóvel em pagamento das cotas subscritas)' - (Direito imobiliário brasileiro: doutrina e prática, Ed. RT, 2ª edição, p. 144)"⁴⁴⁰.

A conferência de bens, quando envolve imóveis ou direitos a eles relativos, só ocorre com o registro do título no Registro de Imóveis⁴⁴¹, estabelecendo o art. 64 da Lei 8.934/94 que "a certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis, passada pelas juntas comerciais em que foram arquivados, será o documento hábil para a transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital social".

Dessa forma, é admitido para registro as certidões ou o original dos instrumentos particulares de constituição ou alteração contratual arquivados no órgão de registro da sociedade, sendo que, apesar da exceção quanto à forma, o instrumento deverá atender os mesmos requisitos a que se submetem as escrituras públicas, tanto quanto à qualificação das partes e descrição dos imóveis, como quanto à apresentação das declarações, certidões e documentos obrigatórios às transmissões de bens imóveis.

⁴³⁹ Op. cit., p. 396.

⁴⁴⁰ CSMSp. Apelação Cível nº 538-6/7. Data: 23/3/2006. Localidade: Campinas. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J. em 30/06/2006.

⁴⁴¹ Art. 1.227 e 1.245 do CC.

Esses títulos, no entanto, não estão sujeitos à exigência de reconhecimento de firma dos subscritores⁴⁴², em decorrência do disposto no *caput* do art. 63 da Lei 8.934/94, que determina que: "Os atos levados a arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma, exceto quando se tratar de procuração".

A comprovação de arquivamento no órgão de registro societário deverá ser sempre exigida, o que é verificado pelo lançamento expresso do número de registro no próprio documento. Vias do contrato que não tenham a comprovação de arquivamento devem ser recusadas. O documento deve ser primeiro arquivado no órgão de registro de sociedades e somente após ser apresentado ao Registro de Imóveis.

No caso de apresentação de certidão, só pode ser aceita a certidão de inteiro teor. A denominada ficha cadastral, também conhecida como breve relato, quando emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo é expedida como um simples impresso, sem nenhuma autenticação e contendo em seu corpo a expressa advertência de que "não tem valor jurídico de certidão", não podendo, por isso, ser utilizada para nenhum propósito no registro de imóveis, já a certidão simplificada, embora seja uma certidão, apresenta, como o próprio nome indica, apenas alguns dados, sendo também inábil para permitir o registro de transmissão de imóvel.

O art. 64 da Lei 8.934/94, por criar exceção à regra geral de que a transmissão de imóveis ocorre por escritura pública, tem sido interpretado restritivamente, aplicando-se somente às transmissões para "formação ou aumento do capital social", como expressamente consignado no final do art. 64. Assim, no caso de diminuição do capital social ou extinção da sociedade, com a entrega de imóveis aos sócios, é necessária a formalização por escritura pública: "Admite-se a utilização de instrumento particular com o fim de materializar a conferência de bens pelos sócios para integralizar o capital social, mas tal exceção, derivada do texto do artigo 64 da Lei Federal 8.934/94, deve ser interpretada de modo restritivo. Tal dispositivo legal permite a utilização de certidão expedida pela Junta Comercial, extraída dos atos constitutivos ou de sua alteração, como título hábil para, perante o registrador, possibilitar a alienação de direitos reais incidentes sobre imóveis, mas sempre, invariavelmente, para a composição ou o aumento do capital social e nunca, para sua redução ou dissolução"⁴⁴³.

⁴⁴² Art. 221, II, da Lei 6.015/73.

⁴⁴³ CSMSP. Apelação Cível nº 063971-0/1. Data: 03/02/2000. Localidade: São Paulo. Relator: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Também deve ser observada a data de arquivamento do documento no registro societário, haja vista que, no caso de sociedade limitada, a exceção à regra de que a transmissão de imóvel se opera por escritura pública não se aplica à conferência de bens ocorrida antes da Lei 8.934/94, mesmo que a certidão da constituição ou alteração da sociedade em que realizada a conferência seja apresentada no registro de imóveis somente agora: "Consigno, também, que, diante da data em que a alteração do contrato social foi submetida à Junta Comercial do Estado de São Paulo, como órgão do registro público, constata-se, de antemão, a inaplicabilidade do artigo 64 da Lei 8.934/64, que confere, às certidões emitidas pelas Juntas Comerciais, o caráter de título, quando relativas a atos constitutivos ou alterações contratuais que resguardem a conferência de bens destinados a integralização do capital social"⁴⁴⁴.

A Lei 8.934/94 equiparou a outros tipos societários a possibilidade de integralização do capital social através da transferência de imóveis por instrumento particular, conforme já previa o artigo 89 da Lei 6.404/76 somente para as sociedades anônimas: "A incorporação de imóveis para formação do capital social não exige escritura pública."

Mas a que tipos societários se aplica a regra do art. 64 da Lei 8.934/94 é uma questão ainda polêmica.

Na vigência do Código Civil de 1916 as sociedades classificavam-se em sociedades civis e sociedades comerciais, sendo que o fator que as diferenciava era o objeto social, ou seja, se havia a prática de atos de comércio a sociedade era considerada comercial.

O artigo 64 da Lei 8.934/94 fala em sociedades mercantis, pois na época em que foi elaborada tal norma vigia a antiga classificação das sociedades em mercantis e civis, o que levou ao entendimento de que não seria possível o uso desse dispositivo para a formação ou aumento de capital de sociedades civis: "Em se tratando de sociedade civil, inaplicável o disposto no art. 64 da Lei nº 8.934/94, não há como julgar viável o ato perseguido"⁴⁴⁵.

No entanto, o Código Civil de 2002 trouxe alteração quanto às sociedades, classificando-as em sociedades empresárias e simples, sendo que nas primeiras há exploração de atividade econômica de produção ou circulação de bens e serviços, já nas sociedades consideradas "não empresárias", apesar de existir a exploração de uma atividade econômica, esta não é realizada de forma

⁴⁴⁴ CSMSp. Apelação Cível nº 092676-0/2. Data: 18/10/2002. Localidade: São Paulo. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁴⁵ CSMSp. Apelação Cível nº 077128-0/2. Data: 14/08/2001. Localidade: São Paulo. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

organizada, ou seja, não há conjugação de fatores de produção (capital, trabalho, tecnologia e matéria prima), sendo a atividade econômica exercida pelos próprios sócios, ainda que tenham funcionários, existindo, assim, uma vinculação entre eles e a atividade. Dessa forma, o fator diferenciador entre sociedade empresária e sociedade simples é a sua estrutura, o modo de atuação dos sócios.

A sociedade empresária é registrada na Junta Comercial, já as sociedades simples têm seus atos arquivados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Além dessas alterações, que não permitem mais se restringir o dispositivo legal às sociedades mercantis, que não mais existem, e não guardam correlação exata com as atuais sociedades empresárias, o art. 1.150 do Código Civil estabelece que no caso da sociedade simples adotar um tipo de sociedade empresária, como, por exemplo, a sociedade simples limitada, o Registro Civil de Pessoa Jurídica deve obedecer as normas fixadas para o registro de sociedades empresárias, ou seja, o Código Civil determina uma equiparação de tratamento para essas sociedades, o que parece incompatível com a manutenção do tratamento diferenciado que ocorria na vigência do Código Civil anterior.

18.2. Fusão, Cisão e Incorporação

Nos casos de fusão, cisão e incorporação de sociedades anônimas, o título para o lançamento das transmissões de imóveis no Registro de Imóveis é a certidão do registro das atas, conforme estabelece o art. 234 da Lei das Sociedades Anônimas: "a certidão, passada pelo registro do comércio, da incorporação, fusão ou cisão, é documento hábil para a averbação, nos registros públicos competentes, da sucessão, decorrente da operação, em bens, direitos e obrigações".

Mas essa dispensa não se restringe às sociedades anônimas: "De qualquer maneira, entende-se que o motivo principal de se reputar possível a cisão de sociedade por cotas independentemente de escritura pública, mesmo envolvendo imóvel, esteja na própria natureza do instituto. Na verdade, a cisão consubstancia a transferência, não de bens específicos, em si considerados, mas sim de uma universalidade de direitos e obrigações. Não se trata de negócio especificamente concernente à transferência de bem imóvel, como o são a venda e compra, a permuta, e assim por diante. Cuida-se mesmo de técnica de reorganização societária. Isto ficou muito claro no parecer proferido, sobre o assunto, no Processo CG n. 254/93, frise-se, a que se conferiu efeito normati-

vo, permitindo a averbação de incorporação de sociedade por cotas, sem escritura pública"⁴⁴⁶.

Conforme também estabelece o art. 234 da Lei das S/A, essas transmissões ingressam no fôlio real por averbação, e não por registro, violando a regra geral de que a transmissão de direitos reais se opera por registro⁴⁴⁷.

Aqui importante frisar que o que ingressa por averbação no Registro de Imóveis é a incorporação de sociedades, não a incorporação de bens à sociedade, que é denominada de conferência, e ingressa na matrícula por registro, conforme estabelecem os arts. 98, §2º, e 234 da Lei 6.404/76: "Segundo tais dispositivos, temos: a) incorporação de sociedade – averbação b) incorporação de bens – registro. Desta Corte colho os seguintes precedentes: Sociedade Anônima. Capital. Incorporação de bens. A transferência do domínio de imóvel faz-se com o registro e não com a averbação. O disposto no artigo 234 da Lei das Sociedades por Ações aplica-se à incorporação de sociedades, em que há sucessão, e não à incorporação de bens ao capital. (...) (RESP 96.713/MG, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15.06.1999, DJ 29.05.2000, p. 147)"⁴⁴⁸.

19. Locação

Os instrumentos particulares de locação podem gerar vários atos no Registro de Imóveis, tendo assim a CGJSP sintetizado as possibilidades existentes: "O contrato de locação pode, no sistema registrário vigente, ser objeto de ato de averbação (para fim de assegurar o exercício do direito de preferência ou para dar publicidade da caução dada em garantia ao cumprimento do contrato de locação - artigo 167, II, nº 16, da Lei nº 6.015/73) ou de registro (para publicidade da cláusula de vigência em caso de alienação - artigo 167, I, nº 3, *idem*)"⁴⁴⁹.

⁴⁴⁶ CGJSP. Decisão 001779/95. Data: 4/9/1995. Localidade: São Paulo. Juiz Auxiliar da Corregedoria: Cláudio Luiz Bueno De Godoy. Corregedor Geral da Justiça: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁴⁷ A distinção de registro e averbação é tratada no Capítulo Princípios, item Taxatividade.

⁴⁴⁸ STJ. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 18.698 - RS (2004/0101097-0). Data do julgamento: 17/02/2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra Eliana Calmon.

⁴⁴⁹ Processo 079729-0/0. Data: 09/08/2001. Despacho do Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça, em 26 de junho 2001. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Mas antes de se analisar cada uma dessas hipóteses deve-se tecer algumas observações aplicáveis aos contratos de locação.

19.1. Vênia conjugal

Inicialmente deve-se observar que não é necessário que todos os proprietários compareçam no contrato como locadores, estabelecendo o art. 169, III, da Lei 6.015/73 que basta "a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador".

Porém, o cônjuge do locador deve anuir quando a locação for por período igual ou superior a 10 anos, como determina o art. 3º da Lei 8.245/91: "O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a dez anos". Ausente a anuência, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente⁴⁵⁰.

Embora o prazo pareça longo, é comum que os contratos de locação de imóveis para a instalação de agências bancárias tenham o prazo de 10 anos ou mais, situações em que deve ser exigida a anuência do cônjuge do locador.

19.2. Proprietário como anuente

Também, como o art. 169, III, da Lei 6.015/73 exige que um dos proprietários figure como locador, não é possível o registro ou averbação de contrato em que terceiro figure como locador, mesmo com a anuência expressa do proprietário: "O requisito de que um dos titulares do domínio participe da avença na qualidade de locador, embora não obste a formalização de contrato de locação válido, mostra-se como circunstância relevante para o registro do instrumento, revelando a pertinência da recusa expressa pelo oficial registrador"⁴⁵¹.

19.3. Registro em Títulos e Documentos

Deve-se observar que o contrato de locação apenas ingressa no Registro de Imóveis para assegurar um dos direitos indicados (caução, preferência e vigência). Para produzir efeitos em relação a terceiros com outras finalidades, o contrato deve ser apresentado no Registro de Títulos e Documentos⁴⁵².

⁴⁵⁰ Art. 3º, parágrafo único, da Lei 8.245/91.

⁴⁵¹ CSMSp. Apelação Cível nº 072802-0/2. Data: 21/11/2000. Localidade: Indaiatuba. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁵² Art. 129, I, da Lei 6.015/73.

19.4. Contratos de sublocação

Mas não é apenas o contrato de locação que pode ser lançado no Livro 2. O contrato de sublocação também pode ser averbado ou registrado, desde que o contrato de locação tenha sido previamente registrado ou averbado, para ser preservada a continuidade, e a sublocação seja consentida: “A sublocação nada mais é do que uma nova locação, em que o senhorio é o locatário, diante do sublocatário. (...) Não há, por isso, falar em falta de previsão legal para ingresso da sublocação no registro predial. Lembre-se, mais, que o artigo 14 da Lei n. 8.245/91 dispõe expressamente que ‘aplicam-se às sublocações, no que couber, as disposições relativas às locações’. Além dos direitos assegurados expressamente pela Lei do Inquilinato, relativos à preferência (art. 30) e renovação (art. 51), não repugna tenha também o sublocatário direito à vigência do contrato no caso de alienação do prédio. É bom ficar claro que o registro do contrato de sublocação estará sempre subordinado a dois requisitos, a saber: a) que a sublocação seja consentida e b) que haja prévio registro do contrato de locação”⁴⁵³.

19.5. Imóvel anteriormente locado a terceiro

Se na matrícula do imóvel já há o lançamento de contrato de locação não é possível o ingresso de novo contrato de locação para o mesmo imóvel sem que o lançamento anterior seja previamente cancelado. Nem mesmo o término do prazo de locação do contrato anterior permite o registro subsequente, haja vista que a Lei 8.245/91 estabelece diversas hipóteses de prorrogação automática dos contratos de locação⁴⁵⁴: “A vigência da locação pré-existente e já registrada exclui a possibilidade de sobrevir registro de outra locação, feita a terceira pessoa que não o primitivo locatário. E o registro da locação há de produzir seus efeitos próprios até que seja cancelado com fulcro em um dos títulos formais de que cuida o artigo 250 da LRP: nem mesmo o só decurso do prazo determinado porventura ajustado na locação justifica ter-se por inválido ou carente de efeitos aquele registro. Mesmo que – para argumentar – assim não fora, a emergência do registro de duas locações do mesmo prédio a pessoas distintas faria gerar publicidade equívoca, frustrando os objetivos colimados pela lei ao admitir o registro da locação”⁴⁵⁵.

⁴⁵³ CSMSP. Apelação Cível nº 035699-0/0. Data: 14/3/1997. Localidade: São Paulo. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁵⁴ Arts. 46, § 1º, 47, 51 e 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91.

⁴⁵⁵ CSMSP. Apelação Cível nº 010854-0/5. Data: 15/12/1989. Localidade: São Paulo. Relator: Milton Evaristo dos Santos. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

19.6. Contrato de locação com prazo vencido

A apresentação de contrato de locação após vencido o seu período de vigência não impede o seu lançamento no Livro 2: "É possível o registro de contrato de locação com prazo já vencido na presunção de que possa estar vigorando por prazo indeterminado"⁴⁵⁶.

19.7. Registro de locação após a alienação do imóvel

Se o imóvel já foi alienado a terceiro, não pode ser registrado contrato de locação celebrado com o antigo proprietário, por violação ao princípio da continuidade, mesmo que o contrato tenha sido firmado antes da alienação: "Se o imóvel locado não estiver inscrito como sendo de propriedade do locador, porque alienado, efetivamente inviável recepcionar para registro contrato de locação que tenha por objeto o mesmo prédio. Na verdade, se o contrário fosse admitido, haveria inegável maltrato da continuidade, que exige rigoroso encadeamento em ordem descendente dos direitos inscritos, de sorte que o ingresso do título está sujeito à perfeita ligação entre aquele que nele figura e o titular do registro-suporte. (...) De outro lado não há falar que a recusa em registrar o contrato de locação ofenderia o direito adquirido do locatário, porque em vigor a locação. Para a vigência desta irrelevante o registro do contrato respectivo. A pretensão de registrar o contrato tem diversa finalidade e o registro só pode ser obtido enquanto não alienado o prédio locado"⁴⁵⁷.

19.8. Locação por não proprietário

Quem tem a posse ou administração do imóvel pode locá-lo, porém, para que seja registrado o contrato em que consignada a cláusula de vigência, ou averbado para o exercício do direito de preferência, exige o art. 169, III, da Lei 6.015/73, por respeito aos princípios da disponibilidade e continuidade, que o contrato ostente como locador um dos proprietários, tendo a jurisprudência permitido que também seja aceito contrato em que figure como locador o compromissário comprador ou cessionário de direitos, desde que os correspondentes títulos estejam registrados: "Locador pode ser o proprietário, o usufrutuário, o possuidor, o fiduciário, os pais, como administradores legais dos filhos, o mandatário, o condomínio, o condômino administrador e mandatário comum (artigos 713, 485, 1.734, 385, 1.300 e 640 do Código Ci-

⁴⁵⁶ CSMSp. Apelação Cível nº 035013-0/0. Data: 1/11/1996. Localidade: São Paulo. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁵⁷ CSMSp. Apelação Cível nº 023198-0/0. Data: 23/6/1995. Localidade: São Paulo. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

vil⁴⁵⁸). Dadas as finalidades restritas do acesso registrário do contrato de locação, inócuo e sem qualquer sentido é a publicidade de relação jurídica em que figura, num dos polos, pessoa que não ostenta condição de proprietária ou promitente compradora ou cessionária⁴⁵⁹.

19.9. Imóveis alienados fiduciariamente

Os imóveis alienados fiduciariamente também apresentam restrições quanto à locação, estabelecendo o art. 37-B da Lei 9.514/97 que "será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores, a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a um ano sem concordância por escrito do fiduciário".

19.10. Caução

A Lei de Locações trouxe hipótese de constituição de direito real de garantia por instrumento particular, a caução de imóveis em garantia.

Estabelece o art. 37, I, da Lei 8.245/91: "No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I – caução", acrescentando o art. 38, § 1º, do mesmo diploma legal que "A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. § 1º A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos; a em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula".⁴⁶⁰

Observe-se ainda que "adotada a ideia de que caução é gênero do que são espécies o penhor, a anticrese e a hipoteca, não há como afastar o entendimento de que 'caução de imóvel', considerados os conceitos de garantia real, tecnicamente, é hipoteca. Entretanto, estando estabelecida na Lei de Locação a possibilidade de se prestar caução em bem imóvel, possibilitando o ingresso da garantia no fôlio real através de averbação, não resta dúvida quanto a ter o

⁴⁵⁸ Atualmente arts. 1.394, 1.196, 1.953, 1.689, 667 e 1.324 do CC de 2002.

⁴⁵⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 023805-0/2. Data: 13/11/1995. Localidade: São Paulo. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁶⁰ A indicação de que a averbação deva ser lançada à margem da matrícula é imprópria, pois apenas no sistema de transcrições as averbações eram lançadas à margem do Livro de Transcrição de Transmissões. Atualmente, as averbações e registros são lançados no Livro 2 – Registro Geral, em seguida à matrícula, que é um ato autônomo.

legislador criado uma garantia real anômala, mais simples e menos formal que as demais garantias reais estabelecidas na legislação brasileira até então"⁴⁶¹.

Importante ressaltar que essa garantia não se distingue da hipoteca apenas pela forma do título (instrumento particular ao invés de escritura pública) ou pelo ato pelo qual ingressa no Livro 2 (averbação ao invés de registro): "em verdade, a caução a que se refere o art. 37, I, da Lei 8.245, de 18.10.1991, não se confunde com garantia hipotecária, tendo características diversas do direito real de garantia previsto no Código Civil. Bem por isso, não tem a caução a característica do direito de sequela, tanto que necessário novo fiador ou substituição da garantia em caso de 'alienação do imóvel' (cf. art. 40, VII, da Lei 8.245/91)"⁴⁶².

Também não se deve confundir essa caução, com aquela prevista no art. 167, II, 8, da Lei 6.015/73, que também gera ato de averbação, mas não contraria o sistema registral, no que tange à distinção dos atos de registro e averbação, por incidir sobre direitos relativos a imóvel, e não sobre o bem em si mesmo.

No controle de legalidade que faz, não pode o oficial permitir a averbação de caução estabelecida em contrato com dupla garantia, por violação ao art. 37, parágrafo único, da Lei 8.245/91, que estabelece ser "vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação".

Assim, a caução constituída em contrato de locação em que também seja estabelecida fiança, não pode ser averbada: "... resta claro, a partir de uma leitura integral da disposição contratual, serem instituídas duas garantias simultâneas. Por um lado, há uma primeira garantia pessoal, de fiança, sobre a qual se operou a renúncia ao benefício de ordem e à faculdade de exoneração e, por outro lado, uma segunda garantia real, de caução constituída sobre bem imóvel, não sendo possível tê-las como confundidas numa única garantia". (...) "A nulidade prevista pelo parágrafo único do artigo 37 da Lei 8.245/91 se consubstanciou"⁴⁶³.

⁴⁶¹ CGJSP. Processo 110/2005. Data: 8/3/2005. Localidade: São Paulo. Juiz Auxiliar da Corregedoria: José Antonio de Paula Santos Neto. Corregedor Geral da Justiça: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁶² CGJSP. Processo 000867/95. Data: 30/5/1995. Localidade: Pederneiras. Juiz Auxiliar da Corregedoria: Márcio Martins Bonilha Filho. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁶³ Juiz Auxiliar da E. Corregedoria Geral, Dr. Marcelo Fortes Barbosa Filho, em parecer lançado nos autos do Proc. CG nº 1.578/97, citado no Parecer CGJSP. Data:

A Lei 8.245/91 não veda expressamente a sobreposição de garantias, mas sim a duplicidade de garantias, que devem ser distinguidas: "nesta há duas garantias à mesma obrigação principal, reforçando diretamente a posição do credor, naquela, um (garantia à obrigação principal) atua em reforço direto e a outra (garantia à garantia) em reforço indireto".⁴⁶⁴

Não obstante, a caução em sobreposição a fiança também não ingressa na matrícula porque, "se a caução é da fiança, não da locação, só daí já se pode extrair a falta de suporte jurídico para a averbação da caução pretendida, uma vez que a averbação de exceção prevista em lei é para caução imobiliária que constitui garantia locatícia, entenda-se, garantia direta da locação (artigos 37, I, e 38, § 1º, ambos na Seção VII denominada "Das garantias locatícias"), não garantia da fiança, que apenas indiretamente poderia beneficiar a locação como ocorreu no caso"⁴⁶⁵.

Tendo em vista a Lei 8.212/91 e sendo a caução uma oneração do imóvel, o ato não poderá ingressar na matrícula se houver penhora do INSS (art. 53, § 1º), assim como deverão ser exigidas as CNDs se a caucionante for pessoa jurídica (art. 47, I, b, da Lei 8.212/91).

19.11. Cláusula de vigência

O registro da cláusula de vigência garante ao locatário o respeito ao prazo de locação pactuado no caso de alienação do imóvel, conforme estabelece a parte final do art. 8º da Lei 8.245/91: "Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado"⁴⁶⁶ junto à matrícula do imóvel".

9/11/1999. Fonte: 2.492/99. Localidade: São Paulo. Juiz Auxiliar Antonio Carlos de Moraes Pucci. Sergio Augusto Nigro Conceição Corregedor Geral da Justiça. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁶⁴ Parecer do Juiz Auxiliar da Corregedoria Vicente de Abreu Amadei no Processo CG nº 1.065/2005, com Ementa publicada no Ementário CGJ - Extrajudicial nº 2/2006 referente ao 2º Trimestre de 2006 – data 28/07/06.

⁴⁶⁵ Parecer do Juiz Auxiliar da Corregedoria Vicente de Abreu Amadei no Processo CG nº 1.065/2005, com Ementa publicada no Ementário CGJ - Extrajudicial nº 2/2006 referente ao 2º Trimestre de 2006 – data 28/07/06.

⁴⁶⁶ Embora o artigo indique impropriamente o ato como averbação, a cláusula de vigência é registrada, conforme art. 167, I, 3, da Lei 6.015/73.

Mas não basta que haja no contrato de locação a convenção usual de que o negócio obriga a herdeiros e sucessores⁴⁶⁷. Conforme determina o art. 8º da Lei 8.245/91 e também o art. 242 da Lei 6.015/73, é necessário que o contrato contenha cláusula expressa de vigência: "Já se decidiu que: 'É imprescindível que o contrato contenha cláusula de vigência, sem a qual este não tem ingresso no registro: e não tem ingresso porque não há direito cujo exercício deva ser assegurado' (Ap. Cível nº 31.716-0, rel. Des. Márcio Martins Bonilha, 'in' JTJ LEX 195/353). No mesmo sentido a Apelação Cível nº 43.830-0/2, rel. Des. Sérgio Augusto Nigro Conceição"⁴⁶⁸.

Na análise de contratos com cláusula de vigência apresentados para registro, é comum a hipótese de que a locação envolva apenas parte do imóvel da matrícula, o que deve ser analisado com cuidado.

Em regra, é viável o registro, desde que seja possível determinar com precisão a área locada, a fim de se impedir o registro de outro contrato de locação da mesma área. No entanto, se a descrição do imóvel ou da área locada não permitir sua determinação, não é possível o registro: "No caso o registro se fará para que seja preservada a vigência da locação perante terceiros, quando da alienação do prédio. E como é evidente apenas com relação à parte locada é que estará assegurado esse direito. A possibilidade do registro, portanto, estará sujeita à necessidade de ser identificável a parte locada. Se os elementos distintivos forem insuficientes para sua individualização o registro estará inviabilizado"⁴⁶⁹.

Outra situação muito comum é a locação de prédio cuja construção ainda não está averbada, o que condiciona o registro do contrato à prévia averbação da construção:

"Não há como dar registro a contrato de locação que tem por objeto prédio de escola com todas suas pertencas, incluindo salas de aula, piscina e quadras, se tais acessões e construções não se encontram previamente averbadas

⁴⁶⁷ CSMSP. Apelação Cível nº 280047/79. Data: 7/8/1979. Localidade: São Paulo. Relator: Humberto de Andrade Junqueira. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁶⁸ Processo 079729-0/0. Data: 09/08/2001. Despacho do Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça, em 26 de junho 2001. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁶⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 027480-0/7. Data: 7/12/1995. Localidade: São Paulo. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

no cadastro imobiliário. Em termos diversos, não há a existência jurídica das acessões, para que sua locação ingresse no registro predial"⁴⁷⁰.

Por outro lado, não é condição para o registro do contrato de locação de um imóvel ser ele previamente unificado: "O contrato faz expressa referência a duas matrizes, que se encontram fisicamente unidas. Isso, porém, não acarreta a necessidade de sua fusão registrária, podendo, o contrato, sem maiores indagações, ser registrado em ambas as matrizes, diante da inequívoca vontade das partes. Como bem posto no recurso, a fusão é mera faculdade dos próprios proprietários, não sendo lícito, se perfeitamente identificáveis os imóveis locados, exigir-se sua unificação definitiva simplesmente para abrigar o registro de mera relação obrigacional, temporária por sua própria natureza"⁴⁷¹.

Mas claro que, se houver a necessidade de averbação da construção que abranja área de ambas as matrículas, a fusão será imprescindível para a averbação da construção, sob pena de violação do princípio da unitariedade, impedindo por via indireta o registro do contrato de locação: "Por fim, quanto à necessidade de unificação das matrículas, trata-se de questão para cuja análise há de se conhecer a exata situação da edificação e de se perquirir da viabilidade de sua averbação apenas em uma ou alguma das matrículas"⁴⁷².

No registro do contrato de locação com cláusula de vigência deve-se observar ainda o art. 242 da Lei 6.015/73, que determina que: "o contrato de locação, com cláusula expressa de vigência no caso de alienação do imóvel, registrado no Livro nº 2, consignará também, o seu valor, a renda, o prazo, o tempo e o lugar do pagamento, bem como pena convencional".

19.12. A cláusula de vigência na locação e o usufruto

Embora o usufrutuário possa locar o imóvel, não poderá instituir cláusula de vigência em caso de alienação: "incontestável que ao usufrutuário, exatamente porque não é o seu proprietário, não é dado dispor da coisa e muito menos, por idênticos fundamentos, comprometer-se ou obrigar-se sobre direito exclusivamente concedido ao nu-proprietário, como ocorre com o poder de disposição do imóvel de que este é titular" (...) "tal registro, de qualquer forma, indiretamente acaba atingindo interesses do proprietário, impondo severa restrição a uma das faculdades inerentes ao direito de propriedade, na medida

⁴⁷⁰ CSMSp. Apelação Cível nº 034485-0/6 Data: 3/2/1997 Localidade: São Paulo Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁷¹ CSMSp. Apelação Cível nº 034485-0/6 Data: 3/2/1997 Localidade: São Paulo Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁷² CSMSp. Apelação Cível nº 072802-0/2. Data: 21/11/2000. Localidade: Indaiatuba. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

em que, sensivelmente, limita a liberdade de contratar vendas ou promessas de vendas por parte dos titulares do domínio”⁴⁷³.

Para que seja possível o registro da cláusula de vigência em contrato de locação celebrado com usufrutuário será necessária a anuência do nu-proprietário: “Nessas condições, como obrigação restritiva que é, somente pode ser convencionada – e assim admitido a registro o respectivo título – pelo proprietário-locador, ou, ainda, quando a locação for contratada por usufrutuário, com a expressa anuência do nu-proprietário”⁴⁷⁴.

19.13. Direito de preferência

O direito de preferência, ou preempção, é estabelecido no art. 27 da Lei 8.245/91: “no caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca”.

Assim, trata-se de direito decorrente de lei, que independe de cláusula expressa, porém, para que possa ser oposto contra o adquirente, deve haver publicidade da locação, o que se dá por averbação, conforme determina o art. 33 da Lei de Locações: “O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel”.

Em decorrência desses dispositivos legais, “a averbação do contrato de locação no registro de imóveis, atendidos os requisitos antes enumerados, e presentes na espécie vertente, institui direito real, à aquisição do imóvel pelo inquilino, no exercício de seu direito de preferência. Note-se que a averbação é fato jurídico a estender os efeitos do direito de preferência, transmudando-o de meramente pessoal em direito real à aquisição, pois, ainda que se tenha operado a transcrição do novo registro, o que é fato constitutivo da proprie-

⁴⁷³ CSMSP. Apelação Cível nº 003191-0/84. Data: 24/2/1984. Localidade: Araçatuba. Relator: Heráclides Batalha de Camargo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁷⁴ CSMSP. Apelação Cível nº 003191-0/84. Data: 24/2/1984. Localidade: Araçatuba. Relator: Heráclides Batalha de Camargo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

dade, nos termos do art. 530, I do CC⁴⁷⁵, tem o inquilino o direito de adjudicar a coisa, desde que a requeira no prazo de seis meses, a contar do registro da alienação”⁴⁷⁶.

Sobre o direito de preferência, importante observar que o art. 32 da Lei 8.245/91 estabelece que "o direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação", e que no caso de imóveis objeto de alienação fiduciária, o parágrafo único do mesmo artigo ainda estabelece que: "nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de preferência de que trata este artigo não alcançará também os casos de constituição da propriedade fiduciária e de perda da propriedade ou venda por quaisquer formas de realização de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica".

No caso de mais de um locatário ou de sublocação, o art. 30 da Lei 8.245/91 estabelece a ordem pela qual é exercido o direito de preferência: 1) Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário; 2) Se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos, em comum, ou a qualquer deles, se um só for o interessado; 3) Havendo pluralidade de pretendentes, caberá a preferência ao locatário mais antigo, e, se da mesma data, ao mais idoso.

19.14. Duplo lançamento

É possível que o mesmo contrato de locação ingresse para a prática de 2 atos referentes ao imóvel locado, ou seja, para o registro e a averbação do mesmo título quanto à mesma matrícula: “Consta, ainda, do contrato de locação que as partes avençam pelo respeito do prazo contratual em caso de venda do imóvel durante sua vigência (cláusula 18 - f. 17). Tal situação, por si só, é fundamento para o pedido de registro nos termos do art. 167, I, 3, da Lei nº 6.015/73. Independente desse registro para fins de continuidade locatícia em caso de venda do imóvel, o pedido inicial do recorrente também objetivou a averbação, nos termos do art. 167, II, 16, da lei registrária, para fins de exercício do direito de preferência aquisitiva. Tal procedimento não necessita estar descrito em cláusula contratual, posto ser decorrente de lei, nos termos dos arts. 27 a 34 da Lei 8.245/91. Entretanto, não há óbice ao locatário solicitar a averbação do contrato de locação para esse fim, como forma de garantia de

⁴⁷⁵ Atualmente art. 1.245 do CC de 2002.

⁴⁷⁶ CGJSP. Processo 1.109/95. Data: 12/6/1995. Localidade: São Paulo. Juiz Auxiliar: Márcio Martins Bonilha Filho. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

seu direito. Não há também qualquer óbice para o contrato de locação ser registrado para fins de continuidade da locação e averbado para fins de preferência, considerando-se que a previsão de duplicidade de atos constante na lei registrária objetiva fins diversos a cada um e o recorrente busca dar publicidade à locação existente”⁴⁷⁷.

Evidentemente, não é possível que o contrato de locação gere os 3 atos possíveis quanto à mesma matrícula porque a caução é lançada no imóvel dado em garantia, não no locado.

19.15. Análise do contrato de locação

A análise do contrato de locação, por sua natureza, permite o abrandamento de exigências: “Por outro lado, conquanto não se negue subordinar-se tal título aos princípios informativos dos Registros Públicos e às normas instrumentais contidas na legislação específica, há de se convir deva merecer exame menos rigoroso, perfeitamente compatível com a natureza do negócio jurídico que encerra e com a própria finalidade do registro correspondente.

Não se olvide que as avenças locatícias, invariavelmente, são elaboradas em instrumentos impressos, sendo, via de regra, preenchidos pelas mãos dos próprios locadores, o que, se, de um lado, prejudica sensivelmente o completo atendimento das formalidades preconizadas pela Lei dos Registros, de outro, dificulta possam os locatários, sempre contratualmente mais fracos, obter, com a desejada rapidez, a espontânea adesão dos senhores à bilateral retificação das omissões verificadas.

Na verdade, somente um enfoque mais condescendente e menos formalista desses títulos lograria obviar o total sacrifício dos direitos legalmente assegurados aos inquilinos, mas que, a exemplo da preferência na aquisição do imóvel locado, tem seu exercício presentemente subordinado ao prévio ingresso do contrato no Registro Imobiliário”⁴⁷⁸.

Esse abrandamento aplica-se somente ao registro e à averbação para preservação da cláusula de vigência e do direito de preferência, respectivamente, que buscam apenas dar publicidade da locação, não se aplicando aos contratos apresentados para a constituição da caução, direito real de garantia, cujo título deve se submeter à qualificação sob os mesmos critérios dos demais títulos em que constituídos direitos reais.

⁴⁷⁷ CSMSp. Apelação Cível nº 082898-0/7. Data: 20/12/2001. Localidade: São Caetano do Sul. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁷⁸ CSMSp. Apelação Cível nº 001454-0/83. Data: 27/7/1983. Localidade: São Paulo. Relator: Bruno Affonso de André. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Além disso, a mitigação de exigências não significa que são ignorados todos os aspectos de análise de qualificação. Assim: “embora pacífico o entendimento de que devam ser mitigadas as exigências para o ingresso dos contratos de locação no registro imobiliário, de forma a facilitá-lo sempre que possível, devem ser atendidos os requisitos legais, que no aspecto subjetivo se resumem à coincidência do nome de um dos proprietários e o do locador, circunstância inócurrenente no contrato em exame e que impede seu ingresso no fôlio real”⁴⁷⁹.

Da mesma forma: “A expressão ‘bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador’, constante do citado artigo 169, III, diz respeito apenas à especialidade subjetiva. Não significa, porém, possa o contrato ser registrado em matrícula que diga respeito a bem diverso ao locado, qualitativa ou quantitativamente (cfr. Apel. Cível n. 34.485-0/6)”⁴⁸⁰.

20. Consórcio para aquisição de imóveis

Conforme definição trazida pela Lei nº 11.795 de 8 de outubro de 2008, que disciplina acerca do sistema de consórcios, em seu artigo 2º “consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”.

A legislação anterior que tratava dos grupos de consórcios não dispensava a forma pública no instrumento de transmissão de imóveis, sendo que somente quando o contrato mesclava a aquisição do bem oriundo de grupo de consórcio com outro instituto que dispensava a lavratura de escritura pública, como na alienação fiduciária, era permitida a forma particular do instrumento de transmissão. Contudo, a atual legislação admite expressamente em seu artigo 45, parágrafo único, que o contrato de compra e venda de imóvel por meio do sistema de consórcios poderá ser celebrado por instrumento particular.

Sendo o grupo de consórcio uma sociedade sem personalidade jurídica⁴⁸¹, gerida por uma administradora de consórcio, mas autônoma com relação aos demais grupos e possuidora de patrimônio próprio, que não se confunde com os de outros grupos, nem mesmo com o patrimônio da administradora, seus bens e direitos, frutos e rendimentos, adquiridos por esta em nome daqueles

⁴⁷⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 072802-0/2. Data: 21/11/2000. Localidade: Indaiatuba. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁸⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 036817-0/7. Data: 24/3/1997. Localidade: São Sebastião. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁸¹ Artigo 3º da Lei 11.795/08.

grupos observam disposições especiais, que no caso de bem imóvel deverão ser averbadas na matrícula, conforme prevê o artigo 5º, parágrafo 7º, que relaciona as seguintes restrições:

“- não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da administradora;

- não compõem o elenco de bens e direitos da administradora, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial;

- não podem ser dados em garantia de débito da administradora.”

21. Incorporação, Convenção, Instituição e Atribuição em Condomínios

A incorporação imobiliária, a convenção e a instituição e especificação de condomínio edilício também podem ser promovidas por instrumento particular, pois nelas não há a constituição ou transmissão de direitos reais.

A instituição e especificação de condomínio é o ato pelo qual se cria o condomínio edilício, também denominado de especial, seja constituído de casas ou de unidades autônomas em edifícios (apartamentos, salas, vagas de garagem, etc.).

Na instituição é necessário que os proprietários discriminem e individualizem as unidades de propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns, determinem a fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns, e especifiquem o fim a que as unidades se destinam⁴⁸².

Averbada a construção do edifício e em seguida registrada⁴⁸³ a instituição do condomínio, serão descerradas matrículas individuais para cada uma das novas unidades autônomas: "Com o registro da instituição e especificação do condomínio, o prédio a que se referia a matrícula de origem deixa de existir no plano jurídico-registrário, dando nascimento as unidades autônomas do condomínio horizontal"⁴⁸⁴.

A Instituição de condomínio deverá também ser apresentada acompanhada da convenção de condomínio.

⁴⁸² Art. 1.332 do CC.

⁴⁸³ Art. 167, I, 17, da Lei 6.015/73.

⁴⁸⁴ 1ª VRPSP. Processo nº 000353/91. Data: 10/12/91. Localidade: São Paulo. Juiz: Kioitsi Chicuta. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Na convenção são estabelecidas as regras que regerão o condomínio, que passarão a ser obrigatórias entre os condôminos desde a sua aprovação, mas só serão oponíveis contra terceiros após registrada a convenção⁴⁸⁵. Nela deve-se determinar, além da especificação e finalidade de cada unidade autônoma, a forma de divisão das despesas do condomínio, a forma de administração, a competência das assembleias, forma de sua convocação e quóruns, as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores, e o regimento interno⁴⁸⁶. “Instituição e convenção são atos distintos que devem ser examinados separadamente. (...) Para melhor ilustrar a perfeita separação desses atos, basta dizer que são lavrados em livros diferentes. A instituição é registrada no Livro 2 (art. 176, *caput*, da Lei 6.015/73) e a convenção no Livro 3 (art. 178, III). Ainda, a Lei 4.591/64 prevê a inscrição (*rectius*: registro) da primeira no art. 7º e o da segunda no § 1º do art. 9º”⁴⁸⁷.

A incorporação, por outro lado, não é pré-requisito para a instituição de condomínio e só será necessária caso o proprietário pretenda negociar os imóveis antes mesmo do término da obra, alienando frações ideais do terreno vinculadas às futuras unidades autônomas, as denominadas "vendas de unidades na planta".

Neste caso a lei exige que o incorporador, antes de negociar as futuras unidades autônomas, registre⁴⁸⁸ a incorporação, apresentando os documentos previstos no art. 32 da Lei 4.591/64, que visam comprovar desde a aprovação do projeto pelo município até a idoneidade financeira do incorporador, isso para resguardar as pessoas que estão adquirindo bens que ainda não foram construídos. A negociação de futuras unidades autônomas sem o prévio registro da incorporação tipifica contravenção relativa à economia popular⁴⁸⁹.

Após o registro da incorporação, quando concluída a obra, deverá o incorporador apresentar os documentos necessários à averbação da construção do edifício (“habite-se” e CND do INSS) e em seguida requerer o registro da instituição e especificação e da convenção do condomínio, quando então serão descerradas as matrículas para as unidades autônomas.

A questão quanto à forma do título é mais complexa quando analisamos a atribuição de unidades autônomas, que, conforme o caso, poderá exigir ou não a formalização por escritura pública.

⁴⁸⁵ Art. 1.333 do CC.

⁴⁸⁶ Art. 1.334 do CC.

⁴⁸⁷ 1ª VRPSP. Processo nº 000165/81. Data: 27/4/1981. Localidade: São Paulo. Juiz: Dr. Narciso Orlandi Neto. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁸⁸ Art. 167, I, 17, da Lei 6.015/73.

⁴⁸⁹ Art. 66, I, da Lei 4.591/64.

A atribuição é um ato autônomo e constitui-se, em regra, como um modo de divisão entre os condôminos.

Veja-se, por exemplo, a hipótese de um prédio de 6 apartamentos construído por 2 pessoas. Se apenas instituírem o condomínio edilício, serão descerradas 6 matrículas tendo os 2 como coproprietários. Porém, podem concomitantemente à instituição e especificação desejar extinguir essa copropriedade, atribuindo a cada proprietário 3 apartamentos.

Essa atribuição, que é um ato autônomo da instituição e especificação de condomínio, deve ser registrada na matrícula de origem, descerrando-se em seguida as matrículas das unidades autônomas indicando-se como proprietárias as pessoas a quem foram atribuídas: "A atribuição de unidades condominiais é modalidade de divisão entre condôminos, e esse ato não se confunde com a instituição do condomínio especial e não é decorrência necessária desta"⁴⁹⁰.

Nessa situação, por ser um ato de divisão de imóveis, deve ser consubstanciada em escritura pública, observando-se ainda o recolhimento de imposto de transmissão caso um dos proprietários receba unidades que totalizem fração ideal do terreno superior à que detinha do terreno em que erigido o edifício.

Porém, há uma segunda hipótese de atribuição. É aquela em que, havendo prévio registro de incorporação, alienações de frações ideais do terreno vinculadas a futuras unidades autônomas foram registradas. Neste caso, não há copropriedade porque o adquirente compra fração ideal do terreno já vinculada a futura unidade autônoma, motivo pelo qual a atribuição não é forma de extinção de copropriedade e, portanto, poderá ser formalizada por instrumento particular: "É certo, como sustentou o recorrido, que para a instituição do condomínio, pela qual os condôminos fazem a atribuição das unidades autônomas, é suficiente que se apresente instrumento particular. Em tal caso há uma divisão menos solene, a qual dispensa a escritura pública, pois não há uma divisão típica em que as partes transferem umas às outras o domínio sobre partes que possuíam em comum extinguindo a comunhão. Sequer comunhão chega existir, porque o terreno é adquirido em partes certas, ainda que ideais, que são já de início destinadas às unidades autônomas de forma predefinida."⁴⁹¹

⁴⁹⁰ CSMSp. Apelação Cível nº 10.489-0/9. Data: 2/10/1989. Localidade: Praia Grande. Relator: Milton Evaristo dos Santos. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁹¹ CSMSp. Apelação Cível nº 461-6/5. Data: 6/12/2005. Localidade: São Paulo (14º SRI). Relator: José Mário Antonio Cardinale. Publicado no D.O.E. de 15/03/2006.

Assim foram distinguidas pela CGJSP as modalidades de atribuição: "A atribuição, na instituição de condomínio por unidades autônomas precedido de incorporação, será, portanto, necessária apenas para identificar a unidade que ficará pertencendo a determinado titular de fração ideal do solo, prestando, ademais, para atestar o cumprimento pelo incorporador da obrigação de entregar ao adquirente a unidade autônoma. (...) A atribuição como meio especial de extinção da copropriedade sobre as unidades autônomas é necessária, por exemplo, na hipótese de instituição de condomínio em edifício que estava sob o regime do condomínio comum do Código Civil, porque, nesse caso, a copropriedade abrange todo o edifício, ou quando duas ou mais pessoas são coproprietárias de duas ou mais unidades autônomas"⁴⁹².

Importante ressaltar que no que tange à atribuição o tema ainda não é pacífico, existindo entendimento diverso, que defende que a atribuição, quando realizada concomitantemente com a instituição, sempre poderá ser formalizada por instrumento particular.

22. Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV

Em 7 de julho de 2009 entrou em vigor a Lei 11.977, que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida, elaborado com a finalidade de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda mensal de até 10 salários mínimos, residentes no Brasil⁴⁹³. Além de inúmeras previsões de concessão de isenções referentes a emolumentos de atos praticados nos Registro de Imóveis e Tabelionatos, o referido diploma legal dispõe acerca de instrumentos que visem à facilitação da aquisição da moradia por famílias de baixa renda, prevendo a admissão de títulos e a prática de atos nas matrículas que promovam a redução dos custos, celeridade e simplificação nos procedimentos, tais como os títulos de legitimação de posse concedidos em decorrência da demarcação urbanística, que deverão ser objeto de registro na matrícula do imóvel, dispensando-se a escritura pública tanto para estes atos como também para a própria conversão da posse em propriedade, após o prazo de 5 anos da data do registro do título da legitimação de posse e demais requisitos, adquirindo-a pela usucapião.

⁴⁹² CGJSP. Processo 001270/2001. Data: 14/1/2002. Localidade: São Bernardo do Campo. Parecer do Juiz Auxiliar Antonio Carlos Moraes Pucci. Corregedor Geral da Justiça: Luis de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁴⁹³Artigo 2º do PMCMV.

CAPÍTULO IV
PESSOA JURÍDICA
ESTRANGEIRA

As pessoas jurídicas estrangeiras, quando pretendem adquirir ou constituir direitos reais sobre imóveis, estão sujeitas a diversas restrições que visam desde a preservação da soberania nacional até assegurar a proteção dos brasileiros que com ela transacionam, o que exige do oficial, na qualificação de títulos envolvendo essas pessoas jurídicas, uma análise cuidadosa, distinguindo os entes de direito público dos de direito privado, bem como se os registros pretendidos demonstram efetiva atuação no País⁴⁹⁴.

1. Pessoa Jurídica de Direito Público Externo

A primeira limitação a ser abordada atinge as pessoas jurídicas de direito público externo⁴⁹⁵, que não podem adquirir bens imóveis no Brasil, exceto para a instalação da sede das representações diplomáticas ou consulares, conforme determina o art. 11, parágrafo 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil⁴⁹⁶: "Os Governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza, que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação".

A exceção quanto às sedes diplomáticas está no parágrafo terceiro, do mesmo artigo: "Os Governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares". Mas mesmo essas aquisições só são possíveis com a expressa autorização do Governo Federal, através do Ministério das Relações Exteriores, conforme determina o art. 4º, § 1º e 5º, da Convenção de Viena sobre Relações Consulares⁴⁹⁷: §1º "Uma repartição consular não pode ser estabelecida no território do Estado receptor sem seu consentimento", § 5º "Não se poderá abrir fora da sede da repartição consular uma dependência que dela faça parte sem haver obtido previamente o consentimento expresso do Estado receptor".

⁴⁹⁴ Além das restrições aqui tratadas, há outras específicas para imóveis rurais (Lei 5.709/71) e para imóveis localizados na faixa de fronteira (Lei 6.634/79).

⁴⁹⁵ Art. 42 do CC.

⁴⁹⁶ Decreto-lei nº 4.657/42.

⁴⁹⁷ A Convenção de Viena sobre Relações Consulares foi promulgada pelo Decreto 61.078/67.

A restrição existente na Lei de Introdução ao Código Civil, que deve ser observada pelo oficial, visa preservar a soberania e integridade do território nacional, impedindo que Estados estrangeiros possam adquirir parte do Território Nacional, mesmo que indiretamente por intermédio de organizações por eles controladas.

Em decorrência dessa proibição, por exemplo, o Estado do Vaticano não poderia adquirir em Território Nacional imóvel com objetivos filantrópicos, somente podendo adquirir imóvel destinado a sua representação diplomática e, mesmo isso, após a autorização do Governo brasileiro.

2. Sociedades estrangeiras

As sociedades estrangeiras, ou seja, aquelas que não têm sede no País e não estão organizadas de conformidade com a lei brasileira, não podem atuar no Brasil sem autorização do Poder Executivo, conforme determina o art. 1.134 do CC.

Essa disposição legal expressa, que já existia anteriormente por força do disposto nos arts. 59 a 73 do Decreto-lei 2.627/40, com vigência mantida pelo art. 300 da Lei 6.404/76, e que hoje se encontra no próprio Código Civil, por vezes não é aplicada corretamente, sendo possível encontrar sociedades estrangeiras atuando no País apresentando apenas o comprovante de inscrição no CNPJ, como se fosse prova da autorização do Poder Executivo exigida pelo art. 1.134 do CC, com o qual não se confunde, o que deve ser observado com muito cuidado pelo oficial.

2.1. Situações que exigem a autorização

O art. 1.134 do CC é claro em estabelecer que não é toda pessoa jurídica que precisa de autorização do Poder Executivo, mas apenas aquelas que pretendem funcionar no País, e o oficial, na verificação da caracterização ou não do efetivo funcionamento no País, deverá analisar com prudência o registro a ser feito, bem como eventuais atos lançados anteriormente referentes à sociedade.

Assim, se uma indústria brasileira receber um empréstimo no exterior e tiver que prestar garantia à instituição financeira estrangeira, para o registro da hipoteca a sociedade estrangeira credora deverá ter CNPJ⁴⁹⁸, mas não precisará comprovar ter autorização do Governo Federal. Isso porque, neste caso, o empréstimo não foi oferecido no Brasil, mas no exterior, ou seja, a sociedade

⁴⁹⁸ Art. 11 da IN RFB 1.005 de 8 de fevereiro de 2010.

não está funcionando no País. Diversamente, a pretensão de registro de uma instituição de condomínio edilício denuncia o funcionamento de fato no País.

Em pioneira decisão sobre o tema, o MM. Juiz Corregedor Permanente da Comarca de São de Bernardo do Campo, Dr. Rodrigo Gorga Campos, em um dos trechos da r. sentença que julgou dúvida procedente, mantendo a exigência de que a pessoa jurídica estrangeira apresentasse autorização do Governo Federal, ressaltou que a sociedade "registrou inúmeras aquisições de imóveis e direitos reais, adquirindo créditos, constituindo garantias e recebendo pagamentos, operações que evidenciam plena atuação no Brasil, estando portanto sujeita à exigência prevista no art. 1.134 do Código Civil"⁴⁹⁹.

Aspectos como a habitualidade e o objeto social da sociedade estrangeira também devem ser analisados, como indicou o ilustre representante do Ministério Público e Curador dos Registros Públicos da Comarca de São Bernardo do Campo, Dr. Maximiliano Roberto Ernesto Führer, que no mesmo processo, em um dos trechos de seu culto parecer, assim se manifestou: "A impressionante relação de transações imobiliárias à fls. bem demonstra a referida atividade empresarial e sua habitualidade. É bom destacar que as operações com bens imóveis fazem parte do objeto social da empresa apresentante, conforme se verifica em seus estatutos"⁵⁰⁰.

Por outro lado, não há necessidade de autorização se a sociedade estrangeira é apenas sócia de pessoa jurídica nacional, conforme estabelece o art. 1.134, parte final, do Código Civil.

2.2. Motivos da necessidade de autorização

A necessidade de autorização da sociedade estrangeira e o atendimento a determinados requisitos para funcionar no País é intuitivo. Imagine-se, por exemplo, que após a aquisição e venda de imóvel a fiscalização fazendária apure falta de recolhimento no ITBI. Como autuará e executará uma pessoa jurídica com sede, por exemplo, nas Ilhas Cayman? E se a construção erigida por uma empresa estrangeira ruir, como os adquirentes e terceiros prejudicados farão para se ressarcir dos prejuízos?

⁴⁹⁹ Processo 043/04-RI da Corregedoria Permanente dos Registros de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo - SP. Data: 26/08/05. Juiz: Rodrigo Gorga Campos.

⁵⁰⁰ Processo 043/04-RI da Corregedoria Permanente dos Registros de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo - SP. Data: 26/08/05. Promotor de Justiça: Maximiliano Roberto Ernesto Führer.

Por essas razões, para funcionar no Brasil, toda sociedade estrangeira deve estar autorizada pelo Poder Executivo Federal, e a autorização só é deferida após cumpridas exigências legais que visam principalmente permitir que a pessoa jurídica efetivamente responda pelas obrigações assumidas ao atuar no País, como se verifica, por exemplo, da necessidade de depósito em dinheiro e em estabelecimento bancário oficial, de capital predefinido⁵⁰¹ e da obrigatoriedade de manter permanentemente representantes no Brasil com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade⁵⁰². Tais exigências justificam-se pela necessidade de estabilidade nas relações entre as sociedades estrangeiras e os que com ela celebrarem negócios, permitindo, assim, futura responsabilização no Brasil da sociedade com sede no exterior.

O art. 1.134 e seguintes do Código Civil elencam os requisitos legais que uma sociedade estrangeira deve atender antes de atuar no País.

2.3. Competência para autorizar

A competência para autorizar o funcionamento no Brasil de sociedade estrangeira é do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, conforme determina o Decreto 5.664/06.

Mas não basta a apresentação da portaria de autorização pois, conforme estabelece o caput do art. 1.136 do Código Civil: "A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro próprio do lugar em que se deva estabelecer", quando se verificará, inclusive, o cumprimento das condições da autorização, como, por exemplo, o efetivo depósito do capital definido no ato de autorização.

Portanto, após autorizada, deverá a sociedade promover o arquivamento de seus atos, da publicação da autorização e de todos os demais documentos em Registro Público e, somente após, poderá atuar no País. No caso das sociedades empresárias⁵⁰³, o arquivamento dos atos se dará na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento da sociedade, conforme estabelecido pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio na Instrução Normativa 81/99, que dispõe sobre os pedidos de autorização. As demais pessoas jurídicas estrangeiras devem ter seus atos arquivados no Registro Civil de Pessoa Jurídica.

⁵⁰¹ Artigo 1.136, §1º, do CC.

⁵⁰² Artigo 1.138 do CC.

⁵⁰³ O art. 5º da IN DNRC 81/99 utilizou a terminologia anterior ao Código Civil de 2002, referindo-se a sociedade mercantil.

Note-se que o fato da sociedade possuir cartão de CNPJ emitido pelo Ministério da Fazenda, expedido apenas para controle fiscal, mas obrigatório para todas as pessoas jurídicas domiciliadas no exterior que possuam no Brasil imóveis, financiamentos ou pratiquem empréstimos em moeda concedidos a residentes no País⁵⁰⁴, funcionem ou não no Brasil, não se confunde com a autorização para funcionamento de competência do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com propósito totalmente diferente, distinção que deve ser feita pelo oficial ao analisar títulos envolvendo pessoas jurídicas estrangeiras.

⁵⁰⁴ Art. 11, XIV, da IN RFB 1.005 de 8 de fevereiro de 2010.

CAPÍTULO V

ENTES SEM

PERSONALIDADE JURÍDICA

Os entes sem personalidade jurídica não podem adquirir imóveis ou direitos a eles relativos. Não obstante, não é incomum que sejam apresentados a registro títulos em que entes despersonalizados agem como se personalidade jurídica tivessem, títulos que por isso devem ser recusados pelo oficial.

A personalidade caracteriza "a pessoa ou a entidade física ou jurídica com aptidão a ser sujeito ativo ou passivo de direitos"⁵⁰⁵, sendo a personalidade jurídica a "denominação propriamente dada à personalidade que se atribui ou se assegura às pessoas jurídicas, em virtude do que se investem de uma qualidade de pessoa, que as tornam suscetíveis de direitos e obrigações e com direito a uma existência própria, protegida pela lei"⁵⁰⁶.

Assim, se a entidade não pode ser sujeito ativo ou passivo de direitos, por lhe faltar personalidade jurídica, não pode, evidentemente, adquirir direitos reais sobre imóveis, o que exige a atenção do oficial, que deve conhecer as entidades sem personalidade jurídica, cujas principais serão analisadas adiante.

Deve-se, no entanto, ressaltar que muitas dessas entidades têm capacidade processual⁵⁰⁷, podendo ser autoras de ações judiciais e, por isso, podem obter o lançamento de penhoras e outras constrições judiciais em seu favor sem qualquer óbice, o que, no entanto, não lhes confere personalidade jurídica.

1. Consórcio de Pessoas Jurídicas

O consórcio de pessoas jurídicas viabiliza, pela reunião de diversas sociedades com atividades complementares, a participação em grandes licitações e a realização de vultosos projetos por sociedades que individualmente não teriam como realizá-los. Estabelece o art. 278 da Lei das Sociedades Anônimas⁵⁰⁸: "As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo".

Porém, o que não se pode esquecer é que os consórcios privados não têm personalidade jurídica. É o que estabelece expressamente o mesmo dispositivo

⁵⁰⁵ SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 1035.

⁵⁰⁶ SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 1036.

⁵⁰⁷ Art. 12 do CPC.

⁵⁰⁸ Lei 6.404/76.

legal, em seu parágrafo 1º: "O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade".

Assim, o consórcio privado não pode, por exemplo, adquirir imóveis em nome próprio. A aquisição deve ser feita em nome das consorciadas.

Não se pode deixar de frisar que usualmente, após o resultado da licitação, as consorciadas do consórcio ganhador constituem uma sociedade entre si, esta sim com personalidade jurídica, mas que normalmente mantém em sua denominação a expressão consórcio, o que pode causar confusão. Para distingui-la do consórcio previsto no art. 278 da Lei 6.404/76 deve-se analisar seu contrato registrado. A sociedade com personalidade jurídica tem contrato ou estatuto social registrado, ostentando em sua denominação a indicação do tipo societário (Ltda, S/A, etc.). O consórcio tem apenas o contrato a que se refere o art. 279 da Lei 6.404/76 registrado, não ostentando indicação de tipo societário em sua denominação.

2. Espólio

Embora o espólio tenha personificação processual⁵⁰⁹, esta não se confunde com personalidade jurídica, impedindo que o espólio adquira direitos reais, “o espólio não tem personalidade jurídica e não pode ser proprietário (...). O espólio não passa de universalidade de bens. Escreve Galba Menegale: ‘Sem embargo da aparência de personalidade, que se percebe no espólio, capaz de demandar e ser demandado, não se pode considerar pessoa jurídica, pois é de existência transitória, tem proprietários conhecidos e não dispõe de patrimônio próprio, uma vez que seus bens, provisoriamente reunidos e subordinados a um conjunto, continuam a pertencer individualmente aos herdeiros’ (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, direção de Carvalho Santos, vol. 21, p. 4, ed. Borsoi)”⁵¹⁰.

Isso não significa que o espólio não possa validamente participar de atos cujos títulos sejam registrados. O que não se admite é que o espólio adquira novos bens, mas os bens do espólio podem ser alienados, desde que com autorização judicial⁵¹¹, e o inventariante, dentro de suas atribuições de administração⁵¹² dos bens do espólio, pode, por exemplo, representá-lo na locação de

⁵⁰⁹ Art. 12, V, do CPC.

⁵¹⁰ CSMSP. Apelação cível nº 10.097-0/0. Data: 18/09/1989. Localidade: Ubatuba.

Relator: Milton Evaristo dos Santos. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵¹¹ Art. 992 do CPC.

⁵¹² Art. 991 do CPC.

imóveis e na quitação de hipotecas, mesmo sem autorização judicial: "A locação, inserindo-se entre os poderes de administração do inventariante, não se sujeita à autorização judicial e ouvida dos interessados de que trata o art. 992 do CPC"⁵¹³. No que tange à locação, observe-se, no entanto, que o inventariante não pode instituir cláusula de vigência, haja vista que "cria verdadeiro gravame sobre bem integrativo da herança, que assim poderá ser partilhado ao herdeiro, desequilibrando os quinhões, o ato em tela, repete-se, encaixa-se perfeitamente entre esses últimos, pelo que só mediante autorização judicial deveria ser praticado"⁵¹⁴.

2.1. Sub-rogação objetiva ou real

Admite-se, no entanto, a sub-rogação objetiva, ou seja, a transferência que decorra de direito adquirido anteriormente pelo "de cujus". Assim, é possível o registro de escritura pela qual o espólio adquira imóvel em cumprimento a anterior compromisso de compra e venda celebrado em vida, a fim de que o imóvel possa ser em seguida partilhado aos herdeiros: "Admite-se a sub-rogação objetiva (ou real) sem que se altere a subordinação da coisa ou direito à comunidade hereditária. Não se admite que um novo bem se inclua no espólio. Portanto, havendo prova documental de que a aquisição imobiliária do espólio guarda correspondência com direitos de promessa de venda e compra de que era titular o 'de cujus', dá-se a sub-rogação objetiva a justificar a aquisição pelo espólio"⁵¹⁵.

3. Condomínio edilício e loteamento

O condomínio edilício constitui-se "por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis"⁵¹⁶, mas esse registro não lhe dá personalidade jurídica, apenas tem consequências patrimoniais e obrigacionais, decorrentes da definição das áreas comuns⁵¹⁷ e individuais (unidades autônomas)⁵¹⁸ e dos deveres estabelecidos na convenção de condomínio⁵¹⁹.

⁵¹³ Ap c/ Rev. nº 626.935-00/3. 2ª Câm. 2º TACivSP. j. 08.04.2002. Relator: Juiz Norival Oliva. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵¹⁴ Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação cível nº 4.261/91. Data: 10/03/1992. Localidade: Rio de Janeiro. 6ª Câmara Cível. Relator: Laerson Mauro. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵¹⁵ CSMSP. Apelação Cível nº 013222-0/3. Data: 10/4/1992. Localidade: Santos. Relator: Dínio de Santis Garcia. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵¹⁶ Art. 1.332 do CC.

⁵¹⁷ Art. 1.331, § 2º do CC.

⁵¹⁸ Art. 1.331, § 1º do CC.

⁵¹⁹ Art. 1.334 do CC.

Trata-se apenas de uma universalidade de bens que, embora tenha capacidade processual, por não ter personalidade jurídica, não pode adquirir bens ou direitos em nome próprio.

"É da jurisprudência absolutamente tranquila deste Conselho Superior da Magistratura que o condomínio em edifício da Lei n 4.591/64 não é pessoa jurídica e não pode adquirir, em seu nome, domínio. A mera capacidade de estar em Juízo não lhe confere personalidade jurídica (Apelações Cíveis 975-0, 5.035-0, 15.106-0, 17.878-0, entre outras). Isso porque, embora se admita no condomínio especial alguma atividade associativa, ela não o transforma, por si só, de direito real *sui generis* em pessoa jurídica. Falta-lhe, segundo a lição de Pontes de Miranda, a *affectio societatis* (Tratado de Direito Privado, Editora RT, tomo 12, parágrafo 1.311). Não se confundem, assim, a singela capacidade judiciária, atribuída pelo artigo 12 do Código de Processo Civil ao condomínio especial, com a personalidade jurídica indispensável para a aquisição de bens no plano substantivo⁵²⁰".

E o Código Civil de 2002 não alterou essa situação: "O novo Código Civil não inovou a matéria. Subsiste previsão legal apenas quanto à capacidade de agir o condomínio em juízo e de administração, institutos criados para viabilizar a defesa dos interesses comuns dos condôminos, e que não lhe atribuem personalidade jurídica para ser titular de domínio"⁵²¹.

Por isso, não pode o condomínio, por exemplo, adquirir imóvel vizinho para ampliação de estacionamento ou para a edificação de salão de festas. A aquisição deve ser realizada em nome dos condôminos, na proporção que detém do terreno ocupado pelo condomínio, e, após regular alteração da especificação, com aprovação da unanimidade dos condôminos⁵²², averbação de eventual aumento de construção, comprovada a regularidade quanto ao município ("habite-se") e ao INSS (CND), alteração da descrição das unidades autônomas, acrescendo-se frações da nova área comum, e alterando-se a convenção do condomínio. Jamais se poderá neste caso adquirir o terreno em nome do condomínio.

⁵²⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 032737-0/2. Data: 18/12/96. Localidade: São Paulo. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵²¹ CSMSP. Apelação Cível nº 253-6/6. Data: 21/3/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵²² Item 74, Capítulo XX, NSCGJSP.

Da mesma forma ocorre com o loteamento, que é apenas uma das formas de parcelamento do solo na qual há a abertura de vias de circulação⁵²³, e que não tem personalidade jurídica, nem capacidade processual.

Tanto para o condomínio, como para o loteamento, uma alternativa para a aquisição de imóveis é a constituição de associação que, após o arquivamento de seus atos constitutivos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, estará dotada de personalidade jurídica e poderá adquirir bens imóveis: “Finalmente, o loteamento 'Condomínio Arujazinho IV', por não ser pessoa jurídica, não pode adquirir direito real. Assim vem decidindo este E. Conselho, obstando acesso ao registro de título translativo da propriedade imobiliária a condomínio (cfr. Ap. Cív. 975-0, 5.035-0, 15.106-0, 17.878-0, e 32.737-0/2). Será possível, isto sim, aos adquirentes dos lotes do 'Condomínio Arujazinho IV' constituir regularmente uma associação que, dotada de personalidade jurídica, poderá adquirir, em seu nome, propriedade de unidades imobiliárias”⁵²⁴.

3.1 Execução de despesas condominiais

No entanto, a própria Lei de Incorporações prevê uma exceção, estabelecendo o art. 63, § 3º, da Lei 4.591/64 a possibilidade de que, nas incorporações em que a construção for contratada pelo regime de administração, na execução extrajudicial de condômino inadimplente, o condomínio adjudique a unidade penhorada.

Essa exceção legal tem sido estendida para as demais execuções para cobrança de débitos condominiais em que o condomínio arremate ou adjudique o imóvel do condômino inadimplente.

Mas, como o condomínio não tem personalidade jurídica, nessas hipóteses o Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo estabelece que seja exigida a comprovação de que a aquisição, bem como a posterior alienação, esteja autorizada pela totalidade dos demais condôminos.

"Dessa forma, a arrematação ou adjudicação deve ser deferida ao condomínio na hipótese acima referida, ou seja, como forma de satisfazer o crédito decorrente da não satisfação, pelo condomínio, das despesas condominiais.

Outra ressalva, ainda, deve ser feita.

Justamente porque o condomínio não é um ente imaterial com personalidade jurídica própria, em que pese o agrupamento dos interesses dos condô-

⁵²³ Art. 2º, § 1º, da Lei 6.766/79.

⁵²⁴ CSMSP. Apelação Cível nº 063447-0/0. Data: 26/5/2000. Localidade: Santa Isabel. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

minos, para que a arrematação ou adjudicação seja possível, é necessário que a aquisição conte com a anuência dos condôminos, por decisão unânime de assembleia geral em que, para essa finalidade específica, não terá o voto do proprietário da unidade autônoma que gerou as despesas condominiais objeto da execução em que foi esta unidade arrematada ou adjudicada.

Igual providência, desde já fica consignado, deverá ser observada para a alienação da mesma unidade autônoma pelo condomínio, pois dependerá o ato da anuência dos condôminos em assembleia geral.

Estas cautelas se impõem porque em casos como o presente, a unidade autônoma, apesar de arrematada ou adjudicada pelo condomínio, será de propriedade conjunta de todos os condôminos, que não podem ser constrangidos a adquirir coisa imóvel, uma vez que a propriedade é fonte de deveres e obrigações, e também não podem, salvo as hipóteses legais, ser constrangidos a alienar imóvel de que são coproprietários"⁵²⁵.

4. Empresário

No Estado de São Paulo não se admite que a pessoa jurídica individual ou o empresário, como denomina o Código Civil de 2002, adquira direitos reais, isso porque o empresário individual é a própria pessoa natural que a constitui, respondendo pessoalmente pelas obrigações que assume no desempenho das atividades. Assim, os imóveis e direitos adquiridos, mesmo que destinados ao objetivo social da pessoa jurídica individual, devem ser adquiridos e registrados em nome da pessoa natural.

Esse é o entendimento do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo: "É indubitoso que o empresário comercial pode exercer a afinidade empresarial individualmente, praticando de modo profissional atos de intermediação, com intuito de lucro. Será, na lição de Rubens Requião, in Curso de Direito Comercial, Editora Saraiva, 16ª edição, 1985, 1º volume, página 74, nº 40, um empresário comercial individual, como a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. Porém, há irregularidade registrária, na medida em que o imóvel está matriculado em nome de firma individual. Ora, é incabível a manutenção desse registro, na consideração de que Espólios, Mas-

⁵²⁵ CSMSP. Apelação Cível nº 253-6/6. Data: 21/3/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

sas Falidas, Condomínios e outras universalidades ('universitas juris'), também não podem figurar como titulares de domínio na tábua registrária"⁵²⁶.

No mesmo sentido Acórdão posterior ao Código Civil de 2002: "a firma individual não tem personalidade jurídica, não podendo, por tal razão, figurar no fólio real como proprietária de imóvel"⁵²⁷.

Mas apesar da impossibilidade de constar na matrícula como titular do direito real a firma individual com o respectivo CNPJ, o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo admitiu em acórdão posterior uma cédula de crédito emitida individual, desde que conste no título a qualificação como pessoa natural, pois no exercício da atividade pelo empresário individual é natural o uso da firma, que ocorre inclusive na celebração de contratos, contudo, permanece o empresário com uma só personalidade perante o direito, que é a da pessoa natural: "Isso, ainda, *in casu*, é possível, sem qualquer retificação do contrato celebrado, porque em conjunto com a indicação da firma e do CNPJ foi, de forma expressa, qualificado o devedor, que é pessoa natural, com o seu nome, RG e CPF, como se verifica logo abaixo da assinatura que lançou na cédula sob a rubrica de emitente"⁵²⁸.

5. Sociedades sem registro

Estabelece o art. 45 do Código Civil que: "Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo".

Assim, sempre deverá o oficial exigir que a sociedade que se apresenta adquirindo bens imóveis e direitos comprove sua constituição no competente Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial, conforme o tipo societário.

Antes do registro no órgão competente, falta-lhe capacidade jurídica, devendo o oficial obstar qualquer ato da sociedade: "O que cumpre observar 'ab

⁵²⁶ CSMSP. Apelação Cível nº 053339-0/0. Data: 29/11/1999. Localidade: Sorocaba. Relator: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵²⁷ CSMSP. Apelação Cível nº 523-6/9. Data: 25/5/2006. Localidade: Jundiaí. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J. de 28/07/2006.

⁵²⁸ CSMSP. Apelação Cível nº 1.065-6/5. Data: 3/3/2009. Localidade: Nhandeara. Relator: Ruy Pereira Camilo. Publicado no D.J.E. de 8/5/2009. Disponível em: <www.arisp.com.br> (kollemata).

initio', todavia, é que o Sindicato (...), cujo ato constitutivo não foi registrado, apelou em nome próprio, o que não se mostra admissível, uma vez que não dispõe de existência legal, nem, 'ipso facto', de capacidade postulatória. É o que dimana da letra do artigo 119 da Lei nº 6.015/73: 'A existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro de seus atos constitutivos'. Disso não discrepa o artigo 45 do Código Civil. Logo, tratando-se de recorrente que não ostenta personalidade e nem sequer existe perante o ordenamento, inviável se mostra conhecer do recurso interposto"⁵²⁹.

Mas caso haja registro de aquisição de imóvel por pessoa jurídica que se descubra ser sociedade de fato, não poderá ser transmitido pelos sócios de fato antes de regularizada sua situação jurídica: "Ademais, se dos assentamentos constantes no Cartório Imobiliário, a propriedade figura em nome da sociedade, apenas esta poderá dispor dos bens, em observância ao princípio da continuidade, salvo se ocorrer a sua dissolução, com os atos registrários pertinentes. Além disso, como já frisou, com inegável acerto, a decisão atacada, 'não cabe ao Oficial reconhecer a existência de sociedade de fato, nem a eficácia dos atos em seu nome praticados. Não lhe compete decidir, qual órgão jurisdicional, se o sócio da sociedade de fato pode, em nome próprio, dispor do patrimônio social. Não pode ainda aceitar a identidade entre o patrimônio da sociedade e o dos sócios. Não é de sua atribuição por fim aceitar a regularidade ou irregularidade da sociedade'. Se o imóvel está registrado em nome de pessoa jurídica, a aparência que resulta do registro é suficiente para que o Oficial só admita as disposições em seu nome feitas"⁵³⁰.

Para a regularização da titularidade de bem eventualmente em nome de sociedade irregular já extinta, "necessária a instauração das vias ordinárias, para o reconhecimento da sua existência de fato, extinção e apuração de bens e direitos"⁵³¹.

6. Fundos de Investimento Imobiliário

Também desprovidos de personalidade jurídica são os fundos de investimento imobiliário, o que é expressamente indicado no art. 1º da Lei 8.668/93: "Ficam instituídos Fundos de Investimento Imobiliário, sem personalidade

⁵²⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 391-6/5. Data: 8/9/2005. Localidade: Guairá. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵³⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 002949-0/83. Data: 7/12/1983. Localidade: São Paulo. Relator: Bruno Affonso de André. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵³¹ CSMSP. Apelação Cível nº 058836-0/4. Data: 9/12/1999. Localidade: Jacaré. Relator: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados a aplicação em empreendimentos imobiliários".

Assim, não devem ser registrados imóveis em nome do fundo, sendo os bens adquiridos "pela instituição administradora, em caráter fiduciário"⁵³², bens que, no entanto, não se comunicam com o patrimônio da administradora, constituindo patrimônio do fundo, o que deve constar de averbação no Registro de Imóveis, que indicará ainda as seguintes restrições quanto aos bens e direitos adquiridos: I - não integram o ativo da administradora; II - não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da instituição administradora; III - não compõem a lista de bens e direitos da administradora, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial; IV - não podem ser dados em garantia de débito de operação da instituição administradora; V - não são passíveis de execução por quaisquer credores da administradora, por mais privilegiados que possam ser; VI - não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre os imóveis, e que o bem adquirido constitui patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário⁵³³.

7. Cartório

Sobre esse tema não se poderia deixar de tratar também dos próprios cartórios, que igualmente não têm personalidade jurídica: "Sem que, destarte, a partir da Lei 8.935 se possa identificar um cartório, criado por lei, ocupado por servidor titular de cargo, de um lugar na Administração. Ao contrário, evidenciou-se o exercício de um serviço público por um particular a quem, por concurso, se delega o seu exercício. Se é assim, não se pode cogitar de uma unidade com personalidade própria a quem sejam afetos direitos e obrigações, menos ainda comunicáveis a seus titulares. As obrigações atinentes ao serviço extrajudicial quem as possui é a pessoa do delegado ou, na vacância, o Estado, afinal seu titular"⁵³⁴.

8. CNPJ de entes sem personalidade jurídica

Importante observar que a mera detenção de CNPJ não significa que a entidade tenha personalidade, sendo o cadastro fiscal obrigatório inclusive para os entes sem personalidade jurídica⁵³⁵.

⁵³² Art. 6º da Lei 8.668/93.

⁵³³ Art. 7º, § 2º, da Lei 8.668/93.

⁵³⁴ CGJSP. Processo 000855/2003. Data: 16/10/2003. Localidade: São Paulo. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵³⁵ Art. 11 da IN RFB 1.005 de 8 de fevereiro de 2010.

CAPÍTULO VI

ATOS NÃO REGISTRÁVEIS

Os atos não registráveis têm em comum o fato de não constituírem direitos reais ou não estarem elencados no rol do art. 167 da Lei 6.015/73, ou em outros dispositivos legais, o que os impede de ingressar no Registro de Imóveis.

Isso não significa que não possam ganhar publicidade a fim de serem opostos em relação a terceiros, mas nesses casos o registro deverá ser feito no Registro de Títulos e Documentos, conforme estabelece o parágrafo único do art. 127 da Lei 6.015/73: "Caberá ao Registro de Títulos e Documentos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício".

As hipóteses mais comuns de atos não registráveis que surgem no Registro de Imóveis são apresentadas a seguir.

1. Promessa de Dação

Conforme estabelece o Código Civil, a dação em pagamento ocorre quando o credor consente em receber prestação diversa da que lhe é devida⁵³⁶. O registro da dação em pagamento de bem imóvel ou direito a ele relativo tem previsão expressa no art. 167, I, 31 da Lei 6.015/73.

No entanto, situação diversa existe no caso de promessa de dação em pagamento de bem imóvel. Esses títulos costumam ser apresentados no Registro de Imóveis na forma de instrumentos de confissão de dívida e promessa de dação em pagamento ou de compromisso de venda e compra com promessa de dação em pagamento, mas, as promessas de dação, por não gerarem direitos reais, não podem ingressar no Registro de Imóveis.

É esse o entendimento do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo: "Evidente que na promessa de dação em pagamento não se verifica a extinção da dívida, não há transferência do bem, permanecendo na esfera de direito pessoal e não real, daí não estar incluído dentre os títulos que podem ter ingresso no registro. Tratando-se de direito pessoal que desembocará na aquisição de um direito real, fica fora do registro, pelo simples fato de nada acrescentar à sua eficácia, nenhum efeito produz o ingresso ao fôlio,

⁵³⁶ Art. 356 do CC.

continua sendo direito pessoal, que se descumprido ensejará ação de indenização por perdas e danos, mesmo que se registrada estivesse"⁵³⁷.

E isso decorre dos direitos reais serem taxativos e “só se estabelecem nos casos definidos em lei, que não podem ser ampliados pela vontade das partes. A promessa de dação em pagamento só confere direito pessoal, não se prestando à transmissão do domínio, nem confere direito real a seu beneficiário. Não tendo o efeito de alterar o registro, a promessa de dação em pagamento não pode, igualmente, ser objeto de averbação”⁵³⁸.

Esse impedimento não foi alterado pelo art. 463, parágrafo único, do Código Civil de 2002, que, ao tratar dos contratos preliminares, estabeleceu que: “O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente”: “Não se diga, ademais, com respeito ao entendimento contrário, que o artigo 463, parágrafo único, do Novo Código Civil tenha mudado o apontado panorama, pois se reportou genericamente à previsão de ‘registro competente’ de ‘contrato preliminar’ sem especificação alguma, quer de registro, quer de contrato; logo, essa norma legal não tem força alguma para alargar o rol dos direitos reais de publicidade imobiliária ou para autorizar transposição de direito: de pessoal para real. Com efeito, ao prescrever, em redação genérica, respeitou-se a natureza própria de cada direito que cada pré-contrato pode gerar. Por exemplo: promessa de compra e venda (‘contrato preliminar’), que pode gerar direito real de aquisição, comporta registro imobiliário (‘registro competente’); todavia, promessa de dação em pagamento (‘contrato preliminar’), que não gera direito real, mas apenas pessoal, não é suscetível de inscrição imobiliária, admitindo-se tão-somente a inscrição em registro de títulos e documentos (‘registro competente’)”⁵³⁹.

2. Novação

Da mesma forma que a promessa de dação em pagamento não pode ser registrada, a substituição de uma dívida por uma obrigação de venda futura também gera apenas direito de crédito e, por isso, não ingressa no Livro 2.

Analisando essa hipótese, o CSMSP distinguiu a novação da dação em pagamento: “Convencionaram as partes, porém, a extinção da obrigação pecuniária e sua substituição por uma nova (*obligatio faciendi*), consistente da venda

⁵³⁷ CSMSP. Apelação Cível nº 084-6/4. Data: 1/12/2003. Localidade: Tanabi. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵³⁸ CSMSP. Apelação Cível nº 002272-0/83. Data: 13/07/1983. Localidade: São Paulo. Relator: Bruno Affonso de André. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵³⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 499-6/8. Data: 18/5/2006. Localidade: São Paulo. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J. de 30/06/2006.

futura de um imóvel. Não há, assim, falar em pagamento, porque se operou o desaparecimento do vínculo preexistente, mas sem a devida prestação. Houve apenas o nascimento de outro vínculo, criado com a finalidade simultânea de extinguir a primeira e fazer nascer uma segunda obrigação. É o que se denomina novação, a teor do artigo 999 do Código Civil⁵⁴⁰. O negócio foi próximo a uma dação em pagamento, com a sutil diferença (essencial para distinguir os negócios) de que não houve a entrega de uma coisa por outra, com imediata transferência do domínio do bem que é seu objeto, mas simples substituição de uma obrigação de dar (pecuniária) por uma nova obrigação de fazer (firmar contrato definitivo). (...) Em suma, o negócio jurídico da novação pode gerar aos recorrentes direito de crédito e execução específica para obtenção de sentença substitutiva da vontade da devedora em firmar o contrato definitivo. Somente então haverá título hábil para a criação de direito real e consequente ingresso no assento imobiliário”⁵⁴¹.

3. Promessa de Permuta

Conforme estabelece o art. 533 do CC, aplicam-se à permuta as regras referentes à compra e venda. Em decorrência disso, já se aceitou que se registrasse título de promessa de permuta de bem imóvel, por aplicação do art. 167, I, 9, da Lei 6.015/73: "Nada impede que a promessa de permuta, embora não expressamente contemplada no inciso I do artigo 167 da Lei 6.015/73, ingresse no fôlio registral. Cuida-se de figura contratual análoga à promessa de venda e compra e, desde que irretratável e irrevogável, passível de constituir direito real de aquisição. A similaridade dos contratos preliminares guarda regra simétrica aos contratos principais de venda e compra e da troca, regidos por regras comuns (art. 1.164 do Código Civil⁵⁴²). Isso porque a permuta, como é corrente, nada mais significa que duas vendas recíprocas e simultâneas entre as mesmas partes permutantes, representando o valor de uma das coisas permutadas, o preço, ou parte do preço, da alienação da outra. De igual modo, a promessa de permuta representaria duas promessas recíprocas e simultâneas de venda (Valmir Pontes, Registro de Imóveis, Editora Saraiva, 1982, pág. 91)"⁵⁴³.

Esse entendimento, no entanto, encontra-se ultrapassado, sendo o mais atual posicionamento contrário ao registro: "correta, ainda, a recusa do ingres-

⁵⁴⁰ Art. 360 do CC de 2002.

⁵⁴¹ CSMSP. Apelação Cível nº 040017-0/0. Data: 17/2/1998. Localidade: São Paulo. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵⁴² Art. 533 do CC de 2002.

⁵⁴³ CSMSP. Apelação Cível nº 037727-0/3. Data: 2/7/1997. Localidade: Itu. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

so do título no registro, já que o compromisso de permuta não está discriminado no rol de títulos registráveis do art. 167, I, da Lei nº 6.015/1973"⁵⁴⁴.

E como a promessa de compra e venda é registrável, mas a promessa de permuta não, é essencial distinguir a permuta da compra e venda quando parte do pagamento é feito em bens.

O mesmo Acórdão que negou acesso ao registro da promessa de permuta abordou esse tema:

"No caso, como se verifica, a contraprestação estipulada, a cargo da apelante, não foi o pagamento do preço em dinheiro, mas a entrega de outro imóvel. Tal circunstância afasta a caracterização da promessa de venda e compra, evidenciando que o que as partes firmaram foi verdadeiro compromisso de permuta de imóveis.

Conforme ensina Orlando Gomes:

‘O preço [no contrato de compra e venda] é a 'quantia' que o comprador se obriga a pagar ao vendedor. Elemento natural do contrato, 'sine pretio nulla venditio', dizia Ulpiano.

Deve consistir em 'dinheiro'. Se é outra coisa, o contrato define-se como 'permuta' ou 'troca'. Não se exige, contudo, que seja exclusivamente dinheiro, bastando que constitua a parcela principal. Para se saber se é 'venda' ou 'troca', aplica-se o princípio 'major pars ad se minorem trahit'; venda, se a parte em dinheiro é superior; troca, se é o valor do imóvel' (Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 245 e ss.)"⁵⁴⁵.

4. Promessa de Instituição de Usufruto

Embora o registro do usufruto⁵⁴⁶ esteja previsto expressamente no art. 167, I, 7 da Lei 6.015/73, não é possível registrar título no qual o proprietário celebre promessa de instituição de usufruto, por não constituir direito real.

Esse é o entendimento do CSMSP: "O artigo 1.225, inciso VII, do Código Civil somente prevê como real o direito do promitente comprador do imóvel, e não é possível, em razão dos princípios da tipicidade e da taxatividade dos direitos reais, estender igual condição ao contrato de compromisso de compra e venda de usufruto que foi celebrado pelos apresentantes do título. Esta con-

⁵⁴⁴ CSMSP. Apelação Cível nº 480-6/1. Data: 23/3/2006. Localidade: Sorocaba. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J. de 20/06/2006.

⁵⁴⁵ CSMSP. Apelação Cível nº 480-6/1. Data: 23/3/2006. Localidade: Sorocaba. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J. de 20/06/2006.

⁵⁴⁶ Art. 1.391 do CC.

clusão não se altera pelo fato do usufruto também constituir direito real, pois aos particulares não é dado modificar e conjugar o conteúdo de dois direitos reais distintos, que são o compromisso de compra e venda de imóvel e o usufruto, para desta forma criar um direito real novo (compromisso de compra e venda de usufruto). (...) A ausência de previsão legal, portanto, impede o registro do contrato de compromisso de compra e venda de usufruto, como foi corretamente reconhecido na r. decisão apelada"⁵⁴⁷.

Sobre esse tema não se pode deixar de ressaltar que embora o usufruto possa ser instituído por ato oneroso, o usufrutuário não pode alienar o usufruto: "Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso "⁵⁴⁸. Quanto à cessão do exercício do direito de usufruto, esta também não pode ser registrada por gerar apenas direito pessoal.

Por outro lado, é possível a transmissão do usufruto ao nu-proprietário e também a transmissão da nua-propriedade e do usufruto à mesma pessoa, ambas hipóteses que resultam na extinção do usufruto pela consolidação⁵⁴⁹: "A norma genérica de impedimento da transmissão do usufruto, decorre da natureza do instituto, que é a de não se perpetuar, visto constituir direito personalíssimo. Ora, nada, porém, impede que o proprietário aliene o domínio e os usufrutuários o usufruto à mesma pessoa, já que se consolidará neste adquirente a propriedade da coisa"⁵⁵⁰.

5. Cessão de Direitos Hereditários

A cessão de direitos hereditários está prevista no art. 1.793 do Código Civil, que estabelece que "O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública".

No entanto, a cessão de direitos hereditários não ingressa no Registro de Imóveis, isso porque, embora o domínio se transfira aos herdeiros pela simples abertura da sucessão, dele não podem dispor enquanto não promovam o registro da partilha⁵⁵¹, não tendo a cessão de direitos hereditários o "efeito de

⁵⁴⁷ CSMSp. Apelação Cível nº 282-6/8. Data: 20/4/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵⁴⁸ Art. 1.393 do CC.

⁵⁴⁹ Art. 1.410, VI, do CC.

⁵⁵⁰ CSMSp. Apelação Cível nº 003278-0/84. Data: 29/06/1984. Localidade: Jaú. Relator: Heráclides Batalha de Camargo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵⁵¹ Apelação Cível nº 267.427. Localidade: Itapetininga - São Paulo, 31 de janeiro de 1978, Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da Justiça e Relator.

transferir o domínio dos bens do espólio, mas, tão-somente, o de transferir os direitos de sucessores, a serem apurados em inventário"⁵⁵².

Também se deve observar que o testamento não ingressa no registro de imóveis, estabelecendo expressamente o item 68.1, Cap. XX, das NSCGJSP que "O testamento não é título que enseje registro de transmissão", devendo ser registrado no cartório da vara da família e sucessões a que distribuído o correspondente inventário⁵⁵³, sendo o posterior formal de partilha ou carta de adjudicação o título hábil a ser apresentado no Registro de Imóveis⁵⁵⁴.

6. Escritura pública de partilha amigável e a Lei 11.441/07:

Embora antes mesmo do advento da Lei 11.441/07, o art. 2.015 do CC já estabelecesse que: "Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz", a redação antiga do art. 982 do CPC previa que o inventário seria sempre judicial "Proceder-se-á ao inventário judicial, ainda que todas as partes sejam capazes". Apesar da possibilidade que havia da partilha ser formalizada por escritura pública quando os herdeiros fossem capazes, o título a ser apresentado ao registro imobiliário não era a escritura, mas o formal de partilha extraído do processo judicial, o que deve ser observado pelo Oficial quando qualifica títulos antigos: "a faculdade conferida aos herdeiros capazes para celebrar partilha amigável por meio de escritura pública não afasta a necessidade de apresentação da escritura no inventário, para integrar o respectivo formal de partilha"⁵⁵⁵.

Contudo, em 4 de janeiro de 2007 entrou em vigor a Lei 11.441 que possibilitou a realização de inventário, partilha, separação e divórcio consensual por escritura pública, dando nova redação ao art. 982 do CPC:

“Art. 982. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial; se todos forem capazes e concordes, poderá fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário.

⁵⁵² Apelação Cível nº 275.009. Localidade: Taquaritinga – São Paulo, 22 de fevereiro de 1979, Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da Justiça e Relator.

⁵⁵³ Art. 1.126, parágrafo único, CPC.

⁵⁵⁴ Art. 1.027 do CPC e art. 221, IV, Lei 6.015/73.

⁵⁵⁵ CSMSP. Apelação Cível nº 161-6/6. Data: 29/6/2004. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Parágrafo único. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado comum ou advogados de cada uma delas, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.”

Assim, o inventário e a partilha de bens de herdeiros capazes podem atualmente ser feitos por escritura pública em Tabelionato de Notas, mediante assistência de advogado que deverá necessariamente estar presente ao ato, sendo que sua qualificação e assinatura constarão no instrumento lavrado. Entretanto, havendo testamento ou interessado incapaz, o inventário deverá ser obrigatoriamente judicial, a fim de preservar o interesse de quem não tem a capacidade e o discernimento indispensáveis ao ato.

O art. 1.031 do CPC também ganhou nova redação com o advento da referida lei:

“Art. 1.031. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos do art. 2.015 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, será homologada de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, com observância dos arts. 1.032 a 1.035 desta Lei.”

A nova disposição deste artigo levantou uma celeuma quanto à necessidade de homologação judicial da escritura de partilha amigável, se haveria a necessidade da homologação para todos os casos ou se somente nas hipóteses de obrigatoriedade do procedimento judicial, como no caso de haver testamento.

Apesar do artigo 1.031 não fazer ressalvas, não discriminando se a homologação aplica-se somente aos casos em que seja adotado o procedimento judicial, seria um contrassenso exigir a homologação judicial da escritura pública de partilha se não houver testamento e os interessados forem capazes, já que o intuito da referida lei é no sentido de desafogar o Judiciário e dar celeridade ao procedimento. Ainda, o referido dispositivo já se encontrava presente no CPC, e com o advento da Lei 11.441/07 apenas foi atualizada a redação que remete ao atual art. 2.015 do CC, permanecendo a norma na Seção IX do Capítulo IX que trata do arrolamento.

7. Arrendamento

O arrendamento é expressamente elencado como ato não registrável no item 68.3 do Capítulo XX das NSCGJSP, não ingressando no fôlo real: "Os direitos reais, sim, se estabelecem em tipos definidos por lei, consoante ‘numerus clausus’ outro qualquer, ainda que assemelhado, não possuirá tal natureza, descabido o recurso à analogia para a imputação extensiva do atributo. ‘Assim, o direito que o proprietário concede ao rendeiro de construir no ter-

reno dado em arrendamento, embora assemelhável ao direito real de superfície, assim não se configura, uma vez que o Código não o contemplou. (...) Em suma, no direito brasileiro, a exemplo do que ocorre noutros sistemas, como nos Códigos francês e alemão, os direitos reais enumerados na lei não podem ser ampliados pela vontade das partes (Lafayette, 'Direito das Coisas', Prefácio, nº 4; Caio Mário Da Silva Pereira, 'Instituições', vol. 4, pg. 12; Orlando Gomes, 'Direitos Reais', pg. 398)' - (CSM, Apelação Cível nº 2.272-0-SP, j. 13.06.83, rel. Des. Bruno Affonso de André)⁵⁵⁶".

Deve-se observar nesse tema a distinção entre arrendamento e locação, esta com previsão de acesso ao Registro de Imóveis: "Feita uma comparação entre os contratos de locação e arrendamento rural, é evidente e inquestionável que dois tipos diversos foram construídos pelo legislador e introduzidos no ordenamento positivo. Com relação ao segundo destes tipos, o índice de tipicidade, como elemento individualizador, se corporifica no objeto do contrato, apontado pelos artigos 92 e 95 da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), que só tem lugar diante do exercício, em imóvel rural, de atividade agrícola ou pecuária e quando possível a identificação deste traço característicos, efeitos específicos se produzem. Assim, o exame de cláusula de vigência, lembrada pelo próprio apelante, demonstra a afirmada diferenciação típica entre os contratos de locação e arrendamento rural. Se, na locação, essa cláusula é facultativa e depende, para sua validade, da consecução de um ato de registro (artigos 1.197 do Código Civil pátrio⁵⁵⁷ e 167, inciso I, 3 da Lei 6.015/73), ela é dispensável no arrendamento rural, dada a existência de norma cogente, prevalecendo, independente da vontade das partes negociais ou de qualquer ato de registro, a continuidade da vigência do contrato, mesmo diante da alienação ou da imposição de ônus real sobre o imóvel rural (artigo 92, parágrafo 5 da Lei 4.504/64). Somam-se as duas argumentações acima deduzidas, para que se firme que, tendo o artigo 167, inciso I, 3 da Lei 6.015/73 previsto, expressamente, apenas o registro de contratos de locação, não se pode expandir tal previsão com a finalidade de abarcar, analogicamente, tipo contratual diverso, ainda que este último ostente várias características similares à locação"⁵⁵⁸.

Ressalte-se que o arrendamento residencial objeto da Lei 10.188/01, que instituiu o Programa de Arrendamento Residencial, é passível de registro no Cartório de Registro de Imóveis por expressa determinação legal: "o contrato de aquisição de imóveis pelo arrendador, as cessões de posse e as promessas

⁵⁵⁶ CSMSP. Apelação Cível nº 499-6/8. Data: 18/5/2006. Localidade: São Paulo (4º SRI). Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J. de 30/06/2006.

⁵⁵⁷ Art. 576 do CC de 2002.

⁵⁵⁸ CSMSP. Apelação Cível nº 032930-0/3. Data: 21/11/1996. Localidade: Marília. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

de cessão, bem como o contrato de transferência do direito de propriedade ou do domínio útil ao arrendatário, serão celebrados por instrumento particular com força de escritura pública e registrados em cartório de Registro de Imóveis competente"⁵⁵⁹. Da mesma forma o arrendamento imobiliário especial com opção de compra previsto na Lei 10.150/00⁵⁶⁰.

8. Posse

A posse por ser uma situação de fato, um estado de aparência, também não é objeto de registro no fôlio real, mas a Lei 6.766/79 traz a possibilidade de registro de uma posse concedida judicialmente nos casos de parcelamento popular.

A posse não é direito real, não sendo relacionada no art. 1.225 do Código de Civil de 2002, nem é elencada no rol do art. 167 da Lei 6.015/73, motivo pelo qual não ingressa no Registro de Imóveis: "a posse não é entre nós, direito registrável, por opção do legislador, que delimitou as funções do registro predial às do repositório da propriedade imobiliária, e dos direitos registráveis. Eles são unicamente aqueles abstrata e expressamente contemplados como tal no direito positivo, e não há previsão legal para o registro de aquisição de direitos possessórios"⁵⁶¹.

E por não ser a posse registrável, não ingressa no registro imobiliário o contrato de comodato, que apenas transmite posse, sendo também expressamente relacionado como ato insuscetível de registro no item 68.3 do Capítulo XX das NSCGJSP.

Apesar da posse não ser um estado de direito, mas simplesmente uma situação de fato, por vezes é necessário que seja concedida a ela uma proteção jurídica especial, em razão de um interesse social, sendo que a segurança jurídica concedida à aquisição de imóveis dá-se justamente com o registro do título. Assim, apesar de não ser um direito real, e não estar elencada no artigo 167 da Lei 6.015/73, o legislador entendeu ser cabível seu ingresso no fôlio real no caso previsto no art. 18, § 5º, da Lei nº 6.766/79, que estabelece que na hipótese de parcelamento popular o registro do loteamento "será instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a imissão provisória na posse". O ilustre Silvio de Salvo Venosa explica bem essa necessidade de tutela do instituto possessório:

⁵⁵⁹ Art. 8º da Lei 10.188/01.

⁵⁶⁰ Art. 41 da Lei 10.150/00.

⁵⁶¹ CSMSP. Apelação Cível nº 013191-0/0. Data: 15/10/1991. Localidade: Pereira Barreto. Relator: Onei Raphael. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

“Embora não se coloque a aparência no estado de categoria jurídica, aparência e posse devem ser examinadas do ponto de vista axiológico. Tanto numa como noutra, a segurança das relações sociais justifica a proteção de situações, não de direitos adquiridos, mas de direitos prováveis. Defende-se a posse porque é uma situação de fato que provavelmente envolve um direito. Como examinaremos, essa proteção provisória da posse concedida pelo ordenamento poderá ter palavra final acerca do direito real, propriedade ou outro de menor extensão, no juízo petitorio, quando então não mais se discutirá a posse, mas o domínio⁵⁶²”.

A Lei 11.977 de 7 de julho de 2009 que dispõe sobre o **Programa Minha Casa Minha Vida**, elaborado com a finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda mensal de até 10 salários mínimos, residentes no Brasil⁵⁶³, prevê expressamente em seu artigo 58 que os títulos de legitimação de posse concedidos em decorrência da demarcação urbanística, deverão ser registrados⁵⁶⁴ na matrícula do imóvel, explicitando em seu artigo 59 que esse registro constitui direito em favor do detentor da posse direta para fins de moradia, observados os requisitos necessários para a sua concessão. Mas a grande novidade se apresenta em seu artigo 60, que prevê a possibilidade do detentor que levou seu título a registro, requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão da posse em propriedade, observado o prazo de 5 anos da data do registro do título da legitimação de posse e demais requisitos, adquirindo tal propriedade pela usucapião. Assim, pela redação do dispositivo, parece-nos que o reconhecimento da usucapião dispensará qualquer procedimento judicial, conferindo tal atribuição ao Oficial de Registro de Imóveis, que simplesmente pela constatação da decorrência do prazo legal e regularidade na documentação apresentada mediante requerimento, promoverá em seguida ao ato do registro da legitimação da posse, um ato de conversão da posse em propriedade em favor do então mero possuidor.

9. Protesto Contra a Alienação de Bens

Estabelece o art. 867 do CPC: "Todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de

⁵⁶² VENOSA, Sílvio de Salvo. *Direito civil: direitos reais*. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 43.

⁵⁶³ Artigo 2º do PMCMV.

⁵⁶⁴ Artigo 167, I, 41, da Lei 6.015/73, alterado pela Lei 11.977/2009.

direito". No entanto, como estabelece o art. 871 do CPC "O protesto ou interpelação não admite defesa nem contraprotesto nos autos; mas o requerido pode contraprotestar em processo distinto", estabelecendo ainda o art. 870, I, do CPC que "far-se-á a intimação por editais: I - se o protesto for para conhecimento do público em geral, nos casos previstos em lei, ou quando a publicidade seja essencial para que o protesto, notificação ou interpelação atinja seus fins".

O entendimento pacificado na jurisprudência era o de que a publicidade do protesto contra a alienação de bens dava-se com a publicação do edital, e não pelo Registro de Imóveis: "A jurisprudência da Terceira Turma desta Corte é pacífica no sentido de que a averbação do protesto no registro imobiliário malfez a disciplina jurídica dos artigos 869 e 870 do Código de Processo Civil. (...) 'O protesto, como está previsto no Código de Processo Civil é medida voluntária em procedimento unilateral que não serve para acrescentar ou diminuir direitos. O parágrafo único do artigo 870 autoriza o protesto contra alienação de bens facultando ao Juiz ouvir aquele contra quem foi dirigido e prevendo a publicação de editais. Não há qualquer referência à averbação no registro de imóveis. Muito menos, a lei especial não prevê essa modalidade de averbação. (...) Não serve, a meu juízo, para justificar a determinação judicial de averbação, o poder geral de cautela, eis que não é possível admiti-lo quando a regra jurídica própria acolhe outra solução que, igualmente, repousa na prudente discricção do Juiz. Permitir a averbação equivale a construir dificuldade para a eventual realização de negócio, sem oportunidade de revisão, diante do procedimento especial acolhido para o protesto. E a regra dos artigos 869 e 870 do Código de Processo Civil não acobertam a medida. Destarte, eu conheço do recurso pela alínea a) e dou-lhe provimento para determinar o cancelamento da averbação' (REsp n 73.662/MG, Terceira Turma, DJ de 23/6/97)"⁵⁶⁵.

Por esses motivos as NSCGJSP relacionavam o protesto contra alienação de bens como ato insuscetível de registro⁵⁶⁶, não era permitido adotar para esse título nem mesmo o procedimento previsto no Provimento CG 17/99 para os mandados judiciais que não contem com previsão legal específica para ingresso no registro imobiliário, mas que determinem a indisponibilidade de qualquer bem imóvel, conforme dispunha o item 102.11.

⁵⁶⁵ STJ. REsp 606.261. Data: 13/6/2005. Localidade: Paraná. Terceira Turma. Relator: Carlos Alberto Menezes Direito.

⁵⁶⁶ Item 68.3 do Cap. XX das NSCGJSP.

Contudo, em 13 de julho de 2007, o ilustre Corregedor Geral de Justiça de São Paulo⁵⁶⁷, aprovando parecer proferido pelo M.M. Juiz Auxiliar da Corregedoria⁵⁶⁸, determinou a alteração do item 68.3 das NSCGJSP, admitindo a averbação do protesto contra a alienação de bens diante de determinação judicial expressa do juiz do processo, em decorrência de entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que admitiu a referida averbação como expressão do poder geral de cautela do juiz e em respeito ao princípio da publicidade (REsp nº 440.837-RS)⁵⁶⁹.

10. Multipropriedade

A multipropriedade, também denominada de tempo compartilhado (*time sharing*), é uma forma de condomínio no qual os coproprietários têm direito limitado de uso do imóvel por determinado tempo, segundo turnos de desfrute.

Exemplo simples de multipropriedade é a aquisição de um imóvel localizado em estância turística por várias pessoas que estabelecem entre si o uso exclusivo do imóvel, por cada proprietário, pelo período de algumas semanas por ano, conforme tabela definida por eles. A vantagem da multipropriedade é a possibilidade de compartilhar as despesas de aquisição e manutenção do bem com o uso exclusivo por determinado período de tempo.

Os contratos de tempo compartilhado não possuem previsão legal no Brasil, havendo apenas Deliberação Normativa da Embratur a respeito⁵⁷⁰, que aborda somente o sistema de tempo compartilhado em meios de hospedagem de turismo.

Embora a copropriedade possa ser lançada no fôlio real, as limitações temporais do uso do imóvel, por serem obrigações de caráter pessoal, não podem ser registradas ou averbadas: "desqualificação decorrente de causa irreregistrável, ou seja, da irreregistrabilidade *in abstracto* da causa (v.g. posse, multipropriedade, cessão de direito hereditário, promessa de permuta, de doação e de dação em pagamento), abarca, por imperativo lógico de coerência, qualquer tipo de inscrição predial (registro ou averbação)"⁵⁷¹.

⁵⁶⁷Desembargador Gilberto Passos de Freitas.

⁵⁶⁸Dr. Vicente de Abreu Amadei.

⁵⁶⁹CGJSP. Processo CG-485/2007 publicado no D.O.J. em 18/7/2007.

⁵⁷⁰ Deliberação Normativa Embratur 378/97.

⁵⁷¹ CSMSP. Apelação Cível nº 499-6/8. Data: 18/5/06. Localidade: São Paulo. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J. em 30/06/2006.

11. Sucessão Provisória

A sucessão provisória do ausente é estabelecida no art. 26 do CC: "Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou, se ele deixou representante ou procurador, em se passando três anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão".

Essa sucessão, no entanto, por não transmitir direito real, não é lançada no Registro de Imóveis.

Analizando esse tema, assim se manifestou o CSMSP: “No caso em tela, expediu-se carta de adjudicação, cujo registro se persegue, ainda em fase de sucessão provisória dos bens do ausente. Sucede que, neste instante, ainda não existe, em verdade, transmissão dominial que o justifique. Explica-se. A partir de e enquanto se processa a sucessão provisória, a ideia do legislador foi, claramente, a de apenas possibilitar a imissão dos herdeiros na posse dos bens, a fim de administrá-los, sempre na expectativa, ainda, da volta do ausente (v.g. Sílvio Rodrigues, *Direito Civil*, Saraiva, 32ª ed., vol. 1, p. 79-81). (...) Veja-se portanto que, às escancaras, o legislador veda a disponibilidade dos herdeiros sobre os bens, quando ainda se processa sua sucessão provisória. (...) Na realidade, é com a sucessão definitiva que os herdeiros adquirem o domínio dos bens do ausente, e mesmo assim sob condição, a de o titular retornar em dez anos e retomar seu patrimônio, no estado em que se encontrar (art. 1.168 do CPC). (...) Ou seja, injustificado o registro da carta de adjudicação ainda na fase da sucessão provisória, à míngua de transmissão dominial ou mutação real qualquer que o autorize, e o que cabe nesta esfera aferir, sabido que os títulos judiciais não se forram à qualificação registrária”⁵⁷².

⁵⁷² CSMSP. Apelação Cível nº 093962-0/5. Data: 30/10/2002. Localidade: São Paulo. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

CAPÍTULO VII

**DOCUMENTOS
DE IDENTIFICAÇÃO**

Seja nos títulos públicos, particulares ou judiciais apresentados a registro, a completa qualificação das pessoas envolvidas nos lançamentos é essencial, devendo o registrador exigir a perfeita identificação das pessoas, mesmo que não tenham apresentado documentos de identidade na lavratura do ato notarial⁵⁷³, sempre exigindo a complementação das informações para o registro, a fim de cumprir as disposições específicas da Lei de Registros Públicos (princípio da especialidade subjetiva).

Tratando-se de pessoa física, o artigo 176, § 1º, II, 4, e III, 2, da Lei 6.015/73 exige que todas as partes, sejam os transmitentes, adquirentes, credores ou devedores, estejam identificadas pelo nome, domicílio, nacionalidade, estado civil, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) e do Registro Geral da cédula de identidade (RG).

As Normas de cada Estado têm ampliado essa exigência também para o cônjuge dos participantes do ato a ser registrado⁵⁷⁴.

Embora a Lei 6.015/73 indique a alternativa de ser a pessoa física identificada pelo número do RG ou CPF, ou ainda, na falta destes, pela filiação, atualmente, tendo o cartão de CPF se tornado obrigatório, não há mais alternativa, devendo ser indicados os números de identificação de ambos os documentos nos livros de registro.

No caso de pessoas jurídicas, o art. 176 da Lei 6.015/73 exige a indicação, além da denominação ou razão social, da nacionalidade, sede social e número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Havendo omissão de dados nos títulos apresentados, ou sendo necessário corrigi-los, e desde que não haja dúvida sobre a identificação das pessoas, é possível complementar ou corrigir os dados com a apresentação de cópia autenticada dos documentos de identidade:

“Comprovado com a exibição de cópia autenticada da cédula de identidade, que no título apresentado há um erro datilográfico, quando fez referência ao número do RG, esse erro pode ser corrigido”⁵⁷⁵.

⁵⁷³ Art. 215, § 5º, do CC.

⁵⁷⁴ Item 52 do Capítulo XX das NSCGJSP.

⁵⁷⁵ CSMSP. Apelação Cível nº 009489-0/6. Data: 27/6/1989. Localidade: São Paulo. Relator: Milton Evaristo dos Santos. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

1. Carteira de identidade – Registro Geral

A carteira de identidade, emitida pelos órgãos de identificação dos Estados e do Distrito Federal, é o documento de identificação do brasileiro e do português residente no País beneficiado pelo Estatuto da Igualdade⁵⁷⁶.

É esse o documento exigido pela Lei de Registros Públicos como identificação a ser lançada nos livros de registro, estabelecendo o art. 176 da Lei 6.015/73 que deve ser lançado na matrícula e nos registros o “número do Registro Geral da cédula de identidade”, sendo o registro geral a distinção da carteira de identidade atualmente disciplinada pela Lei 7.116/83, que define o seu número de identificação como o “registro geral no órgão emissor”⁵⁷⁷, dos demais documentos de identidade. Denomina-se de registro geral, exatamente para se distinguir dos demais números de identificação específicos de determinadas categorias profissionais, que são exclusivos de cada entidade que os emite, não sendo abertos para inscrição a qualquer brasileiro, nem tendo validade indeterminada, como ocorre em regra com o registro geral emitido pelos órgãos de identificação dos Estados.

1.1. Modelos antigos de carteiras de identidade

A validade das carteiras de identidade em modelos anteriores ao estabelecido pela Lei 7.116/83, regulamentada pelo Decreto 89.250/83, foi mantida⁵⁷⁸, sendo documentos válidos de identificação, porém, deve o registrador recusá-los quando, em decorrência da antiguidade das fotos, não for mais possível vincular o documento apresentado à pessoa que o porta. Também não podem ser aceitas quando em decorrência de seu estado de conservação, o documento encontre-se deteriorado de forma a comprometer a segura verificação da autenticidade do documento e perfeita identificação da pessoa. A validade mantida pela lei não implica na possibilidade de sua utilização indeterminada se situações concretas impedirem que mantenha sua finalidade: a segura identificação do portador.

Também com essa preocupação a CGJSP vedou expressamente a aceitação de documento de identidade replastificado, haja vista que essa prática pode, por exemplo, permitir a substituição da foto no documento⁵⁷⁹.

⁵⁷⁶ Lei 7.116/83 e Decreto 89.250/83.

⁵⁷⁷ Art. 3º, d, da Lei 7.116/83.

⁵⁷⁸ Art. 11 da Lei 7.116/83.

⁵⁷⁹ Provimento CG 25/2006 – D.O.J. de 20/10/06.

1.2. Extração de dados das carteiras de identidade

Das carteiras de identidade RG pode-se extrair mais informações do que apenas o número do registro geral, estabelecendo o art. 6º da Lei 7.116/83 que “a carteira de identidade fará prova de todos os dados nela incluídos, dispensando a apresentação dos documentos que lhe deram origem ou que nela tenham sido mencionados”. Como na carteira de identidade podem ser indicados diversos dados⁵⁸⁰, incluindo o número de inscrição no CPF, ela torna desnecessária a apresentação do cartão de inscrição de CPF quando seu número já for indicado no documento de identidade apresentado.

1.3. Estatuto da Igualdade e RG

Além dos brasileiros, natos ou naturalizados, também os portugueses beneficiados pelo Estatuto da Igualdade recebem documentos de identidade RG.

A igualdade de direitos está prevista na Constituição Federal, que estabelece que, salvo as exceções estabelecidas na própria Constituição, “aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro”⁵⁸¹. Essa igualdade não é automática, mas reconhecida caso a caso pelo Ministério da Justiça, através de portarias individuais, conforme estabelece o artigo 5º da Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses, promulgada pelo Decreto 70.391/72⁵⁸². Os portugueses que não tenham reconhecida a igualdade de direitos devem apresentar os documentos específicos de estrangeiros.

Assim, a apresentação de documento de identidade RG não comprova a nacionalidade brasileira, devendo ser observado para os naturais de Portugal se a portaria do Ministério da Justiça indicada no documento de identidade se refere à naturalização, ou ao reconhecimento da igualdade de direitos⁵⁸³, quando constará no campo documento de origem, além dos dados da portaria, a expressão “nacionalidade portuguesa”⁵⁸⁴ e a referência ao Decreto 70.391/72. Importante não confundir a naturalidade, também indicada no documento de identidade, e que é o local de nascimento da pessoa, com sua nacionalidade, já que esta pode ser adquirida por naturalidade ou por naturalização⁵⁸⁵. O portador de carteira de identidade RG só poderá ser brasileiro ou

⁵⁸⁰ Arts. 1º, e, 2º do Decreto 89.250/83, alterado pelo Decreto 1.233/94.

⁵⁸¹ Art. 12, § 1º, CF.

⁵⁸² Decreto Legislativo nº 82/71.

⁵⁸³ Art. 6º, parágrafo único, do Decreto 89.250/83.

⁵⁸⁴ Art. 5º da Lei 7.116/83.

⁵⁸⁵ Art. 12 da CF

português com igualdade de direitos reconhecida, mesmo que nascido em outro país (brasileiro naturalizado), já que os demais estrangeiros residentes no Brasil devem portar outro documento (cédula de identidade expedida pelo Ministério da Justiça).

1.4. Alteração do número de identidade

O pedido de averbação de alteração de numeração do registro geral de uma pessoa deve ser analisado com grande cuidado, haja vista a possibilidade de fraude.

A regra é de que o registro geral não é modificado durante toda a vida da pessoa, sendo mantido o mesmo número quando da emissão de segundas vias, porém, em algumas situações, é possível ser alterado.

A) Mudança de estado

A situação mais comum é a decorrente de mudança de domicílio para outro estado. Como o registro geral é emitido pelo órgão de identificação de cada estado, sua numeração é diferente em cada um, sendo que o prontuário, em um estado, ao se mudar e solicitar o documento em outro estado, recebe nova numeração.

Nesses casos é fundamental a comparação da filiação da pessoa para verificar se se trata da mesma pessoa. Especial cuidado deve ocorrer quando a pessoa tiver nome comum, como José da Silva, João Pereira, etc.

B) Substituição por duplicidade

No Estado de São Paulo diversos números de registro geral foram substituídos em decorrência da constatação de fornecimento dos mesmos números para pessoas diferentes. Nesses casos o instituto de identificação forneceu às pessoas que tiveram seus números anteriores cancelados declaração indicando o número anterior, o novo número e a identificação da pessoa pelo nome, filiação, naturalidade e data de nascimento.

2. Documento de estrangeiro

O documento de identificação do estrangeiro residente no País é a cédula de identidade expedida pelo Ministério da Justiça⁵⁸⁶, através da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras do Departamento da Polícia Federal

⁵⁸⁶ Art. 132 da Lei 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro).

(DPMAF/DPF), da qual deverá ser extraído o seu número de identificação no Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), que será lançado na matrícula.

2.1. Prazo de validade

Os documentos de estrangeiros têm prazo de validade, sendo no entanto dispensados da revalidação os estrangeiros com visto permanente e que tenham participado de cadastramento anterior, desde que tenham completado 60 anos até a data do vencimento do documento ou sejam deficientes físicos⁵⁸⁷.

Posteriormente, nova portaria⁵⁸⁸ do Ministério da Justiça dispôs que o estrangeiro residente na condição de permanente, cuja idade seja igual ou superior a 51 anos à época do registro, ou de qualquer idade, desde que portador de deficiência, será expedida Cédula de Identidade para Estrangeiro (CIE) com prazo de validade indeterminado.

A comprovação da regular situação do estrangeiro no País é imprescindível ao registrador, a fim de impedir que pessoas irregularmente em Território Nacional possam obter o registro de atos em delegações públicas.

2.2. Modelos antigos de carteiras de estrangeiros

Embora os documentos antigos de identidade de estrangeiros, tanto o denominado modelo 19⁵⁸⁹, como o modelo posterior⁵⁹⁰, não contivessem em seu corpo a indicação de prazo de validade, atualmente não podem mais ser utilizados⁵⁹¹, devendo ser exigida a apresentação da cédula de identidade de estrangeiro no modelo atual⁵⁹².

2.3. Implantação do Registro Nacional de Estrangeiros

Até a década de 80 os estrangeiros puderam usar documento de identidade com número de registro geral fornecido pelos órgãos estaduais, sendo o padrão de sua numeração igual ao dos documentos de identidade dos brasileiros e, por isso, quando de sua naturalização, o documento de identidade era alterado, mas sua numeração permanecia a mesma.

⁵⁸⁷ Art. 2º do Decreto-lei n.º 2.236/85, alterado pelas Leis 8.988/95 e 9.505/97.

⁵⁸⁸ Art. 2º da Portaria 2.524 de 17 de dezembro de 2008.

⁵⁸⁹ Art. 135 do Decreto 3.010/38.

⁵⁹⁰ Art. 1º do Decreto-lei 499/69.

⁵⁹¹ Art. 1º da Lei 6.735/79 e Portaria MJ 559/86.

⁵⁹² Art. 1º da Portaria MJ 526/95.

Após a adoção do Registro Nacional de Estrangeiro, foi adotado um novo padrão, uniforme em todo o País, composto de letras e números, que substituiu a numeração anterior.

“Como se verifica, o titular do domínio está qualificado nos assentamentos registrários como sendo portador da cédula de identidade número 2.516.846-SP, enquanto no contrato o locador Manoel dos Santos Silva foi qualificado como portador da cédula de identidade de estrangeiro número W 439.726. Nem a juntada da cópia desta última cédula esclarece os motivos da divergência. Ao contrário, traz forte insegurança sobre a identidade do locador, o que só pode ser superado pelo meio próprio, qual seja o da retificação do registro. Lembre-se que o nome do locador, Manoel dos Santos Silva é muito comum, o que inspira cuidados ainda maiores, pena de se por em risco a segurança dos assentamentos prediais”⁵⁹³.

2.4. Naturalização

No caso de naturalização, também há alteração no número de identificação da pessoa, que deixa de integrar o Registro Nacional de Estrangeiros, passando a receber número do registro geral do correspondente órgão estadual de identificação, sendo possível, ainda, a alteração do nome do naturalizando (art. 114 da Lei 6.815/80).

3. Carteira Nacional de Habilitação

A carteira nacional de habilitação (CNH) é documento de identidade, válido em todo território nacional⁵⁹⁴, porém, nos atos de registro deve ser indicado o número de RG, e não o número do condutor no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação.

O documento de habilitação identifica a pessoa, porém o número do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação não substitui o RG, isso porque a finalidade de lançamento do número de identificação da pessoa é poder identificá-la por um prazo indeterminado. A carteira nacional de habilitação é um documento que tem prazo de validade, só é renovada se não houver débitos do condutor, pode ser recolhida e até cassada em decorrência de infrações de trânsito e só é mantida enquanto a pessoa tenha aptidão física e mental para dirigir automóvel⁵⁹⁵, o que faz com que a pessoa hoje identificada pelo núme-

⁵⁹³ CSMSp. Apelação Cível nº 030763-0/6. Data: 7/6/1996. Localidade: Itapeverica da Serra. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁵⁹⁴ Art. 159 do Código de Trânsito (Lei 9.503/97).

⁵⁹⁵ Código de Trânsito (Lei 9.503/97).

ro de registro da CNH possa não tê-la no futuro quando necessite se identificar para, por exemplo, alienar o imóvel, daí a Lei de Registros Públicos determinar que a identificação seja pelo RG.

Do documento, porém, podem ser extraídos dados, como o número de CPF, mas não o número do RNE, haja vista ter prazo de validade que a CNH não indica, nem deve ser extraído o número de RG quando haja omissão do órgão expedidor ou não indique, nem distingue, o dígito verificador. De qualquer modo, só se pode extrair dados da carteira de habilitação se ela for apresentada dentro de seu prazo de validade, o que deve ser verificado.

4. Carteiras profissionais

As carteiras profissionais expedidas pelo órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional, são válidas em todo o País como prova de identidade, para qualquer efeito⁵⁹⁶.

Assim, não basta ser uma carteira profissional, mas deve ter sido emitida por órgãos controladores de exercício profissional, como OAB, CREA, CRM, CRECI, etc, e, portanto, não são aceitas carteiras de associações de classe, que não se confundem com os órgãos de fiscalização profissional. Importante observar que muitas profissões não têm conselhos de fiscalização, como, por exemplo, os jornalistas e publicitários.

Mas, embora sejam documentos de identidade válidos, a lei exige que nos registros seja lançado o número do registro geral das pessoas, e não o de inscrição no correspondente órgão fiscalizador, que também tem prazo de validade, e que permanecerá na posse da pessoa somente enquanto ela exercer aquela profissão, motivo porque deve ser extraído desses documentos o número do RG, que eles em regra também consignam, que deverá ser lançado nos atos.

5. Cartões de identidade funcional

Os cartões de identidade funcional, expedidos para os agentes públicos militares e civis em exercício no Poder Executivo Federal têm fé pública, podendo ser aceitos como documentos de identidade⁵⁹⁷. Desses documentos, no entanto, deve ser extraído o número do RG, e não do registro do servidor no correspondente órgão público, haja vista que não se confunde com o registro geral, de fácil extração do próprio cartão de identidade funcional, já que nele indicado, e também porque "a aposentadoria, exoneração, demissão ou qual-

⁵⁹⁶ Art. 1º da Lei 6.206/75.

⁵⁹⁷ Decreto nº 5.703 de 15 de fevereiro de 2006.

quer forma de cessação do exercício do agente público torna nulo, de pleno direito, o cartão de identidade funcional expedido, obrigando-se o identificado a restituí-lo, sob as penas da lei"⁵⁹⁸, impedindo sua identificação futura por esse documento caso indevidamente lançado seu número na matrícula ao invés do RG.

Da mesma forma os demais Poderes emitem documentos de identidade para seus servidores, igualmente dotados de fé pública.

6. Retificação judicial

A inserção ou alteração do número de registro geral pode ser realizada pelo oficial quando devidamente comprovada e observadas as cautelas necessárias, porém, na ausência de elementos seguros que permitam a identificação da pessoa, a alteração do elemento de qualificação poderá depender de despacho judicial, conforme estabelece o art. 213, I, g, da Lei 6.015/73, que determina que o oficial retificará o registro ou a averbação de ofício ou a requerimento do interessado no caso de “inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas”.

7. Cadastro de Pessoas Físicas – CPF

O número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, criado em 1968 pelo Decreto-lei 401/68, atualmente é elemento obrigatório em todos os atos lançados no Registro de Imóveis, estabelecendo o artigo 3º, inciso VI, da Instrução Normativa SRF 864/08 que participantes em qualquer operação imobiliária, não só de alienação, mas também de oneração do imóvel, devem possuir inscrição no CPF/MF, não mais havendo valor mínimo da operação para a obrigatoriedade, como já ocorreu no passado⁵⁹⁹.

Todos os títulos apresentados devem indicá-lo, estabelecendo o art. 34, V, do Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) que "o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF será mencionado obrigatoriamente nos instrumentos públicos relativos a operações imobiliárias".

⁵⁹⁸ Art. 1º, § 2º, do Decreto 5.703/06.

⁵⁹⁹ Decreto nº 84.047/79, que tornava obrigatória a inscrição apenas para os participantes de operações imobiliárias de valor superior a 1.000 Unidades Padrão de Capital (UPC).

7.1. Comprovação de inscrição

O principal meio de comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas é o cartão de CPF, que substituiu o antigo CIC (cartão de identificação do contribuinte), que não existe mais, tendo sido mantida a mesma numeração dos contribuintes.

Além do próprio cartão, também são documentos hábeis a comprovar a inscrição, desde que tenham a menção do número de inscrição no CPF: Carteira de identidade, Registro Civil de Nascimento, Carteira Nacional de Habilitação; cartão de crédito; cartão magnético de movimentação de conta-corrente bancária; talonário de cheque bancário; documentos de acesso a serviços de saúde pública, de assistência social ou previdenciários e cartão inteligente emitido por Autoridade Certificadora credenciada no âmbito da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP – Brasil)⁶⁰⁰

O "comprovante de inscrição e de situação cadastral no CPF" impresso a partir da página da Receita Federal na Internet⁶⁰¹ só pode ser aceito quando acompanhado de documento de identificação do inscrito, conforme estabelece expressamente o art. 4º, IV da IN SRF 864/08, e desde que comprovada sua autenticidade na página da Receita Federal na Internet.

No entanto, o comprovante gerado na Internet pode ser utilizado para amparar a correção de simples erros de digitação, mesmo quando não acompanhado de documento de identificação, haja vista que nestes casos não se está utilizando o extrato para comprovar a inscrição, mas apenas para retificar dígitos de número de inscrição já lançados no registro.

7.2. Cartão de CPF de estrangeiros

Também estão obrigados a inscrever-se no CPF os estrangeiros "que possuam no Brasil bens e direitos sujeitos a registro público"⁶⁰².

Desde 1º de dezembro de 2002 a obrigação se estendeu às pessoas físicas residentes no exterior⁶⁰³, que passaram a ser obrigadas a ter inscrição no CPF quando participam de atos sujeitos a registro. Nestes casos a inscrição é solicitada à representação diplomática brasileira do país onde se encontra o contribuinte e essa inscrição, diferentemente da dos estrangeiros residentes no Brasil, não gera cartão CPF, sendo a comprovação de inscrição feita pelo "comprovante de inscrição e de situação cadastral no CPF" impresso a partir da página da Receita Federal na Internet, desde que acompanhado de documento de identidade.

⁶⁰⁰ Art. 4º da IN SRF 864/08.

⁶⁰¹Disponível em: <www.receita.fazenda.gov.br>.

⁶⁰²Art. 3º, XII da IN SRF 864/08.

⁶⁰³Decreto 4.166/02, que alterou a redação do Decreto 3.000/99 e IN SRF 190/02.

7.3. Alteração do número de inscrição

Cada pessoa só pode ter um único número de inscrição no CPF⁶⁰⁴, motivo pelo qual pedidos de alteração de numeração devem ser analisados com muito cuidado, sempre se observando na identificação da pessoa, além do nome, a data de nascimento do contribuinte, dado obrigatório do cartão CPF, a fim de se impedir tentativas de fraudes por homônimos.

O principal motivo de alteração nos registros ocorre no caso de pessoas que, enquanto dependentes, utilizavam o número de inscrição de quem dependiam no Imposto de Renda, um dos pais, cônjuge, etc⁶⁰⁵, e que, quando recebem um número de inscrição individual, precisam atualizar os dados dos registros.

Outro motivo é a duplicidade de inscrições. Até a década de noventa não havia um controle rigoroso na inscrição no cadastro fiscal, o que permitia que uma única pessoa pudesse ter diversos números de inscrição, o que, inclusive, impedia a identificação de uma pessoa apenas pelo número de CPF. Com a adoção de controles mais rigorosos, milhões de inscrições de CPF foram canceladas, inúmeros por duplicidade, o que implica na necessidade de alteração dos dados lançados nos registros.

No caso de divergência de numeração de CPF entre o título apresentado e os dados tabulares, é imprescindível a prévia retificação:

"Se os referidos covendedores alteraram os números de seus CPF, tais elementos novos devem previamente ingressar no registro imobiliário por averbação para ser, após, inscrita a escritura de compra e venda que já os consigna. Se, ao contrário, tais números foram equivocadamente lançados na escritura, deve ela ser retificada pelas partes para merecer registro.

O que não se admite é a inscrição de título com diversa identificação da parte, ainda que parcial, daquela constante do registro"⁶⁰⁶.

7.4. Inscrição cancelada ou nula

É obrigatório que os participantes de atos submetidos a registro estejam inscritos no CPF, mas deve-se observar que não basta a apresentação de um número, mas que esse corresponda a uma inscrição no cadastro. Por isso, o

⁶⁰⁴ Art. 5º da IN SRF 864/08.

⁶⁰⁵ Decreto 3.000/99, art. 34, § 1º, que exige que seja citado nesses casos a condição de dependência.

⁶⁰⁶ CSMSP. Apelação Cível nº 044807-0/5. Data: 28/4/1998. Localidade: Sumaré. Relator: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

número de inscrição cancelado ou nulo, verificado na consulta pública disponível na Internet, não é hábil a ser lançado na matrícula, devendo ser exigida a prévia regularização da inscrição antes do lançamento de qualquer ato.

Deve-se notar que situações cadastrais como pendente de regularização⁶⁰⁷ ou suspensão⁶⁰⁸ não implicam em perda da inscrição, mas decorrem de mera irregularidade fiscal, que não impede a realização de atos de registro, e que a inscrição no CPF é regularmente cancelada após a apresentação da declaração final de espólio. Também há a perda da inscrição por cancelamento quando haja multiplicidade de inscrições. A perda da inscrição por nulidade ocorre quando constatada fraude.⁶⁰⁹

7.5. Regiões Fiscais

O número de inscrição de CPF traz informação sobre o seu local de expedição. O último dígito do número, antes dos 2 números de controle, indica a Região Fiscal em que emitido. Assim, todos os números emitidos no Estado de São Paulo terminam com o dígito 8 (8ª Região Fiscal), os do Estado do Rio de Janeiro 7 (7ª Região Fiscal), do Distrito Federal 1 (1ª Região Fiscal), do Estado do Rio Grande do Sul 0 (10ª Região Fiscal)⁶¹⁰, o que pode ser útil na verificação de erros de digitação e até na análise de pedidos de alteração de numeração.

8. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

O CNPJ é o cadastro administrado pela Receita Federal que registra as informações fiscais das pessoas jurídicas, inclusive dos entes equiparados a pessoas jurídicas, tendo substituído o antigo CGC (cadastro geral de contribuintes), extinto em 1º de julho de 1998⁶¹¹. O número de inscrição no CNPJ é o número de identificação da empresa e se comprova pela apresentação do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica no CNPJ, emitido apenas via Internet e cuja autenticidade deve ser verificada⁶¹².

⁶⁰⁷ Quando há omissão na entrega da declaração de Imposto de Renda no último exercício.

⁶⁰⁸ Quando há omissão na entrega da declaração de Imposto de Renda nos últimos 2 exercícios.

⁶⁰⁹ Arts. 45 e 51 da IN SRF 461/04.

⁶¹⁰ O Brasil é dividido em 10 Regiões Fiscais, assim definidas: 1ªRF: DF, GO, MT, MS, TO; 2ª RF: PA, AC, AM, RO, RR, AP; 3ªRF: CE, MA, PI; 4ª RF: PE, AL, PB, RN; 5ªRF: BA, SE; 6ªRF: MG; 7ªRF: RJ, ES; 8ªRF: SP; 9ªRF: PR, SC e 10ªRF: RS.

⁶¹¹ Art. 214, § 3º, do Decreto 3.000/99.

⁶¹² Art. 21 da IN RFB 1.005 de 8 de fevereiro de 2010.

A inscrição no CNPJ é obrigatória⁶¹³, e seu número deve constar necessariamente dos registros⁶¹⁴.

8.1. Sociedades estrangeiras

Todas as pessoas jurídicas domiciliadas no exterior que possuam no Brasil imóveis, financiamentos ou pratiquem empréstimos em moeda concedidos a residentes no País estão obrigadas à inscrição no CNPJ⁶¹⁵.

Assim, para o registro de uma hipoteca para garantir financiamento concedido por banco estrangeiro, o credor deverá necessariamente ter número de inscrição no CNPJ, que deverá ser lançado no registro da garantia real.

8.2. Inscrição inapta

Mas não basta a apresentação de um número de inscrição, devendo ser verificada a situação cadastral da pessoa jurídica, haja vista que a situação inapta traz grandes reflexos ao registro, sendo consequência dessa situação, que só é declarada em situações extremas, o impedimento de transmitir a propriedade de bens imóveis⁶¹⁶. Quando o título é uma escritura pública, a verificação compete ao tabelião, e quando um instrumento particular, ao registrador.

8.3. Alteração de inscrição

A observação do número de inscrição no CNPJ pode ser muito útil na distinção entre meras alterações de denominações de empresas proprietárias de imóveis ou detentoras de direitos registrados de efetivas transmissões imobiliárias decorrentes de incorporações, fusões e cisões de pessoas jurídicas, com todos os efeitos decorrentes.

Isso porque o número de inscrição não é alterado por mera alteração de denominação ou transformação de um tipo societário em outro (S/A para Ltda, p. ex.). Mas a alteração ocorre, no caso de incorporação, quando o número de inscrição no CNPJ da incorporada é baixado⁶¹⁷, passando a ser utilizado o da incorporadora. De forma similar há alterações de CNPJ na fusão e na cisão de sociedades. Assim, a alteração do número do CNPJ deve provocar atenção do registrador, haja vista sinalizar uma transmissão de propriedade, e não apenas alteração de denominação, sendo necessária a apresentação de

⁶¹³ Art. 214 do Decreto 3.000/99.

⁶¹⁴ Art. 176, § 1º, III, 2, b, da Lei 6.015/73.

⁶¹⁵ Art. 11, XIV, da IN RFB 1.005 de 8 de fevereiro de 2010.

⁶¹⁶ Art. 44, III, c, da IN RFB 1.005 de 8 de fevereiro de 2010.

⁶¹⁷ Art. 27, II, da IN RFB 1.005 de 8 de fevereiro de 2010.

documentos que esclareçam o ocorrido para que possa ser corretamente lançado na matrícula.

8.4. Matriz e filiais

O número do CNPJ é formado por 3 conjuntos, o primeiro, o número de inscrição propriamente dito (número básico), composto de 8 dígitos, o segundo, o que indica se aquela inscrição é do estabelecimento matriz (0001) ou de uma filial, que receberá números sequenciais (0002, 0003, etc.), um para cada filial, e o terceiro, composto por 2 dígitos verificadores, calculados a partir dos números anteriores. Assim, variações no segundo conjunto não representam outra pessoa jurídica, mas apenas indicam ser a matriz ou uma determinada filial e, portanto, não há irregularidade, por exemplo, se uma hipoteca é constituída em favor de banco com CNPJ, por exemplo, 00.000.000/0151-03, e o cancelamento for concedido pelo banco com CNPJ 00.000.000/0001-00. No caso, na constituição da hipoteca compareceu o Banco representado por uma agência (filial nº 151), e o cancelamento foi concedido pela própria matriz.

8.5. CNPJ de entes públicos

No caso de transações imobiliárias da qual participem entes públicos, deve-se utilizar para a União o CNPJ da Secretaria da Administração e do Patrimônio, para o Estado o CNPJ da Secretaria Estadual da Fazenda e para o Município o CNPJ da Secretaria Municipal da Fazenda.⁶¹⁸ No Estado de São Paulo, a Secretaria do Patrimônio da União possui uma Delegacia do Patrimônio da União com CNPJ 00.394.460/0202-58, que será o utilizado no registro de aquisição de imóveis pela União no Estado de São Paulo.

9. Retenção de documentos

A Lei 5.553/68, alterada pela Lei 9.453/97, tipifica como contravenção penal a retenção de documentos de identificação pessoal, estabelecendo, quando a apresentação do documento for necessária para a realização de determinado ato, o prazo máximo de 5 dias para sua devolução. Assim, não deve ser exigido nem aceite documento original quando seja necessária sua permanência em cartório para a prática de atos de registro, devendo ser solicitada, quando necessária a extração de dados, que seja apresentada cópia autenticada do documento de identidade⁶¹⁹.

⁶¹⁸ Resposta nº 82 do Perguntas e Respostas da DOI – <www.receita.fazenda.gov.br>.

⁶¹⁹ O art. 1º da Lei 5.553/68 também impede a retenção de cópias autenticadas de documentos de identidade quando estas estejam sendo utilizadas como documento de identificação, o que pode ser verificado pela forma como é apresentada (em invólucro plástico, cortada, dobrada, etc.).

CAPÍTULO VIII

**REGIME DE BENS
CASAMENTO E DISSOLUÇÃO
DO VÍNCULO MATRIMONIAL**

Regime de bens

O regime de bens adotado no casamento tem grande reflexo no Registro de Imóveis, definindo se há ou não comunicação de patrimônio entre os cônjuges e quais as restrições à disposição de seus bens decorrentes do matrimônio. O regime é estabelecido pelos nubentes ainda antes do casamento, através de pacto antenupcial, que deve ter a forma prevista em lei, sob pena de ser considerado nulo, conforme dispõe o artigo 1.653 do Código Civil: "É nulo o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, e ineficaz se não lhe seguir o casamento".

Em face do direito vigente, o regime de bens pode ser convencional, quando estabelecido através de pacto antenupcial, podendo-se optar pela comunhão universal de bens, separação de bens ou pelo regime da participação final nos aquestos. O regime legal independe de pacto antenupcial, podendo ser o da comunhão parcial de bens ou da separação obrigatória de bens, este nos casos previstos no artigo 1.641 do Código Civil.

1. Regimes legais

Anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, o regime de bens que vigorava caso não houvesse pacto antenupcial, nem fosse obrigatório o regime da separação, era o da comunhão universal de bens. Contudo, com a edição da referida lei, o artigo 258 do Código Civil de 1916 passou a dispor que não havendo convenção ou sendo nula, nem incidindo a separação obrigatória de bens, vigoraria, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial, o qual foi mantido pelo Código Civil de 2002.

1.1. Regime da comunhão parcial de bens

Se o casal não se enquadrar em nenhuma das hipóteses em que o regime da separação de bens seja obrigatório, e não celebrado pacto antenupcial, vigora o regime da comunhão parcial de bens, não se comunicando os bens que cada nubente tinha antes do casamento, comunicando-se entre os cônjuges apenas os bens que estes adquirirem após a realização do matrimônio, salvo as exceções previstas no art. 1.659 do CC, que determina que não se comunicam:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Também não se comunicam "os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento"⁶²⁰.

Por outro lado, comunicam-se⁶²¹:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

A) Outorga uxória

Mas embora no regime da comunhão parcial de bens o imóvel que o cônjuge possuía antes do matrimônio permaneça em seu patrimônio exclusivo, para dispor dele dependerá da anuência do outro cônjuge. Isso porque o art. 1.647 do CC estabelece que, para todos os regimes, com exceção do regime da separação absoluta, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro:

⁶²⁰ Art. 1.661 do CC

⁶²¹ Art. 1.660 do CC

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança⁶²² ou aval;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Se o cônjuge negar a autorização sem motivo justo, ou sendo impossível concedê-la, deve-se buscar suprimento judicial⁶²³, sem o qual a transmissão ou oneração não poderá ser realizada.

Nenhuma autorização é necessária para adquirir imóvel, o que pode ser feito com a participação de apenas um dos cônjuges. Porém, se no mesmo ato o adquirente hipoteca o imóvel para garantir o pagamento de parte do preço que, por exemplo, será pago a prazo, necessariamente deverá comparecer também o outro cônjuge para que a oneração seja válida⁶²⁴.

E embora em decorrência da comunicação ambos os cônjuges devam comparecer alienando ou onerando o bem, só sendo correto o cônjuge comparecer assistindo ao ato quando não ocorrer a comunicação, erro no título quanto à indicação de que um dos cônjuges comparece assistindo à alienação, quando deveria comparecer alienando o imóvel, já foi relevado pelo CSMSP: "Inexiste ofensa aos princípios registrários da continuidade e da disponibilidade que impeçam o ingresso do título em questão no fôlio real, tendo em vista a regularidade do ato de alienação do bem imóvel, efetivado pelo marido com o expresse consentimento da mulher, nos termos do disposto no artigo 235, I, do Código Civil⁶²⁵. Pontes de Miranda, no 'Tratado de Direito Privado', Tomo VIII, 3ª ed., Editor Borsoi, 1971, pág. 122, adverte que se o marido quer alienar bem comum, a espécie não é de assentimento, mas de consentimento, a revelar que comparecem no título prenotado, para alienação do bem imóvel, na forma expressamente prevista no artigo 235, I, do Código Civil, ambos os titulares do domínio. O ato de alienação foi, portanto, formalizado de maneira válida, contando com a efetiva participação, nos limites expressos na lei civil, de cada um dos titulares do domínio, não subsistindo a uma análise sistemáti-

⁶²² STJ Súmula nº 332: Fiança - Autorização de Um dos Cônjuges - Eficácia da Garantia - A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.

⁶²³ Art. 1.648 do CC

⁶²⁴ Art. 1.660, I, e art. 1.647, I, do CC

⁶²⁵ Atualmente art. 1.647, I, do CC de 2002

ca a afirmativa de que apenas o marido tivesse alienado o bem comum. A propriedade imobiliária, como necessário, está sendo transmitida pelo casal, ou seja, por ambos os titulares do domínio, o que viabiliza o ingresso do título no fôlio real"⁶²⁶.

Observe-se ainda que essa comunicação dos bens adquiridos na constância do matrimônio impede, por exemplo, que um dos cônjuges adquira o usufruto e outro a nua-propriedade em transmissão onerosa, porque o cônjuge que adquiriu o usufruto também adquirirá a nua-propriedade em decorrência do regime de bens, extinguindo o usufruto no mesmo ato em decorrência da consolidação⁶²⁷ e tornando sem efeito o negócio jurídico pretendido.

B) Sub-rogação

Sub-rogação significa substituição e "resulta sempre na substituição de coisa, ou pessoa, por outra coisa ou pessoa, sobre que recaem as mesmas qualidades ou condições dispostas anteriormente em relação à coisa, ou à pessoa substituída"⁶²⁸.

Pela sub-rogação os bens particulares de um dos cônjuges podem ser substituídos por outros, que permanecem particulares, mas os reflexos da sub-rogação no registro de imóveis devem ser analisados com muito cuidado para evitar que seja utilizada para burlar o regime de bens adotado pelo casal.

A sub-rogação é expressamente prevista no art. 1.659, I, do CC, que estabelece que não se comunicam os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares. É o caso, por exemplo, em que um imóvel recebido por sucessão hereditária e, portanto, que não se comunicou, é alienado e o produto da venda utilizado para adquirir outro imóvel. O imóvel assim adquirido, embora a título oneroso, que em regra se comunica com o cônjuge, neste caso não se comunicará porque houve sub-rogação.

Essa sub-rogação pode ser indicada no título, mas desde que haja efetiva hipótese de sub-rogação prevista em lei e no ato compareça o cônjuge com o qual o imóvel não se comunicará, anuindo ao ato: "Registro de Imóveis - Escritura de aquisição com expressa declaração de que parte do preço pago resulta de alienação de bens particulares do adquirente - Interveniência da vira-

⁶²⁶ CSMSp. Apelação Cível nº 058746-0/3. Data: 3/2/2000. Localidade: São Sebastião. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶²⁷ Art. 1.410, VI, do CC.

⁶²⁸ Silva, De Plácido e. Op. cit., p. 1330.

go, acedendo à discriminação da parte ideal de propriedade exclusiva - Acesso ao fôlio possível - Recurso provido"⁶²⁹.

Importante frisar que há a necessidade da participação de ambos os cônjuges, não se admitindo declaração unilateral.

Ressalte-se também que não basta a anuência do cônjuge com a não comunicação do bem. Uma aquisição onerosa cujos recursos não provenham de bens que a lei estabeleça como particulares não poderá ser declarada como excluída da comunicação, por violar o regime de bens.

Hipótese comum de sub-rogação ocorre quando o bem é adquirido com numerário recebido em doação, o que, no entanto, deve ocorrer no mesmo ato.

A CGJSP assim esclareceu essa possibilidade: "É regra expressa do art. 269, incisos I e II do CC⁶³⁰, que, no regime da comunhão limitada ou parcial, excluem-se da comunhão tanto os bens adquiridos na constância do casamento, por doação ou sucessão, como os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em sub-rogação de bens particulares. No caso concreto, houve a doação de dinheiro, de tia à sobrinha. Porque adquirido a título gratuito, por doação, o dinheiro passou a ser bem próprio da mulher, não se comunicando ao marido. Ato contínuo, foi adquirido, com o dinheiro doado, ou seja, valor pertencente exclusivamente à mulher, um apartamento. Evidenciou-se, assim, ter sido o imóvel adquirido em sub-rogação de bens particulares de um dos cônjuges, não havendo, por consequência, falar em bem comum ou aquesto"⁶³¹.

Essa incomunicabilidade diverge da cláusula prevista no art. 167, II, 11, da Lei 6.015/73:

“Não há confundir, por óbvio, a incomunicabilidade decorrente do regime de bens do casamento (*ex lege*) com a incomunicabilidade voluntária restritiva de direitos, posta em doação ou testamento"⁶³².

⁶²⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 096913-0/4. Data: 3/2/2003. Localidade: Ituverava. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶³⁰ Atualmente art. 1.659, I e II, do CC de 2002.

⁶³¹ CGJSP. Decisão 000431/96. Data: 23/2/1996. Localidade: Araçatuba. Juiz Auxiliar da Corregedoria: Francisco Eduardo Loureiro. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶³² CGJSP. Decisão 000431/96. Data: 23/2/1996. Localidade: Araçatuba. Juiz Auxiliar da Corregedoria: Francisco Eduardo Loureiro. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Outra situação muito comum em que se discute a comunicação de bens é a do compromisso de compra e venda anterior ao casamento, mas com a lavratura e registro da escritura cumprindo o compromisso após o matrimônio, quando vários aspectos devem ser analisados: "O título aquisitivo do direito real, propriamente dito, é a escritura definitiva (que transmitiu o domínio) e não o compromisso de compra e venda, não incide na espécie exatamente o art. 272 do Código Civil⁶³³, mas sim, conforme ficou bem expresso no acórdão por último transcrito, os artigos 269, II, 271, I e VI⁶³⁴. O raciocínio é o seguinte: como a escritura definitiva foi recebida no estado civil de casado, presume-se a comunicação do bem nos termos do art. 271 inciso I do Código Civil; poderá o cônjuge no entanto excluí-lo da comunhão se provar que já o possuía ao casar ou que foi adquirido com valores a si exclusivamente pertencentes (art. 269 incisos I e II), aí não se incluindo nem os frutos dos bens comuns ou particulares, nem os frutos civis de seu trabalho ou indústria⁶³⁵ que nos termos do art. 271 incisos V e VI pertencem a ambos"⁶³⁶.

1.2. Regime da separação obrigatória de bens

O regime da separação de bens é obrigatório no casamento⁶³⁷:

I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas⁶³⁸ da celebração do casamento;

II - da pessoa maior de sessenta anos;

III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimimento judicial⁶³⁹.

Questão relevante envolve os bens adquiridos na constância do casamento nesse regime. Sobre esse tema o STF editou a Súmula 377, consignando que "no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento".

⁶³³ Atualmente o art. 1.661 do CC.

⁶³⁴ Atualmente art. 1.659, II, art. 1.660, I e VI, do CC de 2002.

⁶³⁵ Atualmente não se comunicam "os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge", conforme art. 1.659, VI, do CC de 2002, e comunicam-se "os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão", nos termos do art. 1.660, V, do CC de 2002.

⁶³⁶ CSMSp. Apelação Cível nº 011544-0/8. Data: 29/10/1990. Localidade: São Paulo. Relator: Onei Raphael. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶³⁷ Art. 1.641 do CC.

⁶³⁸ Art. 1.523 do CC.

⁶³⁹ Art. 1.519 e 1.520 do CC.

Essa comunicação dos aquestos, ou seja, dos bens adquiridos na constância do matrimônio, deve ser observada pelo registrador: "Registro de Imóveis. Escritura de venda e compra. Bem adquirido na constância de casamento celebrado sob o regime da separação obrigatória dos bens. Comunicação dos aquestos por força da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Falecimento de um dos cônjuges na vigência do Código Civil de 1916. Necessidade de abertura da sucessão. Alienação do bem por inteiro pelo cônjuge sobrevivente, na vigência do atual Código Civil. Inadmissibilidade. Princípio da continuidade. Violação. Dúvida procedente. Recurso não provido"⁶⁴⁰.

Importante observar que o CSMSP manifestou entendimento de que a comunicação independe de prova do esforço comum: "Logo, existe a comunicação de aquestos, independentemente da prova do esforço comum na aquisição do bem, porque não se cogita de sociedade de fato, mas de aquisição em virtude do regime de bens adotado no casamento"⁶⁴¹. Ademais, não seria possível que o registrador pudesse analisar esse aspecto por demandar provas estranhas aos dados tabulares.

Para as transmissões posteriores ao Código Civil de 2002, que não manteve a redação do art. 259 do CC de 1916, a doutrina não é pacífica quanto à aplicação da Súmula STF 377, tendo o CSMSP se manifestado no sentido de que: "O novo Código Civil, ao que tudo indica, veio trazer o regime da efetiva separação de bens, mas, como manda a boa hermenêutica, não pode retroagir e atingir situação pretérita, de sorte que deve ser preservado o regime jurídico da época do falecimento do varão"⁶⁴².

Também, deve o registrador impedir tentativas de burla ao regime de bens. Assim, não é possível, por exemplo, que no regime da separação obrigatória de bens haja doação de um cônjuge a outro "tendo como objeto bem havido antes do matrimônio, sem que a comunicação pretendida e cuja convenção seria defesa deixe de representar flagrante burla ao regime de bens imposto legalmente"⁶⁴³.

⁶⁴⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 121-6/4. Data: 30/3/2004. Localidade: Araraquara. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁴¹ CSMSP. Apelação Cível nº 017990-0/6. Data: 26/8/1993. Localidade: São Paulo. Relator: José Alberto Weiss de Andrade. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁴² CSMSP. Apelação Cível nº 121-6/4. Data: 30/3/2004. Localidade: Araraquara. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁴³ 1ª VRPSP. Dúvida nº 00822/94. Data: 04/12/94. Localidade: São Paulo. Juiz: Dr. Luis Mario Galbetti. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

O regime da separação de bens determinado por lei será averbado nas matrículas dos imóveis de propriedade de cada um dos cônjuges e dos imóveis que forem sendo adquiridos após o casamento, determinando o art. 245 da Lei 6.015/73 que incumbe ao Ministério Público zelar pela fiscalização e observância dessa providência.

2. Regimes Convencionais

2.1. Regime da comunhão universal de bens

Como anteriormente à Lei 6.515/77 o regime legal era o da comunhão universal de bens, para os casamentos celebrados até a data em que a lei entrou em vigor não era necessária a celebração de pacto antenupcial para a adoção do referido regime de bens. Para os casamentos realizados após a vigência da Lei 6.515/77 faz-se necessário o registro do pacto antenupcial no Livro 3 do Registro de Imóveis e a sua averbação no Livro 2 para todas as matrículas dos imóveis pertencentes a cada um dos cônjuges.

O regime da comunhão universal de bens tem como característica "a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas"⁶⁴⁴, havendo, no entanto, exceções a essa comunicação, estabelecendo o art. 1.668 do CC que são excluídos da comunhão:

“I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens gravados de fideicomisso⁶⁴⁵ e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos⁶⁴⁶, ou reverterem em proveito comum;

IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.”

Não existe o regime da comunhão de bens. Embora usado de forma corriqueira como sinônimo de comunhão universal de bens, em decorrência da

⁶⁴⁴ Art. 1.667.

⁶⁴⁵ Art. 1.951 do CC.

⁶⁴⁶ Preparativos.

vedação à utilização de abreviações, não deve ser utilizado, especificando-se expressamente tratar-se do regime da comunhão universal ou parcial de bens, conforme o caso.

2.2. Regime da participação final nos aquestos

Introduzido pelo Código Civil de 2002, no regime da participação final nos aquestos cada cônjuge possui patrimônio próprio, formado pelos bens que possuía ao casar e os adquiridos a qualquer título durante o casamento, e caso ocorra a dissolução da sociedade conjugal, faz-se a partilha do patrimônio adquirido onerosamente durante a vida em comum do casal.

É o que estabelece o art. 1.672 do CC: “No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento”, acrescentando o *caput* do art. 1.673 do CC que “integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos, a qualquer título, na constância do casamento”.

Embora a administração dos bens particulares seja exclusiva de cada cônjuge⁶⁴⁷, somente a alienação dos bens móveis é livre⁶⁴⁸, sendo que os imóveis somente poderão ser alienados livremente se assim se convencionar no pacto antenupcial, e desde que sejam particulares⁶⁴⁹.

Havendo a dissolução da sociedade conjugal, estabelece o art. 1.674 do CC que se apurará o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios:

- I - os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se sub-rogaram;
- II - os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade;
- III - as dívidas relativas a esses bens.

Embora o princípio da presunção do registro tenha como consequência transferir o ônus da prova para aquele que alega irregularidade em dados do registro, o art. 1.681 do CC cria uma exceção a essa regra, e após consignar no *caput* que “os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro”, estabelece em seu parágrafo único que “impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição regular dos bens”.

⁶⁴⁷ Art. 1.673, parágrafo único, do CC.

⁶⁴⁸ Art. 1.673, parágrafo único, do CC.

⁶⁴⁹ Art. 1.656 do CC.

2.3. Regime da Separação Convencional de bens

No regime da separação de bens, tanto os bens adquiridos anteriormente, como os adquiridos na constância do casamento, não se comunicam entre os cônjuges, pois cada um possui patrimônio próprio e completamente desvinculado do outro, podendo livremente alienar e gravar com ônus real seus imóveis, conforme estabelece o art. 1.687 do CC: "estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real".

No regime da separação convencional de bens a outorga uxória é desnecessária, mesmo para casamentos anteriores ao Código Civil de 2002: "Destarte, forçoso é concluir que não tem incidência no caso a regra do artigo 2.039 do Código Civil atual, devendo em consequência prevalecer o disposto no artigo 1.647 do mesmo diploma legal, em relação ao contido no artigo 235 do Código Civil de 1916, pois esta última disposição não constitui regra específica de regime de bens, a exigir a aplicação da lei vigente à época da celebração do casamento"⁶⁵⁰.

Essa regra não se aplica a títulos lavrados na vigência do Código Civil anterior, que exigia a vênua conjugal para toda transmissão ou oneração de bem imóvel, o que deve ser observado pelo oficial quando qualifica títulos lavrados sob a égide do Código Civil de 1916. Sobre esse tema, assim se posicionou o CSMSP:

“O Código Civil revogado dispunha, em seu artigo 235, que o marido não podia alienar e gravar bens imóveis, sem o consentimento da mulher, qualquer que fosse o regime de bens adotado no casamento. A exigência de outorga era, como se vê, endereçada de forma absoluta e indistintamente a todos os regimes.

Em disposição geral relativa ao regime de bens entre os cônjuges o artigo 1.647, I, do Código Civil atual, em vigor a partir de janeiro de 2003, estabeleceu a dispensa do consentimento mencionado somente para os casamentos realizados com pactos que convençionem a separação absoluta do patrimônio, não o dispensando para os demais regimes.

Assim, poder-se-ia concluir que os negócios jurídicos realizados na vigência do Código Civil anterior obedecem às regras por ele estabelecidas, enquanto que aqueles celebrados sob a vigência do novo Estatuto Civil, ainda que as pessoas envolvidas tenham se casado anteriormente por pacto de incommunica-

⁶⁵⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 323-6/6. Data: 25/5/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

bilidade patrimonial, respeitarão as normas previstas neste último, dispensando a autorização do outro cônjuge, nos casos de alienação e oneração de bens imóveis”⁶⁵¹.

3. Averbação e registro do pacto antenupcial

Quando o casal adota regime de bens diverso do legal, deve ser lavrada escritura de pacto antenupcial em Tabelionato de Notas⁶⁵², a qual deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis do primeiro domicílio do casal⁶⁵³. Este registro é efetuado no Livro 3 (registro auxiliar), devendo ser apresentado, para tanto, a escritura pública do pacto antenupcial e a certidão de casamento.

Para o registro deverá ser apresentado traslado ou certidão da escritura de pacto, não se admitindo registro de cópia, mesmo que autenticada.

Embora o regime de bens entre os cônjuges comece a vigorar desde a data do casamento⁶⁵⁴, as convenções antenupciais não terão efeito perante terceiros senão depois de registradas pelo oficial do Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges⁶⁵⁵, esclarecendo o art. 244 da Lei 6.015/73 que “As escrituras antenupciais serão registradas no livro n. 3 do cartório do domicílio conjugal, sem prejuízo de sua averbação obrigatória no lugar da situação dos imóveis de propriedade do casal, ou dos que forem sendo adquiridos e sujeitos a regime de bens diverso do comum, com a declaração das respectivas cláusulas, para ciência de terceiros”.

Além do registro do pacto antenupcial no Livro 3 do Cartório de Registro de Imóveis (somente no cartório da comarca do primeiro domicílio do casal), deverá ser efetuada averbação acerca da existência do pacto antenupcial no Livro 2 para todos os imóveis pertencentes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento⁶⁵⁶.

Assim, o pacto pode ser averbado e registrado. Registrado no Livro 3⁶⁵⁷ e averbado no Livro 2.

⁶⁵¹ CSMSP. Apelação Cível 323-6/6. Data: 25/5/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁵² Art. 1.653 do CC.

⁶⁵³ Art. 1.657 do CC.

⁶⁵⁴ Art. 1.639, § 1º, do CC.

⁶⁵⁵ Art. 1.657 do CC.

⁶⁵⁶ Art. 167, II, 1 da Lei 6.015/73.

⁶⁵⁷ Art. 178, V, da Lei 6.015/73.

4. Alteração do regime de bens

O Código Civil de 2002 trouxe a possibilidade de alteração do regime de bens do matrimônio, estabelecendo o art. 1.639, § 2º, que "É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros".

Embora esse artigo não tenha expressamente determinado o registro das novas condições estabelecidas pelos cônjuges no Livro 3 quando o regime for alterado para modalidade diversa da legal, esse registro inquestionavelmente é necessário.

Isso porque o legislador estabeleceu uma publicidade específica para o regime de bens diverso do legal, não se contentando nem mesmo com a publicidade da escritura pública. Determinou que para que as convenções produzissem efeito em relação a terceiros fosse também dada publicidade no Registro de Imóveis da Comarca de domicílio do casal, para que se pudesse conhecer as convenções patrimoniais e respectivas cláusulas independentemente de busca por escrituras: "As escrituras antenupciais serão registradas no Livro 3 do cartório do domicílio conjugal, sem prejuízo de sua averbação obrigatória no lugar da situação dos imóveis de propriedade do casal, ou dos que forem sendo adquiridos e sujeitos a regime de bens diverso do comum, com a declaração das respectivas cláusulas, para ciência de terceiros"⁶⁵⁸.

Se é assim para a escritura, cuja publicidade é irrestrita, por mais forte razão deve ser aplicada a mesma regra à convenção estabelecida pelos cônjuges cuja alteração foi autorizada por sentença, em processo que tramita em segredo de justiça no Juízo da família.

Definitivamente não basta a mera averbação do novo regime de bens no registro de casamento, como em vários casos tem ocorrido, porque a certidão de casamento traz apenas o regime, não as cláusulas específicas adotadas pelos cônjuges, cuja publicidade deve ocorrer da mesma forma que se dá quando o regime é adotado desde o matrimônio, não havendo razão para distinguir o tratamento conforme o momento em que adotado o regime.

Importante lembrar que o regime de bens quando diverso do legal não é definido apenas pela modalidade escolhida. Os cônjuges têm autonomia e podem criar regras e combinar regimes quando estabelecem as cláusulas que vigorarão quanto a seus bens. É o que estabelece o *caput* do art. 1.639 do CC: "É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos

⁶⁵⁸ Art. 244 da Lei 6.015/73.

seus bens, o que lhes aprouver". E o que foi convencionado pelo casal deve receber a publicidade prevista em lei para os regimes diversos do legal, para que possa ter efeitos em relação a terceiros⁶⁵⁹.

Nem mesmo eventual publicação de edital, como também se tem visto em alguns casos, supre a necessidade de registro no Livro 3, pois o edital gera publicidade momentânea, incompatível com a divulgação que as cláusulas do regime devem ter, haja vista seus efeitos se prolongarem indefinidamente, afetando terceiros e produzindo reflexos durante todo o matrimônio.

Finalmente, deve-se observar que a norma legal estabelece que a alteração do regime de bens somente é possível mediante autorização judicial, quando se apurará a procedência das razões invocadas pelos cônjuges, mas não estabelece que a sentença definirá todas as cláusulas que regerão o novo regime e nem que produzirá efeitos em relação a terceiros.

Assim, deferida a autorização judicial para que o regime de bens seja alterado, a nova convenção que os cônjuges decidiram adotar deve cumprir as mesmas formalidades estabelecidas para o correspondente regime de bens, ou seja, se diverso do legal, as cláusulas adotadas devem ser especificadas em instrumento público, que deverá então receber a mesma publicidade que todas as demais convenções que adotem regime diverso do legal, com o registro no Livro 3 do registro de imóveis do local de domicílio do casal. A sentença judicial autoriza esse procedimento, mas não o substitui.

A ARPEN-SP, em seu jornal de agosto de 2008⁶⁶⁰, publicou um artigo defendendo a necessidade da lavratura de escritura pública de pacto nupcial nos casos em que a alteração do regime de bens seja deferida por alvará judicial, conforme o entendimento emanado no Parecer 73/2008-E da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo exarado no processo CG 2008/13415, mas nos casos em que emanado pelo Judiciário um mandado ou uma carta de sentença, a averbação deve ser efetuada de imediato à margem do assento de casamento, após a devida qualificação registrária, dispensada a lavratura da escritura de pacto nupcial, já que a lei não prevê forma especial para as convenções posteriores ao casamento.

⁶⁵⁹ Art. 1.657 do CC.

⁶⁶⁰ Disponível em: <http://www.arpensp.org.br/principal/index.cfm?pagina_id=424>.

Averbação do Casamento

Para a averbação do casamento deverá ser apresentada a certidão expedida pelo Registro Civil de Pessoas Naturais ou cópia autenticada⁶⁶¹.

Da certidão deverão ser extraídos dados como a data de casamento, o regime de bens e o nome do cônjuge. No caso de alteração de nome após o casamento, deverão ser lançados ambos no Livro 5, denominado Indicador Pessoal⁶⁶².

Se apresentada certidão de casamento em que não conste o regime de bens adotado, deverá ser exigida a apresentação de nova certidão com essa informação. O regime de bens é um dos dados que devem ser transpostos para o Livro 2 e não pode ser obtido por presunção de que não foi lançado na certidão de casamento por ser o regime legal. Na realidade, nas certidões antigas não era lançado o regime porque não constava campo próprio em alguns dos formulários adotados, e não por ser o regime legal.

No caso de regime diverso do legal deverá ser exigida certidão do registro da escritura de pacto antenupcial no Registro de Imóveis de domicílio do casal.

Nesse tópico deve-se anotar que antes da vigência do Decreto 4.857/39, não era obrigatória a referência ao nome adotado pela mulher no assento de casamento, quando então o sobrenome do marido era incorporado ao nome da esposa por força do art. 240 do Código Civil de 1916, com a redação anterior à Lei 6.515/77: "O obstáculo que o Sr. Registrador opôs para a averbação do nome da mulher de R. V. de Camargo, providência que deve preceder o registro do título, consistiu somente no fato de não constar no assento o nome que segundo o formal de partilha passou a ser utilizado por M. de M. Costa depois de seu casamento, qual seja, M. Costa Camargo (fls.54). Ocorre que M. de M. Costa e R. V. de Camargo se casaram em 20 de dezembro de 1926 (fls.32/33), durante a vigência do art. 240 do Código Civil de 1916 (somente revogado pela Lei 6.515/77) que assim dispunha: A mulher assume, pelo casamento, com os apelidos do marido, a condição de sua companheira, consorte e auxiliar nos encargos da família (art. 324). (...) Desta forma, o uso do nome do marido decorreu de obrigação legalmente imposta, motivo pelo qual não resta dúvida sobre o fato de ser R. V. de Camargo casado com M. Costa Camargo, nome que, conforme indicado no formal de partilha, M. de M. Cos-

⁶⁶¹ Art. 1.543 do CC.

⁶⁶² Item 90 do Capítulo XX das NSCGJSP.

ta adotou em seu casamento e que deve, por este motivo, ser o objeto de averbação"⁶⁶³.

5. Casamento religioso

No caso de casamento religioso, o termo ou assento subscrito pela autoridade religiosa deverá em 30 dias, a contar da realização da cerimônia, ser registrado no cartório de registro civil de pessoas naturais⁶⁶⁴, e os efeitos do casamento retroagirão à data da celebração⁶⁶⁵. No Registro de Imóveis deverá ser apresentada a certidão expedida pelo Registro Civil de Pessoas Naturais.

6. Casamento no Exterior

O casamento de brasileiro celebrado no exterior deve ser averbado com base na certidão da transcrição de casamento no Livro E do 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais do domicílio do casal⁶⁶⁶.

Importante observar que o art. 1.544 do CC estabelece que: "O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros, deverá ser registrado em cento e oitenta dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou, em sua falta, no 1º Ofício da Capital do Estado em que passarem a residir".

Em decorrência desse dispositivo os Registros Cíveis de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo só tem promovido a transcrição do casamento dos brasileiros após o retorno dos cônjuges ao Brasil, o que tem gerado um impasse quando essas pessoas pretendem adquirir imóvel no Brasil antes de retornarem ao País, representadas por mandatário constituído por procuração lavrada em consulado. Nesse caso, em decorrência do disposto no art. 32, § 1º, da Lei 6.015/73 estabelecer que o assento de casamento para produzir efeitos no Brasil deve ser trasladado no 1º de Registro Civil, é necessário apresentar no Registro de Imóveis certidão da transcrição do casamento, que não é transcrita no Registro Civil por não terem os cônjuges retornado ao País. O que se tem observado é que o impasse tem sido contornado com o interessado promovendo a transcrição em Registro Civil de outro Estado ou de Brasília, que não apresentam a mesma exigência de retorno ao País, sem que o registrador

⁶⁶³ CSMSp. Apelação Cível nº 388-6/1. Data: 13/10/2005. Localidade: São Sebastião.

Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁶⁴ Art. 73 da Lei 6.015/73.

⁶⁶⁵ Art. 1.515 do CC.

⁶⁶⁶ Art. 32, § 1º, da Lei 6.015/73.

de imóveis nada possa fazer, pois não tem como saber o domicílio dos adquirentes, que na escritura é lançado como sendo no exterior.

Se nenhum dos cônjuges for brasileiro não se fará a transcrição no Registro Civil de Pessoas Naturais, devendo então ser apresentado o documento estrangeiro, traduzido por tradutor público juramentado, arquivado no Registro de Títulos e Documentos e legalizado pela autoridade consular, quando não houver acordo internacional dispensando a legalização.

7. Continuidade

Importante observar com muita atenção o estado civil dos nubentes, para se evitar o rompimento da continuidade, com eventuais repercussões patrimoniais.

Assim, se na matrícula o proprietário é qualificado como solteiro, deve-se observar se na certidão é indicado o mesmo estado civil como sendo anterior ao casamento.

Se na certidão constar como divorciado, por exemplo, trata-se de segundas núpcias, devendo ser exigida a prévia averbação do casamento anterior, observando-se eventual comunicação dos bens.

Caso a certidão apresentada não indique o estado civil dos cônjuges antes do matrimônio, ainda assim é possível verificar se se trata ou não de primeiro matrimônio. Basta observar os dispositivos legais indicados no campo que contém a referência aos documentos apresentados. Se for indicada a apresentação dos documentos previstos no art. 180, V, do CC de 1916 ("certidão de óbito do cônjuge falecido, da anulação do casamento anterior ou do registro da sentença de divórcio") ou no art. 1.525, V, do CC de 2002 ("certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio"), um ou ambos os cônjuges tiveram matrimônio anterior e, portanto, deverão ser apresentados documentos que comprovem o estado civil anterior do proprietário, como, por exemplo, sua certidão de nascimento atualizada, na qual são anotadas todas as suas alterações de estado civil⁶⁶⁷.

O mesmo cuidado deve se ter ao complementar a qualificação dos proprietários em antigas transcrições: "Indispensável saber a qualificação completa dos titulares de direitos reais e de seus cônjuges. A omissão quanto a dados pessoais e regime de bens do casamento pode acarretar sérios desvios no re-

⁶⁶⁷ Art. 106 e 107 da Lei 6.015/73.

gistro imobiliário, permitindo a disposição de direitos reais por quem na verdade não os têm"⁶⁶⁸.

Também quando apresentado título indicando o proprietário com estado civil diferente do constante da matrícula sempre deverá se exigir a certidão de casamento para averbação da alteração e análise da comunicação do bem. Assim, se na matrícula o proprietário foi qualificado como solteiro e é apresentado título em que vende o imóvel qualificado como separado, deverá ser averbado previamente o casamento e em seguida a separação, e se o regime de bens importou em comunicação com o cônjuge, não poderá alienar o imóvel sozinho, salvo se previamente registrada a carta de sentença em que o imóvel foi lhe adjudicado na partilha de bens do casal: “Quando do título apresentado conste alteração do estado civil da pessoa interessada, necessária à prévia averbação dessa circunstância, para garantia do encadeamento subjetivo e preservação do trato sucessivo”⁶⁶⁹.

8. Justificação da falta ou perda do registro civil

Estabelece o *caput* do art. 1.543 do CC que “o casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro”. Porém, o parágrafo único desse mesmo artigo estabelece a possibilidade de ser justificada a falta ou perda do registro: “Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova”.

Assim, se necessária a comprovação de casamento e os cônjuges ou herdeiros não puderem apresentar a correspondente certidão, deverão comprovar o casamento em processo judicial. No registro de imóveis não deverá ser apresentada a sentença que reconheceu a existência do casamento, mas certidão do registro da sentença no cartório de registro civil, conforme determina o art. 1.546 do CC: “Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro do Registro Civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento”.

Mesmo casamentos realizados no exterior podem ser comprovados na forma prevista nos arts. 1.543 e 1.546 do CC: “Como se vê, a prova (documental e oral) é bastante satisfatória para convencer da existência de antigo casamento, realizado no Reino da Iugoslávia, e para comprovar que Jaroslav e

⁶⁶⁸ CSMSp. Apelação Cível nº 040014-0/7. Data: 18/11/1997. Localidade: Atibaia. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁶⁹ 1ª Vara de Registros Públicos. Processo 1036/95. Data: 27/11/95. Localidade: São Paulo. Juiz: Asdrubal Nascimbeni. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Ana mantinham a posse do estado de casados. Pouco importa que não possuam certidão do referido matrimônio. É exatamente a falta desse documento, e a enorme dificuldade de se obter segunda via dele, por se tratar de ato celebrado em país atingido em passado remoto pela grande guerra, e esfacelado na atualidade pela guerra civil, que os requerentes batem às portas do Poder Judiciário do Estado onde residem, para solicitar a restauração do documento em questão. Reputam-se, pois, demonstrados pela prova produzida, a existência do matrimônio, o extravio do respectivo registro e a posse do estado de casados, tudo a justificar a restauração pretendida mediante assento desta decisão no registro civil, expedindo-se o competente mandado”⁶⁷⁰.

Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, a ação será julgada pelo casamento se os cônjuges viveram na posse do estado de casados⁶⁷¹, que é definida como uma “situação de fato, em que se apresentam os esposos perante o público, dando a entender ou fazendo crer a sua condição de casados legalmente, o que é aceito pela sociedade”⁶⁷².

9. Regime de bens e casamento no exterior

O casamento celebrado perante a autoridade consular brasileira no exterior rege-se pelas leis brasileiras⁶⁷³.

No entanto, quando realizado perante a autoridade estrangeira, será aplicado o regime de bens do país em que os nubentes tiverem domicílio e, se este for diverso, do primeiro domicílio do casal⁶⁷⁴. Neste caso, administrativamente considera-se que os bens adquiridos na constância do matrimônio se comunicam e, por consequência, exige-se a participação de ambos os cônjuges para alienação ou oneração de bens, por aplicação do estabelecido na Súmula STF 377. É o que determina o CSMSP: “Diante disso, a tese adotada por esse Conselho no sentido de se adotar na esfera administrativa a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal como regra, deve também se estender aos casos de estrangeiros casados no exterior sob o regime da separação de bens. A exclusão do bem da partilha somente por decisão do Juiz competente na esfera

⁶⁷⁰ TJSP. 8ª Câmara de Direito Privado. Apelação cível nº 114.911-4/9. Data: 22/09/99. Localidade: São Paulo. Relator: César Lacerda. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>.

⁶⁷¹ Art. 1.547 do CC.

⁶⁷² SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 1063.

⁶⁷³ Art. 18 da LICC.

⁶⁷⁴ Art. 7º, § 4º, da LICC.

jurisdicional poderá ser decretada, providenciando-se o seu devido ingresso na tábua registral, obedecendo-se, assim, ao princípio da continuidade”⁶⁷⁵.

Para compreender esse entendimento, interessante trazer do mesmo Acórdão esclarecimento sobre a origem da Súmula STF 377: “Portanto, observa-se que a Jurisprudência hoje firmada no Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 377, adveio justamente da intenção de se reparar a injustiça presente em inúmeros casos de estrangeiros casados no exterior, principalmente na Itália, sob o regime da separação de bens, posto que esse era o regime oficial daquele país, os quais após anos de convivência formavam um patrimônio com o esforço comum de ambos”⁶⁷⁶.

10. Separação e divórcio

A dissolução voluntária do vínculo matrimonial dá-se por iniciativa de um ou ambos os cônjuges pela separação, divórcio, anulação ou nulidade do casamento.

O efeito da separação e do divórcio com reflexos para o registro de imóveis é o término do regime matrimonial de bens adotado pelos cônjuges. Como consequência, por exemplo, após a separação não há mais comunicação dos bens adquiridos.

Quando há dissolução do matrimônio deve-se fazer uma averbação informando essa ocorrência. Em respeito ao princípio da continuidade, quando previamente ao divórcio for realizada separação judicial, deve-se, então, efetuar duas averbações, primeiro a da separação, e depois a da conversão em divórcio, pois tais estados civis deram-se em momentos diferentes. O documento hábil para tanto é uma simples cópia autenticada da certidão de casamento atualizada, com a devida averbação de separação e do divórcio.

É necessário que a certidão de casamento apresentada seja atualizada, para que a averbação reflita o atual estado civil do proprietário, haja vista os reflexos, por exemplo, decorrentes de eventual segundo matrimônio: "necessária a apresentação de certidão de casamento atualizada, para a verificação da circunstância relacionada com o respectivo estado civil, em homenagem ao prin-

⁶⁷⁵ CSMSp. Apelação Cível nº 376-6/7. Data: 6/10/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁷⁶ CSMSp. Apelação Cível nº 376-6/7. Data: 6/10/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

cípio da continuidade, pois representa fato jurídico relevante de evidentes repercussões patrimoniais"⁶⁷⁷.

Para a averbação deve ser apresentada a certidão de casamento com a averbação da separação ou divórcio. Nenhum outro documento deve ser aceito, como a certidão de nascimento com essa anotação, nem mesmo a sentença de separação ou divórcio. Isso porque o art. 100, § 1º, da Lei 6.015/73 estabelece que, antes da averbação no Livro de Casamentos, "as sentenças não produzirão efeitos contra terceiros". Da mesma forma dispõe o art. 32 da Lei 6.515/77: "A sentença definitiva do divórcio produzirá efeitos depois de registrada no Registro Público competente". Assim, mesmo que apresentada a carta de sentença da separação do casal para o registro da partilha dos bens, deverá esta ser acompanhada da certidão atualizada de casamento com a devida averbação, pois as decisões judiciais de separação ou divórcio não ganham plena eficácia antes de averbadas no Registro Civil de Pessoas Naturais⁶⁷⁸.

Quanto à separação ou divórcio realizados no exterior, para produzirem efeitos no Brasil, além das mesmas formalidades exigidas para a comprovação do casamento no exterior, devem ser homologados pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 15 da Lei de Introdução ao Código Civil. Importante observar que essa separação ou divórcio somente permitirá a comprovação do estado civil do proprietário, jamais a partilha de bem imóvel, porque sentenças estrangeiras não podem dispor sobre bens imóveis localizados no Brasil, conforme determina o art. 89, I, do CPC: "Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil".

11. Partilha

A sentença ou a escritura pública de separação ou divórcio que decide sobre a partilha dos bens deve ser objeto de registro no Livro 2 quanto ao imóvel de antiga propriedade do casal. O título a ser apresentado no Cartório de Registro de Imóveis é a carta de sentença ou a escritura pública, neste caso quando a separação ou divórcio for consensual, não haja filhos menores ou incapazes do casal e conte com a necessária assistência de advogado⁶⁷⁹.

⁶⁷⁷ CSMSp. Apelação Cível nº 060580-0/5. Data: 05/10/1999. Localidade: Mairiporã. Relator: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAUROS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁷⁸ CSMSp. Apelação Cível nº 094251-0/8. Data: 22/11/2002. Localidade: São Paulo. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAUROS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁷⁹ Art. 1.124-A do CPC.

Quanto ao ato a ser praticado, a CGJSP manifestou-se no sentido de⁶⁸⁰:

“a) ser objeto de registro, a sentença de separação judicial, de divórcio, ou que anula o casamento, quando decidir sobre partilha de bens imóveis, ou direitos reais registráveis (art. 167, inc. I, 25, da Lei de Registros Públicos), e

b) ser objeto de averbação, a sentença de separação judicial, ou de nulidade ou anulação de casamento, que não decidir sobre a partilha dos bens dos cônjuges, ou que apenas afirmar permanecerem estes, em sua totalidade, em comunhão, (art. 167, inc. II, 14, da Lei de Registros Públicos), atentos, neste caso, para a mudança do caráter jurídico da comunhão, com a dissolução da conjugal (art. 267 do Código Civil) e surgimento da condominial ‘pro indiviso’ (arts. 623 e segs. do Código Civil⁶⁸¹)”.

12. Alienação de bens não partilhados

Após a dissolução do matrimônio e mesmo sem que tenha ocorrido a partilha dos bens do casal é possível posterior alienação dos imóveis.

Para isso não é necessário comprovar com certidão da ação de separação ou divórcio que não houve partilha, bastando, declaração expressa dos cônjuges no próprio título ou em documento em separado. Se houve partilha, o título a ser registrado é a carta de sentença extraída do processo de separação: "A jurisprudência deste Conselho Superior da Magistratura atualmente é no sentido de que a separação judicial põe termo ao regime de bens, transformando a comunhão até então existente em condomínio, permitindo a alienação dos bens pelos coproprietários, desde que averbada a alteração no estado civil, independentemente de prévio ingresso no fôlio real da partilha dos bens comuns"⁶⁸².

Para a alienação independentemente de registro da partilha, no ato deverão comparecer ambos os proprietários. Analisando recusa de registro em que compareceu apenas um dos ex-cônjuges alienando o imóvel, assim sintetizou o CSMSP sobre as possibilidades existentes: "O registro do título aquisitivo deu-se quando era ela casada, sob o regime da comunhão de bens, com Vladimir (...). E, vista disso, ou ambos, marido e mulher compareciam na escritura de compra e venda como alienantes, ou um como anuente da alienação feita

⁶⁸⁰ Comunicado CGJSP nº 12/82. Publicado no D.O.J., em 5 de fevereiro de 1982. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁸¹ Atualmente 1.314 e seguintes do CC de 2002.

⁶⁸² CSMSP. Apelação Cível nº 079158-0/3. Data: 05/09/2001. Localidade: São Paulo. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

pelo outro, ou era necessária a vinda de prova da partilha de bens do casal e de que, com esta, a parte ideal do imóvel foi atribuída exclusivamente a Hilda"⁶⁸³.

13. Bem de família

O rompimento do matrimônio não tem consequências sobre o bem de família convencional, estabelecendo expressamente o art. 1.721 do CC que "a dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família".

Assim, não é porque houve a separação ou divórcio que o bem de família deixa de ter a proteção da lei ou possa ser alienado voluntariamente. Para que possa o bem de família ser alienado continuará a ser necessário o consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público, nos termos do art. 1.717, segunda parte, do CC, ou ser comprovada a impossibilidade de sua manutenção, por decisão judicial e ouvidos o instituidor e o Ministério Público, conforme estabelece o art. 1.719 do CC.

Sobre a decisão judicial que autoriza a extinção do bem de família ser jurisdicional ou administrativa, assim se pronunciou a CGJSP: "A informalização das relações jurídicas é marca da sociedade contemporânea e só deve ser abandonada quando há sério risco à segurança dessas mesmas relações. Esse perigo não ocorre na espécie, em que os envolvidos, maiores e capazes, manifestaram o desinteresse na manutenção do bem de família por escritura pública, em situação fática de separados que residem em casas distintas, tudo a apontar para a razoabilidade da redução do rigor no formalismo para a desconstituição do bem de família. Não se identifica como óbice à pretensão resistida via recursal o disposto nos artigos 1.721 e 1.722 do Código Civil vigente, haja vista ter havido, na espécie, pronunciamento judicial que não necessariamente haverá de ser obtido no âmbito jurisdicional contencioso. Caracterizada está, portanto, a hipótese do artigo 1.719 do estatuto civil. Ademais, esta Corregedoria Geral da Justiça já se posicionou quanto ao estatuto civil atual, ao exigir pronunciamento judicial, nem sempre comportar interpretação literal. Assentou-se, sim, que essa imposição serve, em certas hipóteses, apenas

⁶⁸³ CSMSP. Apelação Cível nº 032082-0/1. Data: 14/8/1996. Localidade: Bananal. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

para as situações em que há controvérsia. Na mesma linha pode ser compreendido o referido artigo 1.719⁶⁸⁴.

Em 15 de outubro de 2008 o STJ editou a súmula nº 364 autorizando que o instituto do bem de família instituído pela Lei 8009/91 fosse também aplicado às pessoas solteiras, separadas e viúvas.

14. Reconciliação

A reconciliação é regida pelo art. 1.577 do CC que estabelece que “Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo⁶⁸⁵”, acrescentando o parágrafo único que “a reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens”.

Com a reconciliação se retorna ao *status quo* anterior: “A reconciliação desconstitui os efeitos da sentença de separação consensual ou litigiosa”⁶⁸⁶.

Os efeitos da reconciliação tem sido entendidos como sendo *ex tunc*⁶⁸⁷, preservados os direitos de terceiros. Assim, se um dos cônjuges adquiriu um imóvel durante a separação, com a reconciliação de casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, há a comunicação desse imóvel. Se esse mesmo imóvel foi onerado ou alienado durante a separação, serão preservados os direitos do adquirente ou credor, que não precisará complementar o ato com a anuência do cônjuge, mesmo que submetido a registro após a reconciliação.

15. Separação de fato

A separação de fato é estranha ao Registro, não podendo o oficial analisar esse aspecto: “Está fora do exame qualificador do Oficial delegado, na via estritamente administrativa, o reconhecimento, *sponte propria*, da natureza reservada de bens adquiridos por sucessão hereditária após a separação de fato

⁶⁸⁴ CGJSP. Processo 1095/03. Parecer do Juiz Auxiliar da Corregedoria: José Raul Gavião de Almeida. Data: 15/8/2003. Localidade: São Paulo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁸⁵ Em decorrência da Lei 11.477/07 atualmente também é admitida que seja feita extrajudicialmente por escritura pública lavrada em Tabelionato de Notas.

⁶⁸⁶ TJRS. Apelação Cível nº 597191899. 8ª Câmara Cível. Data: 12/08/99. Relator: Des. Antonio Carlos Stangler Pereira.

⁶⁸⁷ Com efeitos retroativos, em oposição a *ex nunc* (sem efeitos retroativos).

do casal. Admitir tal atuação significaria investir o registrador de jurisdição contenciosa. Seria, mais, permitir que o exame da legalidade se estendesse a situações fáticas, externas e estranhas ao título. Deve em suma, a questão da natureza dos bens adquiridos por sucessão hereditária após a separação de fato do casal ser submetida ao juízo do divórcio, onde se decidirá a eventual necessidade de partilha. Para efeito estritamente registrário, há necessidade de constar a apelante como casada, porque tal era o seu estado civil quando dos óbitos dos autores da herança. A anterior separação de fato é irrelevante para qualificação pessoal do herdeiro. O divórcio do casal será averbado, assim como - após discussão na esfera jurisdicional - o eventual fato dos bens herdados serem próprios da apelante e, por consequência, não sujeitos à partilha. A observância de tal conduta preservará os princípios da legalidade e do trato sucessivo, fundamentais à correta transmissão da propriedade imobiliária"⁶⁸⁸.

O mesmo se aplica à aquisição onerosa, sendo inaceitável título em que o adquirente seja qualificado como separado de fato: “Está fora do exame qualificador do Oficial Delegado, na via estritamente administrativa, o reconhecimento da natureza própria de bens adquiridos por contrato oneroso após a separação de fato do casal”. (...) Para efeito estritamente registrário, há necessidade de constar a apelante como casada, porque tal era o seu estado civil quando firmado o contrato de cessão de direitos de compromissário comprador. A anterior separação de fato é irrelevante para qualificação pessoal da adquirente. Lembre-se, finalmente, que o estado civil tem significativa importância para o registro imobiliário, não só como complementação da especialidade subjetiva, mas sobretudo diante das possíveis implicações patrimoniais decorrentes do regime de bens do casamento”⁶⁸⁹.

Porém, reconhecida jurisdicionalmente a separação de fato e a não comunicação do bem, poderá o registrador, após o trânsito em julgado e em cumprimento a mandado judicial, averbar tratar-se de bem próprio: “Criou-se, em termos diversos, à margem das hipóteses de dissolução da comunhão, prevista no artigo 267 do Código Civil⁶⁹⁰, a possibilidade de cessar a comunicação de bens adquiridos após a separação de fato do casal. O reconhecimento da existência de bens próprios em tal circunstância, deve ser feito, necessariamente,

⁶⁸⁸ CSMSP. Apelação Cível nº 031141-0/5. Data: 4/6/1996. Localidade: São Paulo. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁸⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 038165-0/5. Data: 2/7/1997. Localidade: Santa Rita do Passa Quatro. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁹⁰ Código Civil de 1916.

na esfera jurisdicional, em processo com garantia do contraditório e sentença que produza coisa julgada material”⁶⁹¹.

Frise-se que para o reconhecimento da não comunicação é necessário procedimento jurisdicional em que haja contraditório: “Ao contrário do entendimento do recorrente, houve comunicação do bem objeto da matrícula 153 do Registro de Imóveis de Socorro ante o regime de bens do casamento entre B e P (fls.). Para que seja excluída a comunicação em questão, há necessidade de decisão judicial expressa, em procedimento próprio, de cunho jurisdicional, não se prestando a tanto a decisão que homologou a partilha e adjudicou o bem nos autos do arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de B. Não se desconhece a posição da jurisprudência quando há aquisição de bens por cônjuges separados, sem que haja participação de ambos, quando então se julga a partilha em favor do cônjuge que efetivamente adquiriu o bem com seus esforços próprios. Tais situações são definidas, notadamente, no Juízo da família, observado o contraditório e a ampla defesa, na via jurisdicional”⁶⁹².

16. Alienação entre cônjuges

É possível a compra e venda entre cônjuges desde que o imóvel não tenha se comunicado em decorrência do regime de bens adotado, conforme estabelece o artigo 499 do CC: “É lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da comunhão”.

Em decorrência desse dispositivo legal, um imóvel adquirido por um dos cônjuges quando solteiro não poderá ser alienado ao outro após o matrimônio realizado no regime da comunhão universal de bens, o que é absolutamente natural porque com o matrimônio o imóvel passa a integrar a comunhão de bens do casal e esta alienação seria inócua, em nada alterando a titularidade do imóvel. Por outro lado, a venda pode ser realizada se o regime de bens não importou em comunicação do imóvel alienado, como ocorre no regime da comunhão parcial de bens com relação a imóveis adquiridos antes do matrimônio, mas a venda não implicará em transmissão ao patrimônio exclusivo do adquirente, já que após a venda haverá comunicação do imóvel, por força do regime de bens adotado.

⁶⁹¹ CSMSp. Apelação Cível nº 038165-0/5. Data: 2/7/1997. Localidade: Santa Rita do Passa Quatro. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁹² CSMSp. Apelação Cível nº 095196-0/3. Data: 19/12/2002. Localidade: Socorro. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Importante observar que o dispositivo legal trata de compra e venda, e não de doação, que, na vigência do Código Civil de 1916, não era aceita no regime da separação legal por importar em burla ao regime de bens.

No Recurso Especial nº 471958, o STJ entendeu que são válidas as doações promovidas na constância do casamento por cônjuges sob o regime de separação de bens, justificando que a restrição imposta à época da promulgação do Código Civil de 1916 não mais se justifica atualmente, o que configuraria, até mesmo, uma ofensa ao princípio da dignidade humana.

Contudo, devemos ressaltar que não é esse o entendimento que vem sendo adotado pelo CSMSP, o que deve ser observado pelo Oficial, já que em suas decisões o CSMSP leva em conta a análise de cada caso em concreto: “Escritura pública de doação. Doador casado com uma das donatárias pelo regime da separação legal de bens, em razão de infração do artigo 183, inciso XIII, do Código Civil de 1916. Proibição de doação, *in casu*, decorrente do artigo 226 do mesmo Código, porque promovida pelo cônjuge infrator”⁶⁹³

17. Habilitação anterior à Lei 6.515/77

Como há um lapso de tempo entre a habilitação e a celebração do casamento, que atualmente pode ser de até 90 dias da data que extraído o certificado de habilitação⁶⁹⁴, e na vigência do Código Civil de 1916 era de 3 meses, muitos casamentos foram celebrados no início da vigência da Lei 6.515/77, mas com a habilitação anterior à lei, quando o regime legal era o da comunhão universal e, portanto, sem a apresentação de pacto antenupcial para a adoção desse regime. A ausência de pacto nessas hipóteses já foi aceita pelo CSMSP: “Se o assento do matrimônio dos suscitados indica a adoção do regime da comunhão universal de bens (cfr. fl. 41-v), projetando, em interpretação que se reconhece razoável, o efeito da habilitação matrimonial – *in casu* precedente à lei do divórcio e conformada à lei do tempo em que se efetivou -, não cabe, sem mais, excluir a eficácia vigente no registro pessoal”⁶⁹⁵.

⁶⁹³ CSMSP. Apelação Cível nº 014950-0/2. Data 15/06/1992. Localidade: Itu. Relator: Dínio de Santis Garcia. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁶⁹⁴ Art. 1.532 do CC.

⁶⁹⁵ CSMSP. Apelação Cível nº 920-6/0. Data 4/11/2008. Localidade: Salto. Relator: Ruy Camilo. Disponível em: <www.arisp.com.br> (Kollemata).

CAPÍTULO IX

CLÁUSULAS

Conforme definição de De Plácido e Silva, cláusula "é toda manifestação da vontade imposta em um contrato, ou ato, em virtude da qual se restringe ou se dispõe a respeito das condições em que o mesmo possa exercer seus efeitos em relação às partes que o elaboram e aceitam"⁶⁹⁶.

Na análise de um título é de grande importância conhecer as principais cláusulas que podem ser estipuladas, para corretamente qualificar o título apresentado, num primeiro momento verificando se as cláusulas foram estabelecidas na forma prevista na legislação, em seguida lançando corretamente aquelas cuja publicidade deve ser feita no Livro 2 e finalmente observando a repercussão dessas cláusulas sobre o imóvel, tanto quando da emissão de certidões, como na qualificação de títulos apresentados posteriormente e relacionados ao imóvel.

1. Cláusulas Restritivas: Inalienabilidade, Impenhorabilidade e Incomunicabilidade.

As cláusulas restritivas são gravames que visam impossibilitar a alienação, penhora, sequestro e comunicação de bens transmitidos em doações e disposições testamentárias, devendo tais cláusulas ser impostas no próprio ato da liberalidade e, no caso de doação, poderão ser revogadas posteriormente por nova declaração de vontade de todas as partes.

As principais cláusulas restritivas relacionadas a imóveis são as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, que devem ser averbadas no Livro 2⁶⁹⁷.

A cláusula de inalienabilidade visa ao impedimento da alienação do imóvel pelo donatário ou herdeiro que recebeu o bem. Como consequência de tal restrição, fica o proprietário impedido também de hipotecar e dar o imóvel em anticrese⁶⁹⁸. Ainda, o artigo 1.911 do Código Civil determina que a cláusula de inalienabilidade implica em impenhorabilidade e incomunicabilidade do bem.

Em decorrência da inalienabilidade englobar a incomunicabilidade, em eventual separação ou divórcio, o imóvel doado a um dos cônjuges gravado

⁶⁹⁶ Op. cit., p. 294.

⁶⁹⁷ Art. 167, II, 11 da Lei 6.015/73.

⁶⁹⁸ Art. 1.420 do CC.

com a cláusula de inalienabilidade não pode ser partilhado: "Não poderia, portanto, bem próprio do marido, gravado com a cláusula de inalienabilidade, ter sido levado à partilha do patrimônio do casal, como se comum fosse. A operação levada a efeito significou transferência de bem inalienável, em manifesta afronta a cláusula restritiva"⁶⁹⁹.

Isso porque a cláusula de incomunicabilidade consiste em impedir que o imóvel doado ou recebido em herança integre a comunhão estabelecida com o casamento. Assim, mesmo que o donatário ou herdeiro seja casado pelo regime da comunhão universal de bens, o imóvel recebido com a cláusula de incomunicabilidade não se comunicará com seu cônjuge. É o que estabelece o art. 1.668, inciso I, do CC: "São excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar". Essa é a única restrição dessa cláusula, podendo o imóvel ser livremente alienado ou onerado.

Sobre a cláusula de impenhorabilidade, esta objetiva tão somente impedir que o imóvel doado ou recebido por sucessão venha a ser tomado por dívidas contraídas pelo donatário ou herdeiro. Não impede, porém, que ele venha a ser alienado espontaneamente.

Assim, se o imóvel foi gravado apenas com as cláusulas de incomunicabilidade e de impenhorabilidade, sua alienação é possível sem necessidade do cancelamento prévio de tais cláusulas que, no entanto, serão canceladas em seguida ao registro da transmissão, haja vista as cláusulas não poderem ser sucessivas.

A doação com imposição apenas de cláusulas restritivas não a torna com encargo⁷⁰⁰, mas permanece pura, tendo como consequência, por exemplo, a dispensa da necessidade de curador especial⁷⁰¹ em doação dos pais para o filho menor⁷⁰²: "A imposição da cláusula restritiva não se traduz em obrigação a ser cumprida pela donatária, mas, sim, em proibição de alienação, penhora ou comunicação do bem que a beneficia"⁷⁰³.

⁶⁹⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 038706-0/5. Data: 11/6/1997. Localidade: Buritama. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁰⁰ Art. 553 do CC.

⁷⁰¹ Art. 1.692 do CC.

⁷⁰² Art. 543 do CC.

⁷⁰³ CSMSP. Apelação Cível nº 078532-0/3. Data: 08/10/2001. Localidade: São José do Rio Preto. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

1.1. Imposição de cláusulas por escritura de retificação

Após o registro de doação é inviável a retificação do título para incluir cláusulas restritivas, mesmo que com a participação dos doadores e donatários: "Com a inscrição no registro imobiliário da escritura de doação, título que se mostrava regular, operou-se a transmissão do domínio dos doadores para os donatários. Inviável, portanto, a atual pretensão daqueles que deixaram de ser titulares do domínio de reservarem usufruto e imporem cláusulas restritivas aos atuais proprietários, irrelevante a expressa anuência destes, por ser contrária ao direito a possibilidade de que viessem a impor tais gravames aos próprios bens, cuja consequência é a de limitação da sua responsabilidade patrimonial. A imposição de cláusulas restritivas, assim como a criação do direito real de usufruto, devem ocorrer no próprio ato da liberalidade, por se constituírem em atos que somente podem ser praticados pelos titulares do domínio, transmitido com o registro da escritura de doação"⁷⁰⁴.

Se o título de doação não foi registrado, a transmissão da propriedade ainda não ocorreu e poderia ser registrada a escritura retificada.

1.2. Cláusula em um único grau

As cláusulas restritivas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade podem ser estabelecidas de forma vitalícia, mas não perpétua, pois a perpetuidade da restrição torna o bem imoto na economia, prejudicando a circulação de riquezas. Assim, os Tribunais têm decidido que a vigência da cláusula limita-se ao donatário ou herdeiro, não passando aos seus sucessores, ou seja, em um grau apenas:

“As cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade podem ser instituídas a termo ou condição; ou em caráter vitalício. No primeiro caso a cláusula instituída em favor de donatário ou de sucessor *causa mortis*, por ato entrevivos ou testamento, cessa quando operado o termo ou condição. No segundo aquilo se dá com a morte do beneficiário. Há, todavia, princípio de ordem pública que limita a vontade do doador ou testador que pretenda instituir essas restrições ao direito de propriedade. Essa regra, contida no artigo 1.723 do Código Civil⁷⁰⁵, está relacionada com o princípio de economia política que visa proteger a circulação da riqueza, impedin-

⁷⁰⁴ CSMSP. Apelação Cível nº 056317-0/1. Data: 26/03/99. Localidade: Lençóis Paulista. Relator: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁰⁵ Art. 1.848 do CC de 2002 sem a mesma redação quanto à transmissão dos bens desembaraçados de qualquer ônus aos herdeiros existente no art. 1.723 do CC de 1916.

do haja disposição perpétua que a restrinja. Daí porque a vedação à imposição de cláusula restritiva ao direito de propriedade que ultrapasse a vida do beneficiário⁷⁰⁶.

Por essa razão o cancelamento da cláusula pode ser feito quando do óbito de todos os donatários ou herdeiros diretamente pelo oficial, mesmo que estabelecida em caráter perpétuo: “Não será a vontade do instituidor, no sentido de que ela deverá persistir mesmo depois da morte do beneficiário da cláusula, que impedirá o cancelamento, já que disposição como essa é ilegal e ofende norma de ordem pública em sentido contrário”⁷⁰⁷.

1.3. Restrição aos próprios bens

As cláusulas restritivas mencionadas só podem ser impostas a terceiros por ato de liberalidade, ou seja, para donatários, herdeiros ou legatários, pois embora não haja previsão legal impedindo que se clause os próprios bens, os princípios que norteiam o direito de propriedade dão embasamento a esta posição, pois se assim não fosse os bens imóveis de devedores insolventes não responderiam mais por suas dívidas. Por isso, há “vedação de que tais cláusulas restritivas sejam impostas em atos onerosos ou posteriormente a dada liberalidade, pois a ninguém é permitido gravar os próprios bens”⁷⁰⁸.

Em relação especificamente à cláusula de inalienabilidade, acrescenta-se que “(...) seria ineficaz a cláusula imposta pelo proprietário a si mesmo, à medida que a qualquer tempo poderia ser revogada. De resto, a não disposição dos próprios bens é uma faculdade de quem é proprietário e seu registro seria, no mínimo, despiciendo”⁷⁰⁹.

Não se poderia deixar de lembrar que a instituição de bem de família é a única forma de tornar bem próprio impenhorável⁷¹⁰.

⁷⁰⁶ CGJSP. Processo 001634/95. Data: 09/08/95. Localidade: São Paulo. Juiz Auxiliar da Corregedoria: Marcelo Martins Berthe. Corregedor Geral da Justiça Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁰⁷ CGJSP. Processo 001634/95. Data: 09/08/95. Localidade: São Paulo. Juiz Auxiliar da Corregedoria: Marcelo Martins Berthe. Corregedor Geral da Justiça Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁰⁸ CSMSP. Apelação Cível nº 081249-0/9. Data: 20/12/2001. Localidade: Marília. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁰⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 003294-0/84. Data: 18/06/1984. Localidade: Itatiba. Relator: Heráclides Batalha de Camargo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷¹⁰ Art. 1.715 do CC.

1.4. Inalienabilidade contratual

A cláusula de inalienabilidade só pode ser estabelecida por doação ou testamento, assim, se, por exemplo, for ajustado em contrato de compra e venda a prazo que o adquirente não poderá alienar o imóvel⁷¹¹ até pagar todas as prestações, esta estipulação não passa de uma obrigação contratual e não poderá ser averbada na matrícula do imóvel.

Sobre a inalienabilidade contratual, o art. 1.475 do CC estabelece que: “É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado”. O título que apresentar cláusula impossibilitando o adquirente de alienar o imóvel não é considerado totalmente nulo, mas tão somente a cláusula⁷¹².

1.5. Imposição de cláusula por promissário comprador

Apenas o titular de domínio pode transmitir imóvel por doação ou herança com a imposição de cláusulas: “A disponibilidade é faculdade do proprietário e não do simples promissário comprador. A impossibilidade de alienação do imóvel por este é corolário de seu direito. A impossibilidade de disposição por parte do promitente decorreria, uma vez registrado o contrato, do art. 5º do Decreto-lei 58/37. Assim, ainda que fosse abstraída a vistosa ilicitude da impenhorabilidade clausulada, também por este argumento seria inócua a averbação da inalienabilidade”⁷¹³.

1.6. Doação de numerário e imposição de cláusulas

A regra de que não é possível a imposição de cláusulas restritivas em aquisição onerosa tem exceção, qual seja, quando o impositor da cláusula tenha simultaneamente doado o numerário para a aquisição do bem clausulado.

Esse o atual posicionamento do CSMSP: “Entender-se que o doador deva primeiro adquirir a propriedade do imóvel para, em seguida, como titular do domínio, doar a nua-propriedade com as cláusulas restritivas aos donatários, reservando a si o usufruto, reflete exegese por demais formalista, apegada à letra fria da lei (Código Civil, art. 1.676⁷¹⁴), que onera em demasia os contra-

⁷¹¹ A Lei 11.474/07 instituiu a cláusula de inalienabilidade temporária nos contratos de compra e venda objetos do Programa de Arrendamento Residencial (Vide item 15 Cap III).

⁷¹² Art. 184 do CC.

⁷¹³ CSMSP. Apelação Cível nº 003294-0/84. Data: 18/06/1984. Localidade: Itatiba. Relator: Heráclides Batalha de Camargo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷¹⁴ Art. 1.911 do CC de 2002.

tantes com duplicação dos atos notariais e registrários. Tal norma permite outra interpretação, mais consentânea com os princípios que regem o direito contratual, em que se destaca o da autonomia da vontade dos contratantes limitada, apenas pelos preceitos imperativos e pelos bons costumes, a possibilitar que, no caso ora em apreço, o doador, embora não seja o titular do direito real de propriedade, possa impor as cláusulas restritivas ao bem adquirido, pelos donatários, simultaneamente à doação pecuniária destinada a tal aquisição"⁷¹⁵.

Observe-se que a doação dos recursos deve ser realizada no mesmo ato em que são impostas as cláusulas.

1.7. Justa causa

Estabelece o art. 1.848 do CC: "Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima"⁷¹⁶. Assim, os bens que compõem a legítima só podem ser clausulados havendo justa causa.

Considera-se legítima "a porção ou parte da herança que pertence ou cabe ao herdeiro"⁷¹⁷, estabelecendo o art. 1.846 CC que "pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima".

Em decorrência desses dispositivos o CSMSP impediu a averbação de cláusula de incomunicabilidade instituída "em doação de numerário acoplado ao pagamento do preço em compra e venda" pela ausência de justa causa declarada para a imposição da cláusula : "Há, contudo, um único vício no instrumento de compra e venda do imóvel adquirido pela apelante (fls.9/10), que impede o seu ingresso no registro, na forma como elaborado. Diz respeito à cláusula de incomunicabilidade inserida na escritura. Com efeito, quando a interveniente Maria Helena doou a importância de R\$ 120.000,00, representada pelo apartamento do edifício Príncipe de Liverpool, n. 63, transmitido-o a seguir aos vendedores Edmundo Antonio e sua mulher, fez constar que a doação se fazia com exclusividade, 'em caráter incomunicável, como adiantamento de sua legítima (fl.10)'. A disposição constante do título é nula, porque afronta o disposto no artigo 1.848 do Código Civil, já que efetivada sob a égide

⁷¹⁵ CSMSP. Apelação Cível nº 078532-0/3. Data: 08/10/2001. Localidade: São José do Rio Preto. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷¹⁶ Art. 2.042 do CC.

⁷¹⁷ SILVA, De Plácido. Op. cit., p. 824.

do novo estatuto civil. É que pela regra contida no artigo referido o testador só pode estabelecer cláusula de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima, quando houver justa causa, declarada no testamento. Assim, como não houve no instrumento a expressa menção à exigência formulada pela lei, forçoso é reconhecer a invalidade da restrição"⁷¹⁸.

Observe-se que a averbação só não foi possível porque a doação atingiu a legítima. Se só envolvesse a parte disponível, seria possível impor cláusula na doação, independentemente de justa causa.

1.8. Sub-rogação da restrição

A alienação do bem gravado com a cláusula de inalienabilidade é possível nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.911 do CC, tendo como consequência a sub-rogação⁷¹⁹ das cláusulas ao produto da alienação: "No caso de desapropriação de bens clausulados, ou de sua alienação, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros".

A alienação e a consequente sub-rogação depende sempre de autorização judicial: "a sub-rogação, por ser vedada a vinculação ou imposição de cláusulas restritivas sobre os próprios bens, mesmo porque implicam em limitação de direitos de terceiros, v.g. credores de titular de domínio de imóvel gravado com cláusula de impenhorabilidade; cônjuge de proprietário de imóvel com cláusula de incomunicabilidade, à evidência, depende de apreciação judicial, sendo necessária a utilização do procedimento previsto no inc. II do art. 1.112 do CPC. A sub-rogação não se opera de pleno direito, é imprescindível a autorização judicial"⁷²⁰.

A sub-rogação da cláusula de inalienabilidade, que inclui a incomunicabilidade⁷²¹, em imóvel pertencente ao casal tem como consequência a perda da propriedade pelo cônjuge: "Essencial, para a solução da controvérsia, é compreender-se que a sub-rogação do vínculo importa na integral transferência da

⁷¹⁸ CSMSP. Apelação Cível nº 440-6/0. Data: 06/12/2005. Localidade: Sorocaba. Corregedor Geral da Justiça e Relator: José Mário Antonio Cardinale. Publicado no D.O.J. em 24/02/2006.

⁷¹⁹ Do latim *subrogare*, que significa substituição.

⁷²⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 081249-0/9. Data: 20/12/2001. Localidade: Marília. Relator: Luís de Macedo citando sentença do juiz da Primeira Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital, de 03.02.99, relativa ao Proc. 000.98.021177-8. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷²¹ Art. 1.911 do CC.

situação jurídica restritiva, antes referida a determinado bem, para o outro bem que passará a ser onerado. No que respeita à cláusula de incomunicabilidade, essa transposição poderia gerar alguma aparente perplexidade, nos casos em que o bem que irá receber o vínculo integre a comunhão patrimonial advinda do casamento; com a imposição da cláusula, o bem passaria a ser titulado com exclusividade por um dos cônjuges, por isso mesmo que excluído da comunhão: importaria isto em extinção *sine título*, do direito real cabente ao outro cônjuge? A resposta é positiva, mas não pode ser dissociada da correlata aquisição, pelo mesmo cônjuge, de direito sobre o outro bem, antes apartado da comunhão, e que, com a liberação do vínculo decorrente da sub-rogação, passa a integrá-la. Basta recordar – como o fazem as razões do recurso – que a transferência de vínculo faz presumir completa paridade de valores entre os bens sobre os quais se opera. Assim, nada há de estranhável em que imóvel antes titulado por casal venha, pela superveniente imposição de cláusula de incomunicabilidade, a pertencer a um só dos cônjuges”⁷²².

1.9. Inalienabilidade relativa

É possível estabelecer a cláusula de inalienabilidade de forma relativa, desde que estabelecida de modo expresso, como, por exemplo, quando é mantida dentro do grau estabelecido, mesmo que ocorrendo alienações entre os donatários ou herdeiros:

"Em retorno à exegese da cláusula, no seu conteúdo de inalienabilidade relativa, é indubitosa a outorga do direito aos donatário de alienarem suas respectivas partes uns aos outros, a ninguém mais. Dela se extrai a permissão da venda de donatário a donatário, porque só então o imóvel permaneceria em poder dos descendentes, os donatários, durante a vigência do vínculo. O Código Civil não admite a inalienabilidade senão relativamente ao primeiro nomeado, num grau apenas. No caso, só atinge um grupo de pessoas, da mesma geração, nos lindes restritos de uma família. Dentro desse grupo, e somente entre seus integrantes, poderiam ser realizadas alienações, mas o vínculo permanecería. A venda a um estranho - e entenda-se como estranho quem não for nomeado - era vedada, precisamente por acarretar o desfazimento da cláusula, proibida que é a sucessividade. A vontade dos doadores define-se na

⁷²² CGJSP. Processo 000079/91. Data: 22/4/1991. Localidade: Paraibuna. Juiz Auxiliar da Corregedoria: Aroldo Mendes Viotti. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

conservação do prédio pelos donatários, todos, alguns ou um só e para executar-lhes esse intento somente essa interpretação tem cabimento"⁷²³.

1.10. Exceções às cláusulas restritivas

Além das hipóteses trazidas pelo parágrafo único do artigo 1.911 do Código Civil, o imóvel gravado com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade também responde por:

a. Despesas condominiais:

Sobre a execução de dívida decorrente de despesas condominiais assim se posicionou o CSMSP: "Consistindo, pois, obrigação 'propter rem', está a unidade autônoma sujeita a penhora em ação de execução de despesas de condomínio que dela se originaram, mesmo que gravada por cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade impostas em testamento ou em doação"⁷²⁴.

b. Dívidas Fiscais:

O art. 184 do CTN expressamente estabelece que: "Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis".

Sobre esse tema, assim consignou o MM. Juiz Corregedor Permanente da 1ª Vara de Registros Públicos da Capital em procedimento instaurado em face de solicitação feita pelo Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Município de São Paulo: "Ainda que os imóveis estejam gravados de impenhorabilidade e incomunicabilidade, respondem eles pelo crédito tributário (artigos 1.676 do Código Civil⁷²⁵, 30 da Lei 6.830/80 e 184 do Código Tributário Na-

⁷²³ 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 284.144. Data: 05/02/1980. Relator: Octávio Stucchi. RDI 9 jan-jul 1982. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷²⁴ CSMSP. Apelação Cível nº 138-6/1. Data: 23/4/2004. Localidade: São Bernardo do Campo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷²⁵ Art. 1.911 do CC.

cional). Cuida-se de expressa e clara previsão legal e que dispensa necessidade de interpretação ou mesmo de recomendação"⁷²⁶.

c. Dívidas Trabalhistas

Respondendo o imóvel por dívidas fiscais, também responderá por dívidas trabalhistas, haja vista o art. 186 do CTN estabelecer que: "O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho".

Ao analisar penhora decorrente de execução trabalhista em imóvel impenhorável por estar onerado com hipoteca censual⁷²⁷, assim decidiu o CSMSP: "Tal registro se faz possível ante a interpretação sistemática e conjunta dos artigos 186 do Código Tributário Nacional, 889 da Consolidação das Leis do Trabalho, 10 e 30 da Lei Federal 6.830/80. Na execução dos créditos trabalhistas, incidem, subsidiariamente, as normas pertinentes ao executivo fiscal, as quais autorizam a constrição e a alienação forçada de quaisquer bens constantes do patrimônio do executado, com exceção daqueles declarados, por lei, como impenhoráveis"⁷²⁸.

No entanto, em todas as hipóteses acima, a existência das cláusulas deve ser de conhecimento do juiz do feito, pois, só assim, eventual valor arrecadado com a execução do imóvel que exceda o total da dívida ficará sub-rogado com as cláusulas, conforme estabelece o parágrafo único do art. 1.911 do CC: "No caso de desapropriação de bens clausulados, ou de sua alienação, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros".

Na falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis podem ser penhorados, salvo se destinados à satisfação de prestação alimentícia⁷²⁹.

1.11. Cancelamento das cláusulas

É possível o cancelamento das cláusulas, independentemente de procedimento judicial, seja por revogação, por morte do donatário ou herdeiro, ou

⁷²⁶ Processo 100/91. Data: 5/3/1993. Localidade: São Paulo. Juiz Corregedor Permanente: Dr. Kioitsi Chicuta. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷²⁷ Artigos 59 e 69 do Decreto-Lei 167/67.

⁷²⁸ CSMSP. Apelação Cível nº 088044-0/4. Data: 12/8/2002. Localidade: Araçatuba. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷²⁹ Art. 650 do CPC.

ainda por transmissão a terceiros quando há apenas cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade. A revogação das cláusulas é procedida mediante a apresentação de título contendo a vontade do clausulador e do beneficiário. No caso de falecimento de todos os herdeiros ou donatários do imóvel, mediante a apresentação de requerimento instruído com as certidões de óbito, e no caso de venda o cancelamento das cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade pode ser lançada de ofício após a transmissão.

A CGJSP assim sintetizou as hipóteses de cancelamento de cláusulas restritivas: “É tema incontroverso que o cancelamento de cláusulas restritivas com fundamento na interpretação da vontade do doador ou do testador deve ser endereçado à via jurisdicional (Processos CG 745/95, 120/84, 739/94). Admite-se, porém, o cancelamento administrativo pelo próprio registrador quando fundado em causa automática, aferível pelo singelo exame do título, sem necessidade de recorrer a elementos intrínsecos ou fáticos. É o que se dá, por exemplo, com a morte do donatário, a ocorrência de condição ou termo, ou, como no caso presente, manifestação inequívoca de vontade do doador (somada; é óbvio, à vontade do donatário)”⁷³⁰.

1.12. Cancelamento por revogação

O cancelamento das cláusulas impostas em doação é possível por nova declaração de vontade das partes: “A doutrina e jurisprudência hoje entendem, de modo tranquilo, que os vínculos com que o doador gravou o imóvel podem ser por ele cancelados. Isso porque, sendo a doação um contrato, está sujeita a todas as normas reguladoras dos atos jurídicos dessa espécie, podendo mesmo ser distratada”⁷³¹.

Quanto à forma do título a ser apresentado para o cancelamento, estabelece o art. 472 do CC que “O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.”

Para a revogação requer-se ainda a anuência do donatário, haja vista que o doador não poderá mais decidir isoladamente sobre cláusula incidente sobre imóvel que não mais lhe pertence.

⁷³⁰ Decisão nº 000653/96. Data: 18/3/1996. Localidade: São Paulo (4º SRI). Parecer de Francisco Eduardo Loureiro Juiz Auxiliar da Corregedoria. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷³¹ Decisão nº 000653/96. Data: 18/3/1996. Localidade: São Paulo (4º SRI). Parecer de Francisco Eduardo Loureiro Juiz Auxiliar da Corregedoria. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Também, na revogação de cláusulas não se poderá criar novas restrições: “Ora, já transmitida em definitivo a nua-propriedade, por força da doação perfeita e acabada, sobre ela não mais pode dispor a antiga doadora: ‘Nemo jus plus transferre potest quam ipse haberet’. Nem mesmo se facultaria à atual usufrutuária do imóvel substituir a cláusula de reversão, verdadeira condição resolutiva a onerar a nua-propriedade, pela instituição de outra modalidade de propriedade resolúvel, que tal seria a imposição de cláusula de conotação fideicomissária: a instituição de fideicomisso, ou de cláusula restritiva de outra ordem, tem como antecedente lógico a plena faculdade de dispor da coisa por parte do instituidor, requisito ausente na situação de quem já se despojou do direito que só posteriormente desejaria onerar”⁷³².

Em doação feita por mais de uma pessoa, se falecido um dos doadores não é mais possível revogar as cláusulas no âmbito administrativo. O cancelamento só poderá ser feito em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado, pois a vontade do doador falecido não pode ser substituída pela vontade do sobrevivente. É possível, no entanto, falecido um dos doadores, ser revogada a cláusula que atinge apenas a fração transmitida pelo doador sobrevivente: “Em suma, viável cônjuge doador sobrevivente contratar com o donatário a revogação de vínculos restritivos, no que se refere à parte ideal de prédios que foram de seu domínio”⁷³³.

1.13. Cancelamento por morte dos donatários ou herdeiros

Como as cláusulas não podem ultrapassar a vida dos donatários ou herdeiros, elas podem ser canceladas após a morte de todos os proprietários do imóvel clausulado: “Esquecem-se, aliás, os réus que as cláusulas de inalienabilidade e incomunicabilidade são temporárias, ou vitalícias. Os vínculos perpétuos, ou cuja duração se estenda além da vida de uma pessoa, são condenados (Clóvis, comentários ao art. 1.676 do Código Civil). Daí observar Washington de Barros Monteiro que com a morte do donatário ou do herdeiro extingue-se o ônus e os bens passam livres e desonerados aos respectivos sucessores (Direito das Sucessões - págs. 130 e 131). Inaceitável, como se vê, a tese erigida

⁷³² Decisão 000114/90. Data: 25/7/1990. Localidade: Piratininga. Parecer de Aroldo Mendes Viotti, Juiz Auxiliar da Corregedoria. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷³³ Decisão nº 000653/96. Data: 18/3/1996. Localidade: São Paulo (4º SRI). Parecer de Francisco Eduardo Loureiro, Juiz Auxiliar da Corregedoria. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

pelos apelados, toda ela construída no pressuposto de que a incomunicabilidade permaneceu ou continua, mesmo após a morte do donatário"⁷³⁴.

Não é necessário procedimento judicial para esse cancelamento, bastando a apresentação de requerimento com firma reconhecida do interessado instruído com as certidões de óbito dos proprietários, nos termos do art. 250, III, da Lei 6.015/73.

1.14. Cancelamento por interpretação da vontade dos doadores

O cancelamento de cláusulas restritivas por interpretação de vontade dos doadores não é possível na esfera administrativa.

Sobre esse tema assim já se manifestou a CGJSP: “Mesmo assim, e a despeito do que preceitua o art. 1.676 do CC⁷³⁵, tenciona o requerente ver desonerado o imóvel, para tanto socorrendo-se de interpretação de qual tenha sido o intuito da doadora ao instituir o gravame, ou mesmo querendo ver reconhecida, em relação ao conteúdo e objeto da cláusula restritiva, sua atual ociosidade e até injustiça. O fato é que tudo isto já escapa da apreciação possível que se contém na competência da Corregedoria, afinal órgão de desempenho de mister puramente administrativo. Inexistente qualquer causa automática de cancelamento do gravame tal como a morte de todos os donatários, ou ainda manifestação de vontade do doador, perseguindo-se tal fim, repita-se, com argumentação pertinente à intenção do doador e à finalidade e utilidade da instituição da restrição nada se há de fazer no âmbito administrativo-correcional senão indeferir-se o pleito, remetendo-se o interessado à via jurisdicional”⁷³⁶.

1.15. Cancelamento pela ocorrência de termo ou condição

Também é possível o cancelamento administrativo das cláusulas quando estabelecidas para prevalecerem por determinado período ou até determinada condição. É o que ocorre, por exemplo, quando é estabelecida que a cláusula perdurará até que o herdeiro ou donatário atinja determinada idade. O cancelamento, então, será lançado a pedido do interessado, que deverá apresentar

⁷³⁴ Terceira Câmara do Tribunal de Alçada Civil de São Paulo. Apelação nº 117.145. Data: 30/04/1969. Localidade: São Paulo. Relator: Martiniano de Azevedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷³⁵ Art. 1.911, parágrafo único, do CC

⁷³⁶ Decisão nº 739/94. Data: 7/4/1994. Localidade: Ribeirão Bonito. Parecer de Cláudio Luiz Bueno de Godoy, Juiz Auxiliar da Corregedoria. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

requerimento instruído com documento hábil comprovando o implemento da condição.

Comum que em doações com reserva de usufruto se estabeleçam cláusulas restritivas. Não fixado termo ou condição para a vigência das cláusulas, elas perdurarão mesmo após a extinção do usufruto: “Há de ficar esclarecido, desde logo, não ter a extinção do usufruto, por morte dos doadores, projeção na cláusula de inalienabilidade. Esta restrição não visava garantir os usufrutuários contra a presença de nus-proprietários estranhos e, plenamente válida, não poderia ser levantada como consequência do falecimento dos doadores, determinantes tão só do efeito extintivo do usufruto. À evidência, a vitaliciedade da disposição é dirigida aos donatários, e não aos doadores; enquanto vida tiverem o vínculo subsistirá. Nem se conjugue, apesar do arrimo valioso em Washington de Barros Monteiro, o direito real de usufruto à cláusula de inalienabilidade; uma coisa é reservar os rendimentos do bem, outra é gravá-lo. A extinção do usufruto acarreta a consolidação do domínio, mas sem plenitude, dada a restrição imposta. Em nenhuma dialética, com extremos de habilidade revelará, em tal hipótese, um usufruto de segundo grau”⁷³⁷.

2. Cláusula restritiva convencional em loteamento

Outras restrições que requerem muita atenção do registrador são as estabelecidas quando do registro do loteamento.

Essas restrições constam dos contratos-padrão e deverão ser observadas pelo oficial: “Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do artigo 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações: (...) VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação pertinente”⁷³⁸.

Analisando obrigação convencional do compromissário comprador não subdividir lote, a CGJSP assim se posicionou: “Observe-se que, como salientado na decisão recorrida e no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, restrição convencional dessa natureza, inserida em contrato-padrão de loteamento, tem prevalência ainda que o desdobro tenha sido aprovado pela Municipalidade ou que lei municipal a tenha afastado. Isso porque a restrição

⁷³⁷ 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 284.144. Data: 05/02/1980. Relator: Octávio Stucchi. RDI 9 jan-jul 1982. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷³⁸ Art. 26 da Lei 6.766/79.

em causa, como outras incluídas nos contratos-padrão, tem por finalidade assegurar a qualidade urbanística do loteamento e garantir ao adquirente e aos demais proprietários de lotes o padrão do local e as características do empreendimento. Bem por isso, inclusive, a obrigatoriedade do depósito de modelo dos contratos no registro de imóveis, para que todos os interessados possam ter ciência das restrições convencionais"⁷³⁹.

Contudo, em que pese os precedentes da Corregedoria Geral da Justiça, a questão não se encontra pacificada, tendo um julgado proferido posteriormente pelo r. Órgão decidido diversamente, prevalecendo a legislação urbanística municipal em relação às restrições convencionais de loteamento anteriormente impostas: “REGISTRO DE IMÓVEIS, Desdobro. Lote. Aprovação pelo Município que faz presumir o respeito à legislação urbanística. Restrição urbanística prevista no contrato padrão arquivado com o registro do loteamento, por outro lado, que foi expressamente revogada por legislação municipal posterior. Recurso provido para afastar a recusa da averbação do desdobro”⁷⁴⁰

3. Cláusula resolutiva e pacto comissório

O Código Civil de 1916 trazia em seu artigo 1.163 uma cláusula especial nos contratos de compra e venda, o chamado “pacto comissório”:

"Art. 1.163. Ajustado que se desfça a venda, não se pagando o preço até certo dia, poderá o vendedor, não pago, desfazer o contrato, ou pedir o preço.

Parágrafo único - Se, em 10 (dez) dias de vencido o prazo, o vendedor, em tal caso, não reclamar o preço, ficará de pleno direito desfeita a venda”.

A referida cláusula apresentava-se como uma condição resolutiva do contrato de compra e venda firmado pelas partes, pois caso o adquirente não efetuasse o pagamento do preço na data acordada, o transmitente podia desfazer o contrato.

O Código Civil de 2002 não repetiu a norma intitulada pelo diploma anterior “Do pacto comissório”, contudo, trouxe em seu artigo 474 um instituto muito próximo ao pacto comissório, a “cláusula resolutiva”, pois determina que tal cláusula aposta expressamente em um contrato, opera de pleno direito, já a tácita depende de interpelação judicial, e em seu artigo seguinte determina

⁷³⁹ CGJSP. Processo nº: 29/2006. Data: 28/4/2006. Localidade: Indaiatuba. Juiz Auxiliar da Corregedoria: Álvaro Luiz Valery Mirra. Corregedor Geral da Justiça: Gilberto Passos de Freitas. Disponível em: <www.irib.org.br>.

⁷⁴⁰ CGJPS. Parecer nº 396/2009. Processo CG nº 2009/79569. Data: 9/12/2009. Localidade: Lins. Juiz Auxiliar da Corregedoria: José Marcelo Tossi Silva. Corregedor Geral da Justiça: Reis Kunstz. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>.

que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento.

Dessa forma, quando o contrato dispor expressamente a cláusula resolutiva, o registro deverá mencioná-la, para que seus efeitos possam surtir futuramente.

O pacto comissório e a cláusula resolutiva não devem ser objeto de averbação autônoma⁷⁴¹: "(...) a existência do pacto comissório deve integrar o registro da compra e venda condicional, vedada, pois, sua averbação"⁷⁴².

Essas cláusulas, no entanto, não permitem o cancelamento administrativo do registro da transmissão por requerimento do credor no caso de inadimplemento: "A rescisão do contrato, mesmo quando cláusula contratual preveja efeitos independentemente de qualquer comunicação ou notificação, somente pode surtir efeitos no âmbito registral em se cumprindo as formas legais, que implicam no aforamento de demanda, e na conquista de 'documento hábil' (art. 250, III, da LRP), que deve apresentar a concordância da outra parte. Como estabelece o art. 472, o 'distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato', ou seja, com a concordância de ambas as partes"⁷⁴³.

A cláusula resolutiva não impede a alienação posterior do imóvel, porém, "resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha"⁷⁴⁴.

4. Cláusula de reversão

A cláusula de reversão é prevista no art. 547 do CC, que estabelece que "O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário".

Essa cláusula não prevalece em favor de terceiro, ou seja, o imóvel só pode reverter ao próprio doador⁷⁴⁵.

⁷⁴¹ Item 116, Cap. XX, das NSCGJSP.

⁷⁴² CSMSP. Apelação Cível nº 334-6/6. Data: 6/10/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁴³ Decisão 000.05.008944-7. Data: 14/3/2005. Localidade: São Paulo (5º SRI). Juiz Corregedor Permanente da 1ª VRPSP: Venício Antonio de Paula Salles. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁴⁴ Art. 1.359 do CC.

⁷⁴⁵ Art. 547, parágrafo único, do CC.

Situação que exige cuidado é aquela em que a doação foi realizada por casal e um dos doadores tenha falecido antes do donatário, porque nesse caso apenas a metade doada pelo doador sobrevivente reverterá, sendo a outra metade transmitida aos herdeiros do donatário: "Verifica-se, portanto, que desde o falecimento do doador varão, o donatário passou a ser titular dos direitos de propriedade resolúvel relativos à metade ideal doada por Rita (...), e dos direitos de propriedade plena referentes à metade ideal doada por Teodoro (...). Com o falecimento do donatário, em 26 de novembro de 1.995, abriu-se a sucessão da metade ideal de cuja propriedade plena era ele titular, sendo herdeiras suas quatro filhas, três das quais menores. Apenas a outra metade ideal é que, por força da condição resolutiva imposta, reverte para o patrimônio da recorrente"⁷⁴⁶.

No mesmo parecer referido acima se indicou o título a ser apresentado para o lançamento da reversão quando parte do mesmo imóvel seja objeto de inventário: "não sendo possível, no entanto, o atendimento da sua mais recente postulação, já por ocasião do recurso, de averbação da reversão de sua metade ideal, mediante mera comprovação do óbito do proprietário resolúvel, pois com o falecimento deste e a consequente abertura da sucessão os bens se encontram em um estado de indivisão provisória que somente se resolverá com a oportuna partilha, solucionando-se a questão registrária com o ingresso do correspondente formal, que haverá de compreender a totalidade dos bens, compreendendo tanto a metade ideal integrante da sucessão quanto a outra, que é objeto de reversão em favor da recorrente, embora não seja objeto de partilha entre os herdeiros"⁷⁴⁷.

Nas demais hipóteses, a reversão será averbada mediante a apresentação de certidão de óbito do donatário⁷⁴⁸.

Para a revogação da cláusula de reversão é necessária a declaração de vontade dos doadores e a anuência do donatário, observando-se que deverá ser formalizada da mesma forma exigida para o título de doação⁷⁴⁹: "Assinale-se, em primeiro lugar, que a revogação da cláusula de reversão imposta ao ato de

⁷⁴⁶ CGJSP. Processo nº 000259/98. Data: 05/03/98. Localidade: Poá. Corregedor Geral de Justiça: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁴⁷ CGJSP. Processo nº 000259/98. Data: 05/03/98. Localidade: Poá. Corregedor Geral de Justiça: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁴⁸ Art. 128 do CC.

⁷⁴⁹ Art. 472 do CC.

liberalidade é perfeitamente possível por ato da instituidora, contando com o assentimento da donatária"⁷⁵⁰.

5. Cláusula de acrescer

O usufruto instituído em favor de várias pessoas que gozam do direito ao mesmo tempo, denominado usufruto simultâneo, é exercido de forma parcial, pertencendo a cada usufrutuário uma fração ideal no direito de usufruto, pois o falecimento de cada usufrutuário gera o cancelamento de sua parte respectiva, conforme estabelece o art. 1.411 do CC: "Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente".

A parte final do artigo retro mencionado refere-se ao chamado direito de acrescer no usufruto simultâneo, assim, se estipulado e lançado o direito de acrescer no Livro 2 (a informação já vem contida no registro da instituição ou reserva de usufruto), quando do falecimento de um dos usufrutuários, a sua parte é acrescida aos demais, não gerando cancelamento parcial do usufruto. Contudo, se não convencionada tal cláusula, com o falecimento de um usufrutuário, a sua parte ideal é consolidada na propriedade plena da pessoa do nu-proprietário, cancelando-se parcialmente o usufruto.

6. Cláusula de decaimento

A cláusula de decaimento, ou seja, que estipule a perda total das prestações pagas em caso de resolução do contrato por inadimplemento, é nula. É o que estabelece o art. 53 do CDC: "Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado".

Porém, essa nulidade não impede o registro do título, fulminando apenas a cláusula⁷⁵¹.

Também há nulidade da cláusula que autorize "o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for

⁷⁵⁰ Decisão 000114/90. Data: 25/7/1990. Localidade: Piratininga. Juiz Auxiliar da Corregedoria: Aroldo Mendes Viotti. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁵¹ Art. 184 do CC.

paga no vencimento"⁷⁵². Após o vencimento da dívida, pode o devedor dar a coisa em pagamento do débito⁷⁵³.

7. Cláusula de indivisibilidade

A cláusula de indivisibilidade pode ser ajustada pelos condôminos ou imposta em doação ou testamento. Em todos os casos não pode exceder o prazo de 5 anos⁷⁵⁴.

Antes do término do período convencionado, "a requerimento de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo"⁷⁵⁵.

8. Cláusula *constituti*

Convencionada em muitos instrumentos de compra e venda, o constituto possessório ou cláusula *constituti* tem como consequência: “considerar promovida a tradição da coisa, que lhe serve de objeto, embora continue a ser detida pelo antigo possuidor. Nesta razão, também é chamada de cláusula precária, visto que o possuidor da coisa por ela reconhece que continua em seu poder, mas não tem sobre ela mais que o direito de uso, a título de *constituto* ou precariamente”⁷⁵⁶.

É o que ocorre, por exemplo, quando o vendedor, após a alienação, continua na posse do imóvel, a partir de então, não mais como proprietário, mas como inquilino ou como comodatário.

Por envolver apenas a posse, esse ajuste não é lançado no registro da venda ou averbado no Livro 2.

9. Cláusula de retrovenda

A cláusula de retrovenda é estabelecida no art. 505 do CC: “O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 (três) anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias

⁷⁵² Art. 1.428 do CC.

⁷⁵³ Art. 1.428, parágrafo único, do CC.

⁷⁵⁴ Art. 1.320, § 1º e § 2º, do CC.

⁷⁵⁵ Art. 1.320, § 3º, do CC.

⁷⁵⁶ SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 296.

necessárias”. O direito de retrato é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, e poderá ser exercido contra o terceiro adquirente⁷⁵⁷.

A retrovenda aplica-se apenas a venda e compra de bem imóvel. No caso de outros contratos, como dação em pagamento, por exemplo, retrovenda não será, mas sim condição resolutiva, que se regerá então pelo art. 474 do CC, como já consignou o CSMSp: "Apenas convém lembrar a precisa lição do Ministro Moreira Alves, para quem, em tal caso, "não se tratará propriamente de retrovenda, mas de cláusula que encerra condição resolutiva potestativa (cuja oposição a negócio jurídico é lícita, desde que não vedada por lei especial), a que, em consequência, se aplicará a disciplina das condições resolutivas em geral e não as normas que regulam, especificamente, a retrovenda" (A Retrovenda, 2a Edição RT, pág. 116)"⁷⁵⁸.

O valor a ser pago para recobrar o imóvel é o definido no CC, não podendo as partes alterá-lo: “cabe ao Oficial recusar o registro de atos que a lei proíbe” (acórdão do Cons. Sup. Magistr. na AC. 1.395-0, Catanduva, rel. des. Affonso André, j. 11-11-1982). (...) Na espécie, consoante anota a decisão recorrida, os requisitos legais da retrovenda não estavam presentes. Segundo o artigo 1.140 do Código Civil⁷⁵⁹, realmente, para recobrar o imóvel transacionado deverá o vendedor ‘restituir o preço mais as despesas feitas pelo comprador’. (...) Anota a sentença, *in casu*, que não estava sendo devolvido o preço. Estava, sim, para o retrato, pactuada a devolução de quatro vezes o valor do preço. (...) Depreende-se, de todo o exposto, não ser válida a cláusula de retrovenda”⁷⁶⁰.

Também, não se pode ultrapassar o prazo ajustado, que deverá respeitar o limite legal de 3 anos: "Certo é que, ‘se, após expirado o prazo legal ou convencional, o vendedor vier a adquirir o imóvel, deve ser considerada essa operação como um novo contrato, subordinado à transcrição e aos impostos respectivos, não se podendo praticar mais no Registro Imobiliário qualquer ato com fundamento na retrovenda, já caduca’ (Miguel Maria de Serpa Lopes, Tratado cit., v.3, p. 378). (...) Diante disso, com o retorno dos autos à instância de origem, a escritura denominada de ‘retrato de retrovenda’ poderá ser considerada como de compra e venda, desde que observados os requisitos perti-

⁷⁵⁷ Art. 507 do CC.

⁷⁵⁸ CSMSp. Apelação Cível nº 040017-0/0. Data: 17/2/1998. Localidade: São Paulo. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁵⁹ Art. 505 do CC de 2002.

⁷⁶⁰ CSMSp. Apelação Cível nº 006136-0. Data: 26/9/1986. Localidade: São Paulo. Relator: Sylvio do Amaral. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

nentes à transmissão do domínio de imóvel rural, inclusive, portanto, o recolhimento do imposto de transmissão *inter vivos*"⁷⁶¹.

10. Fideicomisso

O art. 167, II, 11, da Lei 6.015/73, ou seja, o mesmo dispositivo que prevê a averbação das cláusulas restritivas, também estabelece a averbação da constituição do fideicomisso.

O fideicomisso é o instituto em que o fiduciário adquire um bem transmitido pelo fideicomitente, sendo que após sua morte, ou cumprida certa condição, ou, ainda, após certo tempo, transmite-o ao fideicomissário.

O art. 1.952 do CC estabelece que "a substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos⁷⁶² ao tempo da morte do testador", acrescentando o parágrafo único desse dispositivo legal que "Se, ao tempo da morte do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário".

Essa restrição, não se aplica aos testamentos anteriores ao Código Civil de 2002:

"Destarte, o feito encerra a discussão a respeito do cumprimento de testamento lavrado sob as regras do antigo Código Civil quando o testador faleceu já na vigência do novo Código. Especificamente na situação dos autos, o testador instituiu o fideicomisso em relação a fideicomissários já concebidos, disposição que violaria previsão contida no artigo 1.952 do novo Código, por vedar expressamente a substituição de fideicomissária em favor dos não concebidos. O Sr. Oficial recusou o ingresso do título ao fôlio real sob o argumento de que o registro viola expressa disposição legal. Entretanto, embora se reconheça a possibilidade de ser adotado o posicionamento do Sr. Oficial, não é essa a melhor interpretação dos princípios e regras que regem a matéria, nem foi essa a opção do legislador. Isto porque, as Disposições Finais e Transitórias do novo Código Civil, que norteiam a aplicação das regras do antigo e do novo Código Civil, especialmente quanto às incompatibilidades e contradições, nada mencionou a respeito da situação ora enfrentada, quanto à validade

⁷⁶¹ CSMSP. Apelação Cível nº 5-0/80. Data: 18/08/1980. Localidade: Guaíra. Relator: Adriano Marrey. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁶² Difere de nascituros, que são os já concebidos, mas que ainda não nasceram.

do testamento que institui fideicomisso em favor de fideicomissário já concebido"⁷⁶³.

Estabelece ainda o art. 1.959 do CC que "São nulos os fideicomissos além do segundo grau".

Sobre o fideicomisso, a ECGJSP, respondendo a consulta formulada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo, tratou de forma esclarecedora sobre o tema:

"O fideicomisso disciplinado no CC (art. 1.733 e ss.⁷⁶⁴) constitui modalidade de substituição, que repercute nas sucessões testamentárias. Substituição, segundo definição de Clóvis Bevilacqua, "é uma instituição subsidiária e condicional, feita para o caso em que a primeira não produza, ou já tenha produzido o seu efeito" (CC - obs. 1 ao art. 1.279). No fideicomisso, a substituição consiste em instituir herdeiro, ou legatário, com o encargo de transmitir os bens a uma outra pessoa a certo tempo, por morte, ou sob condição preestabelecida. Destarte, o fiduciário recebe o domínio restrito e resolúvel sobre a herança.

O fiduciário⁷⁶⁵, ao contrário do que ocorre com o usufrutuário, pode alienar e gravar o bem fideicometido, em caráter resolúvel⁷⁶⁶. Por outro lado, o fideicomissário, ao inverso do "nu-proprietário" não pode alienar, porquanto é titular de mera expectativa de direito.

Feitas estas considerações, cabe acrescentar que o fideicomisso extingue-se, naturalmente, pelo advento do termo ou condição, passando os bens fideicometidos ao fideicomissário. Pode, ainda, o fideicomisso caducar, na hipótese de o fideicomissário pré-morrer ao fiduciário, adquirindo este, então, o pleno domínio dos bens. O mesmo ocorre nos casos de não se dar o implemento da condição sob a qual é instituído; renúncia da herança, exclusão por indignidade, falta de legitimação do fideicomissário para suceder e perecimento do objeto, sem culpa do fiduciário, não ocorrendo sub-rogação no valor do seguro. Cabe anotar que nos últimos casos a extinção decorre de ato humano.

Observe-se que o registro, averbação e cancelamento do fideicomisso estão submetidos à complexa sistemática dada a característica de propriedade

⁷⁶³ Decisão 1ª VRPSP. Data: 3/7/2006. Processo nº: 583.00.2006.122508-0. Localidade: São Paulo (4º SRI). Juíza Corregedora Permanente: Maria Isabel Romero Rodrigues Henriques. Publicado no D.O.J. de 18/07/2006.

⁷⁶⁴ Arts. 1.951 e ss do CC de 2002.

⁷⁶⁵ Na fonte da qual foi extraído consta fideicomissário.

⁷⁶⁶ Art. 1.359 do CC.

resolúvel do fiduciário e a previsão legal de averbação do fideicomisso (art. 167, II, 11 da Lei 6.015/73⁷⁶⁷).

A transmissão da propriedade, em caráter resolúvel, do testador falecido ao fiduciário é objeto de registro e a constituição do fideicomisso é averbada.

Por isso, com a extinção do fideicomisso é efetuado seu cancelamento e o registro da propriedade em nome do fideicomissário. Há, portanto, duas inscrições sucessivas.

Outra forma corrente de escrituração do fideicomisso admite uma só inscrição, a da propriedade transmitida, alongada com a referência à condição fideicomissária. Neste caso, com a extinção do fideicomisso é necessária apenas a averbação de cancelamento.

Pondo de lado a polêmica⁷⁶⁸, bem enfocada por Afrânio de Carvalho (Registro de Imóveis, Forense, § 132), acerca de qual das soluções é mais adequada, cabe assinalar, a propósito do estudo encetado, que em ambas é necessária a averbação de cancelamento.

Põe-se sempre, então, a questão da forma: É mister, sempre, a ordem judicial para que se proceda o cancelamento? Não. A disposição do inciso VI do art. 1.112 do CPC, relativa à espécie é interpretada de maneira idêntica àquela da exegese dada à hipótese de extinção do usufruto.

A forma do cancelamento do fideicomisso, como aquela do usufruto, sempre está relacionada à atribuição do Oficial, consistente no dever de verificar os aspectos intrínsecos ou extrínsecos dos títulos apresentados. Alguns, independentemente de procedimento judicial para sua informação e a integração de direitos, ensejam a extinção do fideicomisso. Instruem eles o requerimento, dando ocasião ao cancelamento, exatamente como visto quanto ao cancelamento do usufruto.

Entretanto, nem sempre o requerimento instruído com um desses títulos extrajudiciais dá azo ao cancelamento. Pode o registro ser omissivo quanto aos elementos referentes ao fideicomissário. Basta recordar exemplo em que no momento do registro, ainda não existam os fideicomissários por ter sido con-

⁷⁶⁷ Na fonte da qual foi extraído consta art. 167, II, 23, da Lei 6.015/73.

⁷⁶⁸ As NSCGJSP estabelecem em nota ao item 1, a, 22, do Cap. XX: "O registro de fideicomisso não é autônomo. Por isso, deve ser ele mencionado no registro da transmissão".

templada a prole futura do fiduciário. Esta omissão deverá ser suprida judicialmente, ainda que por procedimento retificatório"⁷⁶⁹.

Quanto ao fideicomisso residual, assim se manifestou o CSMSP: "dispor-se que o que se transmitirá aos fideicomissários será a sobra de alienações autorizadas nada mais é do que reforçar a condição de proprietário do fiduciário, posto que resolúvel (art. 1.734⁷⁷⁰), representando, de toda forma, a instituição do chamado fideicomisso residual, pese embora com resistência, predominantemente aceito em doutrina"⁷⁷¹.

11. Cláusulas em transcrições

Na abertura de matrículas a partir de antigas transcrições deve-se ter muito cuidado na análise e transporte⁷⁷² de eventuais cláusulas, haja vista que no sistema anterior os lançamentos das cláusulas ocorriam tanto na coluna de averbações como na coluna de condições da transcrição.

Na coluna de averbações eram lançadas "as cláusulas de inalienabilidade, imposta a imóveis, bem como a constituição do fideicomisso"⁷⁷³, porém, era na coluna de condições do contrato que eram consignadas "todas as cláusulas adjetas que possam afetar a terceiros e de necessária publicidade"⁷⁷⁴.

Assim, o encargo em uma doação, como a determinação de que o imóvel fosse utilizado apenas como escola, constará na transcrição apenas na coluna condições do contrato, e não na coluna averbações, o que deve ser observado com muito cuidado quando do encerramento da transcrição e abertura da matrícula.

12. Cláusula de preempção ou preferência

Entre as cláusulas especiais à compra e venda está a cláusula de preferência ou preempção, pela qual pode ser estabelecido que o comprador, em caso

⁷⁶⁹ Decisão 072016/84. Data: 17/01/1985. Localidade: São Paulo. Parecer do Juiz de Direito Corregedor Renato Gomes Corrêa. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁷⁰ Art. 1.953 do CC.

⁷⁷¹ CSMSP. Apelação Cível nº 095036-0/4. Data: 22/11/2002. Localidade: São Paulo. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁷² Art. 230 da Lei 6.015/73

⁷⁷³ Art. 283, III, do Decreto 4.857/39.

⁷⁷⁴ Art. 247, 11, do Decreto 4.857/39.

de alienação do imóvel, terá a obrigação de oferecê-lo ao vendedor para que possa adquiri-lo pelo mesmo preço pelo qual pretende aliená-lo⁷⁷⁵.

A prelação, como também é denominada a cláusula de preferência, não incide apenas no caso de venda, mas também na hipótese de dação em pagamento, não podendo esse direito ser cedido a terceiros nem ser transmitido a herdeiros.

O direito de preempção para bens imóveis não pode ser estipulado por prazo superior a 2 anos⁷⁷⁶ e caduca se não exercido em até 60 dias da notificação ao vendedor⁷⁷⁷. Para bens móveis os prazos são de 180 dias e 3 dias, respectivamente.

Diferentemente do que ocorre na cláusula estabelecida no contrato de locação, o direito de preferência quando contratado como cláusula de compra e venda não tem previsão para ser averbado nem garante o direito do vendedor haver para si o imóvel pagando o preço da nova alienação se preterido de seu direito, tendo como consequência a responsabilização do alienante por perdas e danos e, se o adquirente tiver procedido de má-fé, também deste solidariamente⁷⁷⁸.

Além da preempção estabelecida voluntariamente pelos contratantes, várias outras hipóteses de direito de preferência são encontradas nos mais diversos diplomas legais.

Sobre o direito de preferência previsto no art. 64, §1º, da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), assim se posicionou o CSMSP: “Na espécie, a alienante possuía registrado o título há mais de 5 anos e o preço se encontrava pago. Discute-se apenas sobre a necessidade de consulta ao INCRA, relacionada com o seu direito de preferência. Bem ressalta o parecer de fls. que o direito de preferência é pessoal e não confere direito real ao Instituto. Trata-se de questão extra-registrária e o INCRA terá sempre a via judicial contenciosa para impugnar o negócio jurídico celebrado à sua revelia”⁷⁷⁹. O Estatuto da Terra prevê ainda preferência ao arrendatário no caso de alienação do imóvel arrendado⁷⁸⁰.

⁷⁷⁵ Art. 513 do CC.

⁷⁷⁶ Art. 513, parágrafo único do CC.

⁷⁷⁷ Art. 516 do CC.

⁷⁷⁸ Art. 518 do CC.

⁷⁷⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 10.129-0/7. Data: 28/08/89. Localidade: Mogi das Cruzes. Relator: Álvaro Martiniano de Azevedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁸⁰ Art. 92, §3º, da Lei 4.504/64.

Outra hipótese de direito de preferência é aquela prevista para os imóveis tombados pelo patrimônio histórico e artístico nacional: “Em face da alienação onerosa de bens tombados, pertencentes a pessoas naturais ou a pessoas jurídicas de direito privado, a União, os Estados e os Municípios terão, nesta ordem, o direito de preferência”⁷⁸¹. O tombamento é registrado no Livro 3, averbado no Livro 2⁷⁸² e havendo alienação do imóvel o Oficial deve informar os órgãos responsáveis pelo serviço de proteção ao patrimônio histórico e artístico⁷⁸³.

Além dessas, há outras hipóteses de preferência legal, como a decorrente de condomínio indiviso (art. 1.322 do CC), hipotecas (art. 1.495 do CC), áreas de interesse municipal elencadas no Estatuto da Cidade (arts. 25 a 27 da Lei 10.257/01) e direito de superfície (art. 22 da Lei 10.257/01).

13. Cláusula de reserva de domínio

A reserva de domínio, pela qual o vendedor reserva para si a propriedade da coisa até que o preço seja integralmente pago, também é uma das cláusulas especiais à compra e venda⁷⁸⁴, porém, aplica-se apenas a bens móveis, não podendo ser estabelecida sobre bens imóveis, não ingressando assim no Registro de Imóveis.

⁷⁸¹ Art. 22 do Decreto-Lei 25/37.

⁷⁸² Item 76 do Capítulo XX das NSCGJSP.

⁷⁸³ Item 76.1 do Capítulo XX das NSCGJSP.

⁷⁸⁴ Art. 521 do CC.

CAPÍTULO X

ASPECTOS FISCAIS

Tributos

O registrador deve sempre observar se nos atos que pratica os tributos foram corretamente recolhidos, sob pena de responder pela falta ou recolhimento indevido subsidiariamente, apesar do CTN falar impropriamente em responsabilidade solidária⁷⁸⁵. Esse dever de fiscalização está expresso no art. 289 da Lei 6.015/73, que estabelece que "no exercício de suas funções, cumpre aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhes forem apresentados em razão do ofício", obrigação que é também elencada no art. 30, XI, da Lei 8.935/94, que inclui entre os deveres dos notários e oficiais de registro: "fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar".

1. Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI

A competência dos entes federativos para recolhimento de impostos sobre a transmissão de bens imóveis é trazida em nossa Carta Magna, competindo aos Municípios "instituir impostos sobre transmissão *inter vivos*, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição"⁷⁸⁶.

Assim, para a incidência de ITBI deve ocorrer uma transmissão *inter vivos* e onerosa de bens imóveis ou de direitos reais sobre imóveis.

1.1. Transmissão *inter vivos*

O primeiro requisito é que haja transmissão *inter vivos*, sendo excluídas as transmissões *causa mortis*, que são fato gerador de outro imposto (ITCMD), e as aquisições que não decorram de transmissão, as denominadas aquisições originárias.

1.2. Aquisição originária e derivada

A aquisição da propriedade pode ser originária ou derivada. São originárias as que não decorrem de títulos anteriores, como acessão, usucapião, des-

⁷⁸⁵ Art. 134, VI, do CTN.

⁷⁸⁶ Art. 156, II, da CF.

propriação e discriminação de terras devolutas⁷⁸⁷. São derivadas as que dependem da existência prévia de direito registrado e sua transmissão, como a compra e venda, doação, permuta, etc.

Os modos de aquisição originária rompem a cadeia dominial, não se sujeitando ao princípio da continuidade, e, diferentemente do que ocorre na aquisição derivada⁷⁸⁸, o registro não é constitutivo de domínio, já que nesse caso o domínio não se adquire pelo registro, que é apenas declaratório, ou seja, o registro dá publicidade da aquisição para que possa ser oposta em relação a terceiros.

1.3. Usucapião

Como é requisito para a incidência de ITBI que haja transmissão *inter vivos*, não há incidência, por exemplo, no registro de mandato⁷⁸⁹ extraído de ação de usucapião, por se tratar de aquisição originária, ou seja, em que o imóvel é adquirido em razão da posse apta a gerar o direito de propriedade, e não por transmissão, como ocorre no modo derivado de aquisição: "cuida-se de aquisição originária, por usucapião, não se cogitando de tributo por transmissão da propriedade"⁷⁹⁰.

Não obstante, sempre deve ser verificada a legislação municipal, pois, havendo legislação expressa determinando o recolhimento do ITBI na aquisição por usucapião, não pode o registrador deixar de cumpri-la, haja vista a impossibilidade de controle de constitucionalidade na esfera administrativa:

"É certo que o ingresso de título judicial tendente ao registro de sentença declaratória de usucapião deve ser admitido no serviço imobiliário, independentemente do recolhimento do imposto de transmissão, mesmo porque constitui modo originário de aquisição da propriedade, consoante pacífico entendimento jurisprudencial deste colendo Conselho Superior da Magistratura.

Porém, no caso concreto, tem-se que há exigência legal para a cobrança do referido imposto de transmissão 'inter-vivos' de bens imóveis e de direitos a ele relativos, conforme o disposto no artigo 2º, inciso III, da Lei Municipal nº 6.586/89, que prevê, expressamente, a incidência do tributo na hipótese de

⁷⁸⁷ Lei 6.383/76.

⁷⁸⁸ Art. 1.245 do Código Civil.

⁷⁸⁹ Art. 226 da Lei 6.015/73.

⁷⁹⁰ CSMS. Apelação Cível nº 000001-6/7. Data: 1/8/2003. Localidade: Atibaia. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

aquisição por usucapião, circunstância que prestigia o óbice oposto ao registro pretendido"⁷⁹¹.

1.4. Desapropriação

Da mesma forma, na desapropriação, outro modo de aquisição originária, não há transmissão e, portanto, não há incidência de ITBI⁷⁹². Nesta regra não se incluem as desapropriações amigáveis, resultantes da convergência de vontades das partes e não de ato de império, que caracterizam forma derivada de transmissão⁷⁹³, com incidência do imposto se não afastada pela vedação constitucional à cobrança de impostos sobre o patrimônio dos entes públicos, a denominada imunidade recíproca⁷⁹⁴.

1.5. Adjudicação compulsória

No caso do registro de carta de sentença, extraída de ação de adjudicação compulsória⁷⁹⁵, o imposto é devido. Neste caso a sentença judicial substitui a escritura de compra e venda não outorgada, tratando-se, portanto, de aquisição derivada, ou seja, de efetiva transmissão geradora de incidência de ITBI: “de rigor, também, a apresentação da guia de recolhimento do ITBI, na forma da respectiva legislação específica, pois houve transmissão de propriedade imobiliária, ainda que decorrente de julgado proferido em ação de adjudicação compulsória, que substituiu manifestação de vontade, suprimindo a outorga de escritura definitiva em pagamento a compromisso de venda e compra quitado”⁷⁹⁶.

1.6. Transmissão onerosa

Outro requisito para a incidência de ITBI é que se trate de transmissão onerosa: "O que importa verificar, pois, é se ocorreu transmissão de bem imóvel e, em caso positivo, se a transmissão se deu a título oneroso, com inci-

⁷⁹¹ CSMSp. Apelação Cível nº 043694-0/0. Data: 27/3/1998. Localidade: Santo André. Relator: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁹² CSMSp. Apelação Cível nº 083417-0/0. Data: 1/2/2002. Localidade: Espírito Santo do Pinhal. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁹³ CSMSp. Apelação Cível nº 342-6/2. Data: 15/7/2005. Localidade: Americana. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁹⁴ Art. 150, VI, a, CF.

⁷⁹⁵ Art. 1.418 do CC.

⁷⁹⁶ CSMSp. Apelação Cível nº 059192-0/1. Data: 14/9/1999. Localidade: Atibaia. Relator: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

dência do ITBI, ou a título gratuito, hipótese de que decorre a incidência do ITCMD"⁷⁹⁷.

1.7. Partilha

Na hipótese de extinção de sociedade conjugal, os bens que um dos cônjuges receber além da meação na partilha só serão tributados pelo ITBI se houver reposição, transformando a transmissão em onerosa. Não havendo reposição, a transmissão ocorre, mas de forma gratuita, e, portanto, há fato gerador de outro tributo (ITCMD)⁷⁹⁸. No caso de cada um dos cônjuges receber bens no exato valor da meação, não há transmissão, mas mera extinção de condomínio, sem a ocorrência de fato gerador de imposto.

A Fazenda do Estado de São Paulo tem entendido que a reposição acontece quando o cônjuge que ficou com o excesso se compromete a pagar, ao outro, valor equivalente à diferença verificada. Como com a reposição ocorre transferência de propriedade a título oneroso, o imposto, se devido, é o de competência municipal e não o de competência estadual.

No caso de reposição, há necessidade de que ela seja feita com bens não pertencentes ao patrimônio do casal.

Quando cada cônjuge fica exatamente com 50% do patrimônio, não há incidência de ITCMD, pois não ocorre transmissão de bens, mas simples partilha (cada um fica com o que já era seu).

As possibilidades de incidência de imposto na partilha de bens foram sintetizadas em enunciados no I Encontro de Juízes de Varas de Família do Rio de Janeiro:

"7.2. Na partilha onde um dos cônjuges recebe quinhão superior à sua meação ideal sem compensação de qualquer espécie, o imposto sobre a doação é devido ao Estado, devendo o valor ser apurado administrativamente.

7.3. Na partilha onde um dos cônjuges recebe quinhão superior à sua meação ideal, com compensação de qualquer espécie, o imposto de reposição é devido ao Município, devendo o valor ser apurado administrativamente.

⁷⁹⁷ CSMSp. Apelação Cível nº 372-6/9. Data: 6/10/2005. Localidade: Patrocínio Paulista. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁷⁹⁸ Art. 1º, § 5º, do Decreto Estadual 46.655/02.

7.4. Na partilha de bens entre cônjuges, se não há recebimento em excesso por qualquer deles, não há imposto a ser recolhido"⁷⁹⁹.

1.8. Divisão

Na divisão em partes iguais não há fato gerador de imposto, por não haver transmissão nem contraprestação, apenas extinção de condomínio civil, especificando-se de forma determinada a parte de cada coproprietário, que antes a detinha de forma *pro indiviso* (em estado de indivisão): "no caso em tela, tendo havido divisão em partes iguais, não houve transmissão de propriedade. Não havendo transmissão, não é caso de incidência de imposto, nem de não incidência ou isenção, sendo, portanto, inexigível a apresentação da guia"⁸⁰⁰.

É o que ocorre quando, por exemplo, duas pessoas são proprietárias de um terreno e decidem dividi-lo em dois, ficando metade para cada, extinguindo o condomínio anterior pela individualização da propriedade de cada um.

A divisão não se confunde com a permuta, que é tributada.

1.9. Permuta

A permuta é transmissão onerosa, incidindo ITBI. Mesmo que denominada de doação recíproca, permanece a competência do Município, por ser irrelevante a denominação que se dê à operação, que equivale a uma dupla compra e venda⁸⁰¹.

Na distinção de permuta e divisão, importante observar que: "visando as partes extinguir a comunhão sobre imóveis diversos, com atribuição de domínio exclusivo de cada um destes a determinadas pessoas, o ato praticado constitui permuta de partes ideais, que é fato gerador do imposto de transmissão, pouco importando tenha sido rotulado como divisão e extinção de condomínio"⁸⁰².

Assim, se duas pessoas têm em comum dois terrenos iguais e decidem extinguir o condomínio existente, ficando um terreno exclusivamente para cada

⁷⁹⁹ Enunciados do I Encontro de Juizes de Varas de Família do Rio de Janeiro, realizado em Nova Friburgo nos dias 30/11/01 a 02/12/01, divulgados pelo Aviso nº 58 da Administração do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

⁸⁰⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 187-6/4. Data: 16/11/2004. Localidade: Itu. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁰¹ Art. 533 do CC.

⁸⁰² Sentença em processo de dúvida inversa do MM. Juiz de Direito Auxiliar da 1ª Vara de Registros Públicos de São Paulo, MM. Juiz José Renato Nalini, em 6 de janeiro de 1984. RDI 15. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

um, não se trata de divisão, mas de permuta, porque cada um receberá do outro a fração que detinha sobre um dos imóveis, incidindo ITBI.

1.10. Transmissão de direitos sobre imóveis

O imposto também incide na transmissão de direitos reais sobre imóveis, sendo excetuada expressamente dessa incidência a transmissão de direitos reais de garantia⁸⁰³.

Assim, na cessão de direitos do credor hipotecário ou fiduciário, por exemplo, embora ocorra a transmissão de direitos reais, como se trata de direitos de garantia, não há a ocorrência de fato gerador.

Já na hipótese de formal de partilha em que o imóvel seja adjudicado ao titular de direitos decorrentes de cessão onerosa de direitos hereditários, sobre a cessão incidirá o ITBI, além da incidência do imposto devido pela sucessão *causa mortis* (ITCMD).

Ainda quanto aos direitos reais sobre imóveis, importante sempre observar a legislação municipal, haja vista a grande diversidade com que cada município legisla sobre o tema. Por exemplo, no caso de constituição do direito real de servidão⁸⁰⁴, encontramos legislações, como a da cidade de São Paulo, que expressamente excluem a servidão da incidência do imposto⁸⁰⁵, mas também encontramos em outras cidades, como em Campinas, leis que expressamente a incluem como hipótese de incidência do ITBI⁸⁰⁶.

1.11. Cessão de direitos registrados

Nos casos em que há compromisso de compra e venda registrado e o cumprimento desse compromisso se dá em favor de cessionário dos direitos de compromissário comprador, respeitando o princípio da continuidade, previamente deverá ser registrada a cessão e em seguida a compra e venda, caracterizando duas incidências de imposto, na cessão de direitos do compromissário comprador e na venda do imóvel ao cessionário:

“A legislação tributária municipal arrola entre as hipóteses de incidência do imposto sobre a transmissão *inter vivos*, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e direitos a eles relativos, a cessão de direitos decorrentes de compromisso de venda e compra e de promessa de cessão.

⁸⁰³ Art. 156, II, CF.

⁸⁰⁴ Art. 1.225, III, do CC.

⁸⁰⁵ Art. 1º, I, b, do Regulamento aprovado pelo Decreto Municipal 46.228/05.

⁸⁰⁶ Art. 2º, IX, da Lei Municipal 12.391/05.

Correta, portanto, a conduta do registrador, a quem a lei atribui rigorosa fiscalização, no exercício de suas funções, do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhes forem apresentados em razão do ofício, que, na espécie, exigiu prova do pagamento de tal imposto para o ingresso da escritura particular de cessão de direitos no fôlio real.

Debate sobre a inconstitucionalidade, nesse particular, da lei municipal tributária não pode ser travado neste procedimento de dúvida, de natureza administrativa, do qual não participa o Fisco⁸⁰⁷.

No Município de São Paulo, para apuração da base de cálculo do imposto, e a fim de que o tributo incida sobre o valor econômico efetivamente transmitido, “nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não pago pelo cedente será deduzido da base de cálculo”⁸⁰⁸. Assim, o imposto só incidirá sobre o valor venal quando o compromisso de compra e venda cujo direito se transmite esteja quitado. Nos demais casos será deduzido do valor venal o valor correspondente às prestações ainda não pagas do compromisso.

1.12. Cessão de direitos não registrados

Havendo na escritura pública, além da venda, cessão de direitos de compromisso de compra e venda não registrado, e não pretendendo as partes registrar o compromisso e a cessão, registrando a compra e venda diretamente do titular de domínio para o adquirente, cessionário do direito do compromisso não registrado, somente um registro será praticado e o oficial será obrigado a exigir apenas o recolhimento do imposto do ato que praticará, ou seja, da venda, e não da cessão que não será registrada:

“Assim, tendo sido respeitado o princípio da continuidade com a outorga da escritura pelos titulares do domínio, não há necessidade de se registrar a cessão antes operada, escapando ao exame do registrador a fiscalização do recolhimento de tributos eventualmente incidentes sobre atos não submetidos a sua atuação”⁸⁰⁹.

Nesses casos, no entanto, quando a legislação municipal considerar a cessão de direitos, mesmo não registrada, como fato gerador de imposto, e não comprovado o recolhimento do tributo, embora não possa obstar o registro,

⁸⁰⁷ CSMSP. Apelação Cível nº 058835-0/0. Data: 8/7/1999. Localidade: Guarujá. Relator: Sérgio Augusto Nigro Conceição. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁰⁸ Art. 7º, § 3º, do Regulamento do Imposto sobre Transmissão *inter-vivos*, aprovado pelo Decreto Municipal 46.228/05.

⁸⁰⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 190-6/8. Data: 13/10/2004. Localidade: Botucatu. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

deverá o oficial informar a Fazenda Pública para que tenha conhecimento da omissão e possa adotar providências⁸¹⁰.

1.13. Conferência de bens, fusão, cisão, incorporação e extinção de sociedade

Visando não onerar as transmissões decorrentes de constituição, alteração e até extinção de sociedades, a Constituição Federal estabelece que o ITBI "não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica"⁸¹¹.

É importante ressaltar que essa imunidade não se aplica quando "a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil"⁸¹², ou seja, as sociedades do ramo imobiliário são tributadas. Além disso, o CTN estabelece que a verificação da atividade e de sua preponderância será feita não apenas com base na atuação anterior da sociedade, mas também analisando a sua atividade nos anos seguintes à aquisição⁸¹³, o que faz com que a legislação municipal em regra determine a necessidade da imunidade ser atestada pela fiscalização, que não apenas analisará a atividade da empresa no momento da transmissão, como poderá acompanhá-la nos anos seguintes, autuando a sociedade caso não recolhido o imposto e posteriormente caracterizada a preponderância de atividade na área imobiliária.

Também não está incluída na imunidade a transmissão de imóvel da pessoa jurídica para o sócio em decorrência de diminuição do capital social.

1.14. Dação em pagamento

Ocorre a dação em pagamento quando o credor consente "em receber prestação diversa da que lhe é devida"⁸¹⁴, importando em transmissão onerosa, sujeita ao recolhimento de ITBI quando envolve imóveis ou direitos reais a

⁸¹⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 009674-0/0. Data: 16/8/1989. Localidade: São Bernardo do Campo. Relator: Milton Evaristo dos Santos. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸¹¹ Art. 156, § 2º, I, CF.

⁸¹² Art. 156, § 2º, I, CF.

⁸¹³ Art. 37, § 1º, CTN.

⁸¹⁴ Art. 356 do CC.

eles relativos: "Imprescindível o recolhimento do ITBI sobre o valor do bem, em se tratando de dação em pagamento de direitos relativos a imóveis"⁸¹⁵.

1.15. Retrovenda

Na hipótese de resolução do contrato em decorrência de cláusula de retrovenda⁸¹⁶ o oficial deve observar a legislação municipal para verificar a incidência ou não do ITBI.

Na cidade de São Paulo o art. 3º, inc. II, do Regulamento do Imposto sobre Transmissão *inter-vivos*, aprovado pelo Decreto 46.228/05, estabelece que: “O imposto não incide: (...) II-sobre a transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo proprietário por força de retrovenda, de retrocessão⁸¹⁷ ou pacto de melhor comprador⁸¹⁸”.

1.16. Sisa

Segundo De Plácido e Silva “Sisa” é uma antiga forma de denominação do imposto sobre transmissão de imóveis, encontrada com frequência em antigas escrituras, como sinônimo de ITBI.⁸¹⁹

2. ITCMD – Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e Doação

O ITCMD compete aos Estados e ao Distrito Federal na transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos⁸²⁰.

Mais amplo que o ITBI, não incide apenas sobre imóveis e direitos reais, mas sobre quaisquer bens e direitos, conforme definido na correspondente legislação estadual. Assim, se o tabelião lança na escritura a doação de dinheiro para a aquisição de imóvel, há a incidência do imposto não somente sobre a operação imobiliária, mas também sobre a doação do numerário.

⁸¹⁵ CSMSp. Apelação Cível nº 398-6/7. Data: 6/10/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸¹⁶ Sobre esse tema ver o Capítulo Cláusulas nesta obra.

⁸¹⁷ Retrocessão é o retorno do bem ao patrimônio do expropriado no caso do imóvel não ter o destino para que se desapropriou (tredestinação) ou não for utilizado em obras ou serviços públicos, hipótese em que o expropriado, se utilizar o seu direito de preferência, deverá pagar ao expropriante o preço atual do imóvel para reavê-lo (art. 519 do CC).

⁸¹⁸ O pacto de melhor comprador, previsto no art. 1.158 do CC de 1916, não foi elencado entre as cláusulas especiais à compra e venda no CC de 2002, passando a ser regido pelas normas das cláusulas resolutivas (art. 474 do CC de 2002).

⁸¹⁹ Op. cit., p. 1306.

⁸²⁰ Art. 155, I, CF.

No Estado de São Paulo a legislação que trata do recolhimento do ITCMD é a Lei Estadual 10.705/00, alterada pela Lei Estadual 10.992/01, que expressamente determina que “não serão lavrados, registrados ou averbados pelo tabelião, escrivão e oficial de registro de imóveis, atos e termos de seu cargo, sem a prova do pagamento do imposto”⁸²¹.

2.1. Doação com reserva de usufruto e extinção

A incidência de ITCMD que mais requer atenção do registrador é a relacionada à doação com reserva de usufruto (denominado usufruto *deducto*) e sua posterior extinção.

Em São Paulo, quando da doação de imóvel com reserva de usufruto, podem as partes escolher entre recolher o ITCMD apenas sobre a nu-propriedade no momento da doação⁸²², ou seja, 2/3 do valor do imóvel⁸²³, ficando o pagamento do imposto sobre o usufruto para ser complementado quando da sua extinção⁸²⁴, ou já recolher o ITCMD sobre a integralidade do valor do bem, não restando nenhuma tributação relacionada à doação pendente para incidência futura ⁸²⁵.

A Consultoria Tributária da Fazenda do Estado de São Paulo assim tratou da tributação na doação com reserva de usufruto: “Não se optando pelo recolhimento do imposto sobre o valor integral da propriedade quando da doação da parcela da propriedade, com a morte do doador original e usufrutuário, o usufruto a ele reservado será transmitido aos donatários originários, nus-proprietários, agora herdeiros, completando-se, então, a propriedade plena do respectivo bem. Nessa oportunidade, o ITCMD referente à transmissão *causa mortis*, para esse bem, terá como base de cálculo o valor correspondente ao usufruto: 1/3 do seu valor na data da transmissão”⁸²⁶.

Assim, para averbar a extinção do usufruto o oficial deve sempre verificar se o imposto, quando da instituição, foi integralmente pago. Se pago sobre o valor total do bem, nada restará a ser pago. Se no ato da doação o imposto foi pago sobre 2/3 do bem, deverá ser exigido o recolhimento sobre o valor do usufruto, ou seja, incidente sobre 1/3 do valor do imóvel.

⁸²¹ Art. 25 da Lei Estadual 10.705/00

⁸²² Art. 31, § 3º, 1 do Decreto Estadual 46.655/02.

⁸²³ Art. 9º da Lei Estadual 10.705/00.

⁸²⁴ Art. 31, § 3º, 2 do Decreto Estadual 46.655/02.

⁸²⁵ Art. 31, § 3º, 3 do Decreto Estadual 46.655/02.

⁸²⁶ Resposta da Consultoria Tributária da Fazenda do Estado de São Paulo ao Posto Fiscal da Capital 313-ITCMD/DRTC-I, de 21 de novembro de 2002.

Importante observar que na vigência da Lei Estadual 9.591/66⁸²⁷ as transmissões *causa mortis* e doações *inter vivos* entre ascendentes e descendentes ou entre cônjuges tinham uma redução de 30%⁸²⁸, que pode ser incorretamente confundida com a falta de pagamento sobre o valor do usufruto (1/3 ou 33,33%).

Também importante conhecer as alíquotas vigentes na época da instituição do usufruto para se saber com segurança se o imposto foi pago sobre a totalidade do imóvel ou apenas sobre a nua-propriedade.

A redação original do art. 11 da Lei Estadual 9.591/66 determinava que a alíquota seria a máxima fixada em Resolução do Senado Federal. Durante a vigência dessa redação a Resolução não foi editada, aplicando-se a alíquota estabelecida provisoriamente pelo art. 8º do Ato Complementar 27/66, fixada em 2% para transmissões não onerosas.

A Lei Estadual 3.199/81, editada em 23 de dezembro de 1981, logo após a Resolução do Senado Federal 99/81, alterou a alíquota das transmissões não onerosas para 4%. Essa lei somente foi revogada em 31 de dezembro de 2000, pela Lei Estadual 10.705/00.

Durante a vigência da redação original da Lei Estadual 10.705/00⁸²⁹, que foi aplicada apenas entre 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro do mesmo ano, haviam faixas de isenção e alíquotas progressivas que devem ser aplicadas quando se verifica se o pagamento do tributo foi integral na constituição do usufruto ocorrido neste período. Assim, durante 2001, doações até 2.500 UFESPs (R\$ 24.575,00) foram isentas, de 2.500 até 12.000 UFESPs (R\$ 117.960,00) sujeitaram-se à incidência de alíquota de 2,5%, com parcela a deduzir de 62,5 UFESPs (R\$ 614,38), e acima de 12.000 UFESPs sujeitaram-se à incidência de alíquota de 4%, com parcela a deduzir de 242,5 UFESPs (R\$ 2.383,78). Nas transmissões *causa mortis* o limite de isenção era de 7.500 UFESPs.

Evidente que a verificação do tributo recolhido anteriormente refere-se ao pagamento do imposto devido à Fazenda do Estado por transmissão não onerosa. No caso de constituição onerosa da nua propriedade para determinada pessoa e do usufruto para outra, o imposto incidente é o ITBI, devido atualmente à Fazenda do Município e tendo como base de cálculo o valor da totalidade do bem.

⁸²⁷ Revogada pela Lei Estadual 10.705/00.

⁸²⁸ Art. 11, § 1º, da Lei 9.591/66.

⁸²⁹ Posteriormente alterada pela Lei Estadual 10.992/01.

Posteriormente, quando da extinção do usufruto em virtude de falecimento do usufrutuário, não haverá incidência do ITCMD, conforme decisão normativa⁸³⁰ que pacificou a questão, tendo a Fazenda do Estado de São Paulo se manifestado nesse sentido em virtude do usufruto ser direito real com caráter temporário, no máximo vitalício, não sendo, assim, passível de transmissão por sucessão hereditária ou testamentária, prevendo a lei paulista que somente incide o ITCMD quando o *de cujus* transmite bens ou direitos, não havendo qualquer previsão de exigência do imposto em relação àquele que recebe bem ou direito em decorrência da morte de outrem sem ser seu sucessor hereditário ou testamentário: “Embora possa ser cindido quanto ao seu exercício, o direito de propriedade é uno e, em virtude da própria natureza temporária do usufruto, em última análise, o verdadeiro proprietário do bem é o titular da nua-propriedade, já que a extinção do usufruto é inevitável. E, nesse sentido, em decorrência da falta de previsão na legislação paulista, a extinção do usufruto, pela morte (ou renúncia) do usufrutuário, não é hipótese de incidência do ITCMD”.

Contudo, atente-se que na hipótese da extinção do usufruto *deducto* pelo evento morte ou renúncia do usufrutuário incidirá o ITCMD em virtude da própria previsão legal⁸³¹, já que nesse caso, o recolhimento em momento posterior da parcela referente ao usufruto (1/3) é mera faculdade prevista em lei: “Note-se, porém, que o fato de a extinção do usufruto não ser hipótese de incidência do ITCMD não traz implicações nas situações em que houve doação do bem imóvel com reserva de usufruto, em favor do doador, em que, sob a permissão estabelecida pelo § 3º do artigo 31 do Decreto 46.655/2002, o imposto não foi recolhido integralmente. Caso em que o donatário escolheu pagar o ITCMD em dois momentos distintos, efetuando, antes da lavratura da escritura, apenas o recolhimento sobre o valor da nua-propriedade, isto é, 2/3 (dois terços) do valor do bem. Nesse caso, com a morte do usufrutuário (ou com a renúncia ao usufruto), consolida-se a propriedade plena na pessoa do nu-proprietário (donatário) e, nessa oportunidade, deverá ser recolhido a parcela restante do imposto referente à doação ocorrida anteriormente (e não referente à extinção do usufruto), que terá como base de cálculo o valor correspondente ao usufruto, isto é, 1/3 (um terço) do valor do bem, devidamente corrigido”⁸³².

Em suma, apesar de toda a complexidade apresentada pela “ficção jurídica” da bipartição da propriedade (nua-propriedade e usufruto) e o recolhimen-

⁸³⁰ Decisão Normativa CAT nº 3 de 26 de fevereiro de 2010.

⁸³¹ Art. 31, § 3º, 2 do Decreto Estadual 46.655/02.

⁸³² Decisão Normativa CAT nº 3 de 26 de fevereiro de 2010.

to do ITCMD paulista, acentuada inclusive pela Decisão Normativa CAT nº 10, de 22 de junho de 2009, posteriormente revogada pela Decisão Normativa CAT nº 3 de 26 de fevereiro de 2010 aludida anteriormente, podemos concluir que na extinção do usufruto pelo evento morte ou renúncia do usufrutuário não incide o referido imposto, em virtude de inexistência de previsão legal, já na hipótese da reserva do usufruto pelo próprio doador, quando futuramente houver sua extinção, seja pela morte ou renúncia do usufrutuário, provocando a consolidação da propriedade plena na pessoa do nu-proprietário, deverá ser verificado se o imposto foi recolhido em sua totalidade quando da doação, pois se foi recolhido apenas sobre 2/3 do valor da propriedade, a parcela restante (1/3) deverá ser recolhida previamente à averbação da extinção do usufruto, pois esse recolhimento não decorre da transmissão *causa mortis* (ou renúncia), mas daquela transmissão não onerosa (doação) já efetuada no passado.

2.2. Extinção do usufruto instituído pelo nu-proprietário

Por força do art. 6º, I, f, da Lei Estadual 10.705/00, há isenção de ITCMD na extinção *causa mortis* do usufruto quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor.

Trata-se de situação diversa da doação do imóvel com reserva de usufruto, na qual o doador transfere a nua-propriedade e reserva para si o usufruto, que é transferido posteriormente ao nu-proprietário quando da extinção do usufruto, ou seja, o imóvel é transferido em sua totalidade, mas em duas etapas, primeiro a nua-propriedade e posteriormente o usufruto. Nesta não há isenção.

Na hipótese isenta de imposto, o proprietário institui em favor de terceiro o usufruto, mantendo para si a nua-propriedade. Com a extinção do usufruto pelo falecimento do usufrutuário, volta ao nu-proprietário a propriedade plena, ou seja, sem aumento de seu patrimônio anterior e sem incidência de imposto por força da referida isenção.

Apesar do referido dispositivo legal referir-se somente à hipótese da extinção *causa mortis* do usufruto, parece-nos que a renúncia do usufrutuário também não seria alvo do imposto, em virtude do entendimento proferido pela Fazenda Estadual na Decisão Normativa CAT nº 3 de 26 de fevereiro de 2010 que entendeu não configurar hipótese de doação: “A consolidação da propriedade plena, pela extinção do usufruto, seja pela morte ou pela renúncia do usufrutuário, não pode ser considerada sucessão legítima ou testamentária e não se caracteriza como doação”.

2.3. ITBI Doação

Até o ano de 2000, o imposto de transmissão não onerosa e *causa mortis* no Estado de São Paulo incidia apenas sobre imóveis e direitos a eles relativos e, por isso, denominava-se ITBI-doação e ITBI-*causa mortis*, o que gerava muita confusão pela utilização da mesma sigla do imposto devido ao Município, tendo como consequência inúmeros recolhimentos efetuados à Fazenda Pública incorreta.

A Lei Estadual 10.705/00, alterada pela Lei 10.992/01, ampliou a incidência do imposto, mudou a metodologia de recolhimento e também sua denominação, passando a ser utilizada a sigla ITCMD. No entanto, para fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2000, aplica-se a Lei Estadual 9.519/66, sendo assim ainda recolhido o imposto sob a denominação de ITBI-doação ou ITBI-*causa mortis*, pago através da guia de arrecadação estadual - demais receitas (GARE-DR), com os códigos de arrecadação próprios.

Assim, para doações e óbitos ocorridos até 31 de dezembro de 2000, mesmo que submetidos a registro posteriormente, será devido o ITBI-doação ou ITBI-*causa mortis*, e para fatos geradores posteriores, será devido o ITCMD, mas todos recolhidos à Fazenda do Estado, variando a legislação aplicável, tendo como consequência não apenas a denominação e a guia de arrecadação utilizada, mas também o próprio procedimento administrativo utilizado na apuração da base de cálculo, alíquotas, hipóteses de isenção, etc.

2.4. Isenção

A Lei Estadual 10.992/01, que alterou a Lei Estadual 10.705/00, fixou a alíquota do imposto em 4% e criou hipóteses de isenção sobre a transmissão não onerosa, que nas doações ocorrem quando: não ultrapassem o valor de 2.500 UFESP; de bem imóvel para construção de moradia vinculada a programa de habitação popular e de bem imóvel doado por particular para o Poder Público.

Especificamente sobre a doação de imóvel ou direito de valor até 2.500 UFESP, há duas situações:

Se ocorrer na esfera judicial, dependerá de reconhecimento pela Fazenda Estadual, devendo para esse fim o interessado comparecer ao posto fiscal para apresentar Declaração de ITCMD, cujo formulário é obtido exclusivamente na página do Posto Fiscal Eletrônico da Secretaria da Fazenda⁸³³.

⁸³³ Disponível em: <www.pfe.fazenda.sp.gov.br>.

Se ocorrer por escritura pública ou instrumento particular os tabeliães e oficiais deverão exigir do donatário declaração relativa a doações isentas recebidas do mesmo doador⁸³⁴, conforme modelo previsto no anexo XV da Portaria CAT - Coordenador de Administração Tributária 15/03.

Na verificação do limite de isenção deve-se lembrar que ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os donatários⁸³⁵, ou seja, mesmo que o imóvel doado ultrapasse o valor de 2.500 UFESP, se forem vários donatários e a fração recebida por cada um for de valor inferior ao limite, haverá isenção.

No caso de doações sucessivas entre os mesmos doador e donatário devem ser somadas todas as doações, dentro de cada ano civil, só se beneficiando da isenção se o valor total no ano civil não ultrapassar 2.500 UFESP⁸³⁶, o que é verificado através de declaração anual, que também deve ser apresentada pelo contribuinte.⁸³⁷

2.5. Fideicomisso

No Estado de São Paulo, o ITCMD incide sobre a transmissão de bem ou direito por qualquer título sucessório, inclusive o fideicomisso⁸³⁸, sendo contribuinte o fiduciário⁸³⁹.

Na posterior extinção do fideicomisso deve-se observar a legislação tributária e, não havendo expressa previsão, não incidirá tributo: “Tributário. Imposto Sobre a Doação. Fideicomisso. Extensão. 1. Não é devido o imposto de doação sobre extinção de fideicomisso, sob pena de ocorrência de bitributação. 2. Ao extinguir-se o fideicomisso não há transmissão de propriedade. 3. Ausência de previsão legal para a imposição do tributo. Princípio da legalidade. 4. Recurso improvido”⁸⁴⁰.

2.6. Pagamento

Para fatos geradores anteriores a 31 de dezembro de 2000, o ITBI-doação e *causa mortis* é recolhido pelo interessado através do formulário impresso

⁸³⁴ Art. 6º, § 3º, do Decreto Estadual 46.655/02.

⁸³⁵ Art. 2º, § 1º, da Lei Estadual 10.705/00.

⁸³⁶ Art. 9º, § 3º, da Lei Estadual 10.705/00.

⁸³⁷ Art. 25 do Decreto Estadual 46.655/02.

⁸³⁸ Art. 2º, § 2º, da Lei Estadual 10.705/00.

⁸³⁹ Art. 7º, II, da Lei Estadual 10.705/00.

⁸⁴⁰ STJ. REsp 606133/ RJ; Recurso Especial 2003/0202412-6. Data: 08/03/2005. Relator: Min. José Delgado. Órgão Julgador: Primeira Turma.

GARE-DR, que deve ser preenchido pelo próprio interessado e pago diretamente na rede bancária.

Para fatos geradores posteriores, o imposto será recolhido por meio do formulário GARE-ITCMD, emitido eletronicamente, mediante programa disponível no Posto Fiscal Eletrônico, acessível por meio do endereço <www.pfe.fazenda.sp.gov.br>.⁸⁴¹

O recolhimento do imposto é dispensado quando, relativamente a cada contribuinte, for inferior a uma UFESP⁸⁴².

2.7. Penalidade

A penalidade aos tabeliães e oficiais pelo descumprimento de obrigação principal ou acessória relativa ao ITCMD é severa, ficando sujeitos a multa correspondente ao valor do imposto não recolhido (art. 21, II, da Lei Estadual 10.705/00).

2.8. Certidão de Regularidade do ITCMD

No Estado de São Paulo, para comprovação do recolhimento, isenção ou não incidência do ITCMD no caso de inventário, partilha, separação consensual ou divórcio consensual lavrado por escritura pública⁸⁴³ deve ser exigida e indicada na escritura a apresentação da Certidão de Regularidade do ITCMD, emitida nos termos da Portaria CAT 5/07, documento que comprova a concordância da Fazenda Estadual com os valores declarados e com o recolhimento do imposto ou, no caso de isenção ou não-incidência, seu reconhecimento pela fiscalização tributária⁸⁴⁴, estabelecendo a referida Portaria que “Não poderão ser lavrados, registrados, inscritos ou averbados atos e termos relacionados com a transmissão de bens e direitos atinentes a esta portaria sem a apresentação da Certidão de Regularidade do ITCMD ou após o termo final de sua validade”⁸⁴⁵.

Em resposta ao ofício nº 0051/2008 expedido pelo 1º Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, a Delegacia Regional Tributária do ABCD – DRT/12 manifestou-se oficialmente no sentido de que “a portaria CAT 05/2007 aplica-se nos inventários extrajudiciais, e, também, na partilha de bens na separação ou divórcio extrajudiciais, na hipótese de excesso de

⁸⁴¹ Art. 13 da Portaria Cat 15/03.

⁸⁴² Art. 34 da Lei Estadual 10.705/00.

⁸⁴³ Arts. 982 e 1.124-A do CPC.

⁸⁴⁴ Art. 2º da Portaria CAT 5/07.

⁸⁴⁵ Art. 5º, parágrafo único, da Portaria CAT 5/07.

meação. Em ambos os casos, antes da lavratura da escritura pública, devem ser apresentados ao Posto Fiscal (no caso da DRT/12, no PF 11 – São Bernardo do Campo, desde o dia 1º de abril), os documentos previstos nos incisos I ou II do artigo 1º da Portaria, conforme o caso. A Certidão de Regularidade do ITCMD é sempre emitida pelo Fisco na forma estabelecida pelo artigo 2º. Na própria certidão será manifestada a concordância com os valores declarados e com o recolhimento do ITCMD ou o reconhecimento da isenção ou da não incidência”.

3. IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

O IPTU, de competência municipal⁸⁴⁶, tem como fato gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”⁸⁴⁷.

Assim, embora os atos praticados no Registro de Imóveis não sejam fatos geradores de IPTU, já que o fato gerador não é a transmissão, mas a propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel urbano, em diversas situações deve o oficial exigir a comprovação de regularidade fiscal do imóvel quanto ao IPTU.

A primeira hipótese é na transmissão de imóveis, exigindo o Decreto 93.240/86, que regulamentou a Lei 7.433/85, que nas escrituras públicas ou nos instrumentos particulares do Sistema Financeiro da Habitação⁸⁴⁸, que impliquem na transferência de domínio, seja apresentada certidão fiscal referente aos tributos que incidam sobre o imóvel⁸⁴⁹, salvo se dispensada pelo adquirente que, neste caso, responderá nos termos da lei, pelo pagamento dos débitos fiscais existentes⁸⁵⁰.

Essa disposição da Lei 7.433/85 é decorrência direta do art. 130 do CTN, que estabelece que “os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação”.

⁸⁴⁶ Art. 156, I, da CF.

⁸⁴⁷ Art. 32 do CTN.

⁸⁴⁸ Art. 4º do Decreto 93.240/86.

⁸⁴⁹ Art. 1º, III, a, do Decreto 93.240/86.

⁸⁵⁰ Art. 1º, § 2º, do Decreto 93.240/86.

Assim, a Lei das Escrituras e seu decreto regulamentador estabeleceram como regra a indicação no título da comprovação da regularidade fiscal do imóvel (art. 1º, § 2º, da Lei 7.433/85, art. 1º, III, a, do Decreto 93.240/86 e parte final do art. 130 do CTN), mas permitindo que o adquirente dispense-a, neste caso passando a responder pelo imposto (art. 1º, § 2º, do Decreto 93.240/86 e primeira parte do art. 130 do CTN). Na prática, o que se verifica é que os adquirentes, sem conhecimento pleno das consequências, em regra dispensam a apresentação das certidões negativas fiscais relativas ao imóvel e, ao não constar do título a prova de quitação, respondem pelo imposto.

Outra hipótese de exigência de comprovação da regularidade fiscal quanto ao IPTU ocorre para o registro de cartas de arrematação e adjudicação, por força do art. 703, II, do CPC, que determina que a carta de arrematação conterá a prova de quitação dos impostos, obrigando o oficial a exigir a apresentação da certidão negativa de tributos sobre o imóvel ou a comprovação do pagamento do imposto desde a arrematação ou adjudicação:

"(...) a comprovação da regularidade do recolhimento do IPTU que incidiu sobre o imóvel a partir da arrematação é obrigatória em razão do dever, previsto no artigo 289 da Lei nº 6.015/73, dos Oficiais de Registro de Imóveis fiscalizarem o pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhe forem apresentados em razão do seu ofício. (...) Toda carta de adjudicação obrigatoriamente deve conter a prova de quitação dos impostos, em observação aos arts. 715 c.c. 703, II, ambos do Código de Processo Civil.

"Portanto, torna-se exigível também a comprovação do pagamento do imposto territorial urbano posterior à data da adjudicação"⁸⁵¹.

Com a alteração da redação do art. 703 do CPC pela Lei 11.382/06, que agora especifica que deverá ser apresentada a prova de quitação do imposto de transmissão, e não mais a genérica referência a impostos antes existente, a expectativa é de que a orientação administrativa se altere, exigindo apenas a prova de quitação do ITBI, e não mais do IPTU para o registro de cartas de arrematação e adjudicação.

4. ITR – Imposto sobre Propriedade Territorial Rural

O ITR é de competência da União⁸⁵², sendo administrado pela Secretaria da Receita Federal, e tem como fato gerador "a propriedade, o domínio útil ou

⁸⁵¹ CSMSp. Apelação Cível nº 339-6/9. Data: 23/6/2005. Localidade: São Paulo (12º SRI). Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁵² Art. 153, VI, CF.

a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município"⁸⁵³.

Em decorrência do disposto no art. 15 do Decreto-lei 57/66, com redação revigorada pela Resolução do Senado Federal nº 09/05⁸⁵⁴, para se definir se o imóvel é rural deve ser adotado o critério de sua utilização: “O ITR não incide somente sobre os imóveis localizados na zona rural do município, mas também sobre aqueles que, situados na área urbana, são comprovadamente utilizados em exploração extrativa, vegetal, pecuária ou agroindustrial”⁸⁵⁵.

Da mesma forma com o que ocorre com o IPTU, os atos praticados no Registro de Imóveis não são fatos geradores do ITR, mas o oficial tem a obrigação de exigir a comprovação de regularidade fiscal na prática dos atos que envolvam imóveis rurais, estabelecendo o art. 21 da Lei 9.393/96 que “é obrigatória a comprovação do pagamento do ITR, referente aos cinco últimos exercícios, para serem praticados quaisquer dos atos previstos nos arts. 167 e 168 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei dos Registros Públicos)”, ressalvando apenas os casos em que a exigibilidade do imposto esteja suspensa, ou em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora⁸⁵⁶, situações em que é expedida certidão positiva com efeitos de negativa.

As consequências pelo descumprimento dessa obrigação são graves, estabelecendo o parágrafo único do art. 21 da Lei 9.393/96 que “são solidariamente responsáveis pelo imposto e pelos acréscimos legais, nos termos do art. 134 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Sistema Tributário Nacional, os serventuários do registro de imóveis que descumprirem o disposto neste artigo, sem prejuízo de outras sanções legais”.

Também o art. 22 da Lei 4.947/66, já em sua redação original, criava a obrigação de comprovação de regularidade quanto ao ITR, estabelecendo a redação atual que a prova de quitação do ITR correspondente aos últimos 5 exercícios será sempre apresentada quando for exigida a apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, que é exigido para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender, prometer à venda imóveis rurais e para a homologação de partilha em sucessão *causa mortis*.

Para a comprovação do pagamento do ITR podem ser apresentados os documentos de arrecadação federal (DARF) devidamente recolhidos e que

⁸⁵³ Art. 29 do CTN.

⁸⁵⁴ Art. 52, X, CF.

⁸⁵⁵ STJ. AgRg no Ag 498512/RS. Data: 22/3/2005. Localidade: Rio Grande do Sul. Relator: Francisco Peçanha Martins. Órgão julgador: 2ª Turma.

⁸⁵⁶ Art. 20 da Lei 9.393/96.

comprovem o pagamento do ITR dos últimos 5 exercícios, ou a Certidão Negativa de Débitos de Imóvel Rural, ou positiva com efeitos de negativa, criada especificamente para a comprovação do cumprimento das obrigações relacionadas com o ITR⁸⁵⁷.

Diferentemente do que ocorre nas transmissões voluntárias com relação à CND do IPTU, não pode o adquirente dispensar a apresentação da CND do ITR, o que deve ser observado pelo oficial sob pena de responder pelo tributo.

Para imóvel urbano que nos últimos 5 anos tenha sido rural, permanece a exigência de apresentação da comprovação do pagamento do ITR para o período em que foi rural⁸⁵⁸.

A apresentação da certidão negativa do ITR e do CCIR é dispensada nos casos de aquisições originárias, como usucapião ou desapropriação: “As duas últimas exigências, apesar de não impugnadas, são impertinentes, pois cuida-se de aquisição originária, por usucapião, não se cogitando de tributo por transmissão da propriedade nem de cadastro perante o INCRA, dado que a aquisição poderia recair sobre imóvel ainda não cadastrado”⁸⁵⁹.

Para os imóveis com área inferior a 200 hectares, conforme estabelece o art. 56 da Instrução Normativa SRF 256/02, a comprovação do pagamento do ITR poderá ser feita por declaração de inexistência de débito, que deverá ser “firmada pelo próprio interessado ou procurador, informando, sob as penas da lei, inexistir débito relativo ao imóvel, referente aos últimos cinco exercícios, ou que o débito se acha pendente de decisão administrativa ou judicial”, a qual deverá “conter, além dos dados que identifiquem a instituição financeira ou o registro de imóveis, o Número do Imóvel na Receita Federal (Nirf), o nome e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do interessado e o código de inscrição no Cadastro de Imóveis Rurais do Incra”⁸⁶⁰.

Conforme estabelece o art. 56, § 2º e 3º, da mesma instrução normativa, os registros de imóveis deverão encaminhar à unidade da SRF local as declarações de inexistência de débito recebidas para verificação de veracidade, sendo fixado como prazo máximo para a remessa, até o décimo dia do mês subsequente àquele em que as declarações tiverem sido firmadas.

⁸⁵⁷ IN SRF 438/04.

⁸⁵⁸ Item 167, Capítulo XX, NSCGJSP.

⁸⁵⁹ CSMSp. Apelação Cível nº 000001-6/7. Data: 1/8/2003. Localidade: Atibaia. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁶⁰ Art. 56, § 1º, da IN SRF 256/02.

5. Análise do registrador

No cumprimento do dever estabelecido no art. 289 da LRP o oficial não deve entrar em questões de competência exclusiva da fiscalização:

"Já se decidiu que 'ao Oficial do Registro de Imóveis compete verificar se houve o recolhimento do imposto devido. Se o recolhimento foi inferior ao devido, a matéria diz respeito ao fisco e não ao Oficial do Registro de Imóveis' (A.C. 268.549, São Bernardo do Campo, 2.5.1978. Des. Andrade Junqueira – 'in' Registro de Imóveis – Narciso Orlandi Neto – edição Saraiva – 1982 – pág. 208 – ementa 213)"⁸⁶¹.

Mas, isso não significa que o oficial deve permanecer inerte. Nas situações em que constatar omissões de recolhimento que não justifiquem o impedimento do registro, deve comunicar a Fazenda Pública:

"Tal conclusão, todavia, não impede que o Oficial comunique ao setor competente da Secretaria da Fazenda a circunstância, para as providências cabíveis. Não poderá, entretanto, obstar o registro do título por esse motivo"⁸⁶².

Mas, embora não possa adentrar em questões complexas e de competência exclusiva da fiscalização fazendária, inúmeros aspectos fiscais devem ser analisados pelo oficial.

5.1. Competência para arrecadar o tributo

Deve o oficial não apenas verificar se o imposto foi recolhido, mas se o imposto foi pago para a Fazenda Pública correta, impedindo o registro quando evidente o erro:

"Como, no presente caso, a doação não foi feita por ato oneroso, mas sim, por ato gracioso, sem compensação patrimonial na partilha, impõe-se a competência tributária ao Estado e não à Prefeitura.

Diante de tal situação, a incidência de tributo corresponde ao ITCMD e não ao ITBI, cujos recolhimentos foram efetuados conforme guias de f. 11 e 12.

⁸⁶¹ CSMSp. Apelação Cível nº 009674-0/0. Data: 16/8/1989. Localidade: São Bernardo do Campo. Relator: Milton Evaristo dos Santos. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁶² CSMSp. Apelação Cível nº 009674-0/0. Data: 16/8/1989. Localidade: São Bernardo do Campo. Relator: Milton Evaristo dos Santos. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos"⁸⁶³.

Pagamentos de tributos para a Fazenda Pública incorreta têm ocorrido com muita frequência, não apenas por equívoco, mas em vários casos visando elidir propositadamente o recolhimento do imposto correto, buscando-se recolher o tributo de menor alíquota. Na cidade de São Paulo, em que a alíquota de ITBI é de 2%, e o ITCMD do Estado é de 4%, essa prática pode ocasionar uma omissão de recolhimento de 50%.

5.2. Tempestividade

Sem analisar o exato valor devido, que é atribuição da fiscalização fazendária, deve o oficial exigir o recolhimento de juros e multa nos casos de recolhimento intempestivo:

"Com efeito, consta no v. acórdão atacado, com clareza e coerência, a interpretação conferida ao prescrito no artigo 289 da Lei de Registros Públicos e ao artigo 30, XI, da Lei nº 8.935/94, pela qual - sem confundir o 'valor' do imposto em si com o 'momento' devido de seu pagamento -, afirma-se, para a qualificação registrária, o dever de verificação do recolhimento do ITBI atrasado com multa e juros, que são consequências lógicas do atraso, ou seja, controle que não é propriamente do *quantum* recolhido, mas sim do pagamento do imposto devido segundo o tempo em que o pagamento efetivou-se."⁸⁶⁴

5.3. Evidentes incorreções

Também devem ser impedidos registros em que há evidentes incorreções da base de cálculo, como, por exemplo, a ausência de inclusão da construção ou do terreno:

"Imprescindível o recolhimento do ITBI sobre o valor do bem, em se tratando de dação em pagamento de direitos relativos a imóveis. Com efeito, com a transmissão dos mencionados direitos imobiliários ocorreu o fato gerador do imposto, sendo assim indispensável a comprovação do recolhimento devido para que o título possa ter acesso ao registro de imóveis. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

E, como este (valor venal), 'outra coisa não é senão aquele preço alcançado nas operações de compra e venda à vista, consideradas as condições nor-

⁸⁶³ Declaração de voto vencedor - Luís de Macedo, Revisor - Ap. Civ. 082885-0/8 Data: 16/12/2003 Localidade: Jundiaí Relator: Luiz Tâmbara.

⁸⁶⁴ CSMSp. Embargos de Declaração 365-6/9-01. Data: 23/3/2006. Localidade: São Paulo. Relator: Gilberto Passos de Freitas.

mais do mercado imobiliário' (Kiyoshi Harada, Direito Financeiro e Tributário, Atlas, São Paulo, 9ª. Ed., p. 395), no caso, o imposto deveria ter sido recolhido tendo como base de cálculo o valor total do bem adquirido, composto este pelas frações ideais, mais aquele correspondente às benfeitorias que advirão, uma vez que, como se depreende do título exibido, foram transmitidas à requerente, com valor determinado pelos interessados, sendo, pois, objeto do negócio jurídico efetivado"⁸⁶⁵.

Como evidente incorreção também se inclui o recolhimento ínfimo, em que há clara tentativa de fraude ao se recolher apenas uma fração do imposto devido, o que não pode ser tolerado pelo registrador, que deve exigir a comprovação de recolhimento do imposto.

5.4. Decadência e prescrição de tributos

A decadência e prescrição de impostos não pode ser analisada pelos oficiais: "(...) não lhes compete, evidentemente, o reconhecimento de eventual prescrição de créditos tributários, matéria estranha, de todo, à atividade registrária. Cogita-se de questão que só pode ser objeto de discussão e decisão em esfera própria, a qual, sem dúvida, não coincide com o restrito âmbito de atuação dos registradores"⁸⁶⁶.

Sobre esse tema não se pode esquecer que a transmissão de imóvel por ato *inter vivos* ocorre com o registro⁸⁶⁷, e não com a lavratura do título e, portanto, não há que se falar em decadência quando o título ainda não foi registrado, já que o que ocorre quando se exige a satisfação do tributo no ato da celebração do contrato é uma efetiva antecipação de seu pagamento, cujo fato gerador se concretizará somente com o registro do título.

5.5. Consequência da falta de recolhimento

A omissão do oficial na verificação da regularidade do recolhimento dos impostos, além de poder provocar sua responsabilidade tributária, na impossibilidade de exigência do pagamento pelo contribuinte⁸⁶⁸, também pode acarretar em sanção disciplinar: "Procedimento Administrativo Disciplinar – Imposto de transmissão *inter vivos* recolhido a menor, ao arrepio do disposto na legislação municipal – Configurada a infração à Lei n.º 8.935/94 – Pena de sus-

⁸⁶⁵ CSMSp. Apelação Cível nº 398-6/7. Data: 6/10/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁶⁶ CSMSp. Apelação Cível nº 154-6/4 Data: 12/5/2004. Localidade: Lorena. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁶⁷ Art. 1.245 do CC.

⁸⁶⁸ Art. 134, VI, do CTN.

pensão adequada, considerando os antecedentes do notário – Recurso improvido"⁸⁶⁹.

6. Certidões Negativas de Débitos – INSS, SRF e PFN

Visando impedir que empresas com dívidas previdenciárias dilapidem seu patrimônio, frustrando eventual execução, a Lei 8.212/91 estabelece inúmeras restrições às empresas inadimplentes, condicionando a prática de diversas transações imobiliárias à apresentação de certidões negativas de débitos expedidas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Secretaria da Receita Federal (SRF) e Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), todas quanto a contribuições sociais.

6.1. Contribuições Sociais

A Lei 8.212/91 não é uma legislação específica do INSS, mas que trata da Seguridade Social, cujas principais fontes de financiamento⁸⁷⁰ são as contribuições sociais, que são fiscalizadas e executadas não apenas pelo INSS (que administra as contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos segurados e sobre o salário-de-contribuição), mas também pela SRF e PFN (no que tange às contribuições incidentes sobre faturamento e lucro⁸⁷¹: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep).

Em decorrência dessa multiplicidade de órgãos envolvidos na arrecadação de contribuições sociais, para o cumprimento das restrições impostas pela Lei 8.212/91 não basta a apresentação de CND quanto às contribuições administradas pelo INSS, mas também das administradas pela Receita Federal, cuja regularidade é comprovada através da apresentação da certidão expedida pela própria Receita Federal, referente aos lançamentos ainda em fase administrativa, e da expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, relativa aos lançamentos após inscritos em Dívida Ativa.

6.2. CND da Dívida Ativa da União

Embora para a comprovação da regularidade perante o INSS seja suficiente a apresentação da CND do INSS, quanto às contribuições administradas pela SRF é necessária a apresentação da CND da SRF e da PFN.

⁸⁶⁹ Proc. CG 247/2006 - Ementário CGJ Extrajudicial nº 3/2006 – D.O.J. de 10/10/2006.

⁸⁷⁰ Art. 11 da Lei 8.212/91.

⁸⁷¹ Art. 204 do Decreto 3.048/99.

Isso ocorre porque, diferentemente do INSS, que é uma autarquia dotada de Procuradoria própria, a Receita Federal não possui corpo de procuradores em sua estrutura, sendo sua atuação apenas enquanto o processo está na esfera administrativa. Após a inscrição em Dívida Ativa o lançamento deixa o âmbito da Receita Federal e, por consequência, deixa de constar das Certidões expedidas pela Receita Federal, passando a ser administrado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, com o débito constando a partir de então exclusivamente nas certidões expedidas pela Procuradoria, motivo pelo qual a apresentação de ambas as certidões é indispensável.

A obrigatoriedade de apresentação da CND da Dívida Ativa da União é encontrada expressamente no art. 62 do Decreto-lei 147/67 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN), que estabelece que “em todos os casos em que a lei exigir a apresentação de provas de quitação de tributos federais, incluir-se-á, obrigatoriamente, dentre aquelas, a certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente”.

A partir de 1º de setembro de 2005, com a edição do Decreto 5.512/05, posteriormente substituído pelo Decreto 5.586/05, as certidões emitidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional passaram a ser emitidas conjuntamente, em um único documento, mas para títulos anteriores deve-se observar se foram apresentadas ambas as certidões, exigindo-se a sua apresentação caso não conste consignado expressamente no título submetido a registro.

6.3. Obrigatoriedade de apresentação de CNDs no Registro de Imóveis

No que tange ao Registro de Imóveis, o art. 47 da Lei 8.212/91 estabelece 3 hipóteses em que são exigidas Certidões Negativas de Débito-CND fornecidas pelos órgãos competentes: 1) das pessoas jurídicas na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo; 2) das pessoas jurídicas na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel incorporado ao ativo permanente e de valor superior ao estabelecido periodicamente por Portaria do Ministério da Previdência Social⁸⁷²; e 3) dos proprietários (pessoas físicas ou jurídicas) de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso de residência unifamiliar que atenda aos requisitos legais.

⁸⁷² A Portaria Interministerial MPS/MF nº 48/09 atualizou os valores para R\$33.228,88.

As certidões negativas também são exigidas para o registro de incorporação (art. 32, “b” e “P” da Lei 4.591/64).

6.4. Alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo

A primeira hipótese de apresentação de certidão negativa quanto a contribuições sociais diretamente relacionada ao Registro de Imóveis é das pessoas jurídicas na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo (art. 47, I, b, da Lei 8.212/91).

6.5. Pessoa Física equiparada a Pessoa Jurídica.

Somente as pessoas jurídicas estão sujeitas a essa restrição, porém, não se pode esquecer que algumas pessoas físicas são equiparadas a pessoas jurídicas e, por isso, estão sujeitas às mesmas restrições, motivo pelo qual sempre que “as partes não estiverem sujeitas a contribuições devidas à Seguridade Social, será, sob as penas da lei, indispensável a declaração dessa circunstância”⁸⁷³.

E essa declaração deve constar tanto das escrituras públicas quanto dos instrumentos particulares em que haja alienação ou oneração de imóvel ou direito a ele relativo: “Com perfeita coerência, em julgado relatado pelo Des. Sérgio Augusto Nigro Conceição e proferido na Apelação Cível nº 42.484-0/5, se reputa ‘inadmissível ... registro do compromisso de compra e venda ... sem a declaração de que os promitentes vendedores não estão sujeitos às contribuições devidas à Previdência Social’. E se explicita: ‘A exigência da declaração mencionada é absolutamente indispensável, ante o teor do artigo 47, inciso I, alínea ‘b’, da Lei Federal nº 8.212/91, reproduzida no item 16, alínea ‘h’, do capítulo XIV, do Tomo II, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, quando as partes não estiverem sujeitas às contribuições devidas à Previdência Social’”⁸⁷⁴.

Também não cabe ao Oficial inferir a equiparação ou não a pessoa jurídica a partir apenas das profissões declaradas das partes: “Nesta matéria, não se admite ao oficial que qualifica o título a tomada de suposições. Cabe ao interessado comprovar a inexistência de débitos, por meio de certidões, ou declarar situação fática que o deixaria a salvo daquela tributação, no caso, o fato de não ser empregador’.

⁸⁷³ Item 16, h, Capítulo XIV das NSCGJSP.

⁸⁷⁴ CSMSP. Apelação Cível nº 275-6/6. Data: 9/2/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

“Não é pela razão de estarem qualificados como profissionais liberais que seria de se exigir do oficial a conclusão de que não sujeitos ao tributo previdenciário. Necessária era a declaração, de maneira expressa, de modo que o declarante ficasse inteiramente responsável pelo seu conteúdo”⁸⁷⁵.

6.6. Alienação ou oneração de bem imóvel

"Alienação é gênero que abrange toda espécie de transferência da propriedade, i.é, toda forma de mutação de titularidade dominial, onerosa ou gratuita, tal como venda, permuta, doação, dação em pagamento, conferência de bens, etc."⁸⁷⁶.

Conforme definição de De Plácido e Silva, onerar significa impor encargos, denominando-se de ônus reais "os encargos ou as obrigações que pesam diretamente à propriedade, limitando sua fruição e disposição, ou para que sirvam de garantias a outras obrigações"⁸⁷⁷. São exemplos de ônus reais a superfície, a servidão, o usufruto, o uso, a habitação, o compromisso de compra e venda, a hipoteca, a anticrese⁸⁷⁸ e a alienação fiduciária⁸⁷⁹.

Assim, em uma compra e venda em que o adquirente no mesmo ato da aquisição hipoteca o imóvel ao vendedor para garantir parte do preço que será pago a prazo, no mesmo ato temos uma alienação e uma oneração e, se forem pessoas jurídicas, ambos, o alienante-credor e o adquirente-hipotecante, deverão apresentar as CNDs, o primeiro por alienar, o segundo por onerar o imóvel. Caso sejam pessoas físicas, ambos deverão declarar não estarem equiparados a pessoas jurídicas.

Outro exemplo de oneração de bem imóvel em que são exigidas as CNDs é o da caução do bem imóvel que garante um contrato de locação, hipótese em que um determinado imóvel é locado e outro é oferecido em garantia (caução para fins locatícios) a fim de assegurar o cumprimento da obrigação pactuada, e sendo forma de oneração de bem imóvel, exigíveis serão as certidões.

⁸⁷⁵ CSMSP. Apelação Cível nº 039540-0/4. Data: 17/2/1998. Localidade: Avaré. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁷⁶ CSMSP. Apelação Cível nº 538-6/7. Data: 23/3/2006. Localidade: Campinas. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J. de 30/06/2006.

⁸⁷⁷ Op. cit., p. 981.

⁸⁷⁸ Art. 1.225 do CC.

⁸⁷⁹ Art. 22 da Lei 9.514/97.

6.7. Direitos relativos a imóveis

Para a alienação ou oneração de direitos relativos a imóveis por pessoa jurídica também é necessária a apresentação das certidões. Assim, no compromisso de compra e venda e na cessão de seus direitos, as CNDs devem ser exigidas: “Abrange, assim, a promessa de venda e compra, uma vez que, registrada esta, nasce o direito real à aquisição do imóvel pelo promitente comprador (art. 1.417 do Código Civil). Ou seja, cuida-se de imóvel e de ‘direito a ele relativo’, nos exatos termos daquela alínea ‘b’ do inciso I do art. 47 da Lei nº 8.212/91”⁸⁸⁰. Da mesma forma, na cessão de créditos hipotecários as CNDs devem ser apresentadas.

Importante observar que o art. 47, I, b, da Lei 8.212/91 não se restringe aos direitos reais, ou seja, envolve também os direitos não registrados relativos a imóveis.

6.8. Oneração de bens móveis

A oneração de bens móveis pode ser constituída no Registro Imobiliário, como ocorre no penhor mercantil e industrial⁸⁸¹. Nesses casos, se o bem móvel estiver incorporado ao ativo permanente da pessoa jurídica e for de valor superior ao fixado em Portaria do Ministério da Previdência, deverão ser exigidas todas as CNDs quanto a contribuições sociais⁸⁸².

6.9. Construção

Entende-se como obra de construção civil para fins de apresentação de CND, além da construção propriamente dita, também a demolição, reforma ou ampliação de edificação ou outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo⁸⁸³.

Neste caso tem se exigido apenas a CND emitida pelo INSS, já que a construção não é fato gerador das contribuições administradas pelos demais entes fiscais, embora esse tema não seja pacífico, já tendo constado de antiga instrução normativa da SRF, hoje revogada, a obrigatoriedade de apresentação de sua certidão para a averbação de construção⁸⁸⁴.

⁸⁸⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 275-6/6. Data: 9/2/2005. Localidade: São Paulo. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁸¹ Art. 1.448 do CC.

⁸⁸² Art. 47, I, c, da Lei 8.212/91.

⁸⁸³ Decreto 3.048/99, art. 257, § 13.

⁸⁸⁴ Art. 2º, c, da IN SRF 93/93.

A CND do INSS a ser apresentada é aquela própria para a obra, que indicará seu endereço e área construída ou demolida. Assim, a CND para essa finalidade é específica, não podendo ser substituída pela CND de regularidade da pessoa jurídica.

6.10. Hipóteses de dispensa da apresentação das CNDs

O Regulamento da Previdência Social⁸⁸⁵ elenca as hipóteses de dispensa de apresentação de CNDs, que devem ser analisadas com muito cuidado, a fim de não serem estendidas indevidamente, o que poderia implicar em graves sanções ao registrador.

Importante notar que, diferentemente do que ocorre com as certidões de regularidade de tributos municipais, as partes não podem dispensar por vontade própria a apresentação das certidões quanto a contribuições sociais, cuja apresentação não é uma faculdade das partes, mas uma obrigação legal.

As hipóteses de dispensa previstas no Regulamento são as seguintes:

1) Instrumento de rerratificação

É dispensada a apresentação das certidões negativas quanto a contribuições sociais na “lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova”⁸⁸⁶.

Assim, se as CNDs já foram apresentadas no ato inicial, não é necessário apresentar novas certidões no momento da retificação ou ratificação. Claro que se houver mudança das pessoas jurídicas alienantes ou que oneram o bem, certidões negativas das novas pessoas jurídicas que ingressam no ato devem ser exigidas.

2) Pessoas jurídicas da área imobiliária

Estabelece o Decreto 3.048/99, art. 257, § 8º, inciso IV, que está dispensada a apresentação de CND na transação imobiliária “que envolva empresa que explore exclusivamente atividade de compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda, desde que o imóvel objeto da transação esteja contabilmente lançado no ativo circulante e não conste, nem tenha constado, do ativo permanente da empresa”.

⁸⁸⁵ Decreto 3.048/99, art. 257, § 8º.

⁸⁸⁶ Decreto 3.048/99, art. 257, § 8º, I.

Do dispositivo acima se verifica que as exigências a que se submetem todas as pessoas jurídicas são mitigadas para que as empresas exclusivamente da área imobiliária possam exercer os atos decorrentes de suas atividades econômicas sem empecilhos.

Mas para que a pessoa jurídica esteja dispensada deve atender a vários requisitos. O primeiro é que exerça exclusivamente as atividades elencadas na norma que criou a dispensa (“compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda”).

A norma utiliza o termo “explore exclusivamente” e relaciona expressamente as atividades possíveis, não deixando dúvida sobre o caráter restritivo, que visa impedir que empresas inadimplentes apenas incluam entre suas atividades algumas das elencadas e automaticamente encontrem-se livres das restrições a que se sujeitam todas as demais pessoas jurídicas.

Nesse controle deve o oficial observar o contrato social e a transação imobiliária que é exercida pela pessoa jurídica.

O objeto social da pessoa jurídica deve incluir apenas as atividades amparadas pela dispensa legal, o que é verificado pelo contrato social registrado no Registro Civil de Pessoa Jurídica ou na Junta Comercial. Incluindo outras atividades a pessoa jurídica sujeita-se à apresentação das certidões negativas.

Da mesma forma, as transações imobiliárias realizadas com dispensa da apresentação de certidões devem ser aquelas previstas no Regulamento da Previdência Social. Assim, mesmo que uma pessoa jurídica altere seu objeto social de participação em outras empresas para exatamente as atividades elencadas no dispositivo normativo, mas pretenda com isso utilizar a dispensa legal para permutar seus imóveis por participação societária em outra pessoa jurídica, não pode se beneficiar da isenção, que exige expressamente que a pessoa jurídica “explore exclusivamente” as atividades elencadas.

O segundo requisito é que “o imóvel objeto da transação esteja contabilmente lançado no ativo circulante e não conste, nem tenha constado, do ativo permanente da empresa”. Esse requisito é atendido por declaração expressa, sob as penas da lei, da própria pessoa jurídica, cujo representante responderá por ela, não competindo ao oficial exigir a apresentação de lançamentos contábeis para apurar a veracidade da declaração feita. Porém, se o imóvel já foi sede da pessoa jurídica ou por suas características já integrou de forma inquestionável o seu ativo imobilizado, como um hotel de uma sociedade do ramo hoteleiro, a declaração não pode ser aceita: “Na medida em que o imóvel em referência já integrou o ativo permanente da apelante, está ela obrigada a apre-

sentar a CND do INSS e da Receita Federal, não fazendo, pois, jus à dispensa (...) Assim sendo, a declaração substitutiva apresentada pela ora apelante não gera, por conseguinte, o efeito liberatório almejado”⁸⁸⁷.

A Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 estabelece quanto ao lançamento contábil do imóvel que esse fato “será relatado no registro da respectiva transação no cartório de Registro de Imóveis”. A correta interpretação desse dispositivo não é de que a declaração do alienante deva ser transcrita no ato praticado no Registro de Imóveis, mesmo porque os atos do Livro 2 são regulados no art. 176 da Lei 6.015/73, que não prevê isso, mas sim que a declaração, que constará da escritura pública ou do instrumento particular, deverá ser arquivada no Registro de Imóveis.

O ato normativo específico da SRF que tratava da dispensa de CNDs foi revogado, aplicando-se atualmente o disposto no art. 16 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3 de 2007, que estabelece que: “Fica dispensada a apresentação de certidão conjunta na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo, que envolva empresa que explore exclusivamente atividade de compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda, desde que o imóvel objeto da transação esteja contabilmente lançado no ativo circulante e não conste, nem tenha constado, do ativo permanente da empresa”. De forma análoga ao estabelecido no âmbito da IN RFB nº 971, estabelece o parágrafo único do mesmo artigo que: “A certidão a que se refere este artigo será substituída por declaração, que constará do registro do imóvel, prestada pela pessoa jurídica alienante, sob as penas da lei, de que atende às condições mencionadas no *caput*, relativamente à atividade exercida, e que o imóvel objeto da transmissão não faz parte de seu ativo permanente”.

3) Construções unifamiliares

Estabelece o Regulamento da Previdência Social as seguintes condições para que sobre uma construção não incidam contribuições sociais e, por consequência, não seja necessária a apresentação de CND⁸⁸⁸: 1) seja unifamiliar; 2) tenha área total não superior a 70 m²; 3) seja destinada a uso próprio; 4) seja do tipo econômico e 5) tenha sido executada sem a utilização de mão de obra remunerada.

⁸⁸⁷ CSMSp. Apelação Cível nº 877-6/3. Data: 14/10/2008. Localidade: Atibaia. Relator: Ruy Camilo. Publicado no D.O.J. em 5/12/2008.

⁸⁸⁸ Art. 278 do RPS.

A IN RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 em seu art. 370 explicitou ainda as restrições de que 6) o proprietário do imóvel ou dono da obra seja pessoa física, 7) não possua outro imóvel e 8) a construção seja residencial.

A comprovação do atendimento desses requisitos pode ser feita pela apresentação do “habite-se” (área construída e finalidade residencial) e por requerimento do próprio interessado declarando expressamente e sob as penas da lei terem sido atendidas todas as condições: "Verificados pelo registrador os requisitos objetivos que levam à dispensa da certidão, qual seja, que se trata de construção residencial com área de superfície inferior a 70 m² (setenta metros quadrados), as demais exigências ficam supridas mediante mera declaração do interessado"⁸⁸⁹.

Tentativas de burla à lei devem ser repelidas, como a averbação de imóvel com área construída com menos de 70 m² e subsequente pedido de averbação de ampliação da construção, devendo o oficial exigir CND para a área total, e não apenas do aumento, caso este tenha ocorrido imediatamente após a construção inicial.

4) Construções antigas

As construções concluídas antes de 22 de novembro de 1966, mesmo que apenas averbadas atualmente, estão dispensadas de apresentação de CND⁸⁹⁰.

5) Constituição de garantia para concessão de crédito rural

Também é desobrigada da apresentação de CNDs a constituição de garantia para concessão de crédito rural, ao produtor rural pessoa física (proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua) e ao segurado especial (produtor, parceiro, meeiro e arrendatário rurais, pescador artesanal e seus assemelhados, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, com ou sem auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de dezesseis anos de idade ou a eles equiparados, que trabalhem comprovadamente com o grupo familiar respectivo), desde que estes não comercializem a sua produção com o adquirente domiciliado no exterior nem

⁸⁸⁹ CGJSP. Processo nº 277/2005. Data: 18/4/2005. Localidade: Araçatuba. Juiz Auxiliar da Corregedoria: Milton Paulo de Carvalho Filho. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁹⁰ Art. 47, § 6º, da Lei 8.212/91.

diretamente no varejo a consumidor pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a outro segurado especial⁸⁹¹.

6) Administradora de grupo de consórcios

A Lei 11.795/08 em seu artigo 5º, § 6º, dispôs expressamente quanto à dispensa da apresentação das CNDs pela administradora de grupo de consórcios quando alienar imóvel integrante do patrimônio do grupo de consórcio, já que tais imóveis compõem o acervo próprio do grupo, autônomo em relação ao da administradora.

6.11. Certidões apresentadas ao tabelião

Quando as certidões foram apresentadas ao tabelião, que consignou sua apresentação na escritura, não é necessária nova apresentação quando do registro. Da mesma forma, nos casos de escrituras antigas, se as certidões não foram apresentadas porque inexigíveis à época, não devem ser exigidas quando do registro.

Esse o entendimento do CSMSP: "É certo que a consumação do efeito de transmissão dominial da venda que se quis evitar somente se dá com o registro. Mas este registro, não é menos certo, depende de um negócio jurídico causal de venda. Não se olvide que o sistema registrário brasileiro, com origem na combinação romana do título mais a tradição, como forma de transmissão do domínio, adotou o princípio do registro constitutivo, mas não puro, porque dependente, justamente, de um título. Ora, o título, no caso da alienação imobiliária, é exatamente o instrumento que dá suporte a um contrato que se aperfeiçoa com o consenso manifestado de forma solene. E, pois, se neste instante se atende à exigência de apresentação de certidão negativa, tal qual a normatização da época, não há porque, depois, se exigir nova apresentação ou mesmo a apresentação de certidão que, ao tempo da prática de ato perfeito e acabado, não se exigia"⁸⁹².

Porém deve o oficial verificar se no título consta a apresentação das CNDs, exigindo-as se não consignada sua apresentação ou constar a apresentação de documento inválido, como certidão positiva, sem efeitos de negativa: "é dever do tabelião exigir a certidão negativa de débito ao lavrar a escritura, e,

⁸⁹¹ Decreto 3.048/99, art. 257, § 8º, II.

⁸⁹² CSMSP. Apelação Cível nº 092305-0/0. Data: 22/8/2002. Localidade: Campinas. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

caso esta exigência não tenha sido observada pelo tabelião, deverá o oficial do registro de imóveis exigí-la no momento da apresentação para registro”⁸⁹³.

6.12. Cédulas de Crédito

Além das dispensas previstas no Regulamento da Previdência Social, a legislação esparsa também apresenta hipóteses de dispensa de apresentação de CNDs.

É o que ocorre com as cédulas de crédito industrial, estabelecendo o art. 42 do Decreto-Lei 413/69 que a constituição das garantias "independe da exibição de comprovante de cumprimento de obrigações fiscais, da previdência social, ou de declaração de bens e certidão negativa de multas".

Esse dispositivo, embora de 1969, não foi revogado pela legislação previdenciária posterior: "(...) já na Lei n.º 3.807, de 26 de agosto de 1960, se exigia o certificado de quitação de débitos para alienação ou oneração de bens imóveis, regra geral que, adiante, com o Decreto-Lei n.º 413 se viu excepcionada por preceito de caráter especial, que dispensou a exibição do certificado para as garantias mobiliária e imobiliária às cédulas de crédito. Na realidade, a lei nova manteve a disposição geral antecedente, a par da especial que subsiste, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil”⁸⁹⁴.

A dispensa é estendida para as cédulas de crédito comercial, de exportação e de importação, que se subordinam às mesmas regras das cédulas de crédito industrial⁸⁹⁵.

6.13. Adjudicação

Nos casos de adjudicação deve-se distinguir a adjudicação compulsória da adjudicação em processo de execução.

Na adjudicação compulsória, decorrente de compromisso de compra e venda, a sentença que substitui a declaração de vontade está sujeita às mesmas restrições para registro que a escritura que substitui: "A sentença proferida em substituição da vontade que deveria ter sido manifestada, não implica em isenção do dever de apresentar certidões negativas previstas na Lei nº 8.212/91,

⁸⁹³ CSMSp. Apelação Cível nº 000530-6/0. Data: 20/7/2006. Localidade: Itanhaém. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J. em 20/10/2006.

⁸⁹⁴ CSMSp. Apelação Cível nº 020383-0/3. Data: 15/8/1995. Localidade: Mauá. Relator: Antônio Carlos Alves Braga. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁹⁵ Art. 3º da Lei 6.313/75 e art. 5º da Lei 6.840/80.

para que seja possível o registro do título, por ser a alienante pessoa jurídica"⁸⁹⁶.

Importante observar que se assim não fosse, a adjudicação compulsória seria utilizada não para obter a satisfação de uma pretensão resistida, mas como forma de contornar exigência legal: "Não pode, porém, a sentença substitutiva de vontade permitir ao apelante a obtenção de vantagens e isenções que não alcançaria, caso houvesse o cumprimento voluntário da obrigação. A sentença, portanto, não o exime do dever de apresentar certidões negativas previstas na Lei Federal nº 8.212/91, para efeito de registro do título"⁸⁹⁷.

Isso, no entanto, não significa que na adjudicação compulsória sempre devem ser exigidas as CNDs, pois pode o adjudicante comprovar incidir no caso concreto a hipótese de dispensa prevista no Decreto 3.048/99, art. 257, § 8º, inciso IV: "Adjudicação de unidade autônoma condominial por substituição da vontade da construtora incorporadora – Evidência de que não integra seu ativo permanente – Bem destinado à venda - Dispensa, *ipso facto*, de certidões negativas do INSS e da Receita Federal - Registro possível"⁸⁹⁸.

A adjudicação decorrente de processo de execução é situação totalmente distinta. Nela há transmissão forçada em processo de execução, não sendo exigíveis as CNDs: "O texto contempla hipótese de alienação por ato voluntário do titular do domínio, como, por exemplo, compra e venda, permuta, doação etc.. E não quando a venda é coativa e involuntária daquele, como na arrematação judicial. 'Esta é 'um ato jurisdicional mediante o qual são os bens penhorados ao devedor postos em alienação, a fim de que, pela venda em licitação pública, apura-se, em dinheiro, o seu valor ou o que for validamente oferecido para com ele se pagar ao credor total ou parcialmente' ('Tratado do Processo de Execução', Antônio Carlos Costa e Silva, Ed. Aide, RJ, 2ª ed., 1986, vol. II, pág. 973). É 'uma alienação forçada, quando resulta de ato independente da vontade do proprietário, tais como...na arrematação judicial ou adjudicação em hasta pública ou leilão público' ('Vocabulário Jurídico', De Plácido e Silva, Forense, RJ, 1982, vol. I, pág. 198)"⁸⁹⁹.

⁸⁹⁶ CSMSP. Apelação Cível nº 100165-0/1. Data: 30/6/2003. Localidade: Salto. Relator: Luiz Tâmbara. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁹⁷ CSMSP. Apelação Cível nº 37.382-0/8. Data: 15/05/1997. Localidade: Birigui. Relator: Márcio Martins Bonilha. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁹⁸ CSMSP. Apelação Cível nº 385-6/8. Data: 6/10/2005. Localidade: Sorocaba. Relator: José Mário Antonio Cardinale. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁸⁹⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 081065-0/9. Data: 03/12/2001. Localidade: Capivari. Relator: Luís de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

6.14. Falência

No caso de alienação de bens de empresa falida⁹⁰⁰, desde que haja autorização judicial, não se exige CNDs: "(...) decretada a quebra, inaugura-se um procedimento concursal: todas as dívidas da sociedade têm seu vencimento antecipado; as ações propostas contra a falida são suspensas e reunidas num único Juízo; o falido perde a disponibilidade de seus bens, que são arrecadados, inventariados e devem ser alienados em benefício de uma massa, nos termos previstos no dec.-lei nº 7.661/45⁹⁰¹. O objetivo primário da legislação constitui, claramente, a proteção e a equalização dos credores, a fim de que, considerada a ordem de preferência derivada da natureza de cada obrigação, possam, mediante rateio e por classe, ser pagos com a alienação forçada do patrimônio da falida. Mostra-se presente, pois, com a falência, situação excepcional, não se justificando a exigência de apresentação das certidões negativas de débitos para com a previdência e o fisco federal"⁹⁰².

A Lei Federal 11.101/05, que disciplinou a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência, consignou expressamente essa dispensa na realização do ativo da massa falida⁹⁰³.

6.15. Entes públicos e filantrópicos

Os entes públicos igualmente estão sujeitos à apresentação de CNDs, não podendo alegar a imunidade recíproca, que abrange apenas impostos, e não contribuições sociais⁹⁰⁴. Assim, até a alienação de um imóvel pertencente à Autarquia INSS somente poderá ser registrada se apresentadas as CNDs do próprio INSS, SRF e PGFN. O mesmo ocorre nas demais situações sujeitas a comprovação de regularidade quanto a contribuições sociais, como no caso de averbação de construção.

Igual tratamento deve receber as entidades filantrópicas, como associações, fundações, etc, que também têm que apresentar as CNDs, não se aplicando a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal às contribuições sociais.

⁹⁰⁰ Outra hipótese de dispensa ocorre nos casos em que a empresa já foi encerrada regularmente e devidamente registrada na JUCESP ou RCPJ.

⁹⁰¹ Atualmente Lei 11.101/05.

⁹⁰² CSMSP. Apelação Cível nº 066368-0/1. Data: 28/03/2001. Localidade: São José do Rio Preto. Relator: Luiz de Macedo. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

⁹⁰³ Art. 146 da Lei 11.101/05.

⁹⁰⁴ Art. 150, VI, a, da Constituição Federal.

6.16. Certidões eletrônicas

As certidões negativas podem ser obtidas via Internet e, portanto, quando não apresentadas, somente devem ser exigidas quando não puderem ser emitidas diretamente pelo Registro de Imóveis.

Quando apresentadas pela parte, somente podem ser aceitas após confirmação de sua validade no endereço eletrônico da Internet. No caso de falsidade, após a confirmação pelo órgão fazendário, o documento falsificado não pode ser devolvido para o apresentante, mas deve ser objeto de representação penal dirigida ao Ministério Público Federal⁹⁰⁵.

6.17. Certidão positiva com efeitos de negativa

Além das certidões negativas, também podem ser aceitas as certidões positivas com efeitos de negativas, emitidas nos termos do art. 206 do CTN. No corpo dessas certidões consta expressamente que têm os mesmos efeitos das certidões negativas.

Muito cuidado é necessário na verificação das certidões apresentadas, pois não raro são apresentadas certidões positivas, que não podem ser aceitas em hipótese nenhuma para a prática de atos que dependam de comprovação de regularidade quanto às contribuições.

6.18. Validade das certidões

O prazo de validade, constante no corpo de todas as certidões deve ser respeitado, observando-se que as CNDs devem estar válidas no momento da prenotação, e não do lançamento do ato, em decorrência do disposto no art. 1.246 do Código Civil: “a necessidade de apresentação de CND-INSS (para averbação de construção) atualizada, ou seja, com prazo de validade em vigor ao tempo da apresentação do título para essa inscrição, é imperativo legal (artigo 257, II, e § 7º, do Decreto 3.048/99) e inteligência que resulta da máxima *tempus regit actum*”⁹⁰⁶.

Atente-se que a dispensa das certidões quando anteriormente apresentadas ao Tabelião justifica-se pela fé pública de que é dotado o ato notarial, dessa forma, tal regra não é aplicável aos contratos particulares, que deverão apresentar as certidões negativas válidas ao tempo da prenotação do título no

⁹⁰⁵ Supremo Tribunal Federal. RE 411690/PR. Relatora: Min. Ellen Gracie. Órgão Julgador: 2ª Turma. Data: 17/08/2004.

⁹⁰⁶ CSMSp. Apelação Cível nº 564-6/5. Data: 30/11/2006. Localidade: Capital. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J de 18/01/2007.

Registro de Imóveis: “O mesmo não se dá, porém, com compromisso particular de compra e venda porque inexistente a fé pública que decorre da prática do ato notarial, razão pela qual seu registro, sendo a alienante empresa que não tem como atividade a comercialização de imóveis, depende da apresentação ao Oficial de Registro de Imóveis de certidões negativas de débitos do INSS e da Receita Federal dentro do seu prazo de validade⁹⁰⁷”.

6.19. Finalidade das certidões

No que tange às certidões do INSS, não basta que seja apresentada a certidão, mas que sua finalidade específica corresponda ao que se pretende registrar, o que deve ser observado com atenção. Assim, uma certidão emitida para finalidade de diminuição de capital social não pode ser aceita para averbação de construção.

6.20. Estabelecimento matriz e filial

Atualmente tanto a CND expedida pelo INSS quanto a CND conjunta emitida pela Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional são expedidas exclusivamente com a identificação do CNPJ da matriz, sendo válidas para todos os seus estabelecimentos, matriz e filiais, exceto para as obras de construção civil⁹⁰⁸.

6.21. Incorporação, fusão e cisão

No caso de transmissão de imóveis e direitos em decorrência de incorporação, fusão e cisão de pessoas jurídicas não é necessária nova apresentação das CNDs no Registro de Imóveis quando anteriormente tenham sido apresentadas no Registro Civil de Pessoa Jurídica ou na Junta Comercial.

Quando não tenham sido apresentadas no registro da alteração social, deverão ser exigidas pelo Registro Imobiliário: "Irrelevante, ainda, o fato de que o contrato social já se encontra registrado na JUCESP sem apresentação de CND alguma, pois o registro comercial não se confunde com o registro predial: cada registro público tem fim específico e normas de regência próprias que justificam exigências legais diferenciadas"⁹⁰⁹.

⁹⁰⁷ CSMSP. Apelação Cível nº 814-6/7. Data: 27/05/2008. Localidade: Barueri. Relator: Ruy Camilo.

⁹⁰⁸ Art. 419 da IN RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009.

⁹⁰⁹ CSMSP. Apelação Cível nº 538-6/7. Data: 23/03/2006. Localidade: Campinas. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Publicado no D.O.J. em 30/06/2006.

6.22. Microempresas

O tratamento privilegiado dado às micro empresas e empresas de pequeno porte não dispensa a apresentação de CNDs no Registro de Imóveis, tornando inexigível, apenas, o documento comprobatório de inexistência de débito, quando do arquivamento de seus atos constitutivos nas juntas comerciais, inclusive de suas alterações.

6.23. Fundos Imobiliários

Alguns fundos imobiliários, por não terem personalidade jurídica, não podem adquirir imóveis em nome próprio. Os imóveis, então, são adquiridos pelas sociedades que administram os fundos que, por não serem as efetivas proprietárias dos imóveis, são dispensadas de apresentação de CNDs. É o que ocorre com o Fundo de Arrendamento Residencial (Lei 10.188/01, art. 2º, § 6º) e o Fundo de Investimento Imobiliário (Lei 8.668/93, art. 7º, § 3º), cujas sociedades administradoras, por não serem de fato as proprietárias dos imóveis, são dispensadas de apresentar CNDs na alienação de bens imóveis integrantes dos fundos.

6.24. Penalidades

A omissão do dever de exigir as CNDs importa em sanções extremamente severas ao registrador. As consequências da omissão são elencadas no art. 48 da Lei 8.212/91: responsabilidade solidária do oficial que registrar o instrumento e sujeição a elevada multa⁹¹⁰, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível.

6.25. Nulidade do ato

Além das sanções imputadas ao oficial o ato praticado é nulo, nos termos do art. 48 da Lei 8.212/91.

Embora a lei expressamente indique que o ato é nulo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o ato é ineficaz apenas em favor do ente previdenciário: "Consoante já teve oportunidade de proclamar a 3.ª Turma deste Tribunal, em interpretação teleológica dos arts. 47/48 da Lei 8.212/91, a falta de apresentação da certidão negativa de débito com o INSS faz o ato de alienação do

⁹¹⁰ Em valor a partir de R\$13.291,66 (art. 7º, VI, da Portaria Interministerial MPS/MF nº 48/09).

imóvel ineficaz em relação à Seguridade Social não impondo, entretanto, a sua nulidade"⁹¹¹.

6.26. Arquivamento de certidões

O arquivamento das certidões negativas é tratado nas Normas de Serviço e na legislação federal.

No Estado de São Paulo, o arquivamento das certidões é obrigatório, conforme determina o item 125, j, Capítulo XX das NSCGJSP: "Os cartórios deverão arquivar, separadamente e de forma organizada, em pastas, classificadores ou microfichas: (...) j) documentos comprobatórios de inexistência de débitos para com a Previdência Social".

O art. 257, § 5º, do Decreto 3.048/99, após indicar os dados das certidões que devem constar dos títulos, também estabelece a obrigação da guarda das certidões negativas: "fica dispensada a transcrição em instrumento público ou particular, do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e a sua data de emissão e a guarda do documento à disposição dos órgãos competentes, na forma por eles estabelecida". O parágrafo 16, do mesmo artigo, todavia, estabelece hipótese de dispensa de arquivamento: "fica dispensada a guarda do documento comprobatório de inexistência de débito, prevista no § 5º, cuja autenticidade tenha sido comprovada pela Internet".

7. Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI

Desde a década de 70 os oficiais estão obrigados a informar as transmissões de imóveis registradas à Secretaria da Receita Federal, através da declaração sobre operações imobiliárias - DOI.

Atualmente a DOI é regida pela Lei 10.426/02, alterada pela Lei 10.865/04, que estabelece significativa multa no caso de falta ou atraso na apresentação da declaração: 0,1% ao mês, sobre o valor da operação, limitada a 1%, com o valor mínimo de R\$ 20,00, por operação imobiliária. Na hipótese de apresentação de dados com incorreções ou omissões a multa é fixada em R\$ 50,00 por informação inexata, incompleta ou omitida.

A declaração, que deverá ser apresentada sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica,

⁹¹¹ Superior Tribunal de Justiça. REsp. 140.252/SP. Data: 09/12/1997. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Órgão Julgador: 4ª Turma.

independentemente de seu valor⁹¹², compete ao Registro de Imóveis quando a transmissão for formalizada por documento celebrado por instrumento particular; por autoridade particular com força de escritura pública; emitido por autoridade judicial (adjudicação, herança, legado ou meação); decorrente de arrematação em hasta pública; ou lavrado pelo tabelião de notas e não constar a expressão "emitida a DOI"⁹¹³. Também o oficial do Registro de Títulos e Documentos está sujeito à apresentação da DOI nos registros de instrumentos particulares de transmissão de imóveis⁹¹⁴.

Não é necessária a apresentação da DOI nos casos de desapropriação para fins de reforma agrária, usucapião, arrematação em hasta pública, quando o imóvel financiado retornar ao agente financeiro e nos instrumentos celebrados há mais de cinco anos, contados da data da lavratura, se instrumento público; do registro, se instrumento particular; ou da emissão do documento, se emitido por autoridade judicial (adjudicação, herança, legado ou meação)⁹¹⁵. Nos casos em que a informação já houver sido entregue à Secretaria da Receita Federal pelo Tabelião e no documento apresentado constar a expressão "emitida a DOI" o oficial também está desobrigado de realizar a comunicação ao órgão fazendário⁹¹⁶. Caso na escritura não seja consignada a informação da emissão da DOI o oficial deverá apresentar a declaração.

A Secretaria da Receita Federal tem editado orientações sobre o preenchimento da DOI, nas quais tem dispensado a comunicação em algumas hipóteses, como a instituição e renúncia de usufruto⁹¹⁷. A promessa de compra e venda deve ser informada, sendo uma das opções do programa de geração da DOI.

A DOI deve ser apresentada até o último dia útil do mês subsequente ao do registro dos documentos, via Internet, utilizando o programa de geração da DOI fornecido pelo órgão fazendário.

8. Cadastro Fiscal Imobiliário

O cadastro fiscal imobiliário constante na certidão fiscal ou no talão de notificação do IPTU reflete a realidade física do imóvel, localizando-o na planta do município segundo numeração que indica sua zona, quadra, unidade

⁹¹² Instrução Normativa SRF nº 473/2004, art. 2º. Disponível em: <<https://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2004/in4732004.htm>>.

⁹¹³ IN SRF 473/2004, art. 2º, § 3º, II.

⁹¹⁴ IN SRF 473/2004, art. 2º, § 3º, III.

⁹¹⁵ IN SRF 473/2004, art. 5º.

⁹¹⁶ IN SRF 473/2004, art. 5º, III.

⁹¹⁷ DOI-perguntas n.º 121 e 134. Disponível em <www.receita.fazenda.gov.br>.

e sub-unidade, com a finalidade de determinação física e controle para a arrecadação de tributos municipais, assim, por exemplo, na cidade de São Bernardo do Campo, o cadastro municipal nº 018.085.006.021, indica que o imóvel se localiza na zona 18 (bairro), quadra 85 (quarteirão), unidade 6 (terreno ou edifício), sub-unidade 21 (apartamento).

Dessa forma, quando for apresentado título hábil de transmissão no Registro de Imóveis, o interessado deverá juntar cópia da certidão fiscal ou do talão de notificação do IPTU, tanto para a verificação do atual cadastro do imóvel, elemento obrigatório da matrícula (art. 176, § 1º, II, b, da Lei 6.015/73), como para a apuração de seu valor venal, utilizado no cálculo dos emolumentos devidos pelo ato: "(...) a ausência da informação fiscal, relativa ao valor venal do imóvel ou unidade, impede a cobrança da taxa de serviço instituída pela Lei 11.331/02, não permitindo a conclusão dos próprios serviços"⁹¹⁸.

9. Arrolamento Fiscal

O arrolamento fiscal pode ser adotado por qualquer um dos órgãos fazendários federais, tendo sido originariamente criado pela Lei 9.532/97 como um meio de controle do patrimônio de grandes devedores, que passam então a ter que comunicar ao órgão fazendário eventuais transmissões de bens arrolados, sob pena de ser proposta a medida cautelar fiscal, prevista na Lei 8.397/92, que tem como objetivo provocar a indisponibilidade dos bens do contribuinte até o montante necessário a satisfazer os débitos tributários.

Posteriormente, o arrolamento passou também a ser utilizado como condição para permitir o prosseguimento de recursos perante os órgãos julgadores de segunda instância no âmbito administrativo.

O arrolamento, como modo de acompanhamento do patrimônio de contribuintes, surge com a Lei 9.532/97 para evitar que a demora nos trâmites administrativos após o lançamento fiscal permitisse que o sujeito passivo dilapidasse todo seu patrimônio, frustrando a satisfação dos débitos.

O arrolamento com essa finalidade só pode ser utilizado quando a dívida for superior a R\$ 500.000,00 e ultrapasse 30% do patrimônio conhecido do contribuinte⁹¹⁹, devendo ser lançado no Livro 2 quanto aos imóveis ou direitos a eles relativos.

⁹¹⁸ 1ª Vara de Registros Públicos de São Paulo. Processo 000.03.158681-3. Data 12/04/04. Juiz Venício Antonio de Paula Salles.

⁹¹⁹ Art. 64 da Lei 9.532/97.

Em síntese, após a comunicação do arrolamento de bens pela autoridade fiscal, o oficial lança no Livro 2 o arrolamento, o que não tem como consequência a indisponibilidade do imóvel ou direito, mas apenas fará com que no caso de alienação ou oneração o oficial informe o órgão fazendário no prazo de 48 horas.

A Lei 9.532/97 estabelece que o arrolamento será registrado⁹²⁰ na matrícula do imóvel, independentemente de pagamento de custas ou emolumentos, a requerimento da autoridade fiscal. No âmbito da Receita Federal o arrolamento fiscal é disciplinado pela Instrução Normativa SRF 264/02, e no âmbito da Previdência Social pela Instrução Normativa MPS/SRP 3/05, atos normativos que detalharam a forma de comunicação do arrolamento e suas consequências para o registrador.

No âmbito da Receita Federal, a unidade fazendária do domicílio do contribuinte (delegacia, inspetoria ou alfândega, conforme o caso) encaminha ofício instruído com relação de bens e direitos para arrolamento⁹²¹, título hábil para o lançamento, desde que haja identidade dos dados do imóvel arrolado e do contribuinte com os dados do imóvel e do proprietário lançados na matrícula, respeitando-se os princípios registrários.

Após promovido o arrolamento, se o imóvel ou direito for alienado ou transferido, deverá o oficial comunicar a ocorrência ao órgão fazendário no prazo de 48 horas⁹²². Embora o dispositivo normativo não inclua a oneração do bem como causa de comunicação, o modelo de ofício anexo à instrução normativa a inclui, indicando a obrigação da informação no caso de "alienação, transferência ou oneração de qualquer dos bens ou direitos relacionados".

Se o oficial não cumprir a obrigação de informar o órgão fazendário, incorrerá na imposição de multa fixada dentro de faixa de valores⁹²³, além de eventual cominação decorrente do dano ao Erário que vier a ser causado pela omissão ou inexactidão da comunicação⁹²⁴.

Deve-se observar ainda que o arrolamento não incide apenas sobre bens, mas também sobre direitos, dessa forma, são passíveis de serem arrolados os

⁹²⁰ Tecnicamente o correto seria averbação, e não registro, por não envolver a transmissão ou constituição de direito real, como corretamente indicado na IN SRF 264/02.

⁹²¹ Art. 4º da IN SRF 264/02.

⁹²² Art. 5º da IN SRF 264/02.

⁹²³ Art. 9º do Decreto-lei 2.303/86, corrigido pelo art. 3º, inciso I, da Lei 8.383/91, art. 30 da Lei 9.249/95.

⁹²⁴ Art. 5º, § 2º, da IN SRF 264/02.

direitos de crédito e os direitos do compromisso de venda e compra, por exemplo.

O cancelamento do arrolamento depende de novo ofício expedido pela mesma autoridade administrativa.

A segunda hipótese de arrolamento, utilizada como condição para se recorrer administrativamente, criada pela Lei 10.522/02, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, julgou inconstitucional o artigo 32 da Medida Provisória 1.699-41/98, convertida na Lei 10.522/02, que deu nova redação ao artigo 33, § 2º, do Decreto 70.235/72⁹²⁵. Assim, a Receita Federal pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 30 de 15 de junho de 2009, declarou a nulidade das decisões que não tenham admitido recurso voluntário de contribuintes, por descumprimento do requisito do arrolamento de bens e direitos, bem como dos demais atos delas decorrentes, proferindo-a *ex officio* ou por requerimento do sujeito passivo, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, realizando um novo juízo de admissibilidade com dispensa do referido requisito.

⁹²⁵STF. ADI 1.976-7/DF. Relator: Ministro Joaquim Barbosa.

APÊNDICE

LIVROS

Livros adotados¹ no Registro de Imóveis²

Livro 1 – Protocolo: para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, ressalvados os apresentados para exame e cálculo de emolumentos.

Livro 2 – Registro Geral: destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 da Lei 6.015/73 e demais diplomas legais, quando não atribuídos ao Livro 3.

Livro 3 – Registro Auxiliar: destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao Registro de Imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente a imóvel matriculado.

Livro 4 – Indicador Real: repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias, visando permitir a localização dos lançamentos existentes a partir dos dados de identificação dos imóveis.

Livro 5 – Indicador Pessoal: repositório dos nomes de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, figurarem nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos números de ordem, visando permitir a localização dos lançamentos existentes a partir dos nomes das pessoas relacionadas aos atos.

¹ No Estado de São Paulo são livros obrigatórios em caráter geral para todos os serviços notariais e de registro: a) Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça; b) Registro diário da receita e da despesa; c) Protocolo; d) Visitas e Correições; e) Normas do Pessoal dos Serviços Extrajudiciais (item 38 do Capítulo XIII das NSCGJSP).

² Artigos 173 a 181 da Lei 6.015/73.

Livro de Indisponibilidades: destinado ao registro dos ofícios da Corregedoria Geral da Justiça ou dos interventores e liquidantes de instituições financeiras em intervenção ou liquidação extrajudicial, comunicando a indisponibilidade dos bens de diretores e ex-administradores das referidas sociedades³.

Livro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros: para lançamento das aquisições de terras rurais por pessoas estrangeiras, físicas e jurídicas, sem prejuízo dos lançamentos nos demais livros⁴.

Livro de recepção de títulos: para lançamento dos títulos apresentados para exame e cálculo dos respectivos emolumentos⁵, que não gozam dos efeitos da prioridade⁶.

Livros adotados no Registro de Imóveis antes da Lei 6.015/73⁷:

Livro 1 - Protocolo: para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente para serem registrados.

Livro 2 – Inscrição hipotecária: destinado à inscrição das hipotecas de qualquer espécie.

Livro 3 – Transcrição das transmissões: para transcrição dos títulos de transmissão de imóveis.

Livro 4 – Registros diversos: para registro da promessa de compra e venda e de todos os demais atos não atribuídos a especificadamente outros livros.

Livro 5 – Emissão de debêntures: para inscrição das emissões de debêntures, sem prejuízo da inscrição eventual e definitiva no Livro 2, das hipotecas que abonarem, especialmente, ditas emissões.

Livro 6 – Indicador real: repositório de todos os imóveis que, direta ou indiretamente, figurarem nos Livros 2, 3, 4 e 8.

Livro 7 – Indicador pessoal: para lançamento, sob a letra respectiva, dos nomes de todas as pessoas que, ativa ou passivamente, individual ou coletivamente, figurarem nos livros de registro.

Livro 8 – Registro especial: destinado à inscrição da propriedade loteada para a venda de lotes a prazo em prestações sucessivas e periódicas⁸.

Livro Auxiliar: para registros em casos expressos em lei⁹ ou a requerimento da parte e às suas expensas, independentemente do que couber em outros livros.

³ Item 93, Capítulo XX das NSCGJSP.

⁴ Art. 10 da Lei 5.709/71.

⁵ Art. 12, parágrafo único, da Lei 6.015/73

⁶ Item 7, Capítulo XX das NSCGJSP.

⁷ Artigos 183 a 197 do Decreto 4.857/39.

⁸ Também para a inscrição da instituição e incorporação de condomínio: artigos 7 e 32 da Lei 4.591/64.

⁹ Inscrição de convenções antenupciais: artigo 198 do Decreto 4.857/39.

APÊNDICE

PRAZOS

ARROLAMENTO FISCAL

48 horas: Prazo para o Oficial informar ao órgão fazendário sobre a alienação, transferência ou oneração de qualquer bem ou direito arrolado (art. 5º da IN SRF 264/02).

HIPOTECA CEDULAR

3 dias úteis: Prazo para registro ou averbação decorrente de Cédula de Crédito Rural, Industrial, Comercial e à Exportação (artigo 38 do Decreto-lei 167/67, artigo 38 do Decreto-lei 413/69, artigo 5º da Lei 6.840/80 e artigo 5º da Lei 6.313/75).

CERTIDÃO

5 dias: Prazo para expedição de certidão, em qualquer de suas modalidades: inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos (artigo 19 da Lei 6.015/73).

30 dias: Prazo de validade da certidão para lavratura de escritura (item 12, d, Capítulo XIV das NSCGJSP).

QUALIFICAÇÃO NEGATIVA – FAZENDA PÚBLICA

5 dias: Prazo para comunicação ao juízo das exigências para registro de título judicial de interesse da fazenda pública (item 37.1 do Capítulo XX das NSCGJSP).

SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO e ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

15 dias: Prazo para registro ou averbação dos títulos decorrentes da Lei 9.514/97, que criou o Sistema Financeiro Imobiliário e instituiu a alienação fiduciária de imóveis (artigo 52 da Lei 10.931/04).

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E BANCÁRIO

15 dias: Prazo para registro ou averbação dos títulos decorrentes da lei 10.931/04, que dispôs, entre outras matérias, sobre a letra de crédito imobiliário, a cédula de crédito imobiliário e a cédula de crédito bancário (artigo 52 da Lei 10.931/04).

QUALIFICAÇÃO NEGATIVA

15 dias: Prazo para exame, qualificação e devolução do título com exigências ao interessado (Item 32 do Capítulo XX das NSCGJSP).

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

15 dias: Prazos para registro de incorporação de condomínio edilício (artigo 32, § 6º, da Lei 4.591/64).

180 dias: Prazo de validade da incorporação, após o qual, se não concretizada, o incorporador não poderá negociar unidades antes de atualizar a documentação prevista no artigo 32 da Lei 4.591/64. Considera-se concretizada a incorporação “caso demonstre o incorporador que, no curso daquele prazo, negociou frações ideais vinculadas à construção de unidades. Para demonstrá-lo, mister se providencie o registro de ao menos um contrato em tais condições. E – relevante assinalar – nada obsta a que esse registro se dê após o escoamento do lapso de 180 dias, desde que a anterioridade do contrato possa vir a ser autêntica e cumpridamente comprovada¹⁰” (artigo 33 da Lei 4.591/64).

“Concretizar ou caracterizar a incorporação significa tomar a iniciativa do empreendimento, que é assumida pelo incorporador, mediante a alienação de ao menos uma das unidades autônomas ou pela contratação da construção, tudo de acordo com o conceito de incorporação, acima mencionado¹¹.

REGISTRO

30 dias: Prazo para registro ou averbação de título quando não houver prazo específico (artigo 188 da Lei 6.015/73).

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR ESTRANGEIRO

15 dias: Prazo para ser apresentado para registro (artigo 10, parágrafo único do Decreto 74.965/74).

¹⁰ CSMSP. Apelação Cível nº 012303-0/6. Data 3/7/1991. Localidade: Campos do Jordão. Relator: Onei Raphael. In: THESAURUS. IRIB, 2005. 4 CD-ROM.

¹¹ CSMSP. Apelação Cível nº 525-6/8. Data 25/5/2006. Localidade: Caraguatatuba. Relator: Gilberto Passos de Freitas. Disponível em: <www.arisp.com.br> (Kollemata).

PRENOTAÇÃO

30 dias: Prazo de validade da prenotação (artigo 205 da Lei 6.015/73), salvo as hipóteses de prorrogação da prenotação, que são a seguir elencadas (item 36 do Capítulo XX das NSCGJSP):

1) Apresentação de título de segunda hipoteca com referência expressa à existência de outra anterior, quando se prorrogará a prenotação para que se aguarde por 30 dias que a primeira hipoteca seja registrada, o que, se não ocorrer, permitirá o registro da segunda, que adquirirá, então, preferência sobre a outra (artigo 189 da Lei 6.015/73);

2) Suscitação de dúvida, quando a prenotação será prorrogada até final decisão. Sendo a dúvida julgada procedente, será cancelada a prenotação. Se a dúvida for improcedente, o título será registrado sob o mesmo número de protocolo que recebeu quando da suscitação de dúvida, preservando-se assim os efeitos do registro desde a data daquela prenotação (artigo 198 e 203 da Lei 6.015/73);

3) Instituição de bem de família, em decorrência da necessidade de se aguardar o prazo de 30 dias, contados da data da publicação do edital, para a apresentação de eventual reclamação contra a instituição do bem de família. Se houver reclamação, será cancelada a prenotação, devolvendo-se a escritura de Instituição com cópia da reclamação ao interessado, que poderá requerer ao juiz que ordene o registro (artigos 263 e 264 da Lei 6.015/73);

4) Loteamento, por ser necessária a publicação de edital por 3 dias consecutivos e se aguardar o prazo de 15 dias para eventual reclamação. No caso de reclamação, o Oficial intimará o requerente e a municipalidade para se manifestarem em 5 dias, sob pena de arquivamento do processo. Com as manifestações será o processo enviado ao juiz para decisão, que antes ouvirá o Ministério Público (artigos 18 e 19 da Lei 6.766/79);

5) Reingresso do título, com todas as exigências cumpridas, se ocorrer na vigência da força da primeira prenotação (item 36.2 do Capítulo XX das NSCGJSP);

6) Mandado de indisponibilidade que não conte com previsão de ingresso na matrícula do imóvel (item 102.2 do Capítulo XX das NSCGJSP, incluído pelo Provimento CG 17/99);

7) Além dessas hipóteses expressamente indicadas no item 36 do Capítulo XX das NSCGJSP, também há a prorrogação da prenotação nos procedimentos de intimação de devedor fiduciante (artigo 26 da Lei 9.514/97) e de retificação administrativa de registro (artigo 213, II, da Lei 6.015/73), em decorrência de em ambos haver a necessidade do Oficial promover intimação ou notificação, podendo ser necessária até a publicação de editais, o que ultrapassa o prazo de validade da prenotação.

APÊNDICE

MODELOS

Modelo de descerramento de matrícula:

Livro 2

Matrícula nº 000 Ficha nº 01

São Bernardo do Campo, 00 de janeiro de 2000

IMÓVEL: Casa nº 100 da Rua Mar de Rosas, no Bairro Boa Vizinhança e seu respectivo terreno, constituído pelo lote 1 da quadra B do Loteamento Legal, com 5,00 metros de frente para a referida rua, 25,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando do lado direito, de quem da via pública olha para o imóvel, com a casa nº 96, e do lado esquerdo, segundo a mesma orientação, com a casa nº 106, ambas da mesma rua, e 5,00 metros de fundos, confrontando com a Praça Verde, encerrando a área de 125,00 metros quadrados.

CADASTRO MUNICIPAL: 000.000.000.

PROPRIETÁRIOS: (nome do proprietário), comerciante, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, e sua esposa (nome da proprietária), comerciante, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens, anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Mar de Rosas, nº 100, Bairro Boa Vizinhança, São Bernardo do Campo/SP.

REGISTRO ANTERIOR: Registro nº 1 da matrícula nº 000 desta serventia, aberta em 00 de janeiro de 2000.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de registro de venda e compra:

Livro 2

Matrícula nº 000 Ficha nº 01

R.1¹², em 00 de janeiro de 2000.

Pela escritura pública de 00 de janeiro de 2000, lavrada no 5º Tabelião de Notas desta Comarca, Livro 000, fls. 00, o proprietário (nome do proprietário), anteriormente qualificado, VENDEU o imóvel desta matrícula, pelo preço de R\$100.000,00, a (nome do adquirente) brasileiro, solteiro, maior, comerciante, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Encanto, nº 1, nesta cidade.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de registro de venda e compra com cláusula resolutiva:

Livro 2

Matrícula nº 000 Ficha nº 01

R.1, em 00 de janeiro de 2000.

Pela escritura pública de 00 de janeiro de 2000, lavrada no 5º Tabelião de Notas desta Comarca, Livro 000, fls. 00, o proprietário (nome do proprietário), anteriormente qualificado, VENDEU o imóvel desta matrícula, pelo preço de R\$110.000,00, a (nome do adquirente) brasileiro, solteiro, maior, comerciante, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Bondade, nº 10, nesta cidade. Do valor da venda, R\$50.000,00 foram pagos à vista e R\$60.000,00 serão pagos em 00 de fevereiro de 2000, sem incidência de juros ou correção, sendo ajustada a CLÁUSULA RESOLUTIVA na falta de pagamento do saldo do preço na forma estabelecida. As demais cláusulas e condições constam na escritura que está sendo microfilmada nesta data.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

¹² Conforme artigo 232 da Lei 6.015/73, o ato deve ser seguido pelo número de ordem do lançamento (que será sequencial, independentemente de se tratar de registro ou averbação) e pelo número da matrícula (R.1-[número da matrícula], Av.2 – [número da matrícula], etc.), mas a repetição do número da matrícula em seguida ao número de ordem é dispensada ao se adotar o sistema de fichas, por já constar a identificação da matrícula no cabeçalho da ficha correspondente (item 43, III, Capítulo XX, NSCGJSP).

Modelo de registro de venda com financiamento do SFH garantido por hipoteca:

Livro 2

Matrícula nº 000 Ficha nº 01

R.1, em 00 de fevereiro de 2000.

Pelo instrumento particular de 00 de janeiro de 2000, com caráter de escritura pública, na forma do artigo 61 e seus parágrafos, da Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, alterada pela Lei nº 5.049, de 29 de junho de 1966, a proprietária (nome da proprietária) anteriormente qualificada, VENDEU o imóvel desta matrícula, pelo preço de R\$100.000,00, a (nome do adquirente) brasileiro, solteiro, maior, consultor, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, residente e domiciliado na Alameda das Árvores, nº 1, nesta cidade. Do valor acima noticiado, R\$79.000,00 foram pagos com recursos próprios em moeda corrente.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

R.2, em 00 de fevereiro de 2000.

Pelo instrumento particular referido no R.1, o adquirente (nome do adquirente) anteriormente qualificado, HIPOTECOU o imóvel adquirido pelo registro anterior ao credor BANCO CONFIANÇA S/A, inscrito no CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-00, com sede na Rua Finanças nº 1000, São Paulo/SP, em garantia do financiamento que este lhe concedeu, no valor de R\$21.000,00, que deverá ser pago através de 204 prestações mensais e consecutivas, no valor inicial total de R\$212,86, incluídos juros à taxa nominal de 6,000% a.a., efetiva de 6,1677% a.a., e seguros, vencendo a primeira prestação em 00 de fevereiro de 2000. O título, contendo as demais condições do financiamento, está sendo microfilmado nesta data.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de registro de venda com alienação fiduciária:

Livro 2

Matrícula nº 000 Ficha nº 00

R.1, em 00 de fevereiro de 2000.

Pelo instrumento particular de 00 de janeiro de 2000, com caráter de escritura pública, na forma do artigo 38 da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, a proprietária CONSTRUTORA SÓLIDA LTDA, anteriormente qualificada, VENDEU o imóvel desta matrícula, pelo preço de R\$64.000,00, a (nome do adquirente) brasileiro, solteiro, maior, consultor, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, residente e domicilia-

do na Rua Felicidades, nº 1, nesta cidade. Do valor acima noticiado, R\$16.000,00 foram pagos com recursos próprios.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

R.2, em 00 de fevereiro de 2000.

Pelo instrumento particular referido no R.1, o adquirente (nome do adquirente) anteriormente qualificado, ALIENOU FIDUCIARIAMENTE o imóvel desta matrícula a CONSTRUTORA SÓLIDA LTDA, anteriormente qualificada, em garantia ao financiamento que esta lhe concedeu, no valor de R\$48.000,00, com prazo de amortização de 240 meses, sendo o encargo inicial de R\$702,44, no qual já estão incluídos juros à taxa nominal de 10,1600% a.a., efetiva de 10,6467% a.a., vencendo-se a primeira prestação no mês subsequente e no dia correspondente ao da assinatura do contrato. O título, com as demais condições do contrato, está sendo microfilmado nesta data.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de averbação da consolidação da propriedade fiduciária:

Av.3, em 00 de fevereiro de 2000.

Fica consolidada a propriedade do imóvel objeto desta matrícula em nome da credora fiduciária CONSTRUTORA SÓLIDA LTDA, anteriormente qualificada, tendo em vista que, a seu requerimento, protocolizado sob nº 000.000, foi procedida a intimação do fiduciante e transcorreu o prazo previsto no artigo 26, § 1º, da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, sem que houvesse a purgação da mora, nos termos do § 7º do mesmo artigo e lei. Esta averbação é feita à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de transmissão *inter-vivos*, feito por intermédio da guia nº 53.921/05-34, autenticada em 00 de maio de 2000, que fica arquivada.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de intimação do devedor fiduciante:

São Bernardo do Campo, 00 de dezembro de 2000.

Ilma. Sra.

(Nome da devedora fiduciante)

Rua das Flores, 3953

São Bernardo do Campo – SP

CEP 0000-000

Prezada Senhora,

Na qualidade de Oficial do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, conforme as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei nº 9.514/97, e em virtude do requerimento de 21 de dezembro de 2006, do BANCO CONFIANÇA S/A, credor do contrato de financiamento imobiliário garantido por ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, firmado em 00 de março de 2000, e devidamente registrado sob os números 6 e 7 na matrícula nº 00.000, deste Registro, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria, venho INTIMÁ-LO, para o cumprimento das obrigações contratuais de pagamento, relativas aos encargos e parcelas vencidas em número de 14 (quatorze).

Informo ainda que o valor em atraso, atualizado até 00 de dezembro de 2000, corresponde a R\$ 19.026,98 (dezenove mil vinte e seis reais e noventa e oito centavos), sujeito à atualização monetária e juros de mora até a DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, além das despesas de cobrança e demais encargos que vencerem neste período.

Nestes termos, procedo à INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que se dirija, no horário das 12 às 18 horas, a esta Serventia, situada à Rua Marechal Deodoro, nº 2086, Centro, São Bernardo do Campo/SP, a fim de realizar o pagamento do débito acima discriminado, no PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, contados do recebimento desta.

Por oportuno, fica Vossa Senhoria ciente de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de CONSOLIDAÇÃO da propriedade do imóvel em favor do CREDOR FIDUCIÁRIO, que então promoverá público leilão para alienação do imóvel, conforme previsão dos artigos 26, § 7º, e 27 da Lei 9.514/97.

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do Oficial)

Modelo de registro de promessa de compra e venda:

Livro 2

Matrícula nº 000 Ficha nº 00

R.1, em 00 de janeiro de 2000.

Pelo instrumento particular de 00 de janeiro de 2000, os proprietários (nome do proprietário), cirurgião dentista, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, e sua esposa (nome da proprietária), psicóloga, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00,

ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Gratidão, nº 2, Centro, nesta cidade, PROMETERAM VENDER o imóvel desta matrícula a (nome do promissário comprador) engenheiro civil, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, e sua esposa (promissária compradora), administradora de empresas, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Amparo, nº 1, apartamento 11, nesta cidade, pelo preço de R\$100.000,00, que será pago da seguinte forma: R\$10.000,00 pagos à título de sinal e princípio de pagamento, R\$10.000,00 serão pagos no momento da desocupação do imóvel e transmissão da posse aos promissários adquirentes, com data limite de 00 de janeiro de 2000, e R\$80.000,00 pagos na data da lavratura da escritura definitiva de alienação do imóvel, o que se dará em até 30 dias da transmissão da posse do imóvel. As parcelas não terão incidência de juros ou correção monetária. O título, com as demais condições do contrato, está sendo microfilmado nesta data.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de registro do cumprimento da promessa de compra e venda:

Livro 2
Matrícula nº 000 Ficha nº 00

R.2 em 00 de janeiro de 2000.

Pela escritura pública de 00 de janeiro de 2000, lavrada no 5º Tabelião de Notas desta Comarca, Livro 000, fls. 00, o proprietário (nome do proprietário), anteriormente qualificado, VENDEU o imóvel desta matrícula, pelo preço de R\$100.000,00, em cumprimento ao compromisso de compra e venda registrado sob nº 1 retro, a (nome do adquirente) brasileiro, solteiro, maior, comerciante, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Encanto, nº 1, nesta cidade.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de doação com reserva de usufruto, direito de acrescer e cláusulas de reversão e restritivas:

Livro 2
Matrícula nº 000 Ficha nº 00

R.1 em 00 de janeiro de 2000.

Pela escritura pública de 00 de janeiro de 2000, lavrada no 5º Tabelião de Notas desta Comarca, Livro 000, fls. 00, o proprietário (nome do proprietário) e sua esposa (nome da proprietária), anteriormente qualificados, DOARAM o imóvel desta matrícula, no valor de R\$60.000,00, a (nome do donatário) brasileiro, solteiro, maior, advogado, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Generosidade, nº 3, Centro, nesta cidade, sendo estabelecida na doação a CLÁUSULA DE REVERSÃO no caso dos doadores sobreviverem ao donatário.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

R.2 em 00 de janeiro de 2000.

Pela escritura pública referida no R.1, os doadores (nome dos doadores), anteriormente qualificados, reservaram para si o USUFRUTO VITALÍCIO do imóvel desta matrícula, atribuindo o valor de R\$20.000,00, sendo estabelecido o DIREITO DE ACRESCER, pelo qual o usufruto será exercido por ambos os usufrutuários e por ocasião da morte de um deles passará em sua totalidade para o outro, somente se consolidando a propriedade plena na pessoa do nu-proprietário com a morte de ambos os usufrutuários.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Av.3, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos da escritura pública referida no R.1, procedo esta averbação para constar que o imóvel desta matrícula encontra-se gravado com as cláusulas de INCOMUNICABILIDADE e IMPENHORABILIDADE, em virtude de imposição estabelecida pelos doadores.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de averbação de óbito com transmissão do usufruto ao supérstite:

Av.4, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos do requerimento de 00 de janeiro de 2000, instruído com cópia autenticada da certidão de óbito expedida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca, assento nº 0000, Livro C nº 00, fls. 000, procedo esta averbação para constar que o usufrutuário (nome do usufrutuário) faleceu em 00 de janeiro de 2000, transmitindo-se o usufruto para o usufrutuário supérstite em decorrência do direito de acrescer.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de averbação de óbito com cancelamento do usufruto:

Av.5, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos do requerimento de 00 de janeiro de 2000, instruído com cópia autenticada da certidão de óbito expedida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca, assento nº 0000, Livro C nº 00, fls. 000, procedo esta averbação para constar que a usufrutuária (nome da usufrutuária) faleceu em 00 de janeiro de 2000, extinguindo-se o usufruto registrado sob nº 2.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de registro de venda e compra de fração ideal:

Livro 2
Matrícula nº 000 Ficha nº 01

R.2, em 00 de janeiro de 2000.

Pela escritura pública de 00 de abril de 2000, lavrada no 5º Tabelião de Notas desta Comarca, Livro 000, fls. 00, a proprietária CONSTRUTORA SÓLIDA LTDA, anteriormente qualificada, VENDEU a fração ideal correspondente a 0,333333% do terreno desta matrícula, que no futuro corresponderá à unidade autônoma apartamento nº 0000, do Edifício Paz, parte integrante do Condomínio Residencial Harmonia, cuja incorporação encontra-se registrada sob o nº 1 retro, pelo preço de R\$100.000,00, sendo que deste valor R\$10.000,00 correspondem a fração ideal do terreno, a (nome da adquirente) brasileira, solteira, maior, professora, RG 00.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Alegria, nº 10, Jardim Vida, nesta cidade.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de averbação de casamento:

Livro 2
Matrícula nº 000 Ficha nº 00

Av.1, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos do requerimento de 00 de janeiro de 2000, instruído com cópia autenticada da certidão de casamento expedida em 00 de janeiro de 2000, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca, assento nº 0000, Livro B nº 00, fls. 000, procedo esta averbação para constar que a proprietária (nome da proprietária) casou-se em 00 de janeiro de 2000, com (nome do marido), brasileiro, contabilista, RG

000000000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, pelo regime da comunhão parcial de bens, passando a contraente a assinar (nome adotado pela proprietária).

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de averbação de separação:

Livro 2
Matrícula nº 000 Ficha nº 00

Av.1, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos do requerimento de 00 de janeiro de 2000, instruído com cópia autenticada da certidão de casamento expedida em 00 de janeiro de 2000, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca, assento nº 0000, Livro B nº 00, fls. 000, procedo esta averbação para constar que o casal (nome da proprietária) e (nome do proprietário) separou-se judicialmente, conforme sentença proferida em 00 de janeiro de 2000 (autos nº 000/00), pelo M. M. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, Dr. (nome do magistrado), voltando a separanda a assinar o nome de solteira, qual seja (nome de solteira da proprietária).

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de averbação de construção:

Livro 2
Matrícula nº 000 Ficha nº 00

Av.1, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos do requerimento de 00 de janeiro de 2000, instruído com certidão de conclusão de obras nº 0000, fls. 00, processo SB 000/2000, expedida pela Prefeitura Municipal em 00 de janeiro de 2000, procedo esta averbação para constar que foi construído no terreno desta matrícula um prédio residencial com a área de 100,00 m², o qual recebeu o nº 10 da Rua Saúde. Foi apresentada a certidão negativa de débitos expedida pela Previdência Social em 00 de janeiro de 2000, sob o nº 00.00000.0000-00.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de registro de arrolamento fiscal:

Livro 2
Matrícula nº 000 Ficha nº 00

R.1, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos do Ofício nº 0000, expedido em 00 de janeiro de 2000, pelo Delegado da Receita Federal desta Cidade, Sr. (nome da autoridade fiscal), referente ao processo administrativo nº 0000000/000, tendo como contribuinte o proprietário (nome do proprietário), anteriormente qualificado, instruído com relação de bens e direitos de 00 de janeiro de 2000, procedo este registro para constar que o imóvel desta matrícula é objeto de arrolamento fiscal, nos termos do § 5º, artigo 64, da Lei 9.532/97.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de cancelamento do registro de arrolamento fiscal:

Av.2, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos do Ofício nº 0000, expedido em 00 de janeiro de 2000, pelo Delegado da Receita Federal desta Cidade, Sr. (nome da autoridade fiscal), referente ao processo administrativo nº 0000000/000, procedo ao cancelamento do arrolamento fiscal de bens registrado sob nº 1 retro, atendendo a determinação da autoridade fiscal.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de averbação de caução em contrato de locação:

Livro 2
Matrícula nº 000 Ficha nº 00

Av.1, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos do requerimento de 00 de janeiro de 2000, instruído com contrato de locação de 00 de janeiro de 2000, procedo esta averbação para constar que a proprietária (nome da proprietária), anteriormente qualificada, CAUCIONOU o imóvel objeto desta matrícula como garantia ao fiel cumprimento do contrato de locação firmado entre (nome do locador), brasileiro, solteiro, maior, consultor, RG 00000000/SPP-SP, CPF 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua das Lembranças, nº 1, nesta cidade, na qualidade de locador e (nome do locatário) brasileiro, solteiro, maior, professor, RG 00000000/SPP-SP, CPF 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua da Solidariedade, nº 2, nesta cidade, na qualidade de locatário, referente ao imóvel situado na Rua Compaixão, nº 1, nesta cidade, pelo prazo de 36 meses, com início em 00 de janeiro de 200X e término em 00 de janeiro de 200Y, com valor de aluguel correspondente a R\$1.000,00 mensais. O contrato de locação, com suas demais cláusulas e condições, está sendo microfilmado nesta data, em seu inteiro teor.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de registro de cláusula de vigência em contrato de locação:

Livro 2

Matrícula nº 000 Ficha nº 00

R.1, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos do contrato de locação de 00 de janeiro de 2000, firmado entre o proprietário (nome do proprietário), anteriormente qualificado, na qualidade de locador, e (nome da locatária), CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-00, sediada na Rua Primavera nº 3, São Paulo/SP, na qualidade de locatária, pelo prazo de 60 meses, com início em 00 de janeiro de 200X e término em 00 de janeiro de 200Y, mediante o pagamento de aluguel mensal no valor de R\$3.000,00, a ser pago todo dia 10 de cada mês no domicílio do locador, sob pena de (pena convencional), procedo o presente registro para constar que, sobre o imóvel objeto desta matrícula vigora a favor da locatária acima referida a CLÁUSULA DE VIGÊNCIA, conforme artigo 576 do Código Civil e artigo 8º da Lei 8.245/91. O contrato de locação, com suas demais cláusulas e condições, está sendo microfilmado nesta data, em seu inteiro teor.

O Escrevente,

Nome e assinatura.

Modelo de averbação de direito de preferência em contrato de locação:

Livro 2

Matrícula nº 000 Ficha nº 00

Av.2, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos do contrato de locação de 00 de outubro de 2000, firmado entre a proprietária (nome da proprietária), anteriormente qualificada, na qualidade de locadora, e (nome da locatária), CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-00, sediada na Rua das Flores, nº 10, nesta cidade, na qualidade de locatária, pelo prazo de 48 meses, com início em 1º de setembro de 2006 e término em 31 de agosto de 2010, mediante o pagamento de aluguel mensal no valor de R\$3.000,00, procedo a presente averbação para constar que, sobre o imóvel objeto desta matrícula, fica garantido ao locatário acima referido o DIREITO DE PREFERÊNCIA, conforme artigo 27, da Lei 8.245/91. O contrato de locação, com suas demais cláusulas e condições, está sendo microfilmado nesta data, em seu inteiro teor.

O Escrevente,

Nome e assinatura.

Modelo de transmissão de bem imóvel em conferência de bens:

Livro 2

Matrícula nº 000 Ficha nº 01

R.1, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos da Ata da Assembleia Geral realizada em 00 de janeiro de 2000, devidamente registrada na JUCESP sob o nº 000000000000, em 00 de janeiro de 2000, os proprietários (nome do proprietário) e sua esposa (nome da proprietária), anteriormente qualificados, TRANSMITIRAM o imóvel desta matrícula, a título de CONFIRMAÇÃO DE BENS, pelo valor de R\$100.000,00, a INDÚSTRIA EFICIENTE S/A, CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-00, sediada na Rua Trabalho, nº 1, Jardim Industrial, nesta cidade.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de averbação de bloqueio de matrícula:

Livro 2
Matrícula nº 000 Ficha nº 01

Av.1, em 00 de janeiro de 2000.

Nos termos do r. Mandado de Bloqueio expedido em 00 de janeiro de 2000, pelo Exmo. Sr. Dr. (nome do juiz), M.M. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível desta Comarca e Corregedor Permanente desta serventia, nos autos do Processo nº 00/00-RI, é feita a presente averbação para constar o BLOQUEIO desta matrícula, ficando, em consequência, vedada a prática de qualquer ato registrário até ulterior determinação.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de registro de hipoteca cedular:

Livro 3
Registro nº 000 Ficha nº 00
Em 00 de janeiro de 2000.

Título:

Hipoteca cedular.

Forma do título:

Cédula de Crédito Rural Hipotecária, emitida em São Paulo-SP, em 00 de janeiro de 2000, sob o nº 0.000.

Emitente:

(nome do devedor), pecuarista, RG nº 0.000.000/SSP-SP, CPF nº 000.000.000-00, casado pelo regime da comunhão universal de bens, anteriormente à vigência da Lei

6.515/77, com (nome da esposa), do lar, RG nº 0.000.000/SSP-SP, CPF nº 000.000.000-00, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Rua da Fazenda, nº 4, nesta cidade.

Financiador:

BANCO CONFIANÇA S/A, CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-00, com sede na Rua Finanças, nº 1000, São Paulo/SP.

Valor:

R\$120.000,00, a serem pagos em uma única parcela, com vencimento em 00 de janeiro de 2000, incidindo juros à taxa efetiva de 8,75% ao ano incidentes sobre os saldos devedores diários da operação, calculados até o último dia do mês, até o vencimento e liquidação da operação.

Vencimento:

Em 00 de janeiro de 2000.

Praça de Pagamento:

São Bernardo do Campo.

Garantias:

Em hipoteca cédular o prédio nº 1 da Rua Danúbio Azul, Vila das Valsas, e seu respectivo terreno medindo 7,00 metros de frente para a referida rua, 20,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, e 7,00 metros nos fundos, encerrando a área de 140,00 m²; confrontando de ambos os lados e nos fundos com próprio municipal; matriculado nesta Serventia sob o nº 000, tendo a hipoteca sido registrada sob nº 1 no Livro 2 – Registro Geral.

A Cédula de Crédito, contendo as demais condições e encargos previstos, está sendo microfilmada, em seu inteiro teor, nesta data.

O Escrevente,

Nome e assinatura.

Livro 2

Matrícula nº 000 Ficha nº 00

R.1, em 00 de janeiro de 2000.

Pela Cédula de Crédito Rural Hipotecária, emitida em São Paulo, em 00 de janeiro de 2000, sob o nº 0.000, registrada sob nº 000 no Livro 3 – Registro Auxiliar desta Ser-

ventia, o proprietário (nome do proprietário) e sua esposa (nome da proprietária), anteriormente qualificados, HIPOTECARAM o imóvel desta matrícula, ao credor BANCO CONFIANÇA S/A, CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-00, com sede na Rua Finanças, nº 1000, São Paulo/SP, em garantia de dívida no valor de R\$120.000,00, a ser paga em uma única parcela, com vencimento em 00 de janeiro de 2000, incidindo juros à taxa efetiva de 8,75% ao ano incidentes sobre os saldos devedores diários da operação, calculados até o último dia do mês, até o vencimento e liquidação da operação.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de registro de pacto antenupcial no Livro 3:

Livro 3
Registro nº 000 Ficha nº 00

Data:
Em 00 de janeiro de 2000.
Título:
Pacto Antenupcial.
Forma do título:
Escritura Pública de 00 de janeiro de 2000, lavrada no 5º Tabelião de Notas desta Comarca (Livro 00, fls. 00).

Outorgantes e reciprocamente outorgados:

(nome do contraente), brasileiro, maior, médico, RG nº 0.000.000/SSP-SP, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Prosperidade, nº 5, nesta cidade; e (nome da contraente), brasileira, maior, comerciante, RG nº 0.000.000/SSP-SP, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Boa Ventura, nº 3, nesta cidade.

Regime de bens adotado:

Comunhão universal de bens, comunicando-se os bens presentes e os futuros, que possuam ou venham a possuir, seja a título oneroso ou gratuito, inclusive por sucessão hereditária.

Datas do casamento, certidão e cartório:

Data do casamento: 00 de janeiro de 2000.

Data da certidão: 00 de janeiro de 2000.

Registro Civil: 3º Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais desta, assento nº 0000, Livro B nº 00, fls. 000.

Nome da contraente após o casamento: (nome adotado pela contraente).
Primeiro domicílio do casal: Travessa da Aliança, nº 1, Bairro União, nesta cidade.

O Escrevente,
Nome e assinatura.

Modelo de Devolução:

1º Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo – SP
Rua Marechal Deodoro, 2086 – Centro – CEP 09710-201
Protocolo nº 00.000.
Natureza: Requerimento
Apresentante: (nome do apresentante)

Para registro do presente título deverão ser cumpridas as seguintes exigências:

A procuração lavrada em outra Comarca, para produzir efeitos nesta Comarca, deverá possuir o reconhecimento de firma do Tabelião subscritor. Desta forma, apresentar a procuração, ou sua cópia autenticada, com o reconhecimento da firma do Tabelião subscritor (item 9 do Capítulo XIV das NSCGJSP).

Outrossim, consta na certidão de casamento que o proprietário casou-se pelo regime da separação de bens. Desta forma, deverá ser apresentada certidão do registro da escritura de pacto antenupcial expedida pelo Registro de Imóveis competente. Caso a referida escritura ainda não tenha sido registrada, o registro deverá ser procedido no Registro de Imóveis do local do primeiro domicílio do casal (artigo 1657 do CC).

São Bernardo do Campo, 00 de janeiro de 2000.

Nome e assinatura do escrevente autorizado

Notas importantes:

1. O presente título foi prenotado em 00/00/2000 sob nº 00.000, com validade até 00/00/2000, conforme artigo 205 da Lei 6.015/73.
2. Não se conformando com a exigência feita, ou não a podendo satisfazer, o interessado, se o ato for de registro, poderá requerer a suscitação de dúvida, nos termos do artigo 198 da Lei 6.015/73, e se o ato for de averbação, poderá contestar a exigência em procedimento administrativo, ambos julgados pelo M.M. Juiz Corregedor Permanente desta Comarca.

Bibliografia

1. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
2. CARVALHO, Afrânio de. Registro de Imóveis: comentários ao sistema de registro em face da Lei 6.015, de 1973, com as alterações da Lei nº 6.216, de 1975. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977.
3. CRISTÓBAL MONTES, Angel. Direito Imobiliário Registral. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2005.
4. NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
5. SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
6. COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, v.2, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
7. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.
8. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v.6: direito das sucessões. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
9. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2005.
10. REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial, v.1. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
11. Thesaurus Notarial, Registral e Imobiliário. IRIB, 2005. 4 CD-ROM. Organização Sérgio Jacomino.
12. GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, v.1. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
13. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2005.

Índice Alfabético–remissivo

- Alienação fiduciária
 - consórcio para aquisição de imóveis 149
 - direito de preferência 147
 - prazo de carência 118
 - procedimento 118
 - reconhecimento de firma 120
- Aquisição
 - derivada 265
 - originária 265
- Arrendamento
 - arrendamento imobiliário especial 130
 - programa de arrendamento residencial (PAR) 127, 129, 184
 - rural 184
- Arrolamento fiscal e medida cautelar fiscal 306
- Assinatura
 - a rogo 79, 110
 - analfabeto 79, 110
 - cego 110
 - fundada dúvida 106
 - legalização 83
 - reconhecimento de firma 104
 - sinal público e raso 69
- Associações 87, 169
- Atualização monetária 96
- Averbação
 - arrolamento fiscal 307
 - cancelamento 52
 - características 32
 - casamento 32, 37, 67, 216, 219, 222, 224, 227, 229
 - caução 67, 137, 138, 141
 - compromisso de compra e venda 121
 - consolidação da propriedade 118
 - construção 45, 55, 123, 144, 150, 168, 289, 292, 295, 300, 301
 - curatela 78
 - distinção de registro 32
 - emancipação 74, 76
 - fundo de investimento imobiliário 173
 - fusão de matrículas 20, 43
 - fusão de S/A 136
 - incorporação de S/A 67, 136
 - requerimento 43, 105
 - taxatividade 32
- Bem de família 230

Bloqueio 53

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF 200

Cadastro Fiscal Imobiliário 305

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

- alteração de numeração 204
- CNPJ de entes públicos 205
- empresário 88
- entes sem personalidade jurídica 173
- filial 205
- inscrição inapta 204
- ITR 284
- matriz 205
- obrigatoriedade 204
- qualificação 193
- sociedade estrangeira 158, 204

Casamento

- alteração de nome 222
- averbação 222
- certidão 222
- continuidade 224
- justificação do estado civil 225
- posse do estado casados 225

Casamento no exterior

- certidão 82, 84, 227
- Registro Civil de Pessoas Naturais 228
- Registro de Títulos e Documentos 228

Cédula de Crédito

- empresário individual 171
- reconhecimento de firma 105
- inalienabilidade 114

Certidões

- certidão de escritura pública 64
- certidão de matrícula 22, 27
- certidão de regularidade do ITCMD 280
- certidão de registro de títulos e documentos 68
- certidão fiscal 94, 305

Certidões Negativas de Débitos

- adjudicação 298
- alienação de bem imóvel 292
- arquivamento 304
- bem móvel 292
- cédulas de crédito 298
- certidão eletrônica 301
- certidão positiva com efeito de negativa 301
- cisão de sociedade 302
- construção 292
- construção antiga 296
- construção unifamiliar 295
- contribuições sociais 288
- crédito rural 296
- direitos relativos a imóveis 292
- dívida ativa da União 288
- ente filantrópico 300
- ente público 300
- escritura pública 297
- falência 300
- filial 302
- finalidade da certidão 302
- fundos imobiliários 303
- fusão de sociedade 302
- incorporação de sociedade 302
- INSS 288
- matriz 302
- microempresas 303
- nulidade 303
- oneração de bem imóvel 291
- oneração de bem móvel 292

- penalidade 303
- pessoa física 290
- pessoa jurídica da área imobiliária 293
- Procuradoria da Fazenda Nacional 288
- rerratificação 293
- Secretaria da Receita Federal 288
- validade 301

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) 19, 94, 283

Cessão de direitos hereditários 181

CETESB 34

CGC – ver CNPJ

CIC – ver CPF

Cláusulas

- acrescer 254
- cancelamento 238, 247
- compromisso de compra e venda 241
- condição 247
- *constituti* 255
- contratual 241
- decaimento 254
- despesas condominiais 245
- direito de acrescer 254
- dívidas fiscais 245
- divórcio 237
- doação de dinheiro com imposição de cláusula 241
- escritura de retificação 239
- exceções 245
- grau 239
- impenhorabilidade 237

- inalienabilidade 237
- inalienabilidade convencional 241
- inalienabilidade relativa 244
- incomunicabilidade 213, 237
- indivisibilidade 255
- interpretação de vontade 249
- justa causa 242
- legítima 242
- loteamento 250
- morte dos donatários 248
- obrigação *propter rem* 245
- parte disponível 243
- penal 96
- perpétua 239
- preempção ou preferência 260
- próprios bens 240
- reserva de domínio 262
- resolutive 251
- retrovenda 255
- reversão 252
- revogação 246
- separação 237
- sub-rogação 243
- termo 249
- transcrições 260
- vitalícia 239

Comodato 185

Compromisso de compra e venda

- adjudicação compulsória 122, 298
- alienação ou oneração a terceiros 122
- cancelamento 122
- CNDs 291
- cessão 38, 94, 114, 125, 130, 146, 232, 250, 270, 271, 292
- cláusula de arrependimento 122
- dispensa de registro 38

- DOI 305
- falência 124
- incorporação 45, 123
- instrumento particular 121
- partilha 167, 214
- usufruto 180

Comunicação de bens

- casamento no exterior 223
- compromisso de compra e venda 214
- espólio 40
- *saisine* 26
- sub-rogação 212
- usufruto 212

Condomínio

- atribuição 152
- carta de arrematação 132
- CNDs 151, 290, 293
- convenção 150, 167
- execução de despesas condominiais 169
- incorporação 150
- instituição 150
- promessa de compra e venda 45, 123
- regimento interno 151
- transcrição 20

Conferência de bens 132, 272, 291

Consórcio 119, 149, 165, 297

Constituto possessório – ver cláusulas

Cópia autenticada 64, 65, 111, 193, 205, 219, 222

Curatela 78

- pródigo 78
- representação 72

Dação em pagamento

- arrendamento imobiliário especial 130
- cindibilidade 56
- cláusula de retrovenda 256
- direito de preferência em locação 146
- ITBI 272, 286
- promessa de dação 177

Declaração sobre Operações

Imobiliárias – DOI

- entes públicos 131
- escritura pública 95
- obrigatoriedade 304

Desapropriação

- dispensa da DOI 305
- dispensa de certidões 284

Desmembramento/desdobro

- loteamento 250
- transcrição 20

Distrato 50, 108

Divisão 46, 69, 152, 255, 269

Divórcio

- alienação de bens não partilhados 229
- averbação 229
- bem de família 230
- certidão atualizada 227
- certidão do registro civil 228
- certidão de regularidade do ITCMD 280
- continuidade 227

- efeitos 228
- escritura pública 113, 182
- espólio 41
- exterior 228
- inalienabilidade 233
- ITBI 268
- ITCMD 268, 280
- partilha 228
- poder familiar 73
- regime de bens 227
- SFH 115

Doação

- capacidade do donatário 76
- cláusula de inalienabilidade 241
- cláusula de incomunicabilidade 213, 237
- cláusula de reversão 252
- competência para arrecadar o tributo 285
- direito de preferência 147
- doação com reserva de usufruto e extinção 274
- doação de ascendentes para descendentes 76, 89, 238, 275
- doação de numerário de imposição de cláusulas 241
- imposição de cláusulas por escritura de retificação 239
- ITCMD 273
- sub-rogação na incomunicabilidade 243

Documento

- distinção de título 66

Documento de identidade

- alteração de numeração 196
- carteira nacional de habilitação 198
- carteira profissional 199

- estrangeiro 196
- identidade funcional 199
- igualdade de direitos 195
- modelo antigo 191, 194
- português 195
- prazo de validade 197
- RG 194

Documento estrangeiro

- legalização 83
- registro em títulos e documentos 83
- tradução 84

Dúvida 43, 271, 313

Empresário 88, 170, 171

Enfiteuse

- laudêmio 118
- SPU 130

Espólio 40, 166, 182

Faixa de fronteira

- restrições 157

Falência 89, 124, 300

Fideicomisso

- constituição 257
- ITCMD 279
- residual 260

Fundação 87, 300

Fusão de matrículas ou transcrições

- condições 42

Hipoteca

- cancelamento 56, 167
- caução 141

- certidões fiscais 92
- CNDs 291
- cessão de créditos hipotecários 126, 292
- hipoteca cédular 246, 311
- imóvel rural 283
- inalienabilidade 114, 237, 241
- legalidade 47
- menores 72, 75
- outorga uxória 211
- prazo da dívida 97
- procuração 80
- prodígio 78
- SFH 114
- sobre parte certa e localizada 31
- sociedade estrangeira 158
- valor da dívida 97

Imóvel rural

- aquisição por pessoa estrangeira 112
- CCIR 19, 94, 283
- descrição 19, 91
- identificação 283
- imposto – ver imposto territorial rural (ITR)

Imóvel urbano

- descrição 20
- imposto – ver imposto sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU)

Impenhorabilidade – ver cláusulas

Inalienabilidade - ver cláusulas

Incomunicabilidade - ver cláusulas

Indisponibilidade

- execução judicial da dívida ativa 30

Inventário

- alvará 41
- extrajudicial 113, 182
- ITCMD 280
- partilha 26, 41, 182
- renúncia 27
- reversão 253

IPTU

- adjudicação e arrematação 282
- certidão fiscal 281
- dispensa pelo adquirente 281
- escrituras públicas 94

ITBI

- adjudicação compulsória 267
- atraso no pagamento 286
- cessão de direitos (não) registrados 271
- cisão 272
- competência para arrecadar 265
- conferência de bens 272
- dação em pagamento 272
- decadência 287
- desapropriação 267
- direitos sobre imóveis 270
- divisão 269
- divórcio 268
- doação 278
- erros 285
- extinção de sociedade 272
- falta de pagamento 287
- fusão de sociedades 272
- incorporação de sociedade 272
- partilha 268
- permuta 269
- prescrição 287

- reposição 268
- retrovenda 273
- separação 268
- SISA 273
- tempestividade 286
- usucapião 266

ITCMD

- alíquotas 275, 278, 286
- atraso no pagamento 286
- cancelamento de usufruto 274
- certidão de regularidade 280
- competência para arrecadar 286
- decadência 287
- divórcio 268
- doação com reserva de usufruto 274
- erros 285
- falta de pagamento 287
- instituição de usufruto pelo nu-proprietário 277
- isenção 278
- ITBI – doação 278
- pagamento 279
- partilha 268
- penalidade 280
- prescrição 287
- redução na doação entre ascendente e descendente e cônjuges 275
- separação 268, 280
- tempestividade 286
- usufruto 274

ITR

- CND de imóvel rural 284
- comprovação de pagamento 283
- declaração de inexistência de débito 284
- definição de imóvel rural 283
- desapropriação 284

- usucapião 284

Locação

- análise do contrato 148
- cancelamento voluntário 50
- caução 67, 141, 148, 291
- cláusula de vigência 140, 143, 145, 148, 167, 184
- contrato de locação com prazo vencido 140
- contratos de sublocação 139
- diferenciação com arrendamento rural 184
- direito de preferência 140, 146, 148
- duplo lançamento 147
- espólio 167
- imóveis alienados fiduciariamente 141
- imóvel anteriormente locado a terceiro 139
- locação por não proprietário 140
- proprietário como anuente 138
- registro de locação após a alienação de imóvel 140
- registro em Títulos e Documentos 138
- valor do contrato 96
- vênua conjugal 138

Loteamento

- cláusula restritiva convencional 250
- compromisso de compra e venda 124
- loteamentos populares 126
- personalidade jurídica 167
- posse 185
- publicidade 28

Medida Cautelar Fiscal – ver
arrolamento fiscal

Menores 72

- curador especial 75
- emancipação 76
- falta de um dos pais 73
- limitação da representação ou assistência dos pais 74
- partilha 228
- tutela 77

Ministério Público

- averbação do regime da separação de bens 216
- bem de família 230
- certidões falsas 301
- fundação 87
- requerimento 42
- selos furtados, roubados e extraviados 71

Moeda estrangeira 95

Multa

- limite 99

Multipropriedade 188

Novação 178

Obrigação *propter rem* 93, 245

Pacto antenupcial

- averbação 219
- escritura pública 209, 222
- ineficácia 209
- pródigo 79
- registro 219

Pacto comissório – ver cláusula
resolutiva

Partilha

- alienação de bens não partilhados 229
- cindibilidade 56
- compromisso de compra e venda 126, 167
- forma pública 113, 182
- formal de partilha 24, 27, 42, 56, 182, 270
- separação e divórcio 228
- SFH 115

Penhora

- alienação fiduciária 117
- cindibilidade 55
- cláusula restritiva de impenhorabilidade 237
- continuidade 37
- débitos condominiais 169, 245
- dívida ativa 30
- dívidas fiscais 245
- entes sem personalidade jurídica 165
- prioridade 30
- qualificação 24

Permuta

- CNDs 291, 299
- direito de preferência 147
- ITBI 269
- promessa de permuta 123, 179

Pessoa Jurídica

- associações – ver associações
- cartório 173
- CNPJ de entes sem personalidade jurídica 173
- competência para autorizar 160

- condomínio edilício 167
 - conferência de bens 132
 - consórcio 149, 165
 - desconsideração da personalidade jurídica 37
 - empresário 170
 - entes sem personalidade jurídica 165
 - espólio 166
 - estrangeira 157
 - fundações – ver fundação
 - fundos de investimento imobiliário 172
 - instrumento particular 133
 - loteamento 167
 - motivos da necessidade de autorização 159
 - oneração de bens móveis 292
 - pessoa jurídica de direito público externo 157
 - qualificação 24
 - representação 85
 - situações que exigem a autorização 158
 - sociedade anônima – ver sociedades
 - sociedade simples – ver sociedades
 - sociedades estrangeiras 158
 - sociedades sem registro 171
- autotutela 57
 - cindibilidade 54
 - continuidade 36
 - disponibilidade 45
 - especialidade 19
 - inscrição ou do registro 43
 - da instância 42
 - legalidade ou legitimidade 47
 - presunção de eficácia do registro 48
 - prioridade 28
 - publicidade 27
 - taxatividade 32
 - unitariedade 30
 - *tempus regit actum* 44

Procuração 79

- analfabetos e pessoas que não possam ler ou assinar 110
- autocontrato 81
- brasileiro no exterior 84
- poder de disposição 80
- poderes especiais e expressos 80
- procuração estrangeiras 82
- procurações referidas no instrumento particular 108
- revogação 82
- substabelecimento 80, 110
- vigência 82
- vinculação da forma 80

Prenotação

- alienação fiduciária 118
- bloqueio 54
- exigências 98
- indisponibilidade de bens 313
- prazo 29
- prioridade 28
- prorrogação 98

Princípios

Programa de arrendamento

residencial (PAR) 127, 129, 184

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 131, 153, 186

Promessa de compra e venda – ver compromisso de compra e venda

- Propriedade
 - resolúvel 117, 248
- Protesto contra alienação de bens
 - 186
- Pública forma
 - concerto e conferência 66
- Reconhecimento de firma 104
 - abono 104
 - advogado 105
 - alienação fiduciária 120
 - analfabeto 110
 - autêntico 104
 - cédulas de crédito 105
 - cegos 110
 - cônsul (dispensa) 83
 - dispensa 83, 103, 104, 106
 - documentos judiciais 106, 111
 - fundada dúvida 106
 - Junta Comercial 134
 - legalização 83
 - procuração pública 103
 - regularização fundiária 106
 - requerimento 50
 - semelhança 104
 - SFH 104
 - SFI 120
 - testemunhas 103, 107
- Regime de bens
 - alteração 220
 - anuência do cônjuge 213
 - burla ao regime de bens 215
 - casamento no exterior 223
 - comunhão parcial de bens 209
 - comunhão universal de bens 216
 - incomunicabilidade 213
 - outorga uxória 210
 - pacto antenupcial 209, 216, 219
- participação final nos aquestos 217
- separação obrigatória de bens 214
- separação obrigatória de bens de estrangeiros 226
- separação convencional de bens 218
- sub-rogação 212
- Regularização fundiária 106
- Retificação
 - reas remanescentes 20
 - averbação 32
 - continuidade 39
 - dispensa de CND 293
 - imposição de cláusulas por escritura de retificação 239
 - judicial 200
 - registros flutuantes 21
- Retrovenda 255, 273
- Salário mínimo 62, 96, 112
- Selos
 - conferência 71
- Sentença estrangeira
 - homologação 61
 - separação ou divórcio 228
- Separação
 - alienação de bens não partilhados 229
 - averbação 26, 227
 - bem de família 230
 - certidão atualizada 227
 - certidão de regularidade do ITCMD 280

- certidão do Registro Civil 227	Testamento 87, 94, 167, 239, 241, 242, 255, 257
- continuidade 224	
- efeitos 227	
- escritura pública 182	Testemunha
- espólio 40	- carta de arrematação 131
- exterior 228	- escritura pública 90, 94
- homologação 228	- firma reconhecida 61, 103
- incomunicabilidade 227	- instrumento particular 107
- ITBI 268	
- ITCMD 268	Títulos
- partilha 228	- definição 20
- poder familiar 73	- distinção de documento 66
- reconciliação 231	- judiciais 37, 47
- regime de bens 209	- pública forma 65
- registro 228	- títulos admitidos no fólio real 61
- separação de fato 231	
- SFH 115	Transcrição
- viuvez 41	- cindibilidade 55
	- cláusulas 260
SISA – ver ITBI	- unitariedade 31
Sistema Financeiro da Habitação – SFH 113	União estável 73
- agentes financeiros 105	
- dispensa do reconhecimento de firma 105	Unificação de imóveis
- institutos do SFI 121	- condições 43, 145
- restrições decorrentes do SFH 114	- transcrição 20
Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI 120	Usucapião
	- aquisição originária 266
Sociedades	- bloqueio 54
- limitada 88	- cancelamento administrativo 52
- simples 85, 136	- certidão negativa do ITR e CCIR 284
- sociedade anônima 67, 68, 86, 137	- DOI 305
	- imóvel da massa falida 90
	- ITBI 266
	- qualificação 27
	- SFH 116
Sucessão provisória 189	Usufruto
	- alienação 181

- cancelamento 50
 - cláusula de acrescer 254
 - cláusula de inalienabilidade 250
 - cláusula de vigência na locação 145
 - consolidação 181
 - curador especial 76
 - DOI 305
 - escritura de retificação 239
 - fideicomisso 258
 - ITCMD 274
 - promessa de instituição 180
 - regime de bens 212
 - tutor 77
- Venda e compra
- ascendente para descendente 75, 108
 - autocontrato 81
 - bem hipotecado 114
 - bem não partilhado 229
 - CNDs 299
 - cláusula *constituti* 255
 - cláusula de decaimento 254
 - cláusula de inalienabilidade 237
 - cláusula de retrovenda 255, 273
 - distrato 109
 - direito de preferência 146
 - fração ideal 151
 - instrumento particular 112
 - ITBI 265
 - pacto comissório 251
 - PAR 127
 - SFH 113, 117
 - sub-rogação 212
 - tutelado 77
 - venda de donatário a donatário 244